

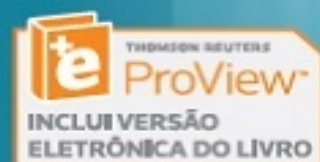
FÁBIO ULHOA COELHO

MANUAL DE
**Direito
Comercial**

Direito de empresa

28.^a EDIÇÃO

Revista, atualizada e ampliada



THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

FÁBIO ULHOA COELHO

MANUAL DE
**Direito
Comercial**

Direito de empresa

1. ed. em e-book baseada na 28. ed. impressa

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

FÁBIO ULHOA COELHO

Manual de Direito Comercial

Direito de Empresa

1. ed. em e-book baseada na 28. ed. impressa

© desta edição e-book [2016]

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

MARISA HARMS

Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda

Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450

CEP 01136-000 – São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RT

(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Visite nosso site: www.rt.com.br

Universitário Texto

Fechamento desta edição: [18.12.2015]



ISBN 978-85-203-6679-0

Diretora Responsável

MARISA HARMS

Diretora de Operações de Conteúdo

JULIANA MAYUMI ONO

Editores: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Iviê A. M. Loureiro Gomes e Luciana Felix

Assistente Administrativo Editorial: Juliana Camilo Menezes

Produção Editorial

Coordenação

DANIEL CESAR LEAL DIAS DE CARVALHO

Analistas Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Rondon Castro de Moraes, Flávia Campos Marcelino Martines, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, George Silva Melo, Maurício Zednik Cassim e Thiago César Gonçalves de Souza

Qualidade Editorial

Coordenação

LUCIANA VAZ CAMEIRA

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavierv Silva, Cinthia Santos Galarza, Cintia Mesojedovas Nogueira, Daniela Medeiros Gonçalves Melo, Daniele de Andrade Vintecinco e Maria Angélica Leite

Capa: Full Throttle

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

CAIO HENRIQUE ANDRADE

Analista Administrativo: Antonia Pereira

Assistente Administrativo: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Analista de Produção Gráfica: Rafael da Costa Brito

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Coelho, Fábio Ulhoa

Manual de direito comercial [livro eletrônico]: direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. -- São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016.

5,22 Mb ; PDF

1. ed. em e-book baseada na 28. ed. impressa.

Bibliografia.

ISBN 978-85-203-6679-0

1. Direito comercial I. Título.

15-11346

CDU-347.7

Índices para catálogo sistemático: 1. Direito comercial 347.7

Para
Claudio Ferraz de Alvarenga

FÁBIO ULHOA COELHO

Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde leciona Direito Comercial desde 1982. É autor de várias obras jurídicas na área, como o Manual de Direito Comercial e o Curso de Direito Comercial, em 3 volumes, publicados pela Editora RT. É advogado.

PRINCIPAIS ABREVIATURAS UTILIZADAS

BC - Banco Central

CC - Código Civil

CCI - Cédula de Crédito Imobiliário

CCom - Código Comercial

CDA - Conhecimento de Depósito Agropecuário

CDC - Código de Defesa do Consumidor

CF - Constituição Federal

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

CP - Código Penal

CPC - Código de Processo Civil

CPP - Código de Processo Penal

CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

CTN - Código Tributário Nacional

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

DREI - Departamento de Registro Empresarial e Integração

EOAB - Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94)

Estatuto - Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/06)

IN-DNRC - Instrução Normativa do Departamento Nacional do Registro do Comércio

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LC - Lei do Cheque (Lei 7.357/85)

LCI - Letra de Crédito Imobiliário

LD - Lei das Duplicatas (Lei 5.474/68)

LF - Lei de Falências (Lei 11.101/2005)

LILE - Lei sobre a Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras (Lei 6.024/74)

LIOE - Lei de Infrações à Ordem Econômica (Lei 12.529/11)

LL - Lei de Locações Prediais Urbanas (Lei 8.245/91)

LMC - Lei do Mercado de Capitais (Lei 4.728/65)

LPI - Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

LRB - Lei da Reforma Bancária (Lei 4.595/64)

LRE - Lei do Registro de Empresas (Lei 8.934/94)

LS - Lei dos Seguros (Decreto-Lei 73/66)

LSA - Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)

LU - Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias (Anexo II da Convenção de Genebra, promulgada pelo Decreto 57.663/66)

Res. - Resolução

WA - *Warrant* Agropecuário

PREFÁCIO

Este livro é o que o seu título diz: um manual. Ou seja, algo para se ter à mão.

Ao escrevê-lo, pensei em compor um guia. Um instrumento que facilitasse aos estudantes e profissionais do direito se localizarem no fascinante mundo do direito comercial. Não me preocupei em discorrer sobre as muitas e interessantes discussões doutrinárias e jurisprudenciais que permeiam cada um dos temas aqui abordados, mas em fazer, quando necessário, apenas uma menção da existência de controvérsias, posições variadas ou divergências.

Perceberá o leitor, por outro lado, que, apesar dos estreitos limites dos objetivos a que se propõe este trabalho, não deixei de explicitar meu entendimento sobre as questões fundamentais da matéria. Procurei, também, manter uma linha de coerência e rigor que considero indispensável a qualquer dissertação científica ou tecnológica.

Claro está, suponho, que a reunião de todos os assuntos do direito comercial, em suas principais divisões (parte geral, direito societário, títulos de crédito, direito falimentar e contratos mercantis), em um único volume, somente poderia ter sido feita a partir de uma seleção. Optei, aqui, em primeiro lugar, por tratar daquilo que cada tema tem de essencial. Para o aprofundamento de um assunto em particular, deverá o leitor socorrer-se da bibliografia comercialista específica. Em segundo lugar, evitei a transcrição, pura e simples, de dispositivos de lei, tendo em vista a facilidade de sua consulta em outras publicações.

Este é um trabalho em evolução. Sua primeira edição é de junho de 1988. Desde então, mais de vinte edições já foram padronizadas, sempre com indispensável atualização, constante revisão e ampliações. Nestes últimos anos, aliás, muitas e importantes alterações têm sido introduzidas no ordenamento jurídico nacional, que direta ou indiretamente envolvem matéria de estudo do direito comercial, e o *Manual* tem procurado acompanhá-las rigorosamente.

No mais, quero dizer que gostei muito de escrever este livro e espero que meus colegas e alunos também gostem de utilizá-lo.

O AUTOR

PRIMEIRA PARTE - TEORIA GERAL DO DIREITO COMERCIAL

(Autor)

Fábio Ulhoa Coelho

Capítulo 1. ATIVIDADE EMPRESARIAL

1. OBJETO DO DIREITO COMERCIAL

Os bens e serviços de que todos precisamos para viver - isto é, os que atendem às nossas necessidades de vestuário, alimentação, saúde, educação, lazer etc. - são produzidos em organizações econômicas especializadas e negociados no mercado. Quem estrutura essas organizações são pessoas com vocação para a tarefa de combinar determinados componentes (os "fatores de produção") e fortemente estimuladas pela possibilidade de ganhar dinheiro, muito dinheiro, com isso. São os empresários.

A atividade dos empresários pode ser vista como a de articular os fatores de produção, que no sistema capitalista são quatro: capital, mão de obra, insumo e tecnologia. As organizações em que se produzem os bens e serviços necessários ou úteis à vida humana são resultado da ação dos empresários, ou seja, nascem do aporte de *capital* - próprio ou alheio -, compra de *insumos*, contratação de *mão de obra* e desenvolvimento ou aquisição de *tecnologia* que realizam. Quando alguém com vocação para essa atividade identifica a chance de lucrar, atendendo à demanda de quantidade considerável de pessoas - quer dizer, uma necessidade, utilidade ou simples desejo de vários homens e mulheres -, na tentativa de aproveitar tal oportunidade, ele deve estruturar uma organização que produza a mercadoria ou serviço correspondente, ou que os traga aos consumidores.

Estruturar a produção ou circulação de bens ou serviços significa reunir os recursos financeiros (capital), humanos (mão de obra), materiais (insumo) e tecnológicos que viabilizem oferecê-los ao mercado consumidor com preços e qualidade competitivos. Não é tarefa simples. Pelo contrário, a pessoa que se propõe realizá-la deve ter competência para isso, adquirida mais por experiência de vida que propriamente por estudos. Além disso, trata-se sempre de empreitada sujeita a risco. Por mais cautelas que adote o empresário, por mais seguro que esteja do potencial do negócio, os consumidores podem simplesmente não se interessar pelo bem ou serviço oferecido. Diversos outros fatores inteiramente alheios à sua vontade - crises políticas ou econômicas no Brasil ou exterior, acidentes ou deslealdade de concorrentes, por exemplo - podem também obstar o desenvolvimento da atividade. Nesses casos, todas as expectativas de ganho se frustram e os recursos investidos se perdem. Não há como evitar o *risco* de insucesso, inerente a qualquer atividade econômica. Por isso, boa parte da competência característica dos empresários dotados de vocação diz respeito à capacidade de mensurar e atenuar riscos.

O *Direito Comercial* cuida do exercício dessa atividade econômica organizada de fornecimento de bens ou serviços, denominada *empresa*. Seu objeto é o estudo dos meios socialmente estruturados de superação dos conflitos de interesses envolvendo empresários ou relacionados as empresas que eles exploram. As leis e a forma pela qual são interpretadas pela jurisprudência e doutrina, os valores prestigiados pela sociedade, bem assim o funcionamento dos aparatos estatal e paraestatal, na superação desses conflitos de interesses, formam o objeto da disciplina.

A denominação deste ramo do direito ("comercial") explica-se por razões históricas, examinadas na sequência; por tradição, pode-se dizer. Outras designações têm sido empregadas na identificação desta área do saber jurídico (por exemplo: direito empresarial, mercantil, dos negócios etc.), mas nenhuma ainda substituiu por completo a tradicional. Assim, embora seu objeto não se limite à disciplina jurídica do comércio, Direito Comercial tem sido o nome que identifica - nos currículos de graduação e pós-graduação em Direito, nos livros e cursos, no Brasil e em muitos outros países - o ramo jurídico voltado às questões próprias dos empresários ou das empresas; à maneira como se estrutura a produção e negociação dos bens e serviços de que todos precisamos para viver. É, também, a expressão adotada pela Constituição Federal para identificar este ramo jurídico (art. 22, I).

2. COMÉRCIO E EMPRESA

Como mencionado acima, os bens e serviços que homens e mulheres necessitam ou desejam para viver (isto é, vestir, alimentar-se, dormir, divertir-se etc.) são produzidos em organizações econômicas especializadas. Nem sempre foi assim, porém. Na Antiguidade, roupas e víveres eram produzidos na própria casa, para os seus moradores; apenas os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos ou na praça. Na Roma antiga, a família dos romanos não era só o conjunto de pessoas unidas por laços de sangue (pais e filhos), mas também incluía os escravos, assim como a morada não era apenas o lugar de convívio íntimo e recolhimento, mas também o de produção de vestes, alimentos, vinho e utensílios de uso diário.

Alguns povos da Antiguidade, como os fenícios, destacaram-se intensificando as trocas e, com isto, estimularam a produção de bens destinados especificamente à venda. Esta atividade de fins econômicos, o *comércio*, expandiu-se com extraordinário vigor. Graças a ela, estabeleceram-se intercâmbios entre culturas distintas, desenvolveram-se tecnologias e meios de transporte, fortaleceram-se os Estados, povoou-se o planeta de homens e mulheres; mas, também, em função do comércio, foram travadas guerras, escravizaram-se povos, recursos naturais se esgotaram. Com o processo econômico de globalização desencadeado após o fim da Segunda Guerra Mundial (na verdade, o último conflito bélico por mercados coloniais), o comércio procura derrubar as fronteiras nacionais que atrapalham sua expansão. Haverá dia em que o planeta será um único mercado.

O comércio gerou e continua gerando novas atividades econômicas. Foi a intensificação das trocas pelos comerciantes que despertou em algumas pessoas o interesse de produzirem bens de que não necessitavam diretamente; bens feitos para serem vendidos e não para serem usados por quem os fazia. É o início da atividade que, muito tempo depois, será chamada de fabril ou industrial. Os bancos e os seguros, em sua origem, destinavam-se a atender necessidades dos comerciantes. Deve-se ao comércio eletrônico a popularização da rede mundial de computadores (*internet*), que estimula diversas novas atividades econômicas.

Na Idade Média, o comércio já havia deixado de ser atividade característica só de algumas culturas

ou povos. Difundiu-se por todo o mundo civilizado. Durante o Renascimento Comercial, na Europa, artesãos e comerciantes europeus reuniam-se em corporações de ofício, poderosas entidades burguesas (isto é, sediadas em burgos) que gozavam de significativa autonomia em face do poder real e dos senhores feudais. Nas corporações de ofício, como expressão dessa autonomia, foram paulatinamente surgindo normas destinadas a disciplinar as relações entre os seus filiados. Na Era Moderna, estas normas pseudossistematizadas serão chamadas de Direito Comercial. Nesta sua primeira fase de evolução, ele é o direito aplicável aos membros de determinada corporação dos comerciantes. Os usos e costumes de cada praça ou corporação tinham especial importância na sua aplicação.

No início do século XIX, na França, Napoleão, com a ambição de regular a totalidade das relações sociais, patrocina a edição de dois monumentais diplomas jurídicos: o Código Civil (1804) e o Comercial (1808). Inaugura-se, então, um *sistema* para disciplinar as atividades dos cidadãos, que repercutirá em todos os países de tradição romana, inclusive o Brasil. De acordo com este sistema, classificavam-se as relações que hoje em dia são chamadas de direito privado em *civis* e *comerciais*. Para cada regime, estabeleceram-se regras diferentes sobre contratos, obrigações, prescrição, prerrogativas, prova judiciária e foros. A delimitação do campo de incidência do Código Comercial era feita, no sistema francês, pela *teoria dos atos de comércio*. Sempre que alguém explorava atividade econômica que o direito considera ato de comércio (mercancia), submetia-se às obrigações do Código Comercial (a obrigação de escriturar seu movimento econômico, por exemplo) e passava a usufruir da proteção por ele liberada (utilização da escritura mercantil como prova em processos judiciais).

Na lista dos atos de comércio não se encontravam algumas atividades econômicas que, com o tempo, passaram a ganhar importância equivalente às de comércio, banco, seguro e indústria. É o caso da prestação de serviços, cuja relevância é diretamente proporcional ao processo de urbanização. Também da lista não constavam atividades econômicas ligadas à terra, como a negociação de imóveis, agricultura ou extrativismo. Na Europa Continental, principalmente na França, a burguesia foi levada a travar uma acirrada luta de classes contra o feudalismo, e um dos reflexos disso na ideologia jurídica é a desconsideração das atividades econômicas típicas dos senhores feudais no conceito aglutinador do Direito Comercial do período.

Esta é a segunda fase da trajetória evolutiva da disciplina, em que ela não mais se considera o direito de alguns sujeitos (os comerciantes), mas a disciplina jurídica de determinados atos (os atos de comércio).

Uma vez ultrapassados os condicionantes econômicos, políticos e históricos que ambientaram a teoria dos atos de comércio, ela acabou revelando suas insuficiências como critério para delimitar o objeto do Direito Comercial. Na maioria dos países em que foi adotada, a teoria experimentou ajustes que, em certo sentido, a desnaturaram. Na Alemanha, em 1897, o Código Comercial definiu os atos de comércio como todos os que o comerciante, em sua atividade, pratica, alargando enormemente o conceito. Mesmo onde havia sido concebida, não se distinguem mais os atos de comércio dos civis segundo os parâmetros desta teoria: no direito francês, hoje, qualquer atividade econômica, independentemente de sua classificação, é regida pelo Direito Comercial se explorada uma sociedade.

A insuficiência da teoria dos atos de comércio forçou o surgimento de outro critério identificador do âmbito de incidência do Direito Comercial: a teoria da empresa.

3. TEORIA DA EMPRESA

Em 1942, na Itália, surge um novo *sistema* de regulação das atividades econômicas dos particulares. Nele, alarga-se o âmbito de incidência do Direito Comercial, passando as atividades de prestação de serviços e ligadas à terra a se submeterem às mesmas normas aplicáveis às comerciais, bancárias, securitárias e industriais. Chamou-se o novo sistema de disciplina das atividades privadas de *teoria da empresa*. O Direito Comercial, em sua terceira etapa evolutiva, deixa de cuidar de determinadas atividades (as de mercancia) e passa a disciplinar uma *forma específica* de produzir ou circular bens ou serviços, a empresarial. Atente para o local e ano em que a teoria da empresa se expressou pela primeira vez no ordenamento positivo. O mundo estava em guerra e, na Itália, governava o ditador fascista Mussolini.

A ideologia fascista não é tão sofisticada como a comunista, mas um pequeno paralelo entre ela e o marxismo ajuda a entender a ambientação política do surgimento da teoria da empresa. Para essas duas concepções ideológicas, burguesia e proletariado estão em luta; elas divergem sobre como a luta terminará. Para o marxismo, o proletariado tomará o poder do Estado, expropriará das mãos da burguesia os bens de produção e porá fim as classes sociais (e, em seguida, ao próprio Estado), reorganizando-se as relações de produção.

Já para o fascismo, a luta de classes termina em harmonização patrocinada pelo estado nacional. Burguesia e proletariado superam seus antagonismos na medida em que se unem em torno dos superiores objetivos da nação, seguindo o líder (*Duce*), que é intérprete e guardião destes objetivos. A empresa, no ideário fascista, representa justamente a organização em que se harmonizam as classes em conflito. Vale notar que Asquini, um dos expoentes da doutrina comercialista italiana, ao tempo do governo fascista, costumava apontar como um dos *perfis* da empresa o *corporativo*, em que se expressava a comunhão dos propósitos de empresário e trabalhadores.

A teoria da empresa acabou se desvencilhando das raízes ideológicas fascistas. Por seus méritos técnicos, sobreviveu à redemocratização da Itália e permanece delimitando o Direito Comercial daquele país até hoje. Também por sua operacionalidade, adequada aos objetivos da disciplina da exploração de atividades econômicas por particulares no nosso tempo, a teoria da empresa inspirou a reforma da legislação comercial de outros países de tradição jurídica romana, como a da Espanha em 1989.

No Brasil, o Código Comercial de 1850 (cuja primeira parte é revogada com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 - art. 2.045) sofreu forte influência da teoria dos atos de comércio. O regulamento 737, também daquele ano, que disciplinou os procedimentos a serem observados nos então existentes Tribunais do Comércio, apresentava a relação de atividades econômicas reputadas *mercancia*. Em linguagem atual, esta relação compreenderia: *a)* compra e venda de bens móveis ou semoventes, no atacado ou varejo, para revenda ou aluguel; *b)* indústria; *c)* bancos; *d)* logística; *e)* espetáculos públicos; *f)* seguros; *g)* armação e expedição de navios.

As defasagens entre a teoria dos atos de comércio e a realidade disciplinada pelo Direito Comercial - sentidas especialmente no tratamento desigual dispensado à prestação de serviços, negociação de imóveis e atividades rurais - e a atualidade do sistema italiano de bipartir o direito privado começam a ser apontadas na doutrina brasileira nos anos 1960. Principalmente depois da adoção da teoria da empresa pelo Projeto de Código Civil de 1975 (ela tinha sido também lembrada na elaboração do Projeto de Código das Obrigações, de 1965, não convertido em lei), os comercialistas brasileiros dedicam-se ao seu estudo, preparando-se para as inovações que se seguiriam à entrada em vigor da codificação "unificada" do direito privado, prometida para breve.

Mas, o projeto tramitou com inesperada lentidão. Durante um quarto de século, enquanto pouca coisa ou nada acontecia no Congresso e a doutrina comercialista já desenvolvia suas reflexões à luz da teoria da empresa, alguns juízes começaram a decidir processos desconsiderando o conceito de atos de comércio - embora fosse este ainda o do direito positivo, porque vigorava a parte primeira do Código Comercial. Estes juízes concederam a pecuaristas um favor legal então existente apenas para os comerciantes (a *concordata*), decretaram a falência de negociantes de imóveis, asseguraram a renovação compulsória do contrato de aluguel em favor de prestadores de serviço, julgando, enfim, as demandas pelo critério da empresarialidade. Durante este largo tempo, também, as principais leis de interesse do direito comercial editadas já se inspiraram no sistema italiano, e não mais no francês. São exemplos o Código de Defesa do Consumidor de 1990, a Lei de Locação Predial Urbana de 1991 e a Lei do Registro de Empresas de 1994.

Em suma, pode-se dizer que o direito brasileiro já incorporara - nas lições da doutrina, na jurisprudência e em leis esparsas - a teoria da empresa, mesmo *antes* da entrada em vigor do Código Civil. Conclui-se a demorada transição quando do início da vigência deste.

4. CONCEITO DE EMPRESÁRIO

Empresário é definido na lei como o profissional exercente de "atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços" (CC, art. 966). Destacam-se da definição as noções de *profissionalismo*, *atividade econômica organizada* e *produção ou circulação de bens ou serviços*.

Profissionalismo. A noção de exercício profissional de certa atividade é associada, na doutrina, a considerações de três ordens. A primeira diz respeito à habitualidade. Não se considera profissional quem realiza tarefas de modo esporádico. Não será empresário, por conseguinte, aquele que organizar episodicamente a produção de certa mercadoria, mesmo destinando-a à venda no mercado. Se está apenas fazendo um teste, com o objetivo de verificar se tem apreço ou desapeço pela vida empresarial ou para socorrer situação emergencial em suas finanças, e não se torna habitual o exercício da atividade, então ele não é empresário. O segundo aspecto do profissionalismo é a pessoalidade. O empresário, no exercício da atividade empresarial, deve contratar *empregados*. São estes que, materialmente falando, produzem ou fazem circular bens ou serviços. O requisito da pessoalidade explica por que não é o empregado considerado empresário. Enquanto este último, na condição de profissional, exerce a atividade empresarial pessoalmente, os empregados, quando produzem ou circulam bens ou serviços, fazem-no em nome do empregador.

Estes dois pontos normalmente destacados pela doutrina, na discussão do conceito de profissionalismo, não são os mais importantes. A decorrência mais relevante da noção está no *monopólio das informações* que o empresário detém sobre o produto ou serviço objeto de sua empresa. Este é o sentido com que se costuma empregar o termo no âmbito das relações de consumo. Como o empresário é um profissional, as informações sobre os bens ou serviços que oferece ao mercado - especialmente as que dizem respeito às suas condições de uso, qualidade, insumos empregados, defeitos de fabricação, riscos potenciais à saúde ou vida dos consumidores - costumam ser de seu inteiro conhecimento. Porque profissional, o empresário tem o dever de conhecer estes e outros aspectos dos bens ou serviços por ele fornecidos, bem como o de informar amplamente os consumidores e usuários.

Atividade. Se empresário é o exercente profissional de uma atividade econômica organizada, então *empresa* é uma atividade; a de produção ou circulação de bens ou serviços. É importante destacar a

questão. Na linguagem cotidiana, mesmo nos meios jurídicos, usa-se a expressão "empresa" com diferentes e impróprios significados. Se alguém diz "a empresa faliu" ou "a empresa importou essas mercadorias", o termo é utilizado de forma errada, não técnica. A empresa, enquanto atividade, não se confunde com o *sujeito de direito* que a explora, o empresário. É ele que fale ("quebra") ou importa mercadorias. Similarmente, se uma pessoa exclama "a empresa está pegando fogo!" ou constata "a empresa foi reformada, ficou mais bonita", está empregando o conceito equivocadamente. Não se pode confundir a empresa com o *local* em que a atividade é desenvolvida. O conceito correto nessas frases é o de *estabelecimento empresarial*; este sim pode incendiar-se ou ser embelezado, nunca a atividade. Por fim, também é equivocado o uso da expressão como sinônimo de *sociedade*. Não se diz "separam-se os bens da empresa e os dos sócios em patrimônios distintos", mas "separam-se os bens sociais e os dos sócios"; não se deve dizer "fulano e beltrano abriram uma empresa", mas "eles contrataram uma sociedade".

Somente se emprega de modo técnico o conceito de empresa quando for sinônimo de *empreendimento*. Se alguém reputa "muito arriscada a empresa", está certa a forma de se expressar: o empreendimento em questão enfrenta consideráveis riscos de insucesso, na avaliação desta pessoa. Como ela se está referindo à atividade, é adequado falar em empresa. Outro exemplo: no princípio da *preservação da empresa*, construído pelo moderno Direito Comercial, o valor básico prestigiado é o da conservação da atividade (e não do empresário, do estabelecimento ou de uma sociedade), em virtude da imensa gama de interesses que transcendem os dos donos do negócio e gravitam em torno da continuidade deste; assim os interesses de empregados quanto aos seus postos de trabalho, de consumidores em relação aos bens ou serviços de que necessitam, do fisco voltado à arrecadação e outros.

Econômica. A atividade empresarial é econômica no sentido de que busca gerar lucro para quem a explora. Note-se que o lucro pode ser o objetivo da produção ou circulação de bens ou serviços, ou apenas o instrumento para alcançar outras finalidades. Religiosos podem prestar serviços educacionais (numa escola ou universidade) sem visar especificamente o lucro. É evidente que, no capitalismo, nenhuma atividade econômica se mantém sem alguma lucratividade e, por isso, o valor total das mensalidades deve superar o das despesas também nesses estabelecimentos educacionais. Mas a escola ou universidade religiosas podem ter objetivos não lucrativos, como a difusão de valores ou criação de postos de emprego para os seus sacerdotes. Neste caso, o lucro é *meio* e não *fim* da atividade econômica.

Organizada. A empresa é atividade organizada no sentido de que nela se encontram articulados, pelo empresário, os quatro fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Não é empresário quem explora atividade de produção ou circulação de bens ou serviços sem alguns desses fatores. O comerciante de perfumes que leva ele mesmo, à sacola, os produtos até os locais de trabalho ou residência dos potenciais consumidores explora atividade de circulação de bens, fá-lo com intuito de lucro, habitualidade e em nome próprio, mas não é empresário, porque em seu mister não contrata empregado, não organiza mão de obra. A tecnologia, ressalte-se, não precisa ser necessariamente *de ponta*, para que caracterização da empresarialidade. Pressupõe-se apenas que o empresário, ao estruturar a organização econômica, detenha e use os conhecimentos próprios aos bens ou serviços que pretende oferecer ao mercado, sejam estes sofisticados ou de amplo conhecimento.

Produção de bens ou serviços. Produção de bens é a fabricação de produtos ou mercadorias. Toda atividade de indústria é, por definição, empresarial. Produção de serviços, por sua vez, é a prestação de serviços. São exemplos de produtores de bens: montadoras de veículos, fábricas de eletrodomésticos, confecções de roupas; e de produtores de serviços: bancos, seguradoras, hospitais, escolas,

estacionamentos, provedores de acesso à *internet*.

Circulação de bens ou serviços. A atividade de circular bens é a do comércio, em sua manifestação originária: ir buscar o bem no produtor para trazê-lo ao consumidor. É a atividade de intermediação na cadeia de escoamento de mercadorias. O conceito de empresário compreende tanto o atacadista como o varejista, tanto o comerciante de insumos como o de mercadorias prontas para o consumo. Os supermercados, concessionárias de automóveis e lojas de roupas são empresários. Circular serviços é intermediar a prestação de serviços. A agência de turismo não presta os serviços de transporte aéreo, traslados e hospedagem, mas os intermedeia quando monta um *pacote de viagem*.

Bens ou serviços. Até a difusão do comércio eletrônico, no fim dos anos 1990, a distinção entre bens ou serviços não comportava, na maioria das vezes, maiores dificuldades: bens são corpóreos, enquanto os serviços não têm materialidade. A prestação de serviços consistia sempre numa obrigação de *fazer*. Com a intensificação do uso da *internet* para a realização de negócios e atos de consumo, certas atividades resistem a classificação nesses moldes. A assinatura de jornal virtual, com exatamente o mesmo conteúdo do jornal de papel, é um bem ou serviço? Os chamados *bens virtuais*, como programas de computador ou arquivo de música baixada pela *internet*, em que categoria devem ser incluídos? Mesmo sem resolver essas questões, não há dúvidas, na caracterização de empresário, de que o comércio eletrônico, em todas as suas várias manifestações (páginas B2B, B2C ou C2C), é atividade empresarial (ver *Cap. 5*, item 6).

5. ATIVIDADES ECONÔMICAS CIVIS

A teoria da empresa não acarreta a superação da bipartição do direito privado, que o legado jurídico de Napoleão tornou clássica nos países de tradição romana. Altera o critério de delimitação do objeto do Direito Comercial - que deixa de ser os *atos de comércio* e passa a ser a *empresarialidade* -, mas não suprime a dicotomia entre o regime jurídico civil e comercial. Assim, de acordo com o Código Civil, continuam excluídas da disciplina juscomercialista algumas atividades econômicas. São atividades civis, cujos exercentes não podem, por exemplo, requerer a recuperação judicial, nem falir.

São quatro hipóteses de atividades econômicas *civis*. A primeira diz respeito às exploradas por quem não se enquadra no conceito legal de empresário. Se alguém presta serviços diretamente, mas não organiza uma empresa (não tem empregados, por exemplo), mesmo que o faça profissionalmente (com intuito lucrativo e habitualidade), ele *não* é empresário e o seu regime será o civil. Aliás, com o desenvolvimento dos meios de transmissão eletrônica de dados, estão surgindo atividades econômicas de relevo exploradas sem empresa, em que o prestador dos serviços trabalha sozinho em casa.

As demais atividades civis são as dos profissionais intelectuais, dos empresários rurais não registrados na Junta Comercial e a das Cooperativas.

5.1. Profissional intelectual

Não se considera empresário, por força do parágrafo único do art. 966 do CC, o exercente de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo que contrate empregados para auxiliá-lo em seu trabalho. Estes profissionais exploram, portanto, atividades econômicas civis, não sujeitas ao Direito Comercial. Entre eles se encontram os profissionais liberais (advogado, médico, dentista, arquiteto etc.), os escritores e artistas de qualquer expressão (plásticos, músicos, atores etc.).

Há uma exceção, prevista no mesmo dispositivo legal, em que o profissional intelectual se enquadra no conceito de empresário. Trata-se da hipótese em que o exercício da profissão constitui *elemento de empresa*.

Para compreender o conceito legal, convém partir de um exemplo. Imagine o médico pediatra recém-formado, atendendo seus primeiros clientes no consultório. Já contrata pelo menos uma secretária, mas se encontra na condição geral dos profissionais intelectuais: não é empresário, mesmo que conte com o auxílio de colaboradores. Nesta fase, os pais buscam seus serviços em razão, basicamente, de sua competência como médico. Imagine, porém, que, passando o tempo, este profissional amplie seu consultório, contratando, além de mais pessoal de apoio (secretária, atendente, coadeira etc.), também enfermeiros e outros médicos. Não chama mais o local de atendimento de consultório, mas de *clínica*. Nesta fase de transição, os clientes ainda procuram aqueles serviços de medicina pediátrica, em razão da confiança que depositam no trabalho daquele médico, titular da clínica. Mas a clientela se amplia e já há, entre os pacientes, quem nunca foi atendido diretamente pelo titular, nem o conhece. Numa fase seguinte, cresce mais ainda aquela unidade de serviços. Não se chama mais clínica, e sim *hospital pediátrico*. Entre os muitos funcionários, além dos médicos, enfermeiros e atendentes, há contador, advogado, nutricionista, administrador hospitalar, seguranças, motoristas e outros. Ninguém mais procura os serviços ali oferecidos em razão do trabalho pessoal do médico que os organiza. Sua individualidade se perdeu na organização empresarial. Neste momento, aquele profissional intelectual tornou-se elemento de empresa. Mesmo que continue clinicando, sua maior contribuição para a prestação dos serviços naquele hospital pediátrico é a de organizador dos fatores de produção. Foge, então, da condição geral dos profissionais intelectuais e deve ser considerado, juridicamente, empresário.

Também os outros profissionais liberais e artistas sujeitam-se à mesma regra. O escultor que contrata auxiliar para funções operacionais (atender o telefone, pagar contas no banco, fazer moldes, limpar o ateliê) não é empresário. Na medida em que expande a procura por seus trabalhos, e ele contrata vários funcionários para imprimir maior celeridade à produção, *pode* ocorrer a transição dele da condição jurídica de profissional intelectual para a de elemento de empresa. Será o caso, se a reprodução de esculturas assinaladas com sua assinatura não depender mais de nenhuma ação pessoal direta dele. Tornar-se-á, então, juridicamente empresário.

5.2. Empresário rural

Atividade econômica rural é a explorada normalmente fora da cidade. Certas atividades produtivas não são costumeiramente exploradas em meio urbano, por razões de diversas ordens (materiais, culturais, econômicas ou jurídicas). São rurais, por exemplo, as atividades econômicas de plantação de vegetais destinadas a alimentos, fonte energética ou matéria-prima (agricultura, reflorestamento), a criação de animais para abate, reprodução, competição ou lazer (pecuária, suinocultura, granja, equinocultura) e o extrativismo vegetal (corte de árvores), animal (caça e pesca) e mineral (mineradoras, garimpo).

As atividades rurais, no Brasil, são exploradas em dois tipos radicalmente diferentes de organizações econômicas. Tomando-se a produção de alimentos, por exemplo, encontra-se na economia brasileira, de um lado, a agroindústria (ou agronegócio) e, de outro, a agricultura familiar. Naquela, emprega-se tecnologia avançada, mão de obra assalariada (permanente e temporária), especialização de culturas, grandes áreas de cultivo; na familiar, trabalham o dono da terra e seus parentes, um ou outro empregado, e são relativamente menores as áreas de cultivo. Convém registrar que, ao contrário de outros países, principalmente na Europa, em que a pequena propriedade rural tem importância econômica no

encaminhamento da questão agrícola, entre nós, a produção de alimentos é altamente industrializada e se concentra em grandes empresas rurais. Por isso, a reforma agrária, no Brasil, não é solução de nenhum problema econômico, como foi para outros povos; destina-se a solucionar apenas problemas sociais de enorme gravidade (pobreza, desemprego no campo, crescimento desordenado das cidades, violência urbana etc.).

Atento a esta realidade (dois grandes modelos de exploração de certa atividade econômica), o Código Civil reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971). Se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial. Esta deve ser a opção do agronegócio. Caso, porém, não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil. Esta última deverá ser a opção predominante entre os titulares de negócios rurais familiares.

5.3. Cooperativas

Desde o tempo em que a delimitação do objeto do Direito Comercial era feita pela teoria dos atos de comércio, há duas exceções a assinalar no contexto do critério identificador desse ramo jurídico. De um lado, a *sociedade por ações*, que será sempre comercial, independentemente da atividade que explora (LSA, art. 2º, § 2º; CC, art. 982). De outro, as *cooperativas*, que são sempre sociedades simples, independentemente da atividade que exploram (art. 982).

As cooperativas, normalmente, dedicam-se às mesmas atividades dos empresários e costumam atender aos requisitos legais de caracterização destes (*profissionalismo, atividade econômica organizada e produção ou circulação de bens ou serviços*), mas, por expressa disposição do legislador, que data de 1971, não se submetem ao regime jurídico-empresarial. Quer dizer, não estão sujeitas à falência e não podem requerer a recuperação judicial. Sua disciplina legal específica encontra-se na Lei 5.764/71 e nos arts. 1.093 a 1.096 do CC, e seu estudo cabe ao Direito Civil.

6. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

O empresário pode ser pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, denomina-se *empresário individual*; no segundo, *sociedade empresária*.

Deve-se desde logo acentuar que os sócios da sociedade empresária *não* são empresários. Quando pessoas (naturais) unem seus esforços para, em sociedade, ganharem dinheiro com a exploração empresarial de uma atividade econômica, elas não se tornam empresárias. A *sociedade* por elas constituída (uma pessoa jurídica com personalidade autônoma, sujeito de direito independente) é que será empresária, para todos os efeitos legais. Os sócios da sociedade empresária são empreendedores ou investidores, de acordo com a colaboração dada à sociedade: os empreendedores, além de capital, costumam devotar também trabalho à pessoa jurídica, na condição de seus administradores, ou as controlam; os investidores limitam-se a aportar capital. As regras que são aplicáveis ao empresário individual não se aplicam aos sócios da sociedade empresária - *é muito importante apreender isto*.

O empresário individual, em regra, não explora atividade economicamente relevante. Em primeiro lugar, porque negócios de vulto exigem naturalmente grandes investimentos. Além disso, o risco de insucesso, inerente a empreendimento de qualquer natureza e tamanho, é proporcional às dimensões do negócio: quanto maior e mais complexa a atividade, maiores serão os riscos. Em consequência, as

atividades de maior envergadura econômica são exploradas por sociedades empresárias *anônimas* ou *limitadas*, que são os tipos societários que melhor viabilizam a conjugação de capitais e segregação de riscos (limitação de perdas). Aos empresários individuais sobram os negócios rudimentares e marginais, muitas vezes ambulantes. Dedicam-se a atividades como varejo de produtos estrangeiros adquiridos em zonas francas (sacoleiros), confecção de bijuterias, de doces para restaurantes ou bufês, quiosques de miudezas em locais públicos, bancas de frutas ou pastelarias em feiras semanais etc.

Em relação às pessoas físicas, o exercício de atividade empresarial é vedado em duas hipóteses (relembre-se que não se está cuidando, aqui, das condições para uma pessoa física ser *sócia* de sociedade empresária, mas para ser empresária individual). A primeira diz respeito à proteção dela mesma, expressa em normas sobre *capacidade* (CC, arts. 972, 974 a 976); a segunda refere-se à proteção de terceiros e se manifesta em *proibições ao exercício da empresa* (CC, art. 973). Desta última, tratarei mais à frente (*Cap. 2*, item 3).

Para ser empresário individual, a pessoa deve encontrar-se em pleno gozo de sua capacidade civil. Não têm capacidade para exercer empresa, portanto, os menores de 18 anos não emancipados, ébrios habituais, viciados em tóxicos, os que não puderem exprimir a vontade, os pródigos, e, nos termos da legislação própria, os indígenas. Destaque-se que o menor emancipado (por outorga dos pais, casamento, nomeação para emprego público efetivo, estabelecimento por economia própria, obtenção de grau em curso superior), exatamente por se encontrar no pleno gozo de sua capacidade jurídica, pode exercer empresa como o maior.

No interesse do incapaz, prevê a lei hipótese excepcional de exercício da empresa: pode ser empresário individual o incapaz *autorizado* pelo juiz. O instrumento desta autorização denomina-se *alvará*. A circunstância em que cabe essa autorização é especialíssima. Ela só poderá ser concedida pelo Judiciário para o incapaz *continuar* exercendo empresa que ele mesmo constituiu, enquanto ainda era capaz, ou que foi constituída por seus pais ou por pessoa de quem o incapaz é sucessor. Não há previsão legal para o juiz autorizar o incapaz a dar início a novo empreendimento.

O exercício da empresa por incapaz autorizado é feito mediante representação (se absoluta a incapacidade) ou assistência (se relativa). Se o representante ou o assistido for ou estiver proibido de exercer empresa, nomeia-se, com aprovação do juiz, um gerente. Mesmo não havendo impedimento, se reputar do interesse do incapaz, o juiz pode, ao conceder a autorização, determinar que atue no negócio o gerente. A autorização pode ser revogada pelo juiz, a qualquer tempo, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito. A revogação não prejudicará os interesses de terceiros (consumidores, empregados, fisco, fornecedores etc.).

Os bens que o empresário incapaz autorizado possuía, ao tempo da sucessão ou interdição, não respondem pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial exercida durante o prazo da autorização, a menos que tenham sido nela empregados, antes ou depois do ato autorizatório. Do alvará judicial constará a relação destes bens.

7. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Juridicamente, a "empresa individual de responsabilidade limitada" (EIRELI) não é um empresário individual. Trata-se da denominação que a lei brasileira adotou para introduzir, entre nós, a figura da *sociedade limitada unipessoal*, isto é, a sociedade limitada constituída por apenas um sócio.

Embora não tenha se valido da melhor técnica, a Lei 12.441/2011, ao alterar disposições do Código Civil para instituir a EIRELI, tinha em vista, inegavelmente, trazer para o direito brasileiro o instituto da sociedade limitada unipessoal. Apesar de ter definido a nova figura como uma pessoa jurídica diferente das sociedades (CC, art. 44, VI), e discipliná-la num Título próprio, *entre* os dedicados, de um lado, ao empresário individual e, de outro, às sociedades, ao dispor detalhadamente sobre a EIRELI a lei valeu-se de conceitos e dispositivos legais próprios da sociedade limitada.

O sócio único da EIRELI, como todos os sócios de sociedades empresárias, não é empresário. Empresário é a pessoa jurídica da EIRELI. Ela é o sujeito de direito que explora a atividade empresarial, contrata, emite ou aceita títulos de crédito, é a parte legítima para requerer a recuperação judicial ou ter a falência requerida e decretada.

Oportunamente, o legislador deverá corrigir as imprecisões técnicas ("empresa", recorde-se, é atividade e não sujeito de direito) e aprimorar a disciplina do tema, tratando, de um lado, do empresário individual com responsabilidade limitada (em que bens e obrigações afetos à atividade empresarial constituem um patrimônio de afetação) e, de outro, da sociedade limitada unipessoal (que, a rigor, não tem nenhuma especificidade em relação à limitada pluripessoal). Enquanto correção e aprimoramento não vêm, cabe à doutrina e à jurisprudência procurar sistematizar as imperfeitas disposições legais sobre a EIRELI - e a melhor forma de proceder a essa sistematização consiste em considerá-la como sendo, simplesmente, a (atual) designação dada pela lei brasileira à sociedade limitada unipessoal.

8. PREPOSTOS DO EMPRESÁRIO

Como organizador de atividade empresarial, o empresário (pessoa física ou jurídica) necessariamente deve contratar mão de obra, que é um dos fatores de produção. Seja como empregado pelo regime do Direito do Trabalho (CLT) ou como representante, autônomo ou pessoal terceirizado vinculados por contrato de prestação de serviços, vários trabalhadores desempenham tarefas sob a coordenação do empresário. Para efeitos do direito das obrigações, esses trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo contratual mantido com o empresário, são chamados *prepostos* (CC, arts. 1.169 a 1.178).

Em termos gerais, os atos dos prepostos praticados no estabelecimento empresarial e relativos à atividade econômica ali desenvolvida obrigam o empresário preponente. Se alguém adentra a loja e se dirige a pessoa uniformizada que lá se encontra, e com ela inicia tratativas negociais (quer dizer, pede informações sobre produto exposto, indaga sobre preço e garantias, propõe forma alternativa de parcelamento etc.), o empresário dono daquele comércio (pessoa física ou jurídica) está sendo contratualmente responsabilizado. As informações prestadas pelo empregado, autônomo ou funcionário terceirizado, bem como os compromissos por eles assumidos, atendidos aqueles pressupostos de lugar e objeto, criam obrigações para o empresário (CC, art. 1.178).

Os prepostos, por evidente, respondem pelos seus atos de que derivam obrigações do empresário com terceiros. Se agiram com culpa, devem indenizar em regresso o preponente titular da empresa; se com dolo, respondem eles *também* perante o terceiro, em solidariedade com o empresário.

Está o preposto proibido de concorrer com o seu preponente. Quando o faz, sem autorização expressa, responde por perdas e danos. O empresário prejudicado tem também direito de retenção, até o limite dos lucros da operação econômica irregular de seu preposto, sobre os créditos deste. Configura-

se, também, eventualmente o crime de concorrência desleal, se houver usurpação de segredo de empresa (LPI, art. 195).

Dois prepostos têm sua atuação referida especificamente no Código Civil: o gerente e o contabilista. O gerente é o funcionário com funções de chefia, encarregado da organização do trabalho num certo estabelecimento (sede, sucursal, filial ou agência). Os poderes do gerente podem ser limitados por ato escrito do empresário. Para produzir efeitos perante terceiros, este ato deve ser arquivado na Junta Comercial ou comprovadamente informado para estes. Não havendo limitação expressa, o gerente responsabiliza o preponente em todos os seus atos e pode, inclusive, atuar em juízo pelas obrigações resultantes do exercício de sua função.

Por sua vez, o contabilista é o responsável pela escrituração dos livros do empresário. Só nas grandes empresas este preposto costuma ser empregado; nas pequenas e médias, normalmente, é profissional com quem o empresário mantém contrato de prestação de serviços.

Entre o gerente e o contabilista, além das diferenças de funções e responsabilidades, há também duas outras que devem ser destacadas: enquanto é facultativa a função do gerente (o empresário pode, simplesmente, não ter este tipo de preposto), a do contabilista é obrigatória (salvo se nenhum houver na localidade - CC, art. 1.182); ademais, qualquer pessoa pode trabalhar como gerente, mas apenas os regularmente inscritos no órgão profissional podem trabalhar como contador ou técnico em contabilidade.

9. AUTONOMIA DO DIREITO COMERCIAL

O Direito Comercial (Mercantil, Empresarial ou de Negócios) é área especializada do conhecimento jurídico. Sua autonomia, como disciplina curricular ou campo de atuação profissional específico, decorre dos conhecimentos extrajurídicos que professores e advogados devem buscar, quando o elegem como ramo jurídico de atuação. Exige-se do comercialista não só dominar conceitos básicos de economia, administração de empresas, finanças e contabilidade, como principalmente compreender as necessidades próprias do empresário e a natureza de *elemento de custo* que o direito muitas vezes assume para este. Quem escolhe o Direito Comercial como sua área de estudo ou trabalho deve estar disposto a contribuir para que o empresário alcance o objetivo fundamental que o motiva na empresa: o lucro. Sem tal disposição, será melhor - para o estudioso e profissional do direito, para os empresários e para a sociedade - que ele dedique seus esforços a outra das muitas e ricas áreas jurídicas.

No Brasil, a autonomia do Direito Comercial é referida até mesmo na Constituição Federal, que, ao listar as matérias da competência legislativa privativa da União, menciona "direito civil" em separado de "comercial" (CF, art. 22, I).

Não compromete a autonomia do Direito Comercial a opção do legislador brasileiro de 2002 no sentido de tratar a matéria correspondente ao objeto desta disciplina no Código Civil (Livro II da Parte Especial). A autonomia didática e profissional não é minimamente determinada pela legislativa. Afinal, Direito Civil não é Código Civil; assim como Direito Comercial não é Código Comercial. À forma considerada mais oportuna de organizar os textos e diplomas legais não corresponde necessariamente a melhor de estudar e ensinar o direito.

Também não compromete a autonomia da disciplina a adoção, no direito privado brasileiro, da

Teoria da Empresa. Como visto, a bipartição dos regimes jurídicos disciplinadores de atividades econômicas não deixa de existir, quando se adota o critério da empresarialidade para circunscrever os contornos do âmbito de incidência do Direito Comercial. Aliás, a Teoria da Empresa não importa nem mesmo a unificação legislativa do direito privado.

A demonstração irresponsável de que a autonomia do Direito Comercial não é comprometida nem pela unificação legislativa do direito privado nem pela Teoria da Empresa encontra-se nos currículos dos cursos jurídicos de faculdades italianas. Já se passaram 70 anos da unificação legislativa e da adoção da Teoria da Empresa na Itália, e Direito Comercial continua sendo tratado lá como disciplina autônoma, com professores e literatura especializados. Até mesmo em reformas curriculares recentes, como a empreendida na Faculdade de Direito de Bolonha a partir do ano letivo de 1996/1997, a autonomia do Direito Comercial foi amplamente prestigiada.

Capítulo 2. REGIME JURÍDICO DA LIVRE-INICIATIVA

1. PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO REGIME JURÍDICO-COMERCIAL

A Constituição Federal, ao dispor sobre a exploração de atividades econômicas, vale dizer, sobre a produção dos bens e serviços necessários à vida das pessoas em sociedade, atribuiu à iniciativa privada, aos particulares, o papel primordial, reservando ao Estado apenas uma função supletiva (art. 170). A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é possível em hipóteses excepcionais, quando, por exemplo, for necessária à segurança nacional ou se presente um relevante interesse coletivo (art. 173).

Estes são os pressupostos constitucionais do regime jurídico-comercial.

Ao atribuir à iniciativa privada papel de tal monta, a Constituição torna possível, sob o ponto de vista jurídico, a previsão de um regime específico pertinente às obrigações do empreendedor privado. Não poderia, em outros termos, a ordem jurídica conferir uma obrigação a alguém, sem, concomitantemente, prover os meios necessários para integral e satisfatório cumprimento dessa obrigação. Se, ao capitalista, a ordem reserva a primazia na produção, deve cuidar para que ele possa desincumbir-se, plenamente, dessa tarefa. Caso contrário, ou seja, se não houvesse um regime jurídico específico para a exploração econômica, a iniciativa privada permaneceria inerte e toda a sociedade sofreria com a estagnação da produção dos bens e serviços indispensáveis à satisfação de suas necessidades. É claro, se o modo de produção não fosse o capitalista, e o Estado fosse o responsável pela produção dos bens e serviços necessários à vida em sociedade, não teria sentido um regime jurídico próprio para a categoria de profissionais que, supletivamente, se dedicassem à exploração econômica.

Por estas razões, é pressuposto jurídico do regime jurídico-comercial uma Constituição que adote os princípios do liberalismo, ou de uma vertente neoliberal, no regramento da ordem econômica. Sem um regime econômico de livre-iniciativa, de livre-competição, não há direito comercial. Ao nível da legislação ordinária, o direito complementa tais pressupostos constitucionais, procurando garantir a livre-iniciativa e a livre-competição por meio da repressão ao abuso do poder econômico e à concorrência desleal.

2. PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA E DA CONCORRÊNCIA

Em consonância com a definição de um regime econômico de inspiração neoliberal (no sentido de "liberalismo mitigado"), pela Constituição, o legislador ordinário estabeleceu mecanismos de amparo à liberdade de competição e de iniciativa. Estes mecanismos, basicamente, configuram a coibição de práticas empresariais incompatíveis com o referido regime, as quais se encontram agrupadas em duas categorias: infração à ordem econômica e concorrência desleal.

2.1. Infrações contra a ordem econômica

As infrações contra a ordem econômica (antigamente chamadas de "abuso do poder econômico") estão definidas na Lei 12.529/11 (LIOE). Para a sua caracterização, é necessário conjugarem-se dois

dispositivos desse diploma legal: de um lado, o *caput* do art. 36, que estabelece o objetivo ou efeitos possíveis da prática empresarial ilícita; de outro, o seu § 3º, que elenca diversas hipóteses em que a infração pode ocorrer.

Note-se que somente configuram infrações contra a ordem econômica as práticas empresariais elencadas no art. 36, § 3º, da LIOE se caracterizado o exercício do poder econômico por meio de condutas que visem a limitar, falsear ou prejudicar a livre-concorrência ou livre-iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços ou aumentar arbitrariamente os lucros (os requisitos mencionados no *caput* do art. 36). Por exemplo, o tratamento diferenciado de adquirentes, com a fixação de preços ou condições especiais para um ou mais deles, está referido no inc. X do § 3º do art. 36 da LIOE. Essa prática discriminatória tanto pode ser absolutamente lícita como caracterizar infração contra a ordem econômica. Depende dos objetivos pretendidos (ou obtidos mesmo sem intenção) pelo empresário que faz a discriminação. Se buscou, por meio dela, prejudicar a livre-concorrência, dominar mercado relevante ou aumentar arbitrariamente os preços, ou um desses efeitos se realizou mesmo sem a intenção dele, então a conduta é infracional. Caso contrário, se os objetivos pretendidos ou os efeitos da prática empresarial não têm relação com exercício abusivo do poder econômico, não existirá qualquer ilicitude.

Em suma, as condutas elencadas no art. 36, § 3º, da LIOE somente caracterizam infração contra a ordem econômica se presentes os pressupostos do *caput* do mesmo art. 36 da LIOE. Por outro lado, qualquer prática empresarial, ainda que não mencionada pelo legislador no § 3º do art. 36, configurará infração contra a ordem econômica se os seus objetivos ou efeitos forem os referidos no *caput* do mesmo dispositivo.

Assim é, na verdade, porque a repressão a tais condutas está fundada no texto constitucional, em que já se encontra totalmente delineada (CF, art. 173, § 4º).

Na análise da vinculação entre a natureza da conduta e o seu objetivo ou efeito (potencial ou realizado), é irrelevante a existência ou não de culpa do empresário. Ou seja, para a caracterização da infração contra a ordem econômica basta a prova de que a prática empresarial produziu (ou poderia produzir) os efeitos lesivos à estrutura do livre mercado, sem pesquisa do ânimo do empresário.

A caracterização de infração à ordem econômica dá ensejo à repressão de natureza administrativa, para a qual é competente o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça. O CADE possui um Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, que julga as infrações, após investigação feita por sua Superintendência-Geral.

Prevê a lei as seguintes sanções administrativas a serem impostas contra os empresários condenados pela prática de infração à ordem econômica: multa, publicação pela imprensa do extrato da decisão condenatória, proibição de contratar com o Poder Público ou com instituições financeiras oficiais, inscrição no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, recomendação de licenciamento obrigatório de Patente titularizada pelo infrator, de negativa de parcelamento de tributos ou cancelamento de benefício fiscal, bem como a determinação de atos societários como cisão ou transferência de controle compulsórios. As decisões administrativas condenatórias, proferidas pelo CADE, são títulos executivos extrajudiciais e comportam execução específica quando impõem obrigação de fazer ou não fazer, podendo o juiz para isso decretar a intervenção na empresa.

Além dessas atribuições, de ordem repressiva, o CADE atua também na esfera preventiva. Algumas operações societárias (fusão ou aquisição de empresa) não são eficazes enquanto não forem aprovadas

pelo CADE. O objetivo é evitar a concretização de atos que poderiam limitar ou reduzir a concorrência (LIOE, art. 88).

2.2. Concorrência desleal

A repressão à concorrência desleal, por sua vez, é feita em dois níveis pelo direito. Na área do direito penal, a lei tipifica como crime de concorrência desleal os comportamentos elencados no art. 195 da LPI. São exemplos desses crimes: publicar falsa afirmação em detrimento de concorrente, com objetivo de obter vantagem; empregar meio fraudulento para desviar, em seu proveito ou de terceiro, a clientela de certo comerciante; dar ou prometer dinheiro a empregado de concorrente para que este proporcione vantagem, faltando a dever do emprego etc. No plano civil, a repressão à concorrência desleal pode ter fundamento contratual ou extracontratual.

No caso de repressão civil com fundamento contratual, o concorrente desleal deve indenizar o empresário prejudicado, por ter descumprido a obrigação decorrente de contrato entre eles.

A jurisprudência brasileira sobre o tema teve início com uma célebre pendência judicial entre a Companhia Nacional de Tecidos de Juta e Antonio Álvares Penteado, em que tiveram atuação profissional grandes nomes do direito nacional e estrangeiro, como Rui Barbosa, Carvalho de Mendonça, Vivante e Planiol. A questão era a seguinte: o Conde Álvares Penteado constituiu a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, transferindo-lhe o estabelecimento empresarial de que era titular (a Fábrica Sant'Anna), e em seguida alienou todas as suas ações nessa sociedade. Algum tempo depois, restabeleceu-se na mesma praça, constituindo uma sociedade concorrente (a Companhia Paulista de Aniagem). O instrumento da alienação era omissivo quanto à possibilidade de restabelecimento do alienante, e a Companhia Nacional de Tecidos de Juta defendia a tese de que a cláusula de não restabelecimento seria implícita em avenças dessa natureza. A tese, que hoje é dominante na jurisprudência e na doutrina, não logrou, naquela oportunidade, sagrar-se vencedora.

Desde a entrada em vigor do Código Civil, na omissão do contrato, o alienante de estabelecimento empresarial não pode restabelecer-se na mesma praça, concorrendo com o adquirente, no prazo de 5 anos seguintes ao negócio, sob pena de ser obrigado a cessar suas atividades e indenizar este último pelos danos provenientes de desvio eficaz de clientela sobrevindos durante o período do restabelecimento (art. 1.147). É hipótese de concorrência desleal cuja repressão tem base contratual.

A repressão civil da concorrência desleal com fundamento extracontratual comporta algumas dificuldades. Em primeiro lugar, quando se tratar de concorrência criminosa (LPI, art. 195), não há dúvida que o comportamento correspondente gera, além da responsabilidade penal, a responsabilidade civil de compor eventuais danos. Mas a própria lei (LPI, art. 209) prevê a possibilidade de o prejudicado haver perdas e danos por atos de concorrência desleal não tipificados como crime, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou entre produtos.

O problema é que a teoria clássica da responsabilidade civil, baseada na culpa, não confere solução satisfatória para a aplicação desse dispositivo legal. Ressalte-se, com efeito, que todo empresário, em regime de competição, está com a deliberada intenção de atrair clientela alheia ao seu estabelecimento, provocando, com isso, dano aos demais empresários do mesmo setor. Tanto a concorrência regular quanto a desleal reúnem os elementos que a teoria clássica da responsabilidade civil elegeu para caracterizar a obrigação de indenizar (dolo, dano e relação causal). Contudo, somente uma dessas

modalidades de concorrência - a desleal - está apta a gerar responsabilidade civil. A distinção entre a concorrência regular e a concorrência desleal é bastante imprecisa e depende de uma apreciação especial e subjetiva das relações costumeiras entre os empresários, não havendo, pois, critério geral e objetivo para a caracterização da concorrência desleal não criminosa.

3. PROIBIDOS DE EXERCER EMPRESA

Em determinadas hipóteses, à vista da mais variada gama de razões, o direito obstaculiza o acesso ao exercício da empresa a certas pessoas. Trata-se de hipótese distinta da incapacidade jurídica. Os proibidos de exercer empresa são plenamente capazes para a prática dos atos e negócios jurídicos, mas o ordenamento em vigor entendeu conveniente vedar-lhes o exercício dessa atividade profissional. É a própria Constituição, ao estabelecer que o exercício de profissão estará sujeito ao atendimento dos requisitos previstos em lei ordinária (CF, art. 5º, XIII), que fundamenta a validade das proibições ao exercício da empresa.

O principal caso de proibição de exercer empresa que interessa ao direito comercial, hoje, é o do falido não reabilitado. O empresário que teve sua quebra decretada judicialmente só poderá retornar a exercer atividade empresarial após a reabilitação também decretada pelo juiz. Se a falência não foi fraudulenta, ou seja, não incorreu o falido em crime falimentar, basta a declaração de extinção das obrigações para considerar-se reabilitado. Se, no entanto, foi o falido condenado por crime falimentar, deverá, após o decurso do prazo legal, obter, além da declaração de extinção das obrigações, a sua reabilitação penal.

O direito comercial proíbe o exercício da empresa também àqueles que foram condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade empresarial. É o que decorre do disposto no art. 35, II, da LRE. Assim, se for aplicada, pelo juízo criminal, a pena de vedação do exercício do comércio a determinada pessoa, a Junta Comercial não poderá arquivar ato constitutivo de empresa, individual ou societária, em que o nome dessa pessoa figure como titular ou administrador. Claro que, uma vez concedida a reabilitação penal, cessa a proibição.

Outra hipótese de proibição do exercício do comércio encontrada no direito comercial diz respeito ao leiloeiro (Decreto 21.981/32, art. 36, § 1º).

As demais hipóteses de proibição do exercício de atividade empresarial não interessam, senão indiretamente, ao direito comercial. São previsões localizadas em outros campos do direito, mais precisamente no direito público.

No direito administrativo, é comum prever o estatuto dos funcionários públicos a proibição para que estes exerçam o comércio, como forma, argumenta-se, de evitar que eles se preocupem com assuntos alheios aos pertinentes ao seu cargo ou função pública.

No direito aeronáutico, os serviços de transporte aéreo doméstico são reservados às pessoas jurídicas brasileiras (Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 216).

No direito constitucional, preveem-se hipóteses de proibição do exercício de determinadas atividades econômicas ao estrangeiro ou às sociedades não sediadas no Brasil, ou não constituídas segundo as nossas leis. É o caso, por exemplo, da assistência à saúde, vedada a empresas com capital estrangeiro, salvo nas exceções legais (CF, art. 199, § 3º).

Há, por fim, no direito previdenciário, norma estabelecendo a proibição do exercício de atividade empresarial aos devedores do INSS (Lei 8.212/91, art. 95, § 2º, d).

O impedido que desrespeitar a proibição está sujeito a consequências de natureza administrativa ou penal. Para fins do direito comercial, ou seja, no que diz respeito às obrigações em que se envolve o proibido, nenhuma consequência existe. Não poderá ele, ou quem com ele tenha contratado, liberar-se dos vínculos obrigacionais, de origem contratual ou legal, alegando a proibição do exercício da atividade (CC, art. 973).

A doutrina costuma acentuar a diferença básica entre a incapacidade para o exercício da empresa e a proibição de ser empresário. A primeira é estabelecida para a proteção do próprio incapaz, afastando-o dos riscos inerentes à atividade econômica, ao passo que as hipóteses de proibição estão relacionadas com a tutela do interesse público ou mesmo das pessoas que se relacionam com o empresário. O direito tem em vista a proteção do incapaz ao bloquear o seu acesso à prática da atividade empresarial, atento à sua deficiência de discernimento. Mas, ao definir que ao falido é vedado o exercício da empresa, o objetivo é o de resguardar os interesses dos demais agentes econômicos que poderiam com este entabular negociações.

4. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MEI

A Constituição Federal, no art. 179, estabelece que o Poder Público dispensará tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, no sentido de simplificar o atendimento às obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, podendo a lei, inclusive, reduzir ou eliminar tais obrigações. O objetivo dessa norma é o de incentivar tais empresas, criando as condições para o seu desenvolvimento.

Em cumprimento à prescrição constitucional, editou-se a Lei Complementar n. 123, de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).

A lei define Microempresa e Empresa de Pequeno Porte em função do valor de sua receita bruta anual (Estatuto, art. 3º). No cômputo da receita bruta anual, que é conceito sinônimo de faturamento, considera-se a soma de todos os ingressos derivados do exercício da atividade comercial ou econômica a que se dedica o empresário.

Os empresários individuais, as EIRELIS ou as sociedades empresárias ou simples que atenderem aos limites legais deverão acrescer ao seu nome empresarial as expressões "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte", ou as abreviaturas ME ou EPP, conforme o caso.

O Estatuto criou o "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte", cuja sigla é Simples Nacional. Trata-se de regime tributário simplificado ao qual podem aderir as microempresas e empresas de pequeno porte. Os optantes do Simples Nacional pagam diversos tributos (IR, PIS, IPI, contribuições e, eventualmente, o ICMS e o ISS) mediante um único recolhimento mensal, proporcional ao seu faturamento.

As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de manter escrituração mercantil, mas devem emitir nota fiscal e conservar em boa guarda os documentos relativos à sua atividade (Estatuto, art. 27). As não optantes devem manter a escrituração de um livro específico, chamado *Livro-Caixa* (art. 26, § 2º).

Em 2008, o Estatuto foi alterado para a criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI) (art. 18-A). Trata-se do empresário individual que tenha auferido receita bruta anual até determinado limite, fixado na lei. Além de se beneficiar com a ampla simplificação dos procedimentos de inscrição no Registro do Comércio e cadastros fiscais e dispensa de escrituração, o MEI tem o direito de recolher os tributos abrangidos pelo Simples Nacional por meio do pagamento de valores fixos mensais.

Capítulo 3. REGISTRO DE EMPRESA

1. ÓRGÃOS DO REGISTRO DE EMPRESA

Uma das obrigações do empresário é a de inscrever-se no Registro das Empresas *antes* de dar início à exploração de seu negócio (CC, art. 967).

O Registro das Empresas está estruturado de acordo com a Lei 8.934, de 1994 (LRE). Trata-se de um sistema integrado por órgãos de dois níveis diferentes de governo: no âmbito federal, o Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI); e no âmbito estadual, a Junta Comercial. Essa peculiaridade do sistema repercute no tocante à vinculação hierárquica de seus órgãos, que varia em função da matéria.

O DREI integra a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (Decreto 8.001/2013) e é o órgão máximo do sistema. Entre as suas atribuições, destacam-se as seguintes:

a) supervisionar e coordenar a execução do registro de empresa, expedindo, para esse fim, as normas e instruções necessárias, dirigidas às Juntas Comerciais de todo o País;

b) orientar e fiscalizar as Juntas Comerciais, zelando pela regularidade na execução do registro de empresa. Caso suas instruções não sejam satisfatoriamente atendidas, caberá, na forma da lei, promover a representação às autoridades administrativas competentes, como o Secretário de Estado a que esteja vinculada a Junta ou mesmo ao Governador;

c) promover ou providenciar medidas correicionais do Registro de Empresa. Dessa competência não deriva o poder para intervir unilateralmente nos serviços da Junta Comercial, quando necessário à correção de falhas ou deficiências. Como a competência do DREI tem natureza exclusivamente supletiva, conforme esclarece a própria lei, em obediência ao princípio constitucional federativo, só poderá ocorrer a intervenção se resultar frutífera a representação endereçada à autoridade estadual hierarquicamente superior à Junta e essa autoridade, então, concordar que a correção se faça pelo órgão federal;

d) organizar e manter atualizado o Cadastro Nacional das Empresas Mercantis. Esse cadastro não tem efeitos registrários, ou seja, a inscrição do empresário nele efetuada não supre o registro na Junta Comercial, para fins de regularidade do exercício do comércio; cuida-se, isto sim, de um simples banco de dados de natureza essencialmente estatística, que serve de subsídio à política econômica federal.

Por esse rol das principais atribuições do DREI, pode-se ter uma ideia do perfil que o legislador lhe conferiu. Trata-se de órgão do sistema de registro de empresas sem função executiva, isto é, ele não realiza qualquer ato de registro de empresa. Compete-lhe, todavia, fixar as diretrizes gerais para a prática dos atos registrários, pelas Juntas Comerciais, acompanhando a sua aplicação e corrigindo distorções.

Já às Juntas Comerciais, órgãos da administração estadual, cabe a execução do registro de empresa, além de outras atribuições legalmente estabelecidas. Destacam-se as seguintes competências:

a) assentamento dos usos e práticas mercantis. O comércio rege-se também por normas

consuetudinárias, cuja compilação é da incumbência da Junta Comercial. Na forma de seu regimento interno, o assentamento deve ser precedido de ampla discussão no meio empresarial e análise de sua adequação à ordem jurídica vigente, pela Procuradoria. Uma vez deliberado o assentamento, a Junta pode expedir aos interessados as correspondentes certidões, que servem em juízo como início de prova;

b) habilitação e nomeação de tradutores públicos e intérpretes comerciais. A Junta funciona, nesse caso, como órgão profissional dessas categorias paracomerciais, cabendo-lhe exercer o poder disciplinar, bem como estabelecer o código de ética da atividade e controlar o exercício da profissão;

c) expedição da carteira de exercício profissional de empresário e demais pessoas legalmente inscritas no registro de empresa.

A subordinação hierárquica da Junta Comercial é híbrida. Deve esse órgão, de acordo com a matéria em pauta, reportar-se ou ao DREI ou ao governo estadual a que pertença, segundo se trate, respectivamente, de matéria técnica de registro de empresa ou de matéria administrativa. Assim, não pode o governador do Estado expedir decreto referente a registro de sociedade empresária, assim como o DREI não pode interferir com as questões específicas do funcionalismo ou da dotação orçamentária do órgão estadual. Em se tratando, portanto, de questões de direito comercial, a subordinação hierárquica da Junta diz respeito ao DREI; já em termos de direito administrativo e financeiro, diz respeito ao Poder Executivo estadual de que faça parte.

A Junta Comercial, no exercício de suas funções registrárias, está adstrita aos aspectos exclusivamente formais dos documentos que lhe são dirigidos. Não lhe compete negar o registro senão com fundamento em vício de forma, sempre sanável. E, mesmo nesta seara, a sua atuação deve orientar-se pelas prescrições legais, sendo-lhe defeso exigir o atendimento de requisito formal não estabelecido no ordenamento jurídico em vigor. O prejudicado por ilegalidade da Junta poderá, evidentemente, socorrer-se do Poder Judiciário. A propósito, a Justiça competente para conhecer a validade dos atos da Junta Comercial é a Estadual, a menos que se trate de *mandado de segurança* contra ato pertinente ao registro das empresas, hipótese em que o órgão estadual age por orientação do DREI e, por essa razão, é da Justiça Federal a competência (CF, art. 109, VIII).

2. ATOS DO REGISTRO DE EMPRESA

A lei de 1994, simplificando bastante a sistemática anterior, reduziu para três os atos do registro de empresa: a matrícula, o arquivamento e a autenticação.

A matrícula é o nome do ato de inscrição dos tradutores públicos, intérpretes comerciais, leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais. Trata-se de profissionais que desenvolvem atividades definidas como "auxiliares do comércio". Os dois primeiros, além de matriculados, são também habilitados e nomeados pela Junta, enquanto os três últimos são apenas matriculados.

O arquivamento é pertinente ao registro do empresário, seja pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, arquiva-se a inscrição na Junta do empresário individual. No segundo, arquivam-se a constituição, dissolução e alteração contratual das sociedades empresárias. As cooperativas, embora sejam sociedades simples, continuam a ter os seus atos arquivados no registro de empresa (em razão de questionável entendimento do DNRC, órgão que antecedeu o DREI no Registro Público de Empresas). São igualmente arquivados os atos relacionados aos consórcios de empresas e aos grupos de sociedades,

assim como os concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil. Arquivam-se, finalmente, as declarações de microempresa e, analogicamente, também as de empresa de pequeno porte, além de quaisquer outros documentos ou atos de interesse de empresários. O Código Civil determina que os atos modificativos da inscrição do empresário sejam *averbados* à margem desta (art. 968, § 1.º). A averbação deve ser considerada uma espécie de arquivamento.

Já a autenticação está ligada aos instrumentos de escrituração, que são os livros comerciais. Nesse caso, a autenticação é condição de regularidade do documento, já que configura requisito extrínseco de validade da escrituração mercantil. Ela pode revestir-se, contudo, também de outra natureza, isto é, a de mero ato confirmatório da correspondência material entre cópia e original do mesmo documento, desde que esteja registrado na Junta (LRE, art. 39, II).

3. PROCESSO DECISÓRIO DO REGISTRO DE EMPRESA

Prevê a lei dois regimes de execução do registro de empresa: decisão colegiada ou singular (LRE, arts. 41 e 42).

Processa-se pelo regime de decisão colegiada o arquivamento de atos relacionados à sociedade anônima, tais como os estatutos, as atas de assembleias gerais, do conselho de administração etc. Nesse mesmo regime se enquadra o arquivamento da transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedade empresária de qualquer tipo, além dos relacionados a consórcio de empresas ou grupo de sociedade.

As Juntas Comerciais possuem dois órgãos colegiados: o Plenário e as Turmas. No primeiro, têm assento os vogais (no mínimo 11 e no máximo 23), que, excluídos o Presidente e o Vice-Presidente, serão distribuídos, na sessão inaugural do órgão, em Turmas de 3 membros cada. As decisões colegiadas competem às Turmas (LRE, art. 21), que deliberam por maioria. O prazo para a decisão colegiada é de 5 dias, findos os quais poderão os interessados requerer o arquivamento independentemente de deliberação.

Já o regime de decisão singular compreende a matrícula, a autenticação e todos os demais arquivamentos. Assim, o contrato social de uma sociedade limitada, sua alteração contratual e a inscrição do empresário individual são, por exemplo, arquivados por decisão singular. Quem determina a prática do ato registral sujeito ao regime de decisão singular é o Presidente da Junta ou o vogal por ele designado. Possibilita a lei também que a designação recaia sobre funcionário público do órgão, que possua conhecimentos comprovados de direito comercial e de registro de empresa. O prazo para a decisão singular é de 2 dias.

O julgamento de recurso dos atos praticados pela Junta sempre se faz pelo regime de decisão colegiada, ainda que o ato recorrido tenha sido praticado em outro regime. A instância competente para julgar o recurso é o Plenário (LRE, art. 19).

4. INATIVIDADE DA EMPRESA

O empresário individual e a sociedade empresária que não procederem a qualquer arquivamento no período de dez anos deve comunicar à Junta que ainda se encontram em atividade (LRE, art. 60). Se não o fizerem, serão considerados inativos. A inatividade da empresa autoriza a Junta a proceder ao cancelamento do registro, com a consequente perda da proteção do nome empresarial pelo titular inativo.

Exige a lei que a Junta comunique, previamente, o empresário acerca da possibilidade do cancelamento, podendo fazê-lo por edital. Se atendida a comunicação, desfaz-se a inatividade; no caso de não atendimento, efetua-se o cancelamento do registro, informando-se o fisco. Se, no futuro, o empresário pretender reativar o registro, deverá obedecer aos mesmos procedimentos relacionados com a constituição de uma nova empresa, não tendo o direito de reivindicar o mesmo nome empresarial anteriormente adotado, caso este tenha sido registrado por outro empresário.

No caso de sociedade empresária, do cancelamento do registro por inatividade não decorre a sua dissolução, mas apenas a irregularidade na hipótese de ela continuar funcionando. Quer dizer, a sociedade com arquivamento cancelado não deve necessariamente entrar em liquidação; mas sobrevêm as consequências do exercício irregular da atividade empresarial, caso os sócios não a encerrem (*Cap. 9, item 4*).

5. EMPRESÁRIO IRREGULAR

O registro no órgão próprio não é da essência do conceito de empresário. Será empresário o exercente profissional de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, esteja ou não inscrito no registro das empresas. Entretanto, o empresário não registrado não pode desfrutar dos benefícios que o direito comercial libera em seu favor. Ele é considerado empresário mesmo sem registro; mas, será um empresário "irregular", ao qual se aplicam as seguintes restrições:

a) o empresário irregular não tem legitimidade ativa para o pedido de falência de seu devedor, consoante prescreve o art. 97, § 1.º, da LF. Por este dispositivo, somente o empresário inscrito na Junta Comercial e que exiba o comprovante desta inscrição está em condições de postular a falência de outro empresário. O irregular, embora não possa requerer a falência de outro exercente de empresa, pode ter a sua própria falência requerida e decretada e pode requerer a própria falência (autofalência);

b) o empresário irregular não tem legitimidade ativa para requerer a recuperação judicial, na medida em que a lei elege a inscrição no Registro de Empresa como condição para ter acesso ao favor legal (LF, art. 51, V);

c) o empresário irregular não pode ter os seus livros autenticados no Registro de Empresa, em virtude da falta de inscrição (CC, art. 1.181). Desta maneira, não poderá se valer da eficácia probatória que a legislação processual atribui a esses instrumentos, no art. 418 do CPC; ademais, se for decretada a sua falência, esta será necessariamente fraudulenta, incorrendo o empresário no crime falimentar previsto no art. 178 da LF.

Essas são as consequências que advêm do exercício de atividade empresarial por pessoa natural sem regular inscrição no Registro de Empresa. Quando se tratar de sociedade empresária, como se verá no momento oportuno, além dessas consequências, deve-se acrescentar mais a do art. 990 do CC ("sociedade em comum"), vale dizer, a responsabilidade pelas obrigações sociais solidária e ilimitada dos sócios, respondendo diretamente aquele que, dentre estes, administrou a sociedade.

Além das consequências acima referidas, verdadeiras sanções reservadas pelo direito comercial aos empresários irregulares, podem ser divisados os seguintes efeitos secundários do exercício da empresa sem o necessário registro na Junta Comercial: a) impossibilidade de participar de licitações, nas modalidades de concorrência pública e tomada de preço (Lei 8.666/93, art. 28, II e III); b)

impossibilidade de inscrição em cadastros fiscais (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, e outros), com as decorrentes sanções pelo descumprimento dessa obrigação tributária acessória; c) ausência de matrícula junto ao INSS, processada simultaneamente à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ); na hipótese de sociedade empresária, a falta da matrícula no INSS também acarreta a proibição de contratar com o Poder Público (CF, art. 195, § 3.º).

Capítulo 4. LIVROS COMERCIAIS

1. OBRIGAÇÕES COMUNS A TODOS OS EMPRESÁRIOS

Todos os empresários estão sujeitos às três seguintes obrigações: *a)* registrar-se no Registro de Empresa antes de iniciar suas atividades (CC, art. 967); *b)* escriturar regularmente os livros obrigatórios; *c)* levantar balanço patrimonial e de resultado econômico a cada ano (CC, art. 1.179).

A inobservância de cada uma dessas obrigações não exclui o empresário do regime jurídico-comercial, mas importa consequências diversas, que visam mais a estimular o cumprimento dessas obrigações que, propriamente, punir o empresário pelo descumprimento. Isso não significa que tais consequências sejam desprovidas de caráter sancionador. Pelo contrário, elas importam, até, em alguns casos, a prática de crime. A inobservância da obrigação de promover sua inscrição no órgão de empresas antes de iniciar suas atividades tem por consequência a irregularidade do exercício da atividade empresarial, ou seja, a ilegitimidade ativa para o pedido de falência e de recuperação judicial, a ineficácia probatória dos livros e a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade, conforme já referido anteriormente (*Cap. 3*, item 5). O descumprimento das duas outras obrigações - escrituração dos livros obrigatórios e levantamento anual de balanço - será objeto de estudo no presente capítulo.

Em princípio, assim, o empresário, pessoa natural ou jurídica, independentemente do ramo de atividade em que atue, da forma societária adotada ou quaisquer outras circunstâncias, é obrigado a escriturar os livros obrigatórios, sujeitando-se os que não o fizerem às consequências que se estudarão em seguida.

Existem duas categorias de empresários dispensados de escriturar os livros obrigatórios: *a)* os Microempresários e Empresários de Pequeno Porte *optantes* pelo Simples Nacional (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, art. 27); *b)* os Microempreendedores Individuais (MEIs) (CC, arts. 970 e 1.179, § 2.º e Lei n. 123/2006, art. 68).

Mas é importante salientar que mesmo os empresários dispensados pela lei de manter a escrituração contábil devem procurar contratar um contador para providenciá-la, assim que o permita seu movimento econômico. Somente com uma contabilidade bem feita e atualizada, o empresário dispõe de todos os instrumentos gerenciais para o desenvolvimento de sua empresa.

Os Microempresários e Empresários de Pequeno Porte que não são optantes pelo Simples Nacional ficam sujeitos a um regime de escrituração contábil específico, em que o único livro obrigatório é o *Livro-Caixa* (Estatuto, art. 26, § 2.º).

2. ESPÉCIES DE LIVROS EMPRESARIAIS

Primeiro, é necessário distinguir entre livros empresariais e livros do empresário. Livros empresariais são aqueles cuja escrituração é obrigatória ou facultativa ao empresário, em virtude da legislação comercial. Porém, além destes, também se encontra o empresário obrigado a escriturar outros livros, não mais por causa do direito comercial, mas, sim, por força de legislação de natureza tributária, trabalhista ou previdenciária. Os livros empresariais são uma parte dos livros do empresário.

Os livros empresariais, por sua vez, são de duas espécies: *obrigatórios* ou *facultativos*.

Obrigatórios são aqueles cuja escrituração é imposta ao empresário; a sua ausência, por isso, traz consequências sancionadoras (inclusive no campo penal). Já os facultativos são os livros que o empresário escreve com vistas a um melhor controle sobre os seus negócios e cuja ausência não importa nenhuma sanção.

Sendo obrigatórios, os livros empresariais se subdividem em duas categorias: os *comuns* e os *especiais*.

Comuns são os livros obrigatórios cuja escrituração é imposta a todos os empresários, indistintamente; ao passo que especiais são aqueles cuja escrituração é imposta apenas a uma determinada categoria de exercentes de atividade empresarial.

No direito comercial brasileiro de hoje há apenas *um* livro comercial obrigatório comum, que é o "Diário" (CC, art. 1.180). Somente a escrituração deste livro é obrigatória a todos os empresários, independentemente da natureza da atividade econômica que exploram, do tipo de sociedade adotado ou outras condições. Qualquer empresário e todos os empresários, pessoas naturais ou jurídicas, devem escriturar o livro "Diário".

Já na categoria dos livros obrigatórios especiais, cabe menção ao: *a*) livro "Registro de Duplicatas", cuja escrituração é imposta a todos os empresários que emitem duplicatas (Lei 5.474/68, LD, art. 19); *b*) O livro "Entrada e Saída de Mercadorias", que deve ser escriturado pelo empresário que explora Armazém-Geral (Decreto 1.102/1903, art. 7.º); *c*) os livros de escrituração imposta a todas as sociedades por ações, como "Registro de Ações Nominativas", "Transferência de Ações Nominativas", "Atas das Assembleias Gerais", "Presença dos Acionistas" (Lei 6.404/76, LSA, art. 100).

Estes são exemplos de livros empresariais obrigatórios especiais porque sua escrituração não é imposta a *todos*, mas apenas a uma parcela dos empresários. A relação completa dos livros desta categoria é bastante extensa e variada, contemplando menção a livros especiais de banco, leiloeiro, corretores navais, desmanche de veículos e outros empresários.

Entre os livros facultativos, podem-se citar o *Caixa* e o *Conta-Corrente*. Aliás, o empresário pode criar instrumentos de registro contábil novos, de acordo com as suas necessidades gerenciais, os quais integrarão, sem dúvida, a categoria de livros empresariais facultativos. Os livros facultativos são raramente utilizados pelos empresários.

3. REGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO

Um livro empresarial obrigatório, comum ou especial, ou facultativo, para produzir os efeitos jurídicos que a lei lhe atribui, deve atender a requisitos de duas ordens: intrínsecos e extrínsecos.

Intrínsecos são os requisitos pertinentes à técnica contábil, estudada pela Contabilidade (CC, art. 1.183). Para atender a estes requisitos, a escrituração deve ser feita em idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, emendas ou transportes para as margens. Em livro separado próprio, o empresário poderá assentar os códigos numéricos ou abreviaturas utilizadas em sua escrituração. Para os livros se apresentarem intrinsecamente regulares, a correção de eventuais erros só pode ser feita por meio de

estornos.

Extrínsecos são os requisitos relacionados com a segurança dos livros empresariais. Atende aos requisitos desta ordem o livro que contiver termos de abertura e de encerramento, e estiver autenticado pela Junta Comercial (CC, art. 1.181).

Somente é considerada regular a escrituração do livro empresarial que observe os dois tipos de requisitos. Um livro irregularmente escriturado, vale dizer, que não preencha qualquer dos requisitos legais, equivale a um "não-livro". O titular de um livro, a que falte requisito intrínseco ou extrínseco, é, para o direito, titular de livro nenhum.

Com o desenvolvimento tecnológico, os empresários e seus contabilistas têm-se valido de instrumentos de escrituração cada vez mais simples e operacionais. O direito tem acompanhado essa evolução para disciplinar o uso de instrumentos alternativos aos antigos livros manuscritos ou datilografados. Admite-se, já há muito tempo, a microfilmagem da escrituração (Lei 5.433/68).

Atualmente, a escrituração mercantil é feita em suporte eletrônico (informatizado), em ambientes de *internet* mantidos pela Receita Federal. E, embora não sejam mais obrigatoriamente encadernandos, continuam a ser chamados de "livros". A escrituração eletrônica deve atender aos mesmos requisitos intrínsecos ou extrínsecos acima examinados, mediante a certificação eletrônica das assinaturas digitais do empresário e do contador.

Para fins penais (CP, art. 297, § 2.º), os livros mercantis (comerciais ou empresariais) se equiparam ao documento público. Assim sendo, quem falsificar a escrituração do livro comercial estará sujeito a pena mais grave que a reservada para o crime de falsificação de documentos administrativos não contábeis do empresário. Outrossim, um livro empresarial falsificado não tem a eficácia probatória que lhe é própria.

4. CONSEQUÊNCIAS DA IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO

Se faltar a um livro obrigatório do empresário um dos requisitos legais - intrínseco ou extrínseco - ou se não possuir livro obrigatório, estará ele sujeito a consequências na órbita civil e penal.

No plano civil, o empresário não poderá valer-se da eficácia probatória que o Código de Processo Civil concede aos livros empresariais (art. 379). É, reconheça-se, uma consequência de menor vulto ao empresário que mantém irregular a sua escrituração, na medida em que apenas o impede de desfrutar de benefícios dados pela lei aos empresários que cumprem a obrigação de escrituração contábil. Fica à vontade do empresário decidir por abrir mão, diga-se assim, do exercício desses direitos.

No entanto, esta não é a única consequência para a irregularidade ou inexistência de escrituração empresarial na órbita das relações civis. Se for requerida a exibição de livro obrigatório contra o empresário, não o possuindo, ou possuindo-o irregular, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos relatados pelo requerente, acerca dos quais fariam prova os livros em questão (CPC, art. 400, I). Esta é a sanção, na esfera do direito civil, mais séria para o empresário que não cumpre a obrigação de manter escrituração regular de seu negócio.

No campo do direito penal, a consequência para a ausência ou irregularidade na escrituração de livro obrigatório encontra-se no art. 178 da LF, que reputa crime falimentar "deixar de elaborar, escriturar ou

autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios". Falindo o empresário ou sociedade empresária que não cumpre a obrigação de manter escrituração regular de seu negócio, a falência será necessariamente fraudulenta.

Os livros empresariais devem ser conservados até a prescrição das obrigações neles escrituradas (CC, art. 1.194). Após o decurso do prazo prescricional de todas as obrigações escrituradas em certo livro, a sua inexistência ou mesmo irregularidade não acarretam as consequências, civis e penais, acima listadas.

Os Microempresários e os Empresários de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de manter escrituração mercantil (item 1). Se não for optante e não mantiver o livro contábil exigido pela regra de escrituração mercantil simplificada (Estatuto, art. 26, § 2.º), estará sujeito às mesmas consequências reservadas aos empresários em geral, quando descumprem o dever de escrituração (não poderá usá-los em juízo para fazer prova em seu favor e, falindo, incorrerá em crime falimentar).

5. EXIBIÇÃO JUDICIAL E EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS LIVROS

Os livros comerciais, em tese, gozam da proteção do princípio do sigilo (CC, art. 1.190). A exibição de livros empresariais em juízo, por esta razão, não pode ser feita por simples vontade das partes ou por decisão do juiz, senão em determinadas hipóteses da lei.

Em primeiro lugar, deve-se distinguir a exibição parcial da exibição total. Aquela se destina a garantir o princípio do sigilo, resguardando da curiosidade alheia as partes da escrituração mercantil que não interessam a certa demanda judicial. Assim, a exibição parcial se faz por extração da suma que interessa ao juízo e sem retenção do livro. Já a exibição total pode importar sua retenção em cartório durante todo o andamento da ação, não se assegurando o sigilo de seus dados.

Por estas razões é que a exibição total dos livros comerciais só pode ser determinada pelo juiz a requerimento da parte e em apenas algumas ações (por exemplo: questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou falência), ao passo que a exibição parcial pode ser decretada também de ofício e em qualquer ação judicial (CPC, arts. 420 e 421; CC, art. 1.191). Somente na falência pode o juiz determinar de ofício a exibição total dos livros. A Súmula 260 do STF, pela qual "o exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes", não exclui a exibição total da escrita dos empresários, quando autorizada em lei.

Exibido total ou parcialmente, ou tendo sido objeto de perícia judicial contábil, o livro empresarial terá a força probante (ou eficácia probatória) que a lei estabelece. Ou seja, o livro empresarial prova contra o seu titular, sendo-lhe permitido, contudo, demonstrar, por outros meios probatórios, a eventual inveracidade dos dados contábeis que lhe são desfavoráveis (CPC, art. 417); e prova a favor de seu titular, em demanda entre empresários, desde que atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos já assinalados (art. 418). Conclui-se, pois, que, de um lado, para que tenha eficácia probatória contra o seu titular, o livro empresarial não precisa necessariamente atender aos requisitos legais de escrituração, os quais a lei só exige para fins de eficácia probatória em favor do empresário que os escriturou; além disso, o livro empresarial não tem eficácia probatória inquestionável em favor de seu titular, quando se tratar de demanda contra não empresário, em razão do princípio constitucional da igualdade, posto que o

ordenamento jurídico não confere idêntico direito à outra parte judicial.

A tutela do sigilo dos livros empresariais não tem o alcance de eximir o empresário da sua exibição para determinadas autoridades administrativas (CC, art. 1.193). Ao contrário, em duas hipóteses o legislador expressamente garante a certos funcionários públicos irrestrito acesso à escrituração mercantil: *a*) autoridade fiscal (CTN, art. 195); e *b*) fiscalização da Seguridade Social (Lei 8.212/91, art. 33, § 1.º). Quanto às demais autoridades administrativas, prevalece ainda o princípio do sigilo consagrado pela legislação cível. O funcionário da Prefeitura do setor de fiscalização da segurança de uso dos imóveis, por exemplo, não pode ter acesso à escrituração do empresário, porque não existe expressa disposição na legislação federal que afaste a incidência do sigilo.

6. BALANÇOS ANUAIS

Todo empresário, pessoa natural ou jurídica, está sujeito à obrigação de levantar, anualmente, dois balanços: *a*) o *balanço patrimonial*, demonstrando o ativo e passivo, compreendendo todos os bens, créditos e débitos; e *b*) o *balanço de resultado econômico*, demonstrando a conta dos lucros e perdas (CC, art. 1.179, *in fine*). A esta obrigação não pode se furtar nenhum empresário, exceto o MEI, o Microempresário e o de Pequeno Porte.

Há, por outro lado, empresários obrigados a levantarem balanço e outros demonstrativos em periodicidade menor que a anual (como as instituições financeiras que devem fazê-lo semestralmente - LRB, art. 31).

A lei tipifica como crime falimentar a inexistência dos documentos de escrituração contábil obrigatórios, entre os quais se incluem os balanços patrimoniais e de resultado econômico (LF, art. 178). Assim, incorrem em conduta criminosa o empresário e os representantes legais da sociedade empresária caso venha a ser decretada a sua falência, se os balanços anuais não tinham sido elaborados e autenticados pelo Registro do Comércio.

Os empresários, contudo, cumprem a obrigação de levantar os balanços, não por temerem a sanção penal, mas, sim, para desfrutarem de benefícios ou evitarem alguns prejuízos. Por exemplo: *a*) as sociedades anônimas estão sujeitas a regime próprio sobre demonstrações financeiras, que incluem o balanço patrimonial (LSA, arts. 178 a 184) e o demonstrativo de resultados do exercício (art. 187), e a ausência de seu levantamento acarreta responsabilidade dos administradores; *b*) a legislação tributária sobre imposto de renda sujeita determinadas categorias de empresários contribuintes ao dever de elaboração de balanços periódicos; *c*) o acesso ao crédito bancário tem sido condicionado à apresentação dos balanços regularmente elaborados, de modo a restar fechado o acesso ao crédito bancário aos empresários que não os possuam; *d*) a participação em licitações públicas depende de comprovação da regularidade econômico-financeira, feita inclusive por meio da apresentação de balanços (Lei 8.666/93, art. 31, I).

Capítulo 5. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL

1. CONCEITO E NATUREZA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL

O complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica é o *estabelecimento empresarial*.

Para se entender a natureza desse instituto jurídico é útil socorrer-se de uma analogia com outro conjunto de bens: a biblioteca. Nela, não há apenas livros agrupados ao acaso, mas um conjunto de livros sistematicamente reunidos, dispostos organizadamente, com vistas a um fim - possibilitar o acesso racional a determinado tipo de informação. Uma biblioteca tem o valor comercial superior ao da simples soma dos preços dos livros que a compõem, justamente em razão desse *plus*, dessa organização racional das informações contidas nos livros nela reunidos.

O estabelecimento empresarial é a reunião dos bens necessários ao desenvolvimento da atividade econômica. Quando o empresário reúne bens de variada natureza, como as mercadorias, máquinas, instalações, tecnologia, prédio etc., em função do exercício de uma atividade, ele agrega a esse conjunto de bens uma organização racional que importará em aumento do seu valor *enquanto* continuarem reunidos. Alguns usam a expressão "aviamento", outros falam em "fundo de empresa", para se referir a esse valor acrescido.

Devido à intangibilidade dessa organização racional que o empresário introduz na utilização dos bens integrantes do estabelecimento empresarial, e tendo em vista que ela tem valor de mercado, o direito necessita desenvolver mecanismos para tutela desse *plus* e do valor que ele representa. Cada bem, isoladamente, possui uma proteção jurídica específica (como, por exemplo, os interditos possessórios ou a responsabilização civil e penal por dano patrimonial etc.). Já o estabelecimento empresarial, essa disposição racional dos bens em vista do exercício da atividade econômica, necessita de uma forma própria de proteção. O direito, assim, em geral, deve garantir a justa retribuição ao empresário quando este perde, por culpa que não lhe seja imputável, o valor representado pelo estabelecimento empresarial. Assim, em caso de desapropriação do imóvel em que o empresário mantém o seu estabelecimento empresarial, a indenização correspondente deve compreender o valor do "fundo de empresa" por ele criado. Na sucessão por morte ou na separação do empresário individual, o estabelecimento empresarial deve ser considerado não apenas pelo valor do simples somatório do preço dos bens, singularmente considerados, que o compõem, mas pelo valor deste agregado ao decorrente da situação peculiar em que se encontram - reunidos para possibilitar o pleno desenvolvimento de uma atividade empresarial.

O estabelecimento empresarial, como um bem do patrimônio do empresário, não se confunde, assim, com os bens que o compõem. Desta forma, admite-se, até certos limites, que os seus elementos componentes sejam desagregados do estabelecimento empresarial, sem que este tenha sequer o seu valor diminuído. Claro está que a desarticulação de todos os bens, a desorganização daquilo que se encontrava organizado, importará desativação do estabelecimento empresarial, em sua destruição. Neste caso, perde-se o valor agregado pelo empresário ao dos bens que compunham o estabelecimento empresarial.

Atente-se, no entanto, para a circunstância de que, embora seja resultante da reunião de diversos bens com vistas ao exercício da atividade econômica, o estabelecimento empresarial pode ser descentralizado. O empresário pode abrir filiais, sucursais ou agências, depósitos em prédios isolados,

unidades de sua organização administrativas lotadas em locais próprios etc. Cada parcela descentralizada do estabelecimento empresarial pode, ou não, ter um valor independente, em razão de inúmeros condicionantes de fato.

Por vezes, o patrimônio do empresário - principalmente, no caso de sociedade empresária - resume-se ao estabelecimento empresarial. Trata-se, no entanto, de institutos jurídicos distintos. Todo estabelecimento empresarial integra o patrimônio de seu titular, mas este não se reduz àquele necessariamente. Os bens de propriedade do empresário, cuja exploração não se relaciona com o desenvolvimento da atividade econômica, integram o seu patrimônio, mas não o estabelecimento empresarial. Além disso, também as obrigações passivas (as dívidas) fazem parte do patrimônio do empresário.

O estabelecimento empresarial é composto por bens corpóreos (mercadorias, instalações, equipamentos, utensílios, veículos etc.) e incorpóreos (marcas, patentes, direitos, ponto etc.). O direito civil e o penal compreendem normas pertinentes à proteção dos bens corpóreos (proteção possessória, responsabilidade civil, crime de dano, roubo etc.); o direito industrial tutela a propriedade da marca, invenções etc.; já a Lei de Locações protege o ponto explorado pelo empresário; a proteção do nome empresarial tem o seu estatuto próprio, e assim por diante. Cada elemento do estabelecimento empresarial tem a sua proteção jurídica específica. O direito comercial tradicionalmente se preocupou com a abordagem apenas da tutela dos bens incorpóreos do estabelecimento empresarial, uma vez que do regime dos corpóreos costumam cuidar outros ramos do saber jurídico (direito das coisas e direito penal).

2. ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL

O contrato de venda do estabelecimento empresarial denomina-se *trespasse*.

Por ser bem integrante do patrimônio do empresário, o estabelecimento empresarial, é também garantia dos seus credores. Por esta razão, o *trespasse* está sujeito à observância de duas formalidades específicas, exigidas por lei para a tutela dos interesses de terceiros.

Em primeiro lugar, o contrato deve ser celebrado por escrito para que possa ser arquivado na Junta Comercial e publicado pela imprensa oficial (CC, art. 1.144). Enquanto não providenciadas estas formalidades, a alienação não produzirá efeitos perante terceiros.

A segunda cautela diz respeito aos direitos dos credores do alienante. O empresário tem sobre o estabelecimento empresarial a mesma livre disponibilidade que tem sobre os demais bens de seu patrimônio, mas a lei sujeita o *trespasse* à anuência dos seus credores. Referida anuência pode ser expressa ou tácita, decorrendo esta última modalidade do silêncio do credor após 30 dias da notificação da alienação que o devedor lhe deve endereçar (CC, art. 1.145). Todo empresário deve, ao alienar seu estabelecimento empresarial, colher a concordância por escrito de seus credores, ou fazer a notificação a eles. Há somente uma hipótese de dispensa desta formalidade: se restarem, no patrimônio do alienante, bens suficientes para o pagamento de suas dívidas (solvência do passivo).

Se o empresário não observar esta segunda cautela, poderá ter a falência decretada (LF, art. 94, III, c); e, vindo a falir, a alienação será considerada ineficaz, perante a massa falida (art. 129, VI), que poderá reivindicar o estabelecimento empresarial das mãos do adquirente. A rigor, portanto, a anuência

dos credores em relação à alienação do estabelecimento empresarial é cautela que interessa mais ao adquirente que propriamente ao alienante.

O passivo regularmente escriturado do alienante transfere-se ao adquirente do estabelecimento empresarial. Diz-se que o adquirente é "sucessor" do alienante. Na hipótese de transferência do estabelecimento, portanto, podem os credores do alienante demandar o adquirente para cobrança de seus créditos. O antigo titular do estabelecimento continuará responsável pelas obrigações apenas durante certo prazo (1 ano, contado da publicação do contrato de alienação, para as obrigações vencidas antes do negócio; e contado da data de vencimento, para as demais).

Podem as partes do contrato de alienação de estabelecimento estipular que o alienante ressarcirá o adquirente, por uma ou mais obrigações, principalmente as que se encontram *sub judice*. Entre eles, prevalecerá esta estipulação, mas a cláusula de não transferência de passivo não liberará o adquirente perante terceiros. Ele poderá ser demandado pelo credor do alienante por obrigação regularmente escriturada por este. Se for condenado a pagar ao terceiro credor, o adquirente terá o direito de cobrar o alienante em regresso, com base na cláusula de não transferência de passivo que contrataram.

O credor do alienante somente perde o direito de cobrar o crédito do adquirente do estabelecimento se expressamente renunciou a este direito ao anuir com o trespasse.

Está protegido, de modo particular, o credor trabalhista do alienante do estabelecimento empresarial. A lei estabelece a imunidade dos contratos de trabalho em face da mudança na propriedade ou estrutura jurídica da empresa (CLT, art. 448). O empregado, assim, pode escolher entre demandar o adquirente ou o alienante. É certo, também, que enquanto não prescrito o direito trabalhista, o alienante responde, mesmo que já vencido o prazo anual do Código Civil.

Também o credor tributário está sujeito a condições específicas, na hipótese de venda do estabelecimento empresarial. Pelo direito tributário, o adquirente tem responsabilidade subsidiária ou integral pelas obrigações fiscais do alienante, respectivamente nos casos de este continuar a explorar atividade econômica ou deixar de fazê-lo (CTN, art. 133)

O adquirente não responde, porém, pelas obrigações do alienante (inclusive as de natureza trabalhista e fiscal) se adquiriu o estabelecimento empresarial mediante lance dado em leilão judicial promovido em processo de recuperação judicial ou falência (LF, arts. 60, parágrafo único, e 141, II). Nesse caso, ele não é considerado sucessor do antigo titular do estabelecimento empresarial. Essa regra, que ressalva a responsabilidade do adquirente, é prevista em lei não só como forma de atrair o interesse de potenciais licitantes no leilão como principalmente para proporcionar o mais elevado pagamento por esse ativo do devedor em recuperação ou falido. Por isto, são os credores que acabam beneficiados pela regra da exclusão de sucessão do adquirente nestes casos excepcionais.

Finalmente, lembre-se de que a cláusula de não restabelecimento é implícita em qualquer contrato de alienação de estabelecimento empresarial. O alienante não poderá, nos 5 anos subsequentes à transferência, restabelecer-se em idêntico ramo de atividade empresarial, concorrendo com o adquirente, salvo se devidamente autorizado em contrato (Cap. 2, item 2.2).

3. PROTEÇÃO AO PONTO (LOCAÇÃO EMPRESARIAL)

Dentre os elementos do estabelecimento empresarial, figura o chamado "ponto", que compreende o

local específico em que ele se encontra. Em função do ramo de atividade explorado pelo empresário, a localização do estabelecimento empresarial pode importar acréscimo, por vezes substantivo, no seu valor.

Se o empresário se encontra estabelecido em imóvel de sua propriedade, a proteção jurídica deste valor se faz pelas normas ordinárias de tutela da propriedade imobiliária do direito civil. Já, se está estabelecido em imóvel alheio, que locou, a proteção jurídica do valor agregado pelo estabelecimento seguirá a disciplina da "locação empresarial".

No direito brasileiro, há duas grandes espécies de locação predial: a locação residencial e a não residencial. O uso que o locatário está autorizado a imprimir ao imóvel é o critério de distinção entre essas duas modalidades de regime locatício. Ao locatário da locação residencial não é possível, em regra, explorar qualquer atividade econômica no imóvel objeto de locação; já o locatário da locação não residencial está contratualmente autorizado a explorar atividade econômica no imóvel locado.

Se a locação não residencial atender a certos requisitos, ela será classificada como "empresarial". Neste caso, a lei reconhece ao empresário locatário o direito à renovação compulsória do contrato de locação.

Para que uma locação possa ser considerada empresarial, isto é, para que se submeta ao regime jurídico da renovação compulsória, é necessário que satisfaça os seguintes três requisitos (LL, art. 51):

a) O locatário deve ser empresário (a lei, anterior ao CC, menciona comerciante ou sociedade civil com fim lucrativo). A lei cogita de atividade industrial também, mas trata-se de redundância, porque esta é uma das espécies da atividade empresarial. Por esse requisito, ficam excluídos do regime da locação empresarial os profissionais liberais que individualmente exercem a sua atividade econômica, as associações civis sem fins lucrativos, as fundações etc.

b) A locação deve ser contratada por tempo determinado de, no mínimo, 5 anos, admitida a soma dos prazos de contratos sucessivamente renovados por acordo amigável. Soma esta, inclusive, que pode ser feita pelo sucessor ou cessionário do locatário (STF, Súmula 482).

c) O locatário deve-se encontrar na exploração do mesmo ramo de atividade econômica pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos, à data da propositura da ação renovatória. Requisito que a lei cria tendo em vista a necessidade de um tempo de estabelecimento em certo ponto para que este agregue valor minimamente apreciável à empresa lá explorada.

Assim, a lei reconhece ao locatário empresário que explore o mesmo ramo de empresa, há pelo menos 3 anos ininterruptos, em imóvel locado por prazo determinado não inferior a 5 anos, o direito à renovação compulsória de seu contrato de locação. Tutela-se o valor agregado ao estabelecimento pelo uso de um mesmo ponto durante certo lapso temporal. Chama-se esta tutela de garantia de inerência no ponto, ou seja, ampara-se o interesse do empresário de continuar estabelecido naquele imóvel que locou.

O exercício desse direito se faz por uma ação judicial própria, denominada "renovatória", que deve ser proposta no prazo entre 1 ano e 6 meses anteriores ao término do contrato a renovar, sob pena de decadência do direito (LL, art. 51, § 5.º).

O direito de inerência do locatário, no entanto, é relativo, já que a legislação ordinária não pode

reconhecê-lo em detrimento do direito de propriedade do locador. Este tem fundamento constitucional e, portanto, eventual lei que criasse o direito à renovação compulsória do contrato de locação, desconsiderando o direito de uso, gozo e disposição sobre o bem de que é titular o locador, seria um diploma inconstitucional. O direito que se concede ao empresário no sentido de garantir-lhe a continuidade da exploração de um imóvel locado não pode importar o aniquilamento do direito de propriedade que o locador exerce sobre o bem. Por esta razão, quando a renovação compulsória do contrato de locação for incompatível com a proteção jurídica da propriedade, em virtude do fundamento constitucional desta última contraposta ao fundamento de lei ordinária daquela, prevalecerá a tutela aos interesses do locador, devendo o locatário entregar o imóvel.

É a própria lei que define os casos em que o direito à renovação compulsória será ineficaz, em face da tutela do direito de propriedade. Trata-se de elenco legal meramente exemplificativo, porque a inoperância do direito à renovação, nesses casos, decorre das disposições constitucionais. Sempre que o direito de propriedade for desprestigiado em decorrência da renovação da relação locatícia, esta não poderá ocorrer, mesmo que inexistia específica previsão legal, pois a tutela do direito do locador no tocante à exceção de retomada deflui diretamente da Constituição.

O locatário que não puder exercer o seu direito de inerência, em virtude de exceção de retomada, deverá ser, em determinadas hipóteses, indenizado pelo valor que acresceu ao bem.

São os seguintes os fatos referidos em lei ordinária que autorizam a "exceção de retomada" e as hipóteses em que o locatário será indenizado:

a) Insuficiência da proposta de renovação apresentada pelo locatário (LL, art. 72, II). Em sua ação renovatória, deverá o empresário apresentar uma proposta de novo aluguel. Se o valor locatício de mercado do imóvel for superior, a renovação do contrato pelo aluguel proposto importaria em desconsideração do direito de propriedade do locador. Por essa razão, se não melhorar o locatário a sua proposta, a locação não será renovada. Algumas decisões judiciais têm determinado a renovação pelo valor de aluguel apurado em perícia, compatibilizando-se dessa forma os interesses das partes.

b) Proposta melhor de terceiro (LL, art. 72, III). Se o locatário oferece novo aluguel compatível com o mercado, mas o locador possui proposta melhor de outra pessoa, a renovação acarretaria ofensa ao seu direito de propriedade. Assim sendo, a menos que o locatário concorde em pagar o equivalente ao ofertado pelo terceiro, a locação não será renovada.

c) Reforma substancial no prédio locado (LL, art. 52, I). Se o Poder Público obriga o locador a introduzir reformas no imóvel ou se o proprietário mesmo quer reformá-lo, para valorização do seu patrimônio, então o locatário não terá reconhecido o seu direito de inerência ao ponto. Nessa hipótese, será devida a indenização se o início das obras retardar por mais de 3 meses contados da desocupação.

d) Uso próprio (LL, art. 52, II). O proprietário pode querer utilizar o imóvel, seja para finalidades econômicas ou não. A lei restringe essa exceção, vedando-a no caso de pretender o locador explorar no prédio a mesma atividade explorada pelo locatário, mas essa limitação é inconstitucional, incompatível com o direito de propriedade. Assim, o locador pode, em qualquer caso, pretender a retomada para uso próprio, ainda que o seu objetivo seja o de competir com o locatário. Claro que, assim sendo, será devida indenização pela perda do ponto, para que não se caracterize o enriquecimento indevido do locador. Note, aqui, a situação específica da chamada "locação-gerência", hipótese em que a locação compreende não somente o imóvel, como também um estabelecimento empresarial nele já instalado pelo

locador. Neste caso, a exceção de retomada não é decorrência apenas da proteção constitucional ao direito de propriedade. Ela se justifica também por não ter sido o locatário que agregou o valor ao ponto comercial. Na locação-gerência, ademais, não cabe indenização ao locatário em razão da retomada, exatamente porque o ponto de referência dos consumidores foi constituído pelo locador antes da locação.

e) Transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de 1 ano e titularizado por ascendente, descendente ou cônjuge (ou sociedade por eles controlada), desde que atue em ramo diverso do locatário (LL, art. 52, II). Terá este direito à indenização apenas se, a despeito da restrição legal, o novo usuário do prédio explorar atividade igual ou semelhante à sua, ou, entendo, se não se realizar o uso nas condições alegadas que impediram a renovação (se o imóvel é locado a terceiros, p. ex.).

4. "SHOPPING CENTER"

O empresário que se dedica ao ramo dos *shopping centers* exerce uma atividade econômica peculiar, pois não se limita a simplesmente manter um espaço apropriado à concentração de outros empresários atuantes em variados ramos de comércio ou serviço. A sua atividade não se resume à locação de lojas aleatoriamente reunidas em um mesmo local. Ele não é um empreendedor imobiliário comum.

O que distingue o empresário do *shopping center* dos empreendedores imobiliários em geral é a organização da distribuição da oferta de produtos e serviços centralizados em seu complexo (o *tenant mix*). A ideia básica do negócio é pôr à disposição dos consumidores, em um mesmo local, de cômodo acesso e seguro, a mais ampla gama de produtos e serviços. Em outros termos, deve haver um planejamento da distribuição da oferta, uma relativa organização da competição interna. Assim, as locações dos espaços devem atender às múltiplas necessidades do consumidor, de sorte que não falem certos tipos de serviço (banco, correio, cinema, lazer etc.) ou de comércio (restaurante, papelaria, farmácia etc.), mesmo se houver uma atividade central desenvolvida pelo *shopping center* (moda, decoração, material de construção etc.).

Um mero empreendedor imobiliário apenas loca os seus prédios comerciais a quem se propuser a pagar o aluguel que ele considera adequado. A sua preocupação volta-se unicamente ao valor locatício de mercado do seu imóvel e à solvência do locatário. Um empreendedor de *shopping center*, por sua vez, organiza o *tenant mix*, isto é, fica atento às evoluções do mercado consumidor, à ascensão ou decadência das marcas, às novidades tecnológicas e de *marketing*, bem como ao potencial econômico de cada empresário instalado no seu complexo. Tudo isso com o objetivo de atrair o consumidor. Se ele descuidar-se da organização da distribuição dos produtos e serviços abrigados no seu empreendimento, poderá perder valiosos pontos na competição entre os *shopping centers*.

Em razão dessas particularidades, discute-se muito sobre a tutela do interesse de inerência ao ponto dos locatários de espaços em *shopping*. A dinâmica característica desse tipo de empreendimento, em certas ocasiões, revela-se incompatível com a eterna permanência de alguns empresários. Se, por exemplo, determinada marca de produtos de perfumaria tem recebido uma aceitação entre os consumidores maior que outra, o *shopping center* com espaço locado pelo titular da marca em decadência tem interesse, partilhado por todos os demais locatários, em substituí-lo pelo titular da que está em ascensão. A lei reconhece o direito de inerência ao ponto aos locatários de espaços em *shopping centers* (LL, art. 52, § 2.º), mas, em determinadas situações, a renovação compulsória do contrato de locação pode representar entrave ao pleno desenvolvimento do complexo. Atentos a essa circunstância e meditando sobre a intrincada relação jurídica que se estabelece entre o empreendedor do *shopping* e o

lojista, muitos autores procuraram discutir se a sua natureza seria, mesmo, a de uma locação. Propuseram classificá-lo como contrato atípico misto (Orlando Gomes), uma coligação de contratos (Requião) ou mesmo um negócio jurídico diverso do de locação, chamado "contrato de estabelecimento" (Buzaid) ou de "centro comercial" (Villaça Azevedo).

O entendimento mais adequado, contudo, parece ser o do reconhecimento de aspectos bastante específicos na relação contratual em questão, mas não a ponto de descaracterizar a sua natureza locatícia (Carvalhosa, Caio Mário, Washington). E, neste sentido, o direito de inerência do lojista não pode implicar o esvaziamento do direito de propriedade do empreendedor do *shopping*. Se ficar provado que este último não consegue organizar plenamente o *tenant mix* na hipótese de acolhimento da ação renovatória, então esta deve ser rejeitada para efetiva tutela constitucional do direito de propriedade. Nessa equação, nenhuma especificidade se nota quanto ao contrato de locação entre o empreendedor de *shopping* e o lojista, posto que, conforme assinalado anteriormente, sempre que o reconhecimento do direito de inerência do locatário, na locação empresarial, redundar em desrespeito ao direito constitucional de propriedade do locador, deve-se prestigiar este último.

O contrato de locação de espaço em *shopping center* costuma contemplar um aluguel com características bastante peculiares, desdobrado em parcelas fixas, reajustáveis de acordo com o índice e a periodicidade definidos no instrumento contratual, e em parcelas variáveis, geralmente um percentual do faturamento obtido pelo locatário no estabelecimento locado. Para mensurar o valor da parcela variável do aluguel, o locador pode auditar as contas do locatário, bem como vistoriar suas instalações ou fiscalizar o seu movimento econômico. Além do aluguel, há outras obrigações pecuniárias assumidas pelo locatário de loja em *shopping center*. Em geral, paga-se uma prestação conhecida por *res sperata*, retributiva das vantagens de se estabelecer em um complexo comercial que já possui clientela própria. Deve o locatário também filiar-se à associação dos lojistas, pagando a mensalidade correspondente. Esta associação suporta as despesas de interesse comum, como as de publicidade em certas épocas ao ano (Natal, dia das mães etc.). É usual também a cobrança do aluguel em dobro no mês de dezembro, em decorrência do extraordinário movimento econômico que se costuma verificar nesse mês. Estes e outros encargos podem ser livremente pactuados, prevendo a lei apenas a proibição de cobrança de despesas extraordinárias de condomínio e os gastos com obras ou substituição de equipamentos modificativos do projeto originário, bem como as despesas não previstas em orçamento prévio (LL, art. 54, §§ 1.º e 2.º).

Há, por fim, um modo de ocupação de estabelecimentos comerciais, que guarda semelhança com os *shopping centers* em seu aspecto externo, isto é, enquanto espaço de concentração de diferentes empresários. São os *outlet centers*, estabelecimentos em que os próprios fabricantes, grandes distribuidores e, por vezes, alguns varejistas instalam-se em pequenos *stands*, para a venda de seus produtos por preços atrativos, com vistas a propiciar o escoamento de estoque. A locação desses espaços é feita, em geral, por curtíssimo prazo, e os locatários assumem obrigação contratual de praticar preços inferiores aos de mercado.

5. PROTEÇÃO AO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO

O elemento de identificação do estabelecimento empresarial não se confunde com o nome empresarial, que identifica o sujeito de direito empresário, nem com a marca, identidade de produto. Não se confundem estes três elementos de identificação disciplinados no direito comercial, recebendo da lei, cada um deles, uma proteção específica. Comum aos três regimes protetivos é o direito à utilização exclusiva da identidade.

O título de estabelecimento não precisa, necessariamente, compor-se dos mesmos elementos linguísticos presentes no nome empresarial e na marca. Uma sociedade empresária pode chamar-se "Comércio Silva Ltda.", ser titular da marca "Alvorada" e seu estabelecimento denominar-se "Loja da Esquina". Terá ela direito de uso exclusivo das três diferentes expressões, observadas as peculiaridades da proteção jurídica deferida a cada uma delas.

A proteção do título de estabelecimento se faz, atualmente, por regras de responsabilidade civil e penal, caso se caracterize a concorrência desleal (LPI, arts. 195, V, e 209). O empresário que imitar ou utilizar o título de estabelecimento que outro havia adotado anteriormente deve indenizar este último pelo desvio eficaz de clientela.

6. COMÉRCIO ELETRÔNICO (INTERNET)

A rede mundial de computadores (*internet*) tem sido largamente utilizada para a realização de negócios. No início, para facilitar a compreensão da novidade, sugeriu-se que ela teria criado um novo tipo de estabelecimento, o *virtual*. Um estabelecimento acessível exclusivamente por transmissão eletrônica de dados (enquanto o estabelecimento *físico* se acessa pelo deslocamento no espaço). Atualmente, com a difusão do comércio eletrônico, o paralelo não é mais significativo. A *internet* é vista, hoje, não mais como um estabelecimento virtual, mas como um canal de negócios (compras, vendas, prestação de serviços) específico.

Comércio eletrônico, assim, significa os atos de circulação de bens, prestação ou intermediação de serviços em que as tratativas pré-contratuais e a celebração do contrato se fazem por transmissão e recebimento de dados por via eletrônica, normalmente no ambiente da *internet*.

São três os tipos de comércio eletrônico: B2B (que deriva da expressão *business to business*), em que os internautas compradores são também empresários, e se destinam a negociar insumos; B2C (denominação derivada de *business to consumer*), em que os internautas são consumidores, na acepção legal do termo (CDC, art. 2.º); e C2C (*consumer to consumer*), em que os negócios são feitos entre internautas não empresários, cumprindo o empresário titular do *site* apenas funções de intermediação.

Os contratos celebrados via página B2B regem-se pelas normas do direito comercial. Os celebrados via página B2C, pelo direito do consumidor. No caso da página C2C, as relações entre o empresário titular do estabelecimento virtual e os internautas regem-se também pelo direito do consumidor, mas o contrato celebrado entre esses últimos está sujeito ao regime contratual de direito civil (ver *Cap. 8*, item 3).

Os canais de venda na *internet* possuem sempre um endereço eletrônico, que é o seu *nome de domínio*. O da livraria RT, por exemplo, é "www.livrariart.com.br".

O nome de domínio cumpre duas funções. A primeira é técnica: proporciona a interconexão dos equipamentos. Por meio do endereço eletrônico, o computador do comprador põe-se em rede com os equipamentos que geram a página do vendedor. A segunda função tem sentido jurídico: identifica o canal de venda de determinado empresário na rede mundial de computadores. Cumpre, assim, em relação à página acessível via *internet*, igual função à do *título de estabelecimento* em relação ao ponto.

Os nomes de domínio, desde dezembro de 2005, são registrados, no Brasil, pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), uma associação civil de direito privado sem fins

econômicos.

Capítulo 6. NOME EMPRESARIAL

1. NATUREZA E ESPÉCIES

O empresário, seja pessoa natural ou jurídica, tem um nome empresarial, aquele com que se apresenta nas relações econômicas. Quando se trata de empresário individual, o nome empresarial pode não coincidir com o civil; e, mesmo quando coincidentes, têm o nome civil e o empresarial naturezas diversas. A sociedade empresária, por sua vez, não tem outro nome além do empresarial.

O Código Civil reconhece no nome, civil ou empresarial, a manifestação de um direito da personalidade da pessoa natural ou jurídica (arts. 16, 52 e 1.164). Esta, contudo, não é a classificação correta do nome empresarial. Ele é um elemento do patrimônio do empresário, um bem incorpóreo integrante do estabelecimento empresarial.

Como elemento de identificação do empresário, o nome empresarial não se confunde com outros elementos identificadores que habitam o comércio e a empresa, os quais têm, também, proteção jurídica, como a marca, o nome de domínio e o título de estabelecimento. O nome empresarial identifica o sujeito que exerce a empresa (o empresário); a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços; o nome de domínio identifica o sítio na rede mundial de computadores; e o título do estabelecimento identifica o ponto.

Na maioria das vezes, por conveniência econômica ou estratégia mercadológica, opta-se pela adoção de expressões idênticas ou assemelhadas, o que, a rigor, não tem nenhuma relevância jurídica, posto que nome empresarial, marca, nome de domínio e título de estabelecimento continuam a ser considerados institutos distintos, ainda quando possuírem um mesmo conteúdo e forma.

Cada um destes elementos de identificação recebe, do direito, tratamentos específicos, próprios, decorrentes de sua natureza, dos quais se cuida no momento oportuno (*Cap. 5*, itens 5 e 6; *Cap. 7*, item 3.2). Por ora, basta ressaltar que o nome empresarial não se confunde com esses outros designativos empresariais.

O direito contempla duas espécies de nome empresarial: a *firma* e a *denominação*.

No linguajar cotidiano do comércio, firma tem o sentido de sociedade ou de empresa, mas, no rigor da técnica jurídica, essa expressão é reservada para uma das espécies de nome empresarial.

A firma e a denominação se distinguem em dois planos: quanto à estrutura, ou seja, aos elementos linguísticos que podem ter por base; e quanto à função, isto é, a utilização que se pode imprimir ao nome empresarial.

No tocante à estrutura, a firma só pode ter por base um nome civil, do empresário individual ou dos sócios da sociedade empresária. O núcleo do nome empresarial dessa espécie será sempre um ou mais nomes civis. Já a denominação deve designar o objeto da empresa e pode adotar por base nome civil ou qualquer outra expressão linguística (que a doutrina costuma chamar de *elemento fantasia*). Assim, "A. Silva & Pereira Cosméticos Ltda." é exemplo de nome empresarial baseado em nomes civis; já "Alvorada Cosméticos Ltda." é nome empresarial baseado em elemento fantasia.

Somente levando-se em conta a estrutura, por vezes, não é possível discernir se determinado nome empresarial é firma ou denominação. Claro, se não há referência ao ramo de atividade econômica, não pode ser denominação; se fundado em elemento fantasia, não pode ser firma. Mas, desde que ambas as espécies podem adotar nome civil como base para a construção do nome empresarial, a identificação de uma ou outra espécie não deve deixar de considerar a função que o nome empresarial exerce. No exemplo acima citado de nome empresarial composto sobre nome civil, é rigorosamente impossível descobrir sua espécie sem consulta ao contrato social da sociedade limitada e análise da sua utilização.

Explique-se: quanto à função, os nomes empresariais se diferenciam porque a firma, além de identidade do empresário, é também a sua assinatura, ao passo que a denominação é exclusivamente elemento de identificação do exercente da atividade empresarial, não prestando a outra função.

O empresário individual, ao se obrigar juridicamente, e o representante legal da sociedade empresária que adota firma, ao obrigá-la juridicamente, devem ambos assinar o respectivo instrumento não com o seu nome civil, mas com o empresarial. Portanto, se Antonio Silva Pereira é empresário individual inscrito sob a firma "Silva Pereira, Livros Técnicos", a assinatura apropriada para os instrumentos obrigacionais relacionados com o seu giro econômico deverá reproduzir essas expressões, inclusive "livros técnicos". Se ele é administrador de sociedade que comerce sob a firma "Silva Pereira e Cia. Ltda.", não deverá assinar sua assinatura civil, mesmo que sobre o nome empresarial da sociedade, escrito, impresso ou carimbado. Deverá assinar o nome empresarial da sociedade, na forma com que assinou, no campo próprio, o contrato social; isto é, reproduzindo com seu estilo individual as expressões constituintes da firma, inclusive "e Cia. Ltda.". Já o representante legal de sociedade empresária que gire sob a denominação "Alvorada Cosméticos Ltda.", para obrigar a sociedade, deve lançar a sua assinatura civil sobre o nome empresarial dela, escrito, impresso ou carimbado. Não poderá, neste caso, assinar a denominação.

Por esta razão, pelas diferenças funcionais entre a firma e a denominação, é que os contratos sociais de sociedades empresárias que adotam firma devem ter campo próprio para que o representante ou representantes legais assinem o nome empresarial. Geralmente, ao pé da última página do instrumento, sob o título "firma por quem de direito", é que eles lançam a assinatura que usarão no exercício dos poderes de representação. E geralmente fazem uso da mesma assinatura que têm para os atos da vida civil, o que, embora, a rigor, não corresponda à prescrição legal, vem sendo sedimentado há tempos pelo costume.

Conclui-se, pois, que a análise da natureza do nome empresarial daqueles empresários legalmente autorizados a usarem firma ou denominação, e que adotaram nome empresarial baseado em nome civil, não pode prescindir da consulta ao ato constitutivo (contrato social ou estatuto). Se dele constar cláusula em que o representante legal assenta a assinatura que usará nos instrumentos obrigacionais relativos aos negócios sociais, então é o caso de firma. Na ausência de cláusula com tal objetivo, será denominação. A simples análise da estrutura do nome empresarial é insuficiente para uma conclusão correta sobre o assunto.

2. FORMAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Em relação ao empresário individual e a cada tipo de sociedade empresária, o direito contempla regras específicas de formação do nome empresarial. Ademais, há tipos de sociedades empresárias que podem adotar firma ou denominação, segundo a vontade de seus sócios, e há tipos que só podem adotar

uma ou outra espécie de nome empresarial.

Analise-se cada hipótese.

O empresário individual só está autorizado a adotar firma, baseado, naturalmente, em seu nome civil. Poderá ou não abreviá-lo na composição do nome empresarial e poderá, se desejar, agregar o ramo de atividade a que se dedica. Desta forma podem-se elencar as seguintes alternativas para o nome empresarial de uma pessoa natural chamada Antonio Silva Pereira que se inscreva como empresário individual na Junta Comercial: "Antonio Silva Pereira"; "A. S. Pereira"; "Silva Pereira"; "S. Pereira, Livros Técnicos" etc.

A sociedade em nome coletivo está autorizada apenas a adotar firma social, que pode ter por base o nome civil de um, alguns ou todos os seus sócios. Esses nomes poderão ser aproveitados por extenso ou abreviadamente, de acordo com a vontade dos seus titulares. Se acaso não constar o nome de todos os sócios, é obrigatória a utilização da partícula "e companhia" (ou abreviadamente: "& Cia."). Poderão também os sócios agregar, ou não, o ramo de empresa correspondente. Uma sociedade empresária desse tipo, composta pelos sócios Antonio Silva, Benedito Pereira e Carlos Sousa, poderá optar por uma das seguintes soluções: "Antonio Silva, Benedito Pereira & Carlos Sousa", "Pereira, Silva & Sousa", "A. Silva, B. Pereira & Sousa, Livros Técnicos", "Antonio Silva & Cia." etc.

A sociedade em comandita simples também só pode compor nome empresarial por meio de firma, da qual conste nome civil de sócio ou sócios comanditados. Os sócios comanditários não podem ter seus nomes aproveitados na formação do nome empresarial, porque não têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações da sociedade. Desta maneira, será obrigatória a utilização da partícula "e companhia", por extenso ou abreviadamente, para fazer referência aos sócios dessa categoria. O nome civil do sócio comanditado pode ser usado por extenso ou abreviadamente, e pode-se agregar o ramo de negócio explorado pela sociedade. Assim, pode-se cogitar das seguintes alternativas para o nome empresarial de uma sociedade em comandita simples, em que os sócios comanditados sejam Antonio Silva e Benedito Pereira: "Antonio Silva, Benedito Pereira & Cia.", "B. Pereira & Companhia", "Silva, Pereira & Cia. - Livros Técnicos" etc.

A sociedade em conta de participação, por sua natureza de sociedade despersonalizada, está proibida de adotar nome empresarial (CC, art. 1.162).

A sociedade limitada está autorizada, por lei, a girar sob firma ou denominação. Se optar por firma, poderá incluir nela o nome civil de um, alguns ou todos os sócios que a compõem, por extenso ou abreviadamente, valendo-se da partícula "e companhia" ou "& Cia.", sempre que omitir o nome de pelo menos um deles. Mas, adotando firma ou denominação, não poderá o nome empresarial deixar de contemplar a identificação do tipo societário por meio da expressão "limitada", por extenso ou abreviada ("Ltda."), sob pena de responsabilização ilimitada dos administradores que fizerem uso do nome empresarial (CC, art. 1.158). A identificação do ramo de atividade no nome empresarial é optativa quando a limitada adota firma, e obrigatória quando adota denominação. São, assim, exemplos de nome empresarial de sociedade limitada: "Antonio & Silva Ltda.", "Silva & Pereira, limitada", "A. Silva & Pereira, Livros Técnicos Ltda.", "Alvorada Comércio de Livros Técnicos Ltda." etc.

Quando a pessoa jurídica tiver um sócio apenas, autoriza a lei a formação do nome empresarial mediante firma ou denominação. Do nome, porém, deve constar a sigla "EIRELI", abreviatura de *empresa individual de responsabilidade limitada* (CC, art. 980-A, § 1.º).

A sociedade anônima só pode adotar denominação de que deve constar referência ao objeto social, desde a entrada em vigor do Código Civil (art. 1.160). É obrigatória a identificação do tipo societário no nome empresarial por meio da locução "sociedade anônima", por extenso ou abreviadamente, usada no início, no meio ou no fim da denominação, ou pela expressão "companhia", por extenso ou abreviada, constante do início ou do meio da denominação, segundo prescreve o art. 3.º da Lei 6.404/76. Também é autorizado o emprego de nomes civis de pessoas que fundaram a companhia ou concorrem para o seu bom êxito. Exemplos: "S/A Alvorada - Livros Técnicos"; "Alvorada S.A. - Livros Técnicos"; "Alvorada Livros Técnicos Sociedade Anônima"; "Companhia Editora de Livros Técnicos Alvorada"; "Alvorada - Cia. Comercial de Livros Técnicos", "Indústrias Demóstenes de Alcântara S/A" etc.

A sociedade em comandita por ações pode adotar firma ou denominação. No primeiro caso, pode aproveitar apenas o nome civil, por extenso ou abreviado, dos sócios diretores ou administradores que respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Na denominação, exige-se referência ao objeto social. Adotando firma ou denominação, será obrigatória a identificação do tipo societário pela locução "comandita por ações", mesmo abreviada. Se fundado no nome civil de um ou mais acionistas com responsabilidade ilimitada (diretores), é obrigatória a locução "e companhia", por extenso ou abreviada. Exemplificativamente: "Antonio Silva e Companhia, Comandita por Ações"; "Alvorada Livros Técnicos C.A."; "Comandita por Ações Silva, Pereira & Cia." etc.

A sociedade empresária de qualquer tipo que tenha ingressado em juízo com a medida de recuperação judicial deve acrescentar ao seu nome, em todos os atos, contratos e documentos, a expressão "em Recuperação Judicial" (LF, art. 69).

Finalmente, deve-se mencionar que o empresário, pessoa natural ou jurídica, ao se registrar como Microempresário ou Empresário de Pequeno Porte, terá acrescido ao seu nome a locução identificativa destas condições (ME ou EPP) (Estatuto, art. 72).

3. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, ao contrário do nome civil, pode ser alterado pela simples vontade do empresário, seja este pessoa natural ou jurídica, desde que respeitadas as normas de formação já analisadas. É a hipótese de alteração voluntária do nome empresarial, que depende exclusivamente da vontade do seu titular. Se sociedade empresária, é claro, a alteração voluntária exigirá a concorrência da vontade de sócios que detenham participação do capital social que lhe assegure o direito de alterar o contrato social ou o estatuto.

Além desta hipótese, há outras em que a alteração do nome empresarial opera-se independentemente da vontade do empresário. Trata-se, agora, de alteração obrigatória, ou vinculada.

Em relação aos nomes empresariais fundados em nome civil, são causas de alteração obrigatória:

a) saída, retirada, exclusão ou morte de sócio cujo nome civil constava da firma social: neste caso, enquanto não se proceder à alteração do nome empresarial, o ex-sócio ou o seu espólio continua a responder pelas obrigações sociais nas mesmas condições em que respondia quando ainda integrava a sociedade (CC, arts. 1.158, § 1.º, e 1.165);

b) alteração da categoria do sócio, quanto à sua responsabilidade pelas obrigações sociais, se o nome civil dele integrava o nome empresarial: se sócio comanditado de uma sociedade em comandita

simples passa a ser comanditário, ou se o acionista não diretor da sociedade em comandita por ações deixa as funções administrativas, o seu nome civil não poderá continuar a compor o nome da sociedade, a firma social. Até que se altere este nome, o sócio continuará a responder pelas obrigações sociais como se ainda integrasse a categoria anterior (CC, art. 1.157, *caput* e parágrafo único);

c) alienação do estabelecimento por ato entre vivos: o empresário individual ou a sociedade empresária não podem alienar o nome empresarial (CC, art. 1.164). Mas, na hipótese de alienação do estabelecimento empresarial, por ato entre vivos, se previsto em contrato, o adquirente pode usar o nome do alienante, precedido do seu, com a qualificação de *sucessor de*.

Estas três causas de alteração obrigatória do nome empresarial fundado em nome civil decorrem de regra de composição que se costuma chamar de "princípio da veracidade" (LRE, art. 34). De acordo com este princípio, é defeso ao empresário valer-se, na composição de seu nome empresarial, de elementos estranhos ao nome civil, de que seja titular como pessoa natural, ou de que sejam titulares os seus sócios, se pessoa jurídica. Este princípio não se aplica, integralmente, à denominação da sociedade anônima, que pode ser composta por nome civil de fundador ou pessoa que tenha concorrido para o êxito da empresa, ainda que não seja mais acionista (CC, art. 1.160, parágrafo único; LSA, art. 3.º).

Além das alterações em decorrência do princípio da veracidade, prevê o direito duas outras causas que ensejam a mudança compulsória da firma ou denominação:

a) Transformação: a sociedade empresária pode experimentar alteração de tipo societário (passar de sociedade limitada para anônima, ou vice-versa). Nesta hipótese, as regras de formação do nome empresarial relativas ao tipo societário em que se transformou a sociedade devem ser observadas, alterando-se os aspectos do nome empresarial então existentes que com elas forem incompatíveis. A consequência da não alteração do nome comercial será a ineficácia da transformação perante terceiros que contratarem com a sociedade.

b) Lesão a direito de outro empresário: pelo sistema de proteção do nome empresarial, que adiante se especifica, o empresário estará obrigado a alterar o seu nome empresarial sempre que este lesar direito de outro exercente de atividade empresarial, sob pena de alteração coercitiva e responsabilização por perdas e danos.

4. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL

Inicialmente, deve-se atentar para o fato de que o direito protege o nome empresarial com vistas à tutela de dois diferentes interesses do empresário: de um lado, o interesse na preservação da clientela; de outro, o da preservação do crédito. Afinal, se determinado empresário, conceituado no meio empresarial, vê um concorrente usando nome empresarial idêntico ou semelhante ao seu, podem ocorrer consequências que devem ser prevenidas, em dois níveis. Quanto à clientela, pode acontecer de alguns desavisados entrarem em negociações com o usurpador do nome empresarial, imaginando que o fazem com aquele empresário conceituado. Neste caso, o uso indevido do nome idêntico ou assemelhado importa inequívoco desvio de clientela. Quanto ao crédito, o empresário conceituado poderá ser, parcial e temporariamente, prejudicado com o protesto de títulos ou pedido de falência do usurpador. Tanto num quanto noutro nível, o empresário que teve o seu nome imitado poderá sofrer consequências patrimoniais danosas.

Ao proteger o nome empresarial, portanto, o direito tem em vista a tutela desses dois interesses. Por esta razão, porque não visa somente a evitar o desvio desleal de clientela, é que a proteção não deve se restringir aos empresários que atuem no mesmo ramo da atividade empresarial. Como tem em mira, também, a preservação do crédito, não pode o empresário que explora determinada atividade pretender usar nome imitado de empresário explorador de atividade diversa, sob o pretexto de não ser possível a concorrência entre ambos. Salvo, é claro, autorização contratual, pela qual o titular do nome empresarial legitima o uso de nome idêntico ou semelhante por outro empresário.

O titular de certo nome empresarial tem o direito à exclusividade de uso, podendo impedir que outro empresário se identifique com nome idêntico ou semelhante, que possa provocar confusão em consumidores ou no meio empresarial. Assim, em caso de identidade ou semelhança de nomes, o empresário que anteriormente haja feito uso dele terá direito de obrigar o outro a acrescentar ao seu nome distintivos suficientes; ou mesmo a alterá-lo totalmente, se não houver outra forma de distingui-los com segurança (LRE, art. 35, V; CC, art. 1.163; LSA, art. 3.º, § 2.º).

Mas o que seja um nome idêntico ou semelhante, isto a lei não esclarece. A solução, assim, é dada pelo seguinte critério de natureza doutrinal: a identidade ou semelhança não diz respeito senão ao núcleo do nome empresarial. Os elementos identificadores do tipo societário, do ramo de atividade, bem como as partículas gerais ("& Cia.", "Irmãos", "Sucessor de" etc.), devem ser desprezados na análise da identidade ou semelhança entre dois nomes empresariais. Por núcleo do nome empresarial se entende a expressão que é própria do seu titular, aquela que o torna conhecido, tanto entre os consumidores como no meio empresarial. É a parte do nome empresarial que não se pode abstrair sem desnaturá-lo, sem perder de vista aquele específico sujeito de direito que se pretende identificar.

Exemplificativamente, considerem-se os seguintes três nomes empresariais:

- a) "Alvorada - Comércio e Indústria Ltda.";
- b) "Primavera - Comércio e Indústria Ltda.";
- c) "Companhia Exportadora e Importadora Primavera".

Os nomes *a* e *b*, embora tenham mais elementos absolutamente idênticos entre si, são nomes empresariais diferentes e o titular de um deles não tem qualquer direito em relação ao titular do outro. Isto porque o núcleo de um ("Alvorada") é inconfundível com o do outro ("Primavera"). Já os nomes *b* e *c* possuem somente uma expressão idêntica, sendo todas as demais completamente diferentes. Inobstante, o titular do nome empresarial anterior terá direito de obrigar o titular do outro a abster-se de fazer uso dele, posto que o núcleo de ambos é igual ("Primavera").

O Registro do Comércio adota esse entendimento de restringir ao núcleo do nome empresarial a análise da identidade ou semelhança apenas quando se trata de denominação com expressões de fantasia incomuns. Em relação às demais denominações e às firmas, as Juntas levam em conta a composição total do nome, sendo idênticos os homógrafos e semelhantes os homófonos (LRE, art. 35, V).

No campo do direito penal, a lei define a usurpação de nome empresarial como crime de concorrência desleal (LPI, art. 195, V).

Capítulo 7. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. ABRANGÊNCIA DO DIREITO INDUSTRIAL

Quatro são os bens imateriais protegidos pelo direito industrial: a patente de invenção, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca (LPI, art. 2º, I a III). O empresário titular desses bens - patente ou registro - tem o direito de explorar economicamente o respectivo objeto, com inteira exclusividade. O empresário com sua marca registrada pode impedir que concorrente se utilize da mesma marca ou de alguma semelhante. Para que uma pessoa explore bem industrial patentado ou registrado (invenção, modelo, desenho ou marca), ela necessita da autorização ou licença do titular do bem. Como os demais bens integrantes do patrimônio do empresário, as patentes e registros podem ser alienadas por ato *inter vivos* (Cap. 36) ou *mortis causa*.

Os direitos industriais são concedidos pelo Estado, por meio de uma autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão.

2. PATENTES

A patente diz respeito à invenção ou ao modelo de utilidade.

Invenção é o ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará produzindo uma invenção. Embora toda invenção seja, assim, original, nem sempre será nova, ou seja, desconhecida das demais pessoas. E a novidade, conforme se verá em seguida, é condição de patenteabilidade da invenção.

Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resultam melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. É chamada, também, de "pequena invenção" e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada.

A patenteabilidade de invenções e modelos de utilidade está sujeita aos seguintes requisitos:

a) *Novidade* - não basta, para a obtenção do direito industrial, que a invenção ou o modelo sejam originais, característica de natureza subjetiva (isto é, relacionada ao inventor). É necessário que a criação seja desconhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial (numa palavra, os *experts* da área). Ou, para fazer uso do termo da lei, a criação não poderá estar compreendida no "estado da técnica" (LPI, art. 11).

b) *Atividade inventiva* - a lei define que a invenção apresenta inventividade quando não é uma decorrência óbvia do estado da técnica (LPI, art. 13). Em outros termos, a invenção deve despertar no espírito dos técnicos da área o sentido de um real progresso. Ao seu turno, o modelo de utilidade atende ao requisito, se não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, segundo o parecer dos

especialistas no assunto (LPI, art. 14).

c) *Aplicação industrial* - somente a invenção ou modelo suscetível de aproveitamento industrial pode ser patenteado (LPI, art. 15). Quem cria uma máquina cujo funcionamento depende de combustível ainda inexistente, por exemplo, não tem direito à patente por faltar à sua invenção o requisito da industriabilidade.

d) *Não impedimento* - a lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a patenteabilidade de determinadas invenções ou modelos (LPI, art. 18). São exemplos de impedimento legal: afronta à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas; substâncias resultantes de transformação do núcleo atômico; seres vivos, exceto se transgênicos (dotados de características não alcançáveis pela espécie em condições naturais).

Após o devido procedimento administrativo, o INPI expede a patente, único instrumento de prova admissível pelo direito para demonstração da concessão do direito de exploração exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade.

A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do respectivo "depósito" (a data em que o pedido foi protocolado no INPI). Para garantir ao inventor pelo menos um tempo razoável de utilização da invenção ou modelo, contudo, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7, para os modelos, contados da expedição da patente (LPI, art. 40). Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente.

Há situações em que o titular da patente está obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. Isto porque o direito considera relevante o interesse social relacionado ao acesso às comodidades propiciadas pelo desenvolvimento industrial. Em outros termos, se o titular da patente de invenção ou modelo de utilidade não está exercendo o seu direito de forma a atender regular e convenientemente o mercado, outros empresários interessados e capacitados terão o direito de explorá-la, por meio da licença compulsória. Evidentemente, os licenciados remunerarão o dono da patente. Assim, se os direitos concedidos pelo INPI são exercidos de forma abusiva, ou se, por meio deles, se pratica abuso do poder econômico, caberá a licença compulsória. Também se impõe esta licença se o titular da patente, tendo já transcorrido 3 anos da sua expedição, não a explora por completo, ou se verifica o caso de insatisfatória comercialização (LPI, art. 68 e §§ 1º e 5º).

Concedida a primeira licença compulsória, prevê a lei o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou modelo de utilidade seja feita, agora pelo licenciado, de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação irregular que houvera dado ensejo ao licenciamento obrigatório, opera-se a caducidade da patente; isto é, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizava, e a invenção ou modelo caem em domínio público (LPI, art. 80).

Além do término do prazo de duração e da caducidade, são hipóteses legais de extinção da patente: a) a renúncia aos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não houver prejuízo para terceiros (licenciados, por exemplo); b) a falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada "retribuição anual"; c) a falta de representante no Brasil, quando o titular é domiciliado no exterior.

3. REGISTRO INDUSTRIAL

A marca e o desenho industrial são registráveis no INPI, para fins de concessão do direito de exploração exclusiva. O direito brasileiro confere ao registro industrial o caráter de ato administrativo constitutivo. Ou seja, o direito de utilização exclusiva do desenho ou da marca não nasce da anterioridade em sua utilização, mas da anterioridade do registro.

Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos, e serve tanto para conferir-lhe um ornamento harmonioso como para distingui-los de outros do mesmo gênero. Lembre-se, por exemplo, a cadeira *Hill House*, projetada pelo arquiteto Charles Mackintosh em 1902, cuja forma (desenho industrial, *design*) tem especificidades que permitem sua imediata identificação. A marca, por sua vez, é o signo que identifica produtos e serviços, como *Coca-cola*, *RT*, *Itaú*.

3.1. Desenho industrial ("design")

O registro de desenho industrial está sujeito aos seguintes requisitos:

a) *Novidade* - a exemplo do que estabelece a lei relativamente aos objetos das patentes, o desenho industrial deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica (LPI, art. 96). A forma criada pelo *designer* deve, para merecer a proteção do direito industrial, propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor.

b) *Originalidade* - o desenho industrial é original quando apresenta uma configuração própria, não encontrada em outros objetos, ou quando combina com originalidade elementos já conhecidos (LPI, art. 97). Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é estética.

c) *Desimpedimento* - a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações (LPI, art. 100). São exemplos de impedimento: desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à liberdade de consciência; formas comuns, vulgares ou necessárias.

O registro de desenho industrial tem o prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito, e pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada (LPI, art. 108). A taxa devida ao INPI pelo titular deste registro, denominada "retribuição", tem incidência quinquenal (LPI, art. 120).

3.2. Marca

A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial (que identifica o empresário), o nome de domínio (designativo do canal de negócios ambientado na *internet*) e o título de estabelecimento (referido ao local do exercício da atividade econômica).

A lei cuida, além da marca de produtos e serviços, de duas outras categorias: a marca de certificação e a marca coletiva (LPI, art. 123, II e III). A primeira atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor.

Para que a marca possa ser registrada, é indispensável o atendimento dos seguintes requisitos:

a) *Novidade relativa* - não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por esta razão, inclusive, a marca é protegida, em princípio, apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais o identificado por ela pode eventualmente ser confundido pelos consumidores.

b) *Não colidência com marca notória* - as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126).

c) *Não impedimento* - a lei impede o registro, como marca, de determinados signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc. (LPI, art. 124). Para ser registrado como marca, o signo não pode enquadrar-se nos impedimentos legais.

A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de "marca de alto renome" (McDonald's, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica.

O registro de marca tem a duração de 10 anos, a partir da sua concessão (LPI, art. 133). Este, ao contrário do prazo da patente, é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o interessado pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro.

A taxa devida ao INPI para eficácia do registro de marca denomina-se "retribuição" e é devida na concessão e a cada prorrogação do registro (LPI, arts. 133, § 1º, e 155, III).

O registro de marca caduca, salvo força maior, se a sua exploração econômica não tiver início no Brasil em 5 anos, a partir da sua concessão, na hipótese de interrupção desta exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou na de alteração substancial da marca.

Com o desenvolvimento do comércio eletrônico, surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Lembre-se que os endereços eletrônicos da *internet* são registrados pelo NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR). Esta associação civil de direito privado, porém, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços; tal função é, como visto, do INPI. Em consequência, e também com o objetivo de agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que o solicitar

poderá identificar seu sítio na *internet* com ele. Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas usurparam marcas de renome na formação de endereços eletrônicos.

No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pelo NIC.br a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca. A ordem de chegada só prevalecerá se os dois interessados possuírem (em classes diferentes) o registro da marca adotada no nome de domínio.

4. UNIÃO DE PARIS

O Brasil é país *unionista*, isto é, signatário de uma convenção internacional referente à propriedade industrial - a Convenção de Paris. Em função disto, vigoram no direito brasileiro os princípios e normas consagrados pela referida Convenção, também conhecida por "União de Paris".

Assim, não é admissível, no direito brasileiro, a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros, em matéria de direito industrial. Seria inválida, salvo denúncia da Convenção, uma lei interna que, por hipótese, concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular o inventor nacional, como medida de protecionismo ao desenvolvimento de uma tecnologia brasileira. É o chamado princípio da assimilação.

Ademais, o direito brasileiro reconhece o "princípio da prioridade", pelo qual é possível a qualquer cidadão de país signatário da União reivindicar prioridade de patente ou registro industrial, no Brasil, à vista de igual concessão obtida, anteriormente, em seu país de origem, desde que o faça em 6 meses, para o modelo ou desenho industriais, marca ou sinal de propaganda, ou em 12 meses, para a invenção ou modelo de utilidade, contados da apresentação de seu primeiro pedido. Equivale, na prática, à eliminação das fronteiras nacionais, para fins de proteção da propriedade industrial. Claro está que idêntico direito tem o brasileiro em relação aos demais países da União.

Capítulo 8. O EMPRESÁRIO E OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1. INTRODUÇÃO

Antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), as relações e contratos dos consumidores com os empresários estavam disciplinadas pelo direito civil ou comercial, observados os limites da teoria dos atos de comércio. Quando eram consumidos produtos que, por esta teoria, tinham a natureza de mercantis, aplicavam-se as normas do Código Comercial. Caso contrário, sujeitava-se o negócio ao Código Civil. Com o advento do CDC, as relações e contratos de consumo passaram a contar com regime jurídico próprio, cujas normas visam a proteção dos consumidores.

Aplica-se, assim, o CDC sempre que os sujeitos de direito se encontram numa *relação de consumo* legalmente caracterizada.

A relação de consumo envolve sempre, em um dos polos, alguém enquadrável no conceito legal de fornecedor (CDC, art. 3.º) e, no outro, no de consumidor (art. 2.º).

Fornecedor é a pessoa que desenvolve *atividade* de oferecimento de bens ou serviços ao mercado, e consumidor aquela que os adquire ou utiliza como *destinatária final*. Sempre que a relação jurídica ligar exercente de atividade de oferecimento de bens ou serviços ao mercado e o destinatário final destes, ela é uma relação de consumo e sua disciplina será a do regime de tutela do consumidor.

Os contratos de compra e venda, nesse sentido, podem ser de duas naturezas distintas, segundo o direito privado brasileiro da atualidade. Será compra e venda *ao consumidor* se configurada a relação de consumo, isto é, se o vendedor puder caracterizar-se como fornecedor e o comprador como consumidor (no caso, por exemplo, da aquisição de automóvel na concessionária); mas será *mercantil*, se o comprador não for o destinatário final da coisa (compra de automóveis pela concessionária junto à fábrica), ou civil se o vendedor não exercer atividade de fornecimento do bem em questão (venda do automóvel usado a um amigo, por exemplo). No primeiro caso, aplica-se o CDC; nos dois últimos, o Código Civil, respeitadas as especificidades dos contratos empresariais.

A definição da natureza da relação ou do contrato e, por via de consequência, do regime jurídico aplicável repercute em diversos aspectos, notadamente quanto aos direitos do comprador, aos prazos para o seu exercício, obrigações do vendedor, garantias, cláusulas do contrato etc.

O conceito de empresário, núcleo do moderno direito comercial (*Cap. 1, item 4*), está compreendido no de fornecedor. Todo empresário é fornecedor. Desse modo, os deveres e responsabilidades previstos pelo CDC para os fornecedores são também pertinentes aos empresários nas suas relações com os consumidores.

2. QUALIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO

Ao disciplinar a qualidade dos produtos ou serviços, o CDC introduziu três conceitos: fornecimento perigoso, defeituoso e viciado.

2.1. Fornecimento perigoso

O fornecimento é perigoso se da utilização dos produtos ou serviços decorre dano, motivado pela insuficiência ou inadequação das informações prestadas pelo fornecedor sobre os riscos a que se expõe o consumidor. Todo produto ou serviço pode expô-lo a variados graus de risco à vida, saúde ou integridade física. Se inexistir defeito no produto ou serviço, então o dano é consequência de sua má utilização pelo consumidor. Ora, a má utilização pode ter sido motivada pela insuficiência ou inadequação das informações prestadas pelo fornecedor, situação em que o fornecimento perigoso se caracteriza.

Certo desinfetante pode ser tóxico para pessoas alérgicas. A rigor, o produto não apresenta nenhum problema (defeito ou vício), mas apenas produz efeitos nocivos em determinados consumidores. O fornecedor tem o dever de informar a possibilidade de tais efeitos na embalagem ou no rótulo da mercadoria. Ele somente está dispensado de alertar os consumidores acerca dos riscos amplamente conhecidos pelas pessoas em geral (o legislador, no art. 8.º do CDC, fala em "riscos considerados normais e previsíveis"). O fabricante de facas, por exemplo, não precisa informar sobre o potencial letal do produto, suficientemente difundido entre os consumidores (as crianças aprendem, desde cedo, as cautelas necessárias ao seu manuseio).

Todas as questões relacionadas com o fornecimento perigoso resolvem-se na análise da suficiência e adequação das informações prestadas pelo fornecedor, acerca dos riscos do produto ou serviço. Proíbe a lei (CDC, art. 10) o fornecimento com alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do usuário. O produto ou serviço possuirá essa característica apenas se for impossível prestar adequadamente aos consumidores as informações que os capacitem à sua utilização sem riscos. Não é qualquer característica intrínseca à mercadoria ou ao serviço que irá torná-los mais ou menos seguros, mas sim a suficiência e adequabilidade das informações prestadas pelo fornecedor.

Pelos danos decorrentes de fornecimento perigoso respondem, objetivamente, o fabricante, o produtor, o construtor, o importador (CDC, art. 12, *in fine*) e o prestador de serviços (art. 14).

2.2. Fornecimento defeituoso

Fornecimento defeituoso é aquele em que o produto ou serviço apresenta alguma impropriedade danosa ao consumidor. Porém, aqui, o dano não se origina da má utilização do produto ou serviço, ocasionada pela insuficiência ou inadequação das informações sobre os seus riscos, mas em razão de problema intrínseco ao fornecimento. Por problema no envasamento do refrigerante, por exemplo, ocorreu maior concentração de gás, e desta resultaram a quebra da garrafa e ferimentos no consumidor.

A responsabilidade do fabricante, produtor, construtor e importador dos produtos ou do prestador de serviços pela indenização dos danos decorrentes de fornecimento defeituoso é *objetiva* (CDC, arts. 12 e 14). Ou seja, independe de culpa. Na verdade, o empresário pode antecipar em certa medida alguns dos possíveis acidentes de consumo (dimensionando, por cálculos estatísticos, a probabilidade de alguns refrigerantes, durante o ano, serem envasados com concentração superior de gás, por exemplo). Esses defeitos não decorrem de culpa do empresário, mas de limitação da capacidade e do conhecimento humanos. Isto é, por mais cauteloso e diligente que seja o fornecedor, por mais que invista em controle de qualidade e em aperfeiçoamento tecnológico de sua empresa, alguma inevitável margem de defeituosidade no fornecimento é inevitável, graças à falibilidade dos homens e mulheres.

Na teoria tradicional da responsabilidade civil, o agente só deve indenizar a vítima se agiu com culpa. Assim, no passado, a explosão da garrafa aqui exemplificada seria tida por caso fortuito ou força maior, hipótese em que a própria vítima arcava com os custos do infortúnio. A legislação consumerista opera uma inversão na hipótese. Se o fornecedor pode antecipar a probabilidade de defeitos e seus desdobramentos danosos, ele poderá então considerar a indenização correspondente como item de custo, para, em seguida, repassá-lo ao preço do fornecimento, socializando entre todos os consumidores as repercussões econômicas do evento danoso. Exatamente por possuir as condições para proceder à socialização dos custos relacionados aos acidentes de consumo, ao empresário pode-se atribuir responsabilidade *objetiva*.

São excludentes da responsabilidade objetiva desses fornecedores (CDC, art. 12, § 3.º): *a*) a prova de que não houve fornecimento (detectado o defeito, o produto foi separado para inutilização, mas terceiros o furtaram e o comercializaram, por exemplo); *b*) inexistência do defeito (situação em que os danos somente podem ser atribuídos a outros fatores, como a força maior ou o caso fortuito *posteriores* ao fornecimento); *c*) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (anotando-se que a culpa concorrente não exonera o fornecedor).

O empresário comerciante responde pelo acidente de consumo apenas se conservou inadequadamente produto perecível ou se o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador não puderem ser facilmente identificáveis (CDC, art. 13). Por sua vez, o profissional liberal responde de modo subjetivo, ou seja, somente em caso de culpa (CDC, art. 14, § 4.º).

O prazo prescricional para a responsabilização do fornecedor é de 5 anos (CDC, art. 27).

2.3. Fornecimento viciado

O fornecimento viciado, por fim, é aquele em que o produto ou serviço apresenta impropriedade inócua, isto é, da qual não decorre dano considerável ao consumidor. A mesma impropriedade pode ser *defeito* ou *vício*, dependendo da circunstância de causar, ou não, prejuízo. Se o automóvel apresenta problema em seu sistema de freios, mas isto é detectado pelo consumidor antes de qualquer acidente, verifica-se fornecimento viciado; se, contudo, o problema não é detectado a tempo, e, em razão dele, ocorre acidente de trânsito, verifica-se fornecimento defeituoso.

Diante de vício no fornecimento, o consumidor pode optar, *grosso modo*, por uma de três alternativas: *a*) desfazimento do negócio, com a devolução dos valores já pagos, devidamente corrigidos (ação redibitória); *b*) redução proporcional do preço (ação estimatória); *c*) eliminação do vício, se necessário com a substituição do produto ou a reexecução do serviço (ação executória específica). Na compra e venda civil e na comercial, o comprador de coisa viciada dispõe apenas da alternativa entre a ação redibitória e a estimatória.

A legislação consumerista trata de três espécies de fornecimentos viciados: vício de qualidade ou de quantidade dos produtos e de qualidade dos serviços. Caracteriza-se vício de qualidade do produto se este é impróprio ao consumo, tem impropriedade que lhe reduz o valor ou se há disparidade entre a sua realidade e as informações do fornecedor (CDC, art. 18). O produto é impróprio ao consumo se está vencido o seu prazo de validade, se há adulteração, alteração, avaria, falsificação, inobservância de normas técnicas ou se, por qualquer razão, não atende às finalidades a que se destina (CDC, art. 18, § 6.º).

No fornecimento viciado de produtos, sendo o vício de qualidade, tem o fornecedor direito de tentar o saneamento da impropriedade (CDC, art. 18). Esse direito não existe se o produto for essencial ao consumidor ou se a eliminação do vício não for possível sem o comprometimento da sua eficácia, características ou valor (CDC, art. 18, § 4.º).

O vício de quantidade dos produtos ocorre se o seu conteúdo líquido é inferior às indicações constantes da rotulagem, embalagem ou publicidade, salvo as variações próprias de sua natureza. Diante de vício deste tipo, pode o consumidor pleitear, de imediato, o seu saneamento, mediante a complementação do peso ou medida (CDC, art. 19, II), além da ação redibitória e estimatória.

Há viciamento de qualidade no serviço se este é inadequado para o fim que razoavelmente dele se espera, ou ocorrer inobservância de normas regulamentares de prestabilidade (CDC, art. 20, § 2.º).

O direito de reclamar por vícios no fornecimento decai no prazo de 30 dias (produtos e serviços não duráveis) ou de 90 dias (produtos e serviços duráveis). Alimentos e bebidas são produtos não duráveis; já a lavagem de automóvel é exemplo de serviço não durável; o eletrodoméstico é produto durável, enquanto a pintura de casa é serviço durável. O termo inicial para a fluência desse prazo é a entrega do produto ou o término da execução do serviço, quando o vício é aparente ou de fácil constatação (CDC, art. 26, § 1.º), e é a sua manifestação, na hipótese de vício oculto (art. 26, § 3.º).

3. PROTEÇÃO CONTRATUAL

A legislação civil sobre contratos pressupõe a existência de partes livres e iguais que transigem sobre os seus respectivos interesses, com pleno domínio da vontade. As pessoas, neste contexto, contratam *se querem, com quem querem e como querem*. A ideia de ser o contrato *lei entre as partes* corresponde a este cenário pressuposto das normas civis e empresariais.

A realidade das relações de consumo, no entanto, é bem diferente. O consumidor não contrata se quiser, com quem quiser e como quiser, mas se vê muitas vezes obrigado a contratar bens e serviços essenciais, de um ou poucos fornecedores e sem a menor possibilidade de discutir os termos da negociação. Pense-se, por exemplo, no contrato de fornecimento de energia elétrica, na aquisição de alimentos e utensílios básicos etc. O consumidor encontra-se, perante o fornecedor, numa clara situação de vulnerabilidade. Em geral, ele tem relativamente ao produto ou serviço que consome *muito menos informações* do que o fornecedor.

O Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor os meios jurídicos para atenuar as distorções derivadas da vulnerabilidade em que se encontra perante o fornecedor. Cinco princípios podem ser destacados nessa matéria:

a) *Irrenunciabilidade de direitos* - são nulas as cláusulas contratuais que importem, tácita ou expressamente, renúncia, pelo consumidor, dos direitos que lhe são assegurados. Em termos gerais, este princípio se encontra inscrito no art. 51, I, do CDC. Outras disposições, contudo, são exteriorizações desta concepção básica, segundo a qual a proteção jurídica do consumidor é de ordem pública, com caráter cogente. São exemplos de aplicação específica do princípio: nulidade da desconsideração do direito de optar pelo reembolso da quantia paga, quando autorizado por lei (art. 51, II), vedação da transferência de responsabilidade (art. 51, III), impossibilidade de inversão do ônus de prova em detrimento do consumidor (art. 51, VI), imposição de arbitragem necessária (art. 51, VII) e invalidade de

cláusulas em desacordo com o sistema legal de proteção ao consumidor (art. 51, XV). Em virtude desse princípio, não tem validade qualquer disposição contratual, mesmo que indubitavelmente assinada pelo consumidor, que importe limitação ou frustração do exercício de direito legalmente reconhecido. No contrato de consumo, não é admitida a renúncia a direito nem mesmo por meio de cláusula *adicionada* a contrato de adesão, como permite a lei relativamente aos contratos cíveis: o art. 424 do CC considera nula a renúncia do aderente apenas se for *antecipada*, ou seja, constar já do formulário ou de outro instrumento do contrato de adesão preparado pelo estipulante.

b) *Equilíbrio contratual* - a equidade nas relações de consumo é um dos valores fundamentais presentes no sistema de proteção contratual. Nenhuma oneração excessiva será imposta aos consumidores, que não podem ficar em situação desvantajosa perante o empresário. Com este espírito, o legislador fulminou com a nulidade o estabelecimento de faculdades ao empresário que não sejam correspondentes às reconhecidas aos consumidores (CDC, art. 51, XI e XII). Também não se encontram respaldadas juridicamente as disposições contratuais autorizando o empresário, unilateralmente, a alterar as condições do negócio (art. 51, X e XIII). Igualmente são inválidas as cláusulas com exigências injustificáveis da parte do empresário (art. 51, VII e VIII).

c) *Transparência* - as relações de consumo devem pautar-se na mais absoluta transparência, ou seja, o consumidor deve ter prévio e completo conhecimento da exata extensão das obrigações assumidas por ele e pelo empresário, em decorrência do contrato. Neste sentido, o consumidor não estará vinculado se não lhe for dada ciência prévia do conteúdo do instrumento ou se este for redigido de modo a dificultar a compreensão do seu alcance (CDC, art. 46). Por outro lado, as informações precisas constantes de mensagem publicitária, transmitida por qualquer meio de comunicação, integram o contrato (art. 30). Por fim, o legislador determina que os contratos de adesão escritos devem ser redigidos de forma clara e compreensível e elaborados com destaque para as cláusulas limitativas de direitos do consumidor (art. 54, §§ 3.º e 4.º). Como se nota, a transparência nas relações de consumo significa a possibilidade de o consumidor ter acesso às informações relativas às condições do negócio que está realizando ou pretende realizar. Nenhum expediente poderá ser validamente utilizado pelo empresário para impedir que o consumidor celebre contrato ignorando parcialmente as obrigações ou os direitos assumidos.

d) *Interpretação favorável ao consumidor* - como o instrumento contratual é elaborado unilateralmente pelo fornecedor, a lei (CDC, art. 47) estabelece que a sua interpretação deve favorecer o consumidor, de modo que eventual tentativa de redação ambígua ou obscura do contrato resulte ineficaz. Segundo este princípio, se a disposição do contrato comportar mais de uma interpretação, a que trazer maiores vantagens ao consumidor deve ter preferência sobre as demais.

e) *Execução específica dos contratos de consumo* - os contratos de consumo comportam execução específica, ou seja, pode o juiz adotar toda e qualquer medida que viabilize o atingimento do efeito concreto pretendido pelas partes. Em regra, as obrigações de fazer decorrentes de contrato de consumo se resolvem em perdas e danos, somente por opção do autor da demanda ou por impossibilidade material da tutela específica ou de resultado prático correspondente (CDC, art. 84). A mesma proteção é deferida a toda manifestação escrita de vontade, recibos e pré-contratos (art. 48). Tanto o empresário como o consumidor encontram-se sujeitos a esta regra, de sorte que o primeiro pode, por exemplo, obter ordem judicial que o autorize a realizar, por conta do consumidor, as revisões no bem vendido, se este último assumiu a obrigação de as fazer.

Convém notar, afinal, que aos dois últimos princípios de tutela dos consumidores foram

transformados, com a entrada em vigor do Código Civil em 2003, em regras gerais do direito contratual. Também os contratos cíveis, não sujeitos ao CDC, devem ser interpretados em favor do aderente (quando são de adesão) e comportam, em regra, execução específica (CC, arts. 423 e 475).

4. PUBLICIDADE

Há três formas de publicidade ilícita previstas pelo Código de Defesa do Consumidor: a simulada, a enganosa e a abusiva.

Publicidade simulada é a que procura ocultar o seu caráter de propaganda. A veiculação da publicidade deve ser feita de modo que o consumidor possa percebê-la, fácil e imediatamente, adotando as cautelas próprias diante da natureza necessariamente parcial da mensagem transmitida (CDC, art. 36). São exemplos de publicidade simulada a inserção, em jornais e periódicos, de propaganda com a aparência externa de reportagem, ou a subliminar, captável pelo inconsciente, mas imperceptível ao consciente.

O parágrafo único do art. 67 do projeto de CDC aprovado pelo Legislativo previa como crime a realização de publicidade simulada, mas houve veto presidencial, e, assim, inexistia qualquer tipo de sanção para essa hipótese de publicidade ilícita.

Publicidade enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor em erro. Na lei (CDC, art. 37, § 1.º), menciona-se a transmissão de informação parcial ou totalmente falsa, mas o conceito não é correto. A publicidade pode ser falsa e não ser necessariamente enganosa. Isso porque o instrumento principal da veiculação publicitária é a mobilização do imaginário do consumidor, com o objetivo de tornar o produto ou serviço desejado. Ora, o fantasioso (necessariamente falso) nem sempre induz ou é capaz de induzir o consumidor em erro. A promoção, por exemplo, de um chocolate por meio de filme publicitário com pessoas levitando ao consumi-lo implica a veiculação de informações falsas (o produto não tem o efeito apresentado), mas evidentemente é insuscetível de enganar o consumidor. Não é necessário que exista dolo do fornecedor, para se caracterizar a enganiosidade. Esta é aferida de modo objetivo, isto é, a partir do potencial de enganiosidade apresentado pelo anúncio.

Já a publicidade abusiva (CDC, art. 37, § 2.º) é aquela que agride os valores sociais. O fabricante de armas não pode promover o seu produto reforçando a ideologia da violência como meio de resolução de conflitos, ainda que esta solução resultasse eficiente, em termos mercadológicos, junto aos segmentos da sociedade composta pelos consumidores de armamentos. Também é abusiva a publicidade racista, sexista, discriminatória e a lesiva ao meio ambiente. Na avaliação da abusividade, no entanto, é necessário não confundir agressão a valores sociais com desconfortos derivados de problemas pessoais. O palavrão, a nudez, o erotismo não são necessariamente abusivos, dependendo do contexto de sua apresentação pelo anúncio.

Como se relaciona com os valores socialmente aceitos, a publicidade considerada abusiva em determinado momento histórico pode deixar de sê-lo em outro e vice-versa. Se, nos anos 1960, era aceitável a publicidade de eletrodomésticos apresentando mulheres como as únicas responsáveis pelas tarefas do lar, hoje em dia isto caracterizaria um reprovável sexismo e abusividade.

A realização de publicidade enganosa ou abusiva gera responsabilidade civil, penal e administrativa. Assim, o fornecedor que as promover deve indenizar material e moralmente o consumidor. Além disso,

responderá pela prática de crime (CDC, art. 67) e deverá veicular contrapropaganda, que desfça os efeitos do engano ou do abuso (arts. 56, XII, e 60).

Em virtude do princípio da transparência, as informações precisas que o empresário veicula por meio da publicidade integram o contrato que vier a ser celebrado com o consumidor (CDC, art. 30). Têm estas informações caráter vinculativo e obrigam, também, aqueles que, embora não patrocinem a publicidade, dela se utilizam. É o caso do comerciante que reforça a propaganda do fabricante da mercadoria. Anote-se, contudo, que apenas as informações suficientemente precisas têm este caráter vinculativo. As genéricas podem eventualmente dar ensejo à caracterização de algum tipo de publicidade ilícita, mas não constituem condição de negócio.

Se o empresário negar cumprimento ao veiculado pela publicidade, pode o consumidor exigir a observância estrita das condições anunciadas ou optar por produto ou serviço semelhante ou pela resolução do contrato com indenização (CDC, art. 35). As mesmas consequências são previstas em relação à oferta ou apresentação do produto ou serviço.

SEGUNDA PARTE - DIREITO SOCIETÁRIO

(Autor)

Fábio Ulhoa Coelho

Capítulo 9. TEORIA GERAL DO DIREITO SOCIETÁRIO

1. CONCEITO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

Na construção do conceito de sociedade empresária, dois institutos jurídicos servem de alicerces. De um lado, a *pessoa jurídica*; de outro, a *atividade empresarial*. Uma primeira aproximação ao conteúdo deste conceito se faz pela ideia de pessoa jurídica empresária, ou seja, que exerce atividade econômica sob a forma de empresa. É uma ideia correta, mas incompleta ainda. Somente algumas espécies de pessoa jurídica que exploram atividade definida pelo direito como de natureza empresarial é que podem ser conceituadas como sociedades empresárias. Além disso, há pessoas jurídicas que são sempre empresárias, qualquer que seja o seu objeto. Um ponto de partida, assim, para a conceituação de sociedade empresária é o da sua localização no quadro geral das pessoas jurídicas.

No direito brasileiro, as pessoas jurídicas são divididas em dois grandes grupos. De um lado, as pessoas jurídicas de direito público, tais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, os Territórios e as autarquias; de outro, as de direito privado, compreendendo todas as demais. O que diferencia um de outro grupo é o regime jurídico a que se submetem. As pessoas jurídicas de direito público gozam de uma posição jurídica diferenciada em razão da supremacia dos interesses que o direito encarregou as de tutelar; já as de direito privado estão sujeitas a um regime jurídico caracterizado pela igualdade, inexistindo valoração diferenciada dos interesses defendidos por elas. Uma pessoa jurídica de direito público se relaciona com uma pessoa jurídica de direito privado em posição privilegiada, ao passo que as de direito privado se relacionam entre si em pé de igualdade. É irrelevante, para se determinar o enquadramento de uma pessoa jurídica num ou noutro destes grupos, a origem dos recursos destinados à sua constituição. Isto porque o direito contempla pessoas jurídicas constituídas, exclusivamente, por recursos públicos, mas que se encontram, por determinação constitucional, sujeitas ao regime de direito privado, que são as empresas públicas.

Por esta ideia, inclusive, introduz-se a subdivisão existente no grupo das pessoas jurídicas de direito privado. De um lado, as chamadas estatais, cujo capital social é formado, majoritariamente ou totalmente, por recursos provenientes do poder público, que compreende a sociedade de economia mista, da qual particulares também participam, embora minoritariamente, e a já lembrada empresa pública. De outro lado, as pessoas jurídicas de direito privado não estatais, que compreendem a fundação, a associação e as sociedades. As sociedades, por sua vez, se distinguem da associação e da fundação em virtude de seu escopo negocial, e se subdividem em sociedades *simples* e *empresárias*.

A distinção entre sociedade simples e empresária não reside, como se poderia pensar, no intuito lucrativo. Embora seja da essência de qualquer sociedade empresária a persecução de lucros – inexistente

pessoa jurídica dessa categoria com fins filantrópicos ou pios –, este é um critério insuficiente para destacá-la da sociedade simples. Isto porque também há sociedades não empresárias com escopo lucrativo, como as sociedades de advogados por exemplo.

O que irá, de verdade, caracterizar a pessoa jurídica de direito privado não estatal como sociedade simples ou empresária será o modo de explorar seu objeto. O objeto social explorado sem empresarialidade (isto é, sem organização profissional dos fatores de produção) confere à sociedade o caráter de simples; enquanto a exploração empresarial do objeto social caracterizará a sociedade como empresária (*Cap. 1*).

Por critério de identificação da sociedade empresária elegeu, pois, o direito o modo de exploração do objeto social. Esse critério material, que dá relevo à maneira de se desenvolver a atividade efetivamente exercida pela sociedade, na definição de sua natureza empresarial, é apenas excepcionado em relação às sociedades por ações. Estas serão sempre empresárias, ainda que o seu objeto não seja empresarialmente explorado (CC, art. 982, parágrafo único; LSA, art. 2.º, § 1.º). De outro lado, as cooperativas nunca serão empresárias, mas necessariamente sociedades simples, independentemente de qualquer outra característica que as cerque (CC, art. 982, parágrafo único). Salvo nestas hipóteses – sociedade anônima, em comandita por ações ou cooperativas –, o enquadramento de uma sociedade no regime jurídico empresarial dependerá, exclusivamente, da forma com que explora seu objeto. Uma sociedade limitada, em decorrência, poderá ser empresária ou simples: se for exercente de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, será empresária; caso contrário ou se dedicando a atividade econômica civil (sociedade de profissionais intelectuais), será simples.

Assentadas estas premissas, a sociedade empresária pode ser conceituada como a pessoa jurídica de direito privado não estatal, que explora empresarialmente seu objeto social ou adota a forma de sociedade por ações.

2. PERSONALIZAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que a compõem. Este princípio, de suma importância para o regime das pessoas jurídicas, também se aplica à sociedade empresária. Tem ela personalidade jurídica distinta da de seus sócios; são pessoas inconfundíveis, independentes entre si. A sociedade é uma pessoa (jurídica) e os sócios são *outras* pessoas (naturais ou jurídicas).

Pessoa jurídica é um expediente do direito destinado a simplificar a disciplina de determinadas relações entre os homens em sociedade. Ela não tem existência fora do direito, ou seja, para além dos conceitos partilhados pelos integrantes da comunidade jurídica. Tal expediente tem o sentido, bastante preciso, de autorizar determinados sujeitos de direito à prática de atos jurídicos em geral.

Explique-se: sujeito de direito e pessoa não são conceitos sinônimos. Antes, sujeito de direito é gênero do qual pessoa é espécie. Todos os centros subjetivos de referência de direito ou obrigações, vale dizer, tudo aquilo que a ordem jurídica reputa apto a ser credor ou devedor de prestações é chamado de “sujeito de direito”. Ora, isto inclui determinadas entidades que não são consideradas pessoas, como a massa falida, o condomínio horizontal, o nascituro, o espólio etc. Estas entidades, despersonalizadas compõem, juntamente com as pessoas, o universo dos sujeitos de direito.

O que distingue o sujeito de direito despersonalizado do personalizado é o regime jurídico a que ele está submetido, em termos de autorização genérica para a prática dos atos jurídicos. Enquanto as pessoas estão autorizadas a praticar todos os atos jurídicos a que não estejam expressamente proibidas, os sujeitos de direito despersonalizados só poderão praticar os atos a que estejam, explicitamente, autorizados pelo direito.

Assim, a uma indagação do tipo “tal sujeito pode praticar tal ato jurídico?” deve se responder partindo da definição da natureza personalizada ou despersonalizada do sujeito. No primeiro caso, a resposta será afirmativa se inexistir proibição; no segundo caso, será afirmativa se existir uma permissão explícita. Por exemplo: qualquer pessoa capaz pode exercer empresa, desde que não esteja proibida; já o nascituro, o condomínio horizontal, a massa falida, os sujeitos de direito despersonalizados em geral não poderão exercer atividade empresarial (mesmo inexistente proibição que os alcance) por faltar, no ordenamento jurídico em vigor, norma permissiva expressa.

Estas definições acerca do regime jurídico dos sujeitos de direito personalizados e despersonalizados convivem com três exceções: os atos jurídicos típicos da pessoa natural, como o casamento ou a adoção, não podem ser praticados pela pessoa jurídica, mesmo se, eventualmente, o ordenamento jurídico deixar de prever vedação expressa neste sentido; os atos jurídicos da essência dos sujeitos de direito despersonalizados podem ser por estes praticados, mesmo se eventualmente o ordenamento deixar de autorizá-los de modo expresso, como no caso da celebração de contrato de trabalho pelo condomínio horizontal; finalmente, o Estado, embora seja pessoa jurídica, depende de autorização expressa do direito para praticar, validamente, negócio jurídico, em virtude do sentido específico que assume o princípio da legalidade no direito público.

De qualquer forma, a sociedade empresária, como uma pessoa jurídica, é sujeito de direito personalizado, e poderá, por isso, praticar todo e qualquer ato ou negócio jurídico em relação ao qual inexistir proibição expressa.

Importante ressaltar, aqui, que a EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada) é também uma pessoa jurídica – a rigor, trata-se da designação dada, pela lei brasileira, à sociedade limitada unipessoal. Assim sendo, o seu único sócio também não se confunde com a EIRELI. São sujeitos de direito distintos. A unipessoalidade da pessoa jurídica não a descaracteriza como sujeito de direito personalizado. Não há, quanto a este aspecto, absolutamente nenhuma diferença entre a EIRELI e qualquer sociedade pluripessoal, sendo uma e outras pessoas jurídicas inconfundíveis com os sócios que a compõem.

A personalização das sociedades empresariais gera três consequências bastante precisas, a saber:

a) *Titularidade negocial* – quando a sociedade empresária realiza negócios jurídicos (compra matéria prima, celebra contrato de trabalho, aceita uma duplicata etc.), embora ela o faça necessariamente pelas mãos de seu representante legal (Pontes de Miranda diria “presentante legal”, por não ser a sociedade incapaz), é ela, pessoa jurídica, como sujeito de direito autônomo, personalizado, que assume um dos polos da relação negocial. O eventual sócio que a representou não é parte do negócio jurídico, mas sim a sociedade.

b) *Titularidade processual* – a pessoa jurídica pode demandar e ser demandada em juízo; tem capacidade para ser parte processual. A ação referente a negócio da sociedade deve ser endereçada contra a pessoa jurídica e não os seus sócios ou seu representante legal. Quem outorga mandato judicial,

recebe citação, recorre, é ela como sujeito de direito autônomo.

c) *Responsabilidade patrimonial* – em consequência, ainda, de sua personalização, a sociedade terá patrimônio próprio, seu, inconfundível e incommunicável com o patrimônio individual de cada um de seus sócios. Sujeito de direito personalizado autônomo, a pessoa jurídica responderá com o seu patrimônio pelas obrigações que assumir. Os sócios, em regra, não responderão pelas obrigações da sociedade. Somente em hipóteses excepcionais, que serão examinadas a seu tempo, poderá ser responsabilizado o sócio pelas obrigações da sociedade.

O fim da personalização da sociedade empresária resulta de todo um processo de extinção, também conhecido por dissolução em sentido largo (ou dissolução-procedimento), o qual compreende as seguintes fases: a) dissolução, em sentido estrito (ou dissolução-ato), que é o ato de desfazimento da constituição da sociedade; b) liquidação, que visa à realização do ativo e pagamento do passivo da sociedade; c) partilha, pela qual os sócios participam do acervo da sociedade. Há quem pretenda a existência de uma quarta fase de extinção, consistente no decurso do prazo de prescrição de todas as obrigações sociais (Fran Martins). Por outro lado, há diversos modos de se extinguir a personalidade jurídica da sociedade, além da dissolução; por exemplo: a incorporação em outra, a fusão, a cisão total e a falência. De qualquer forma, relegando o tratamento mais demorado deste tema para o momento oportuno, registre-se, aqui, que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se extingue em virtude de um ato ou fato singular, mas somente após a conclusão de todo um processo, judicial ou extrajudicial.

3. CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS

Classificam-se as sociedades empresárias segundo diversos critérios. Cuidarei de cinco deles. Primeiramente, a classificação das sociedades de acordo com a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais; em seguida, a classificação quanto ao regime de constituição e dissolução; na sequência, a classificação quanto às condições para alienação da participação societária; depois, a relativa ao número de sócios; e, por fim, a classificação baseada na nacionalidade.

Antes de examinar cada um destes critérios, no entanto, faz-se necessário apresentar a enumeração dos tipos societários existentes no direito comercial. São eles: a sociedade em nome coletivo (N/C), a sociedade em comandita simples (C/S), a sociedade em comandita por ações (C/A), a sociedade em conta de participação (C/P), a sociedade limitada (Ltda.) e a sociedade anônima ou companhia (S/A).

Desses seis tipos societários, deve-se destacar a sociedade em conta de participação, que a lei define como despersonalizada (CC, arts. 991 a 996). Dela se cuidará em momento próprio. Por ora, melhor desconsiderá-la, por motivos didáticos, na classificação das demais sociedades empresárias.

3.1. Classificação quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais

Em razão do princípio da autonomia patrimonial, ou seja, da personalização da sociedade empresária, os sócios não respondem, em regra, pelas obrigações desta. Se a pessoa jurídica é solvente, quer dizer, possui bens em seu patrimônio suficientes para o integral cumprimento de todas as suas obrigações, o ativo do patrimônio particular de cada sócio é, absolutamente, inatingível por dívida social. Mesmo em caso de falência, somente após o completo exaurimento do capital social é que se poderá cogitar de alguma responsabilidade por parte dos sócios, ainda assim condicionada a uma série

de fatores.

A responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade empresária é sempre subsidiária, porque é legalmente assegurado aos sócios o direito de exigirem o prévio exaurimento do ativo do patrimônio social (CC, art. 1.024; CPC, art. 795, § 1.º). Quando a lei qualifica de “solidária” a responsabilidade de sócios – ao delimitar a dos membros da N/C (CC, art. 1.039) dos comanditados da C/S (art. 1.045), dos diretores da C/A (art. 1.091) ou dos da limitada em relação à integralização do capital social (art. 1.052) –, ela se refere às relações entre eles; quer dizer, se um sócio descumpra sua obrigação, esta pode ser exigida dos demais, se solidários.

Quando se diz, portanto, que a responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade é subsidiária, o que se tem em mira é, justamente, esta regra de que sua eventual responsabilização por dívidas sociais tem por pressuposto o integral comprometimento do ativo do patrimônio social. É subsidiária no sentido de que se segue à responsabilidade da própria sociedade. Esgotadas as forças do patrimônio social é que se poderá pensar em executar bens do patrimônio particular do sócio por saldos existentes no passivo da sociedade.

O direito brasileiro da atualidade não conhece nenhuma hipótese de limitação de responsabilidade pessoal. Assim, quando a sociedade estiver respondendo por obrigação sua, terá responsabilidade ilimitada; também o sócio, quando responder por ato seu, ainda que relacionado com a sociedade, terá responsabilidade ilimitada. Somente se concebe, no presente estágio evolutivo do direito nacional, a limitação da responsabilidade subsidiária. Os sócios respondem, assim, pelas obrigações sociais, sempre de modo subsidiário, mas limitada ou ilimitadamente.

Se o ativo do patrimônio social não foi suficiente para integral pagamento dos credores da sociedade, o saldo do passivo poderá ser reclamado dos sócios, em algumas sociedades, de forma ilimitada (ou seja, os credores poderão saciar seus créditos até a total satisfação, enquanto suportarem os bens dos patrimônios particulares dos sócios). Em outras sociedades, os credores somente poderão alcançar dos bens dos patrimônios particulares dos sócios um determinado limite, além do qual o respectivo saldo será perda que deverão suportar. Há, ainda, um terceiro grupo de sociedades, em que alguns dos sócios têm responsabilidade ilimitada e outros limitada. A classificação que se verá a seguir tenta sintetizar este quadro.

As sociedades empresárias, portanto, segundo o critério que considera a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, dividem-se em:

a) *Sociedade ilimitada* – em que todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. O direito contempla um só tipo de sociedade desta categoria, que é a sociedade em nome coletivo (N/C).

b) *Sociedade mista* – em que uma parte dos sócios tem responsabilidade ilimitada e outra parte tem responsabilidade limitada. São desta categoria as seguintes sociedades: em comandita simples (C/S), cujo sócio comanditado responde ilimitadamente pelas obrigações sociais, enquanto o sócio comanditário responde limitadamente; e a sociedade em comandita por ações (C/A), em que os sócios diretores têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais e os demais acionistas respondem limitadamente.

c) *Sociedade limitada* – em que todos os sócios respondem de forma limitada pelas obrigações sociais. São desta categoria a sociedade limitada (Ltda.) e a anônima (S/A).

Variam de um tipo societário para outro as regras de determinação do limite da responsabilidade dos sócios. Têm-se regras próprias para a sociedade limitada e para o sócio comanditário da sociedade em comandita simples, de um lado, e para a sociedade anônima e acionista não diretor da sociedade em comandita por ações, de outro lado. Em relação às duas primeiras hipóteses, os sócios respondem até o limite do total do capital social não-integralizado; em relação às duas últimas, o acionista responderá até o limite do valor não integralizado da parte do capital social que ele subscreveu.

Ao ingressar numa sociedade empresária, qualquer que seja ela, o sócio deve contribuir para o capital social. Se a sociedade está em constituição ou se houve aumento do capital social com novas participações, o ingressante subscreve uma parte. Ou seja, ele se compromete a pagar uma quantia determinada para a sociedade, contribuindo, assim, com o capital social e legitimando a sua pretensão à percepção de parcela dos lucros gerados pelos negócios sociais. Poderá fazê-lo à vista ou a prazo. Na medida em que for pagando o que ele se comprometeu a pagar, na subscrição, à sociedade, diz-se que ele está *integralizando* a sua participação societária. Quando todos os sócios já cumprirem as respectivas obrigações de contribuir para a formação da sociedade, o capital social estará totalmente integralizado.

O sócio da sociedade limitada e o comanditário da sociedade em comandita simples respondem pelas obrigações sociais até o total do capital social não integralizado, ou seja, até o limite do valor do que ainda não foi integralizado no capital social da sociedade. Mesmo que um sócio já tenha integralizado, totalmente, a sua parte, se outro ainda não fez o mesmo com a parcela que lhe caberia, o primeiro poderá ser responsabilizado pelas obrigações sociais dentro do limite do valor que o seu sócio ainda não integralizou. É claro, poderá, posteriormente, em regresso, ressarcir-se do sócio inadimplente, mas responderá perante a massa dos credores da sociedade pelo total do capital não integralizado.

Já os acionistas da sociedade anônima, ou os da comandita por ações com responsabilidade limitada, respondem somente por aquilo que subscreveram e ainda não integralizaram. Estas hipóteses diferenciam-se das duas primeiras, posto que o acionista nunca poderá ser responsabilizado pela não integralização da participação societária devida por outro acionista.

Anote-se que o limite da responsabilidade subsidiária dos sócios pode ser “zero”. Vale dizer, se todo o capital social já estiver integralizado, os credores da sociedade não poderão alcançar o ativo do patrimônio particular de qualquer sócio com responsabilidade limitada. Deverão, em decorrência, suportar o prejuízo.

É oportuno frisar, também, que as regras de definição do limite da responsabilidade subsidiária dos sócios de responsabilidade limitada são apresentadas pela lei com expressões e conceitos diversos, dos quais se cuidará no momento oportuno. Trata-se, aqui, apenas de uma forma diferente de explicar as relações jurídicas, sem mudança de conteúdo, indispensável à sistematização da matéria; sem a adoção de termos mais genéricos que os dos dispositivos legais aplicáveis a cada sócio de responsabilidade limitada, não se poderia chegar a categorias abrangentes dos diferentes tipos societários envolvidos com a questão.

3.2. Classificação quanto ao regime de constituição e dissolução

Um determinado conjunto de tipos societários tem a sua constituição e dissolução disciplinadas pelo Código Civil; outro grupo de tipos societários rege-se, neste assunto, pelas normas da Lei 6.404/76 (Lei das sociedades por ações – LSA). Cada um desses grupos, assim, está relacionado a um regime constitutivo e dissolutório específico.

Segundo esse critério, têm-se:

a) *Sociedades contratuais* – cujo ato constitutivo e regulamentar é o contrato social. Para a dissolução deste tipo de sociedade não basta a vontade majoritária dos sócios, reconhecendo a jurisprudência o direito de os sócios, mesmo minoritários, manterem a sociedade, contra a vontade da maioria; além disto, há causas específicas de dissolução desta categoria de sociedades, como a morte ou a expulsão de sócio. São sociedades contratuais: em nome coletivo (N/C), em comandita simples (C/S) e limitada (Ltda.).

b) *Sociedades institucionais* – cujo ato regulamentar é o estatuto social. Estas sociedades podem ser dissolvidas por vontade da maioria societária e há causas dissolutórias que lhes são exclusivas como a intervenção e liquidação extrajudicial. São institucionais a sociedade anônima (S/A) e a sociedade em comandita por ações (C/A).

A sociedade contratual, pois, tem sua constituição e dissolução regidas pelo Código Civil, ao passo que a sociedade institucional rege-se, neste ponto, pelas normas específicas da LSA. Quando se fizer o estudo mais detido da constituição e dissolução de uma e outra categoria de sociedades, serão elucidadas as características próprias de cada categoria.

3.3. *Classificação quanto às condições de alienação da participação societária*

Há sociedades em que os atributos individuais do sócio interferem com a realização do objeto social e há sociedades em que não ocorre esta interferência. Em algumas, a circunstância de ser o sócio competente, honesto ou diligente tem relevância para o sucesso ou fracasso da empresa, ao passo que, em outras, tais características subjetivas decididamente não influem na realização do objeto social.

No primeiro caso, quando as particularidades individuais dos sócios podem comprometer o desenvolvimento da empresa a que se dedica a sociedade, os integrantes desta devem ter garantias acerca do perfil de quem pretenda fazer parte do quadro de sócios. No segundo caso, o direito pode – e, até certo ponto, deve – descuidar-se disto, posto que o perfil do eventual novo sócio não repercutirá no sucesso ou fracasso do empreendimento.

Justamente em função dessa realidade é que o direito comercial criou um grupo de sociedades em que a alienação da participação societária por um dos sócios a terceiro estranho à sociedade, depende da anuência dos demais sócios; e outro grupo em que esse negócio jurídico *independe* da mencionada anuência.

A participação societária de uma sociedade contratual é denominada “cota” (que se pode grafar também “quota”); a de uma sociedade institucional é denominada “ação”. Uma ou outra são bens do patrimônio do sócio (ou acionista), não pertencem à sociedade. Desse modo, o seu titular, o sócio, pode dispor livremente da participação societária, tal como dispõe dos demais bens de seu patrimônio. O adquirente de cota ou ação torna-se sócio da sociedade e passa a exercer os direitos que esta condição lhe confere. Nas sociedades em que as características subjetivas dos sócios podem comprometer o sucesso da empresa levada a cabo pela sociedade, garante-se o direito de veto ao ingresso de terceiro estranho ao quadro de sócios. Desta forma, a alienação da participação societária condiciona-se à anuência dos demais, quando se tratar de adquirente não sócio. Já nas sociedades, em que os atributos subjetivos de cada sócio não influem na realização do objeto social, a circulação da participação societária é livre, incondicionada à concordância dos demais sócios.

Em vista desse quadro, dividem-se as sociedades nas seguintes categorias:

a) *Sociedades de pessoas*) – em que os sócios têm direito de vetar o ingresso de estranho ao quadro de sócios.

b) *Sociedades de capital*) – em relação às quais vigora o princípio da livre circulabilidade da participação societária.

É claro que não existe sociedade composta exclusivamente por “pessoas” ou exclusivamente por “capital”. Toda sociedade surge da necessária conjugação desses dois elementos imprescindíveis. O que faz uma sociedade ser “de pessoas” ou “de capital” é, na verdade, o direito de o sócio impedir o ingresso de terceiro não sócio existente nas de perfil personalístico e ausente nas de perfil capitalístico. Em outros termos, em algumas sociedades, as “pessoas” são mais importantes que o “capital”; em outras, ocorre o inverso.

Em função disto, justamente, é que as cotas sociais representativas do capital social de uma sociedade “de pessoas” são impenhoráveis por dívidas particulares do seu titular. O direito de veto ao ingresso de terceiros estranhos à sociedade é incompatível com a penhorabilidade das cotas sociais. O arrematante da cota na execução judicial contra o seu titular ingressaria no quadro de sócios independentemente da vontade dos demais.

Outra consequência específica da sociedade “de pessoas” é a dissolução parcial por morte de sócio, quando um dos sobreviventes não concorda com o ingresso de sucessor do sócio falecido no quadro de sócios. Quando a sociedade é “de capital”, os sócios sobreviventes não podem opor-se a tal ingresso e a sociedade não se dissolve.

As sociedades institucionais são sempre “de capital”, enquanto as contratuais podem ser “de pessoas” ou “de capital”. Assim, na sociedade anônima (S/A) e em comandita por ações (C/A), os acionistas não têm o direito de impedir o ingresso de terceiro não sócio na sociedade, assegurado o princípio da livre-circulação das ações (LSA, art. 36). Nestes tipos de sociedades, as ações são sempre penhoráveis por dívida de sócio e a morte não permite a dissolução parcial, seja a pedido dos sobreviventes ou dos sucessores.

Nas sociedades em nome coletivo (N/C) e comandita simples (C/S), a cessão das quotas sociais depende da anuência dos demais sócios (CC, art. 1.003), regra que lhes confere perfil personalístico. Suas quotas sociais são, em decorrência, impenhoráveis. Em relação às consequências da morte de sócio, a sociedade em nome coletivo é “de pessoas”, mas o contrato social poderá atribuir-lhe perfil diverso se assegurar aos sucessores o ingresso na sociedade (art. 1.028, I); e a sociedade em comandita simples ostenta natureza diversa segundo a espécie de sócio falecido: é “de pessoas”, em caso de morte de comanditado, e “de capital”, se falecido um comanditário – sendo que, neste último caso, o contrato social pode alterar a natureza da C/S, prevendo a liquidação das quotas (art. 1.050).

Na sociedade limitada (Ltda.), o contrato social definirá a existência, ou não, e extensão do direito de veto ao ingresso de novos sócios. Poderá, também, dispor sobre as consequências do falecimento de sócio. Pode, portanto, o contrato social atribuir-lhe a natureza personalística ou capitalística. Caso seja omissivo, a cessão de quotas a terceiros estranhos à sociedade pode ser obstada por sócio ou sócios com mais de um quarto do capital social (CC, art. 1.057). Consequentemente, a sociedade limitada é “de pessoas”, a menos que o contrato social lhe confira natureza capitalista.

3.4. Classificação quanto à quantidade de sócios

Segundo o critério da quantidade de sócios, as sociedades empresárias podem ser *pluripessoais* ou *unipessoais*. No primeiro caso, possuem dois ou mais sócios, que unem seus esforços para a realização da finalidade comum, de ganhar dinheiro mediante a exploração de uma atividade empresarial. Já as sociedades unipessoais são constituídas por um único sócio.

Apenas em duas hipóteses o direito brasileiro admite as sociedades unipessoais.

A primeira é a *subsidiária integral*. Trata-se de uma sociedade necessariamente do tipo “anônima”, constituída por escritura pública, por uma sociedade brasileira (LSA, art. 251). A pessoa natural e a sociedade estrangeira não podem constituir subsidiária integral.

A outra hipótese de sociedade unipessoal do direito brasileiro é a EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada). Trata-se aqui de uma sociedade do tipo “limitada”, sujeita a regras próprias atinentes à composição do nome empresarial e forma de constituição (CC, art. 980-A e seus parágrafos). A EIRELI pode ser constituída por qualquer pessoa natural ou jurídica.

Para fins didáticos, convém estudar os temas de direito societário focando-se, inicialmente, as sociedades pluripessoais como modelo geral; e reservando-se, no final, atenção específica ao estudo das unipessoais (*Cap. 13*, item 8).

3.5. Classificação quanto à nacionalidade

Outro critério de classificação das sociedades empresárias tem em vista a sua nacionalidade.

Considera-se nacional a sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e com sede de administração localizada no Brasil (CC, art. 1.126), sendo irrelevante a nacionalidade do capital ou mesmo a dos acionistas. A sociedade empresária organizada de acordo com legislação alienígena, ou com sede no exterior, é considerada, portanto, estrangeira, submetendo-se, em decorrência, a controle governamental específico (necessidade de autorização para funcionar no país, possibilidade de cassação da autorização etc).

4. SOCIEDADE IRREGULAR

Assim como ocorre com o empresário individual, a sociedade empresária deve ser registrada na Junta Comercial. O seu ato constitutivo (contrato social ou estatuto) é que será objeto de registro, devendo este ser anterior ao início das atividades.

A sociedade sem registro é chamada, na doutrina, de sociedade irregular, ou “de fato”. Alguns autores adotam a proposta de Waldemar Ferreira no sentido de se considerar irregular a sociedade que tenha ato constitutivo escrito, embora não registrado, e “de fato” a sociedade que sequer ato constitutivo escrito possui. Mas, a rigor, a distinção nem sempre se justifica; ambos os tipos de sociedades, com ou sem ato constitutivo escrito, estão sujeitos ao mesmo regime jurídico decorrente da inexistência do registro. A distinção somente ganha relevância na discussão sobre o cabimento de ação entre sócios para declarar a existência da sociedade. Esta ação judicial somente pode ser proposta se, desde logo, quem a promove (alegando a qualidade de sócio) exibir o contrato social ou outro documento escrito, ainda que não registrado (CC, art. 987). Em outros termos, aquele que integra sociedade “de fato” não tem ação para o

reconhecimento do vínculo societário; mas o que integra uma sociedade irregular teria.

No Código Civil, a sociedade empresária irregular ou “de fato” é disciplinada sob a designação de “sociedade em comum”. Não se trata de novo tipo societário, mas de uma situação em que a sociedade empresária ou simples pode eventualmente se encontrar: a de irregularidade caracterizada pela exploração de atividade econômica sem o prévio registro exigido na lei.

Além das restrições comuns ao empresário individual irregular – vale dizer: ilegitimidade ativa para o pedido de falência e de recuperação judicial e ineficácia probatória dos livros comerciais –, o direito reserva uma sanção específica para a sociedade empresária que opera sem registro na Junta Comercial. Os sócios da sociedade sem registro responderão sempre ilimitadamente pelas obrigações sociais, sendo ineficaz eventual cláusula limitativa desta responsabilidade no contrato social (CC, art. 990). Os sócios que se apresentaram como representantes da sociedade terão responsabilidade direta e os demais, subsidiária; mas todos assumem responsabilidade sem limite pelas obrigações contraídas em nome da sociedade.

Deve se recuperar, aqui, os efeitos decorrentes do exercício irregular da empresa, os quais também são pertinentes às sociedades empresárias. A falta de registro da sociedade na Junta Comercial repercute negativamente nas obrigações tributárias acessórias, nas obrigações perante a Seguridade Social e nas relações com o Poder Público (*Cap. 3, item 5*).

5. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica – princípio jurídico que a distingue de seus integrantes como sujeito autônomo de direito e obrigações – pode dar ensejo à realização de fraudes.

Se uma pessoa natural se vincula contratualmente a outra, por obrigação de não fazer e, na qualidade de representante legal de sociedade empresária, faz exatamente aquilo que se havia comprometido omitir, no rigor do princípio da autonomia da pessoa jurídica, não teria havido quebra do contrato. Quem fez foi a sociedade, e não a pessoa natural que agiu em nome dela. Assim também ocorreria se empresário individual vendesse, a prazo, o seu estabelecimento empresarial a sociedade de que detivesse 90% do capital, instituindo se sobre ele garantia de direito real em seu próprio favor. Em ocorrendo a falência da sociedade, o seu sócio majoritário, por ser credor preferencial, seria pago anteriormente aos quirografários. Aquele que, no insucesso do negócio, deveria ser considerado devedor (o empresário individual antigo titular do estabelecimento) assume a condição de credor privilegiado, com direito prejuízo ao atendimento dos demais.

Como se vê destes exemplos, por vezes a autonomia patrimonial da sociedade empresária dá margem à realização de fraudes. Para coibi las, a doutrina criou, a partir de decisões jurisprudenciais (nos EUA, Inglaterra e Alemanha, principalmente) a “teoria da desconsideração da pessoa jurídica”, pela qual se autoriza o Poder Judiciário a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sempre que ela tiver sido utilizada como expediente para a realização de fraude. Ignorando a autonomia patrimonial, será possível responsabilizar se, direta, pessoal e ilimitadamente, o sócio por obrigação que originariamente cabia à sociedade.

Pressuposto inafastável da desconsideração da pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da *separação patrimonial*. Não basta qualquer fraude, mas exige-se especificamente a

manipulação da autonomia patrimonial. Tampouco é suficiente a simples insolvência da pessoa jurídica, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios devem ter ampla vigência.

A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada na manipulação da autonomia patrimonial, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração.

A desconsideração da pessoa jurídica não atinge a validade do ato constitutivo, mas importa em sua ineficácia episódica. Uma sociedade que tenha a autonomia patrimonial desconsiderada continua válida, assim como válidos são todos os demais atos que praticou. A separação patrimonial em relação aos seus sócios é que não produzirá nenhum efeito na decisão judicial referente àquele específico ato objeto da fraude. Essa é, inclusive, a grande vantagem da desconsideração em relação a outros mecanismos de coibição da fraude, tais como a anulação ou dissolução da sociedade. Por apenas suspender a eficácia do ato constitutivo, no episódio sobre o qual recai o julgamento, sem invalidá-lo, a teoria da desconsideração preserva a empresa, que não será necessariamente atingida por ato fraudulento de um de seus sócios, resguardando-se, dessa forma, os demais interesses que gravitam ao seu redor, como o dos empregados, dos demais sócios, da comunidade etc.

O pressuposto da desconsideração, já se viu, é a ocorrência de fraude perpetrada com o uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Esta, que é a formulação mais corrente da teoria, dá, pois, relevo à presença de elemento subjetivo. Fábio Konder Comparato propôs uma formulação diversa, em que os pressupostos da desconsideração da autonomia da sociedade são objetivos, como a confusão patrimonial ou o desaparecimento do objeto social. Por essa razão, é possível chamar a primeira de concepção subjetivista e esta última de concepção objetivista da teoria da desconsideração da pessoa jurídica.

Na lei, a desconsideração da personalidade jurídica é mencionada nos arts. 28 do CDC, 34 da Lei Antitruste (LIOE), 4.º da legislação protetora do meio ambiente (Lei 9.605/98) e 50 do CC (dispositivo, aliás, inspirado na formulação objetivista de Comparato).

Capítulo 10. CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES CONTRATUAIS

1. NATUREZA DO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE CONTRATUAL

A sociedade empresária nasce do encontro de vontades de seus sócios. Este encontro, de acordo com o tipo societário que se pretende criar, será concretizado em um contrato social ou estatuto, em que se definirão as normas disciplinadoras da vida societária.

As sociedades em nome coletivo, em comandita simples e limitada são constituídas por contrato social. Isto terá repercussões no regime dissolutório aplicável a elas. As sociedades contratuais dissolvem-se de acordo com o que prevê, sobre a matéria, o Código Civil.

O contrato social é uma espécie bastante peculiar de contrato. As normas gerais de direito civil pertinentes aos contratos não podem, pura e simplesmente, ser aplicadas à disciplina do contrato social, em razão mesmo de suas particularidades. Das regras atinentes à formação, inexecução ou extinção dos contratos em geral, nem tudo se aproveita no desate de questões societárias.

De qualquer forma, os autores costumam apontar o contrato de sociedade como espécie do gênero "contrato plurilateral", em que converge para um mesmo objetivo comum a vontade dos contratantes. No caso, os sócios celebram o contrato social com vistas à exploração em conjunto de determinada atividade comercial, unindo seus esforços e cabedais para a obtenção de lucros que repartirão. Como parte de um contrato plurilateral, cada contratante assume obrigações perante os demais. Além disso, deste contrato surge um novo sujeito de direito, a sociedade, perante a qual os contratantes também são obrigados. A obrigação de o sócio integralizar a quota do capital social decorre do contrato social; o credor desta obrigação é a sociedade nascida do mesmo contrato.

2. REQUISITOS DE VALIDADE DO CONTRATO SOCIAL

Para a validade do contrato social, o direito elegeu determinados requisitos. Sem a observância destes, a sociedade não se forma validamente, podendo ser decretada a sua anulação ou declarada a nulidade. A invalidação não se confunde com a dissolução da sociedade (em sentido largo, ou seja, compreendendo o processo de extinção e não apenas o ato que lhe dá origem), embora tanto uma como outra importem o desaparecimento, em definitivo, dos efeitos do ato que constitui ou pretendeu constituir a sociedade.

A invalidação e a dissolução diferem em três aspectos: quanto aos sujeitos, aos motivos e aos efeitos. Quanto aos sujeitos, a dissolução pode decorrer da vontade dos particulares (sócios ou seus sucessores) ou de decisão judicial, ao passo que a invalidação decorre, sempre e apenas, de ato do Poder Judiciário. Quanto aos motivos, a invalidação do ato constitutivo funda-se em uma desconformidade deste com o ordenamento jurídico em vigor, enquanto a dissolução se baseia em outros fatores, como a impontualidade no cumprimento de obrigação líquida (dissolução por falência), a inviabilidade do objeto social (CC, art. 1.034), a dissidência de sócio (CC, art. 1.077) etc. Finalmente, quanto aos efeitos, a dissolução opera irretroativamente e a invalidação, retroativamente. A irretroatividade da dissolução e a retroatividade da invalidação têm em vista, apenas, o principal efeito do ato constitutivo, qual seja, a existência da pessoa jurídica. Os atos jurídicos praticados pela sociedade empresária, não relacionados com a sua existência propriamente dita, não serão invalidados pela só invalidação do ato constitutivo.

Por fim, a invalidação da sociedade importará exercício irregular da empresa, mesmo que o contrato social tenha sido registrado.

Para ser válido, o contrato social deve obedecer a duas ordens de requisitos. Em primeiro lugar, os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico; em segundo, aqueles que o direito reservou especialmente para o ato constitutivo de sociedade empresária. Assim, têm-se:

a) *Requisitos genéricos* - a validade do contrato social depende da observância dos elementos que validam os atos jurídicos em geral: agente capaz, objeto possível e lícito, além da forma prescrita ou não defesa em lei (CC, art. 104). No que diz respeito ao primeiro deles, é importante ressaltar que a contratação de sociedade limitada por menor, devidamente representado ou assistido, é admitida desde que ele não tenha poderes de administração e o capital social esteja totalmente integralizado (CC, art. 974, § 3º); quanto ao objeto, a validade do contrato social depende da possibilidade e licitude da atividade econômica explorada, sendo inválida, por exemplo, uma sociedade formada para a prática de crime; e no tocante à forma, o contrato social deve ser escrito, por instrumento particular ou público, mas pode ser, de acordo com regras a seguir estudadas, excepcionalmente oral.

b) *Requisitos específicos* - além do atendimento aos requisitos dos atos jurídicos em geral, devem os contratos sociais atender os requisitos que lhes são característicos: todos os sócios devem contribuir para a formação do capital social, seja com bens, créditos ou dinheiro; e todos os sócios participarão dos resultados, positivos ou negativos, da sociedade. Esses requisitos decorrem do próprio conceito de contrato social (CC, art. 981).

Uma sociedade empresária que dispense um dos sócios da contribuição para a formação de seu capital social não é válida; assim como também não tem validade aquela que exclua um ou alguns dos sócios dos lucros (sociedade chamada "leonina") ou das perdas sociais (CC, art. 1.008). É nula a sociedade em que se pactuar, por hipótese, que um dos sócios será indenizado pelos demais em caso de falência, porque isto equivaleria à exclusão daquele sócio das perdas sociais.

Acentue-se que a lei não veda a distribuição diferenciada dos lucros entre os sócios, nem a distribuição desproporcional à participação de cada um no capital social; a vedação, com efeito, recai sobre a exclusão de sócio da distribuição dos lucros.

Cabe fazer menção, ainda, à *affectio societatis* como pressuposto de existência da sociedade empresária pluripessoal. Esse pressuposto diz respeito à disposição, que toda pessoa manifesta ao ingressar em uma sociedade empresária, de lucrar ou suportar prejuízo em decorrência do negócio comum. Esta disposição, este ânimo, é condição de fato da existência da sociedade pluripessoal, posto que, sem ela, não haverá a própria conjugação de esforços indispensável à criação e desenvolvimento do ente coletivo.

O pressuposto de existência da sociedade empresária pluripessoal não se confunde com os seus requisitos de validade. A sua falta compromete a existência do ente social; a dos requisitos, a validade deste.

3. CLÁUSULAS CONTRATUAIS

O contrato social deverá prever as normas disciplinadoras da vida social. Qualquer assunto que diga respeito aos sócios e à sociedade pode ser objeto de acordo de vontades entre os membros da pessoa

jurídica empresária. É claro que nem tudo poderá ser previsto e exaustivamente regrado, mas, desde que não contemple solução ilegal, repudiada pelo direito, o contrato social poderá dispor sobre qualquer tema de interesse para os sócios.

Algumas cláusulas contratuais são, no entanto, necessárias para a completa regularidade da sociedade empresária. A lei exige do contrato social que atenda a determinadas condições para o seu registro na Junta Comercial (LRE, art. 35, III). Um contrato social omissivo quanto à cláusula dessa natureza não pode ser registrado e, portanto, a sociedade empresária contratada será irregular, sofrendo as consequências dessa situação e se submetendo às normas da "sociedade em comum". Já há outro grupo de cláusulas contratuais que não são indispensáveis ao registro do contrato social. A sua inexistência não impede o registro da sociedade empresária. É claro que tais cláusulas, a despeito de sua facultatividade, vinculam os sócios - e em certas vezes os sucessores dos sócios - ao avençado.

Assim, fala-se em duas espécies de cláusulas: de um lado, as essenciais, condição de registro do contrato e consequente regularidade da sociedade empresária, e, de outro lado, as acidentais.

São cláusulas essenciais do contrato social exigidas pelo art. 997, I a IV e VI do CC:

a) *Qualificação dos sócios* - o contrato deverá conter o nome e a qualificação dos sócios, compreendendo esta última, para as pessoas naturais, a nacionalidade, o estado civil e a profissão; e, para as jurídicas, a nacionalidade e sede. Além desses dados, os sócios são qualificados pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso.

b) *Objeto social* - a atividade explorada economicamente pela sociedade deverá ser declarada no contrato social de forma precisa e detalhada.

c) *Nome empresarial* - o contrato social deverá conter o nome empresarial sob o qual girará a sociedade.

d) *Sede* - deverá esclarecer o contrato social qual é o município da sede da sociedade, o local onde, ordinariamente, pode ser encontrado o seu representante legal.

e) *Prazo de duração* - a sociedade pode ser contratada por prazo determinado ou indeterminado, de acordo, exclusivamente, com a manifestação de vontade dos sócios.

f) *Capital social e quotas dos sócios* - o contrato social deverá especificar o capital social da sociedade, bem como o modo e prazo de sua integralização e as cotas pertencentes a cada um dos sócios.

g) *Nomeação do administrador* - cabe ao contrato social estabelecer a representação legal da sociedade, nomeando o seu administrador ou administradores. Certas sociedades contratuais (N/C e C/S) não podem ser representadas por pessoa estranha ao quadro de sócios; mas a limitada pode ser representada por não sócio, nomeado no contrato social ou em ato separado.

Trata-se de cláusulas indispensáveis à regularidade de qualquer sociedade empresária contratual.

Além das cláusulas essenciais, o contrato social deve atender a mais uma formalidade, para fins de obtenção do registro na Junta Comercial: o visto de um advogado, exigido para a validade de todos os

atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas (EOAB, art. 1º, § 2º).

Como exemplo de cláusula contratual accidental, que visa a melhor disciplinar a vida da sociedade, mas cuja ausência não importa irregularidade desta, têm-se a cláusula arbitral (disciplina o modo de escolha de árbitro para decisão das pendências entre os sócios), a cláusula sobre o reembolso (fixa prazos e procedimentos para pagamento ao sócio dissidente de alteração contratual) e a cláusula reguladora dos efeitos da morte de sócio, entre outras.

4. FORMA DO CONTRATO SOCIAL

O contrato social deve ser escrito, mas excepcionalmente o direito admite a forma oral. Cabe a prova da existência da sociedade entre certas pessoas (sócios "de fato") por qualquer modo, inclusive testemunhas, cartas, perícia em contas bancárias (CC, art. 987). Nestes casos, provada a existência de negócios em comum, a sociedade terá sido oralmente contratada entre os sócios "de fato". Claro está que uma sociedade contratada pela forma oral será, inevitavelmente, irregular, porque, faltando o instrumento escrito, o registro do ato constitutivo não é possível.

Atente-se que a prova da existência de sociedade contratada oralmente só pode beneficiar terceiros não sócios. Quer dizer, nas ações judiciais entre os sócios, ou destes contra terceiros, fundadas na existência da sociedade, a exibição de documento escrito é exigência legal (CC, art. 987).

O contrato social poderá ser celebrado, à escolha dos sócios, por instrumento particular (hipótese mais comum) ou por instrumento público lavrado por tabelião (mais rara). Depende, frise-se, exclusivamente da vontade dos sócios. Mesmo que faça parte da sociedade um sócio que não saiba ou não possa assinar, ou haja integralização do capital social com bens imóveis, o contrato social pode instrumentalizar-se pela forma privada. Assim, o instrumento público é dispensável se o sócio que não sabe ou não pode assinar outorgar, por instrumento público, procuração com poderes especiais a mandatário; este, então, firmará o contrato social feito em instrumento particular, em nome daquele sócio. Por sua vez, a dispensa do instrumento público depende de o contrato social descrever o imóvel como exigido para fins de registro imobiliário e conter, sempre que necessária, a outorga do cônjuge (LRE, art. 35, VII).

A forma das alterações contratuais não está vinculada à adotada pelo ato constitutivo (LRE, art. 53). Feito este por escritura pública, poderá ser alterado por instrumento particular e vice-versa.

5. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O ato constitutivo da sociedade empresária pode ser objeto de alteração, de acordo com a vontade dos sócios ou por decisão judicial. Se acaso as regras de convivência adotadas quando da constituição da sociedade não são mais satisfatórias, desde que se observem os requisitos de validade, os pressupostos de existência e as cláusulas essenciais, poderão os sócios livremente alterar as disposições contratuais.

A regra é a de que as deliberações sociais, exceto as que importam alteração contratual, são tomadas por maioria de votos. Salvo em hipóteses excepcionais, que se examinarão em seguida, a vontade majoritária dos sócios é eficaz para decidir os destinos da sociedade.

A maioria societária é definida não em função da quantidade de sócios, mas da participação de cada um deles no capital social. O voto de cada sócio tem o peso proporcional à respectiva cota no capital social. Um único sócio, então, pode representar a maioria societária, desde que a sua cota represente mais da metade do capital social. O número de sócios só importa em caso de desempate. Numa sociedade de três sócios, em que um deles é titular de metade do capital social, ocorrendo divergência entre este e os dois outros, caracteriza-se o empate. Prevalecerá, contudo, a vontade destes, por serem em maior número (dois contra um).

Em caso de não ser possível superar o empate pelo critério de quantidade de sócios, deverá observar-se o disposto no contrato social; se prevista cláusula de arbitragem, os sócios deverão socorrer-se da decisão do árbitro. Omissa o contrato social, caberá ao juiz decidir, no interesse da sociedade, fazendo prevalecer qualquer um dos votos proferidos pelos sócios. De se anotar que não pode o juiz impor uma terceira solução, não cogitada por nenhum dos sócios, como forma de superação do empate.

Quando as deliberações dos sócios importam alterações contratuais, exige-se, na sociedade em nome coletivo e em comandita simples, a unanimidade para mudança de cláusula essencial (CC, art. 999). Se um dos sócios dessas sociedades se manifestar contrariamente à alteração pretendida pelos demais, independentemente da participação societária dele, o contrato social permanece inalterado. Ainda nessas sociedades, a alteração do contrato social em cláusula não essencial pode ser feita pelo voto de sócios que representam mais da metade do capital social.

Se a sociedade é limitada, a alteração contratual pode ser aprovada por sócios que representem três quartos do capital social (CC, arts. 1.071, V, e 1.076, I). Este *quorum* de deliberação é exigido, qualquer que seja a natureza da cláusula em mudança (essencial ou accidental). Os minoritários da limitada com até 25% do capital social devem se submeter à alteração aprovada pela maioria ou exercer o direito de retirada (sendo, neste último caso, reembolsados pelo valor patrimonial de suas quotas).

Anote-se que a lei, ao contrário do que seria o mais desejável, não guardou correspondência entre as hipóteses em que se exige a unanimidade da vontade dos sócios ou *quorum* qualificado de três quartos para eficácia da alteração contratual e as hipóteses em que o registro da alteração pode ser feito com a assinatura apenas do sócio ou sócios representantes da maioria social. Com efeito, são coisas distintas e discerníveis a deliberação da alteração contratual e o registro do respectivo instrumento. Assim, o direito, por vezes, dispensa a assinatura de todos os sócios no instrumento de alteração que só poderia ter sido deliberada pela unanimidade e, também, exige, às vezes, a assinatura de todos os sócios no instrumento de alteração contratual para cuja deliberação é suficiente a maioria qualificada. Uma exigência não interfere na outra.

Para que a alteração contratual seja registrada, independentemente do *quorum* exigido por lei para a sua deliberação, é necessária apenas a assinatura no instrumento respectivo de sócio ou sócios titulares da maioria do capital social. A assinatura de todos os sócios da sociedade contratual somente é exigível se o próprio contrato contiver cláusula restritiva de alteração por simples maioria (LRE, art. 35, VI).

Exemplificativamente, desejando um sócio de sociedade em nome coletivo alterar o seu objeto social, para fins de diversificação da atividade explorada, deverá convencer todos os demais sócios da necessidade ou oportunidade da alteração, posto tratar-se de tema que exige a unanimidade (CC, arts. 999 e 1.040). Mas o instrumento de alteração contratual, que muda o objeto da sociedade, poderá ser arquivado na Junta Comercial com a assinatura apenas do sócio ou sócios majoritários, se não houver

cláusula proibitiva nesse sentido.

6. TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO

Quando um empresário individual considera que unir-se a outro investidor ou empreendedor poderia contribuir para o desenvolvimento de sua empresa, isto é, da atividade econômica que explora empresarialmente, ele terá duas alternativas.

Na primeira, ele constitui uma sociedade empresária com este outro investidor ou empreendedor, transferindo para a nova pessoa jurídica todos os bens afetos à atividade empresarial, bem como os direitos de crédito que titula perante terceiros, a título de integralização do capital social. Em seguida, transfere à sociedade empresária constituída cada dívida (obrigação passiva) que tenha, em razão daquela empresa.

A segunda alternativa consiste em requerer à Junta Comercial a *transformação do registro de* empresário individual em registro de sociedade empresária (CC, art. 968, § 3º). Essa alternativa é mais simples e barata, porque todos os elementos do patrimônio afetado à atividade empresarial, incluindo obrigações passivas, são transmitidas à nova sociedade empresária.

A "transformação de registro" guarda semelhança, mas não se confunde com a "transformação" de um tipo societário em outro (*Cap. 15, item 16*). Na verdade, a "transformação de registro" de empresário individual em registro de sociedade empresária consiste simplesmente em outra modalidade de constituição de alguns tipos societários, assim como a "transformação de registro" de sociedade empresária em registro de empresário individual corresponde a uma modalidade específica de dissolução de alguns tipos societários.

Só as sociedades do tipo limitada em nome coletivo e em comandita podem ser constituídas e dissolvidas por meio de transformação de registro (IN-DNRC n. 112/2010, art. 3º).

Capítulo 11. SÓCIO DA SOCIEDADE CONTRATUAL

1. REGIME JURÍDICO DO SÓCIO DA SOCIEDADE CONTRATUAL

A natureza da situação jurídica do sócio é *suigeneris*, quer dizer, insuscetível de rigorosa sujeição a um regime jurídico próprio ou aproximado de alguma outra figura jurídica, com vistas à definição de parâmetros que auxiliassem a solução das pendências relativas aos seus direitos, deveres e obrigações perante a sociedade. Neste sentido, não se revela correto entendê-lo seja como um proprietário da sociedade empresária (esta, sendo pessoa jurídica, é inapropriável) ou como seu credor (embora tenha direito a participar dos lucros sociais, em caso de falência, o sócio não poderá concorrer à massa, obviamente, se não dispuser de outro título). Desta forma, o sócio submete-se a um regime jurídico que lhe é próprio, composto por um conjunto de obrigações e direitos que a lei e, por vezes, o contrato social lhe reservam.

Na província das obrigações, há que se mencionar duas de índole legal: participar da formação do capital social e das perdas sociais até o limite da correspondente responsabilidade subsidiária, segundo o tipo societário e outras circunstâncias juridicamente relevantes.

O sócio que não cumpre com a sua obrigação de contribuir para a formação do capital social é denominado "remisso". Ao assinar o contrato social, o sócio pode comprometer-se a integralizar a prazo a cota subscrita, fixando-se, no contrato, os vencimentos correspondentes. O atraso no cumprimento desta obrigação, ou seja, a não integralização do prometido dentro dos prazos contratualmente fixados, importa a mora do sócio inadimplente. Deverá, então, indenizar a sociedade dos danos emergentes da mora. Permanecendo inadimplente, os demais sócios poderão optar entre cobrar judicialmente o remisso ou excluí-lo da sociedade. A ação para a cobrança do principal a integralizar, acrescido de juros, poderá adotar a forma executiva e o título será o próprio contrato social, desde que assinado por duas testemunhas. Já para a apuração da indenização devida será necessária ação de conhecimento.

Os demais sócios, no entanto, podem optar pela exclusão do sócio remisso, com diminuição do capital social e restituição das entradas feitas. É também lícito aos demais sócios descontarem, destas entradas, quando da restituição, o crédito da sociedade por juros de mora ou por indenização pelo dano emergente da mora, além de outras prestações contratualmente previstas - por exemplo: correção monetária ou multa. Cabe igualmente a alternativa de redução do valor da quota do remisso ao montante integralizado, reduzindo-se o capital social. Finalmente, se não desejarem que a sociedade sofra qualquer efeito em seu crédito, por força da diminuição do capital social decorrente da exclusão do sócio remisso, e sendo ela limitada, poderão os demais sócios atribuir a si ou a terceiro ou mesmo à própria sociedade, as cotas tomadas do sócio inadimplente (CC, arts. 1.004 e 1.058).

No campo dos direitos, podem ser citados os seguintes:

a) *Participação nos resultados sociais* - os lucros gerados pela sociedade, em função do que for deliberado pela maioria societária, observadas eventuais disposições contratuais pertinentes, terão uma das seguintes destinações: capitalização, constituição de reserva ou distribuição entre os sócios. Nesta última hipótese, cada sócio será credor de parte proporcional à sua participação no capital social, salvo previsão contratual diversa (que só não poderá excluir qualquer dos sócios dos lucros). No término dos negócios sociais, dissolvendo-se a sociedade, terá o sócio o direito de participar do acervo social, na

proporção ainda de sua cota, se solução diversa não houver no contrato social. Outro pressuposto para o exercício do direito de participação nos resultados sociais é a inexistência de débito previdenciário da sociedade, isto porque a sociedade empresária devedora do INSS está legalmente proibida de distribuir lucros (Lei 8.212/91, art. 52; Lei 4.357/64, art. 32).

b) *Administração da sociedade* - o sócio da sociedade contratual tem o direito de intervir na administração da sociedade, participando da escolha do administrador, da definição da estratégia geral dos negócios etc. É claro que a vontade da minoria societária não prevalecerá em confronto com a da maioria, mas é assegurado a todos os sócios o direito de participação nas deliberações sociais.

c) *Fiscalização da administração* - o sócio tem o direito de fiscalizar o andamento dos negócios sociais, especificando a lei duas formas de exercício deste direito: exame, a qualquer tempo ou nas épocas contratualmente estipuladas, dos livros, documentos e do estado de caixa da sociedade (CC, art. 1.021); e prestação de contas aos sócios pelos administradores (CC, art. 1.020), na forma prevista contratualmente ou no término do exercício social.

d) *Direito de retirada* - o sócio pode, em determinadas condições, retirar-se da sociedade, dissolvendo-a parcialmente. Terá, então, direito de receber, do patrimônio líquido da sociedade, a parte equivalente à sua cota do capital social.

Na maioria das sociedades contratuais de prazo indeterminado, o sócio pode retirar-se sem necessidade de motivação. Deverá notificar os demais sócios, os quais devem, em 60 dias, providenciar a alteração contratual correspondente (CC, art. 1.029). Nas contratadas com prazo determinado, somente se houver justa causa comprovada em juízo, poderá o sócio retirar-se antes de vencido o prazo de duração. Em sendo limitada a sociedade com prazo, o direito de retirada surge também quando houver alteração contratual, incorporação ou fusão da qual divirja o sócio (CC, art. 1.077).

No tocante à propriedade dos lucros gerados pela sociedade empresária, há quem defenda a tese de que eles pertencem à pessoa jurídica sempre, sendo as distribuições periódicas meras antecipações daquilo que os sócios teriam direito ao término dos negócios sociais. Os dividendos, assim, seriam simples amortização de investimento. Esta não é, no entanto, a forma predominante de se entender o assunto. Se os lucros sociais pertencessem sempre à sociedade, falindo esta, os sócios responderiam, perante os credores da pessoa jurídica, também pelo que teriam recebido, até a falência, a título de participação nos lucros sociais, o que não acontece. Os lucros sociais pertencem à sociedade até o exato momento em que a maioria societária, deliberando acerca da destinação do resultado, opta por distribuí-lo, total ou parcialmente, entre os sócios. A partir desta deliberação, os sócios são credores da sociedade pelos dividendos correspondentes e poderão cobrá-los, inclusive judicialmente, salvo em caso de falência da sociedade. Os lucros sociais destinados à capitalização ou à constituição de reservas continuarão no patrimônio da sociedade.

O pagamento dos sócios, a título de participação nos lucros sociais, não se confunde com outros tipos de remuneração a que o sócio pode ter direito. Assim, o contrato social poderá destinar um *pro labore* aos que, além da integralização da parte por ele subscrita do capital social, dedicam também trabalho para o desenvolvimento da empresa na função de administrador. Enquanto o lucro remunera o capital investido, e é, por isto, devido mesmo para o sócio que sequer comparece à sede da empresa, o *pro labore* remunera o trabalho despendido pelo sócio. Esta última remuneração, bem como a definição do sócio ou sócios que terão direito a ela, deve constar do contrato social e observar o disposto na legislação tributária.

2. EXCLUSÃO DE SÓCIO

O sócio da sociedade contratual - a regra não se aplica aos de sociedade institucional - pode ser excluído quando ocorrer uma das hipóteses estabelecidas em lei:

a) *Mora na integralização* - quando o sócio deixa de cumprir, nos prazos, com a sua obrigação de integralizar a cota por ele subscrita, os demais sócios poderão, conforme já estudado, optar pela exclusão do sócio (CC, art. 1.004).

b) *Justa causa* - caracterizada pela violação ou falta de cumprimento das obrigações sociais como, por exemplo, no caso de o sócio concorrer com a sociedade empresária, explorando (individualmente ou em outra sociedade) a mesma atividade.

Para a exclusão de um dos sócios, é necessária a ocorrência de alguma destas causas. A exclusão não é, propriamente, assunto de deliberação da sociedade. Não é a sociedade que expulsa o seu sócio. São os demais sócios que, à vista da ocorrência de fato que a lei define como ensejador da expulsão, passam a titularizar o correspondente direito. A efetiva ocorrência de fato dessa natureza é condição inafastável da exclusão. Se inexistiu a causa legalmente prevista, ela não será possível por mera disposição de vontade dos demais sócios.

Outro aspecto de alguma imprecisão doutrinária diz respeito à necessidade de vontade majoritária para deliberação da ocorrência de causa de exclusão. Para certos autores, a exclusão sempre seria de sócio minoritário e corresponderia a direito da maioria societária. Nada mais equivocado, porém, posto que o sócio majoritário também pode ser remisso ou entrar em concorrência com a sociedade; cabe, nestes casos, à minoria societária o direito de exclusão daquele.

Nas sociedades em nome coletivo e em comandita simples, a expulsão do sócio (minoritário ou majoritário) só pode ser extrajudicial, quando fundada na mora do remisso. Se o fundamento é diverso (descumprimento de outras obrigações sociais), a expulsão deve ser sempre judicial (CC, art. 1.030).

Na sociedade limitada, a exclusão de sócio minoritário pode-se operar por simples alteração contratual levada a registro na Junta Comercial, devendo o sócio excluído socorrer-se do Poder Judiciário para provar eventual inoportunidade de causa de exclusão. A exclusão do sócio minoritário por simples alteração contratual somente é cabível se o contrato de sociedade a permitir e houver deliberação em assembleia de sócios, para a qual tenha sido convocado o excluído (CC, art. 1.085). Caso o contrato social não permita a expulsão do sócio minoritário, esta deverá necessariamente ser feita por via judicial.

Já se a hipótese é a de exclusão de sócio majoritário da sociedade limitada, deverão os demais sócios postulá-la perante o Poder Judiciário, cabendo-lhes o ônus da prova da causa de exclusão.

Expulso da sociedade, o sócio terá direito ao valor patrimonial de sua participação societária. Opera-se, em decorrência da expulsão, a dissolução parcial da sociedade, com diminuição do capital social. Se os sócios o desejarem, evidentemente, poderão evitá-la, subscrevendo e integralizando novas cotas.

Capítulo 12. SOCIEDADES CONTRATUAIS MENORES

1. GENERALIDADES

O Código Civil, além da limitada (que será estudada no próximo capítulo), disciplina três outros tipos de sociedades empresárias constituídas por contrato entre os sócios: em nome coletivo (N/C), em comandita simples (C/S), em conta de participação (C/P). Chamaremos estas três sociedades de contratuais menores, tendo em vista sua pouquíssima presença na economia brasileira.

Da sociedade em conta de participação se cuidará em tópico próprio, à vista de suas excepcionais peculiaridades, no quadro do direito societário (item 4).

Acerca das duas outras (N/C e C/S), é possível delimitarem-se certas normas que englobam aspectos comuns aos respectivos tipos. São regras extraídas da disciplina das sociedades simples, que se aplicam subsidiariamente às empresárias:

a) na questão da alienação da participação societária, são sociedades "de pessoas", aplicando-se, em decorrência, o disposto no art. 1.003 do CC, pelo qual a cessão da cota social está condicionada à concordância dos demais sócios. Por outro lado, as suas cotas sociais são impenhoráveis por obrigação individual de sócio;

b) adotam firma na composição do respectivo nome empresarial, o que significa que este também será a assinatura apropriada para a prática de negócio jurídico por parte da sociedade;

c) somente o nome civil de sócio de responsabilidade ilimitada poderá fazer parte da firma. Sócio com responsabilidade não ilimitada, cujo nome civil haja sido aproveitado na composição do nome empresarial da sociedade, responderá ilimitadamente pelas obrigações sociais;

d) somente o sócio com responsabilidade ilimitada pode administrar sociedade. A inobservância desta vedação importa a responsabilidade ilimitada do sócio que exercer a representação legal;

e) somente pessoa natural pode ser sócia com responsabilidade ilimitada. Desse modo, a pessoa jurídica não pode integrar a N/C, nem ser comanditada na C/S.

Tendo-se, assim, presentes estas regras comuns aos dois tipos de sociedades contratuais menores personalizadas do Código Civil, podem ser examinados os aspectos peculiares de cada tipo.

2. SOCIEDADE EM NOME COLETIVO

É o tipo societário em que todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Todos, assim, devem ser pessoas naturais. Qualquer um dos sócios, de outro lado, pode ser nomeado administrador da sociedade e ter seu nome civil aproveitado na composição do nome empresarial. Encontra-se este tipo societário disciplinado nos arts. 1.039 a 1.044 do CC.

Na hipótese de falecimento de sócio, se o contrato social não dispuser a respeito, opera-se a liquidação das quotas do falecido (CC, art. 1.028). Para que os sucessores do sócio morto tenham o direito de ingressar na sociedade, mesmo contra a vontade dos sobreviventes, é indispensável no contrato

social cláusula expressa que o autorize.

3. SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES

É o tipo societário em que um ou alguns dos sócios, denominados "comanditados", têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais, e outros, os sócios "comanditários", respondem limitadamente por essas obrigações. Somente os sócios comanditados podem ser administradores, e o nome empresarial da sociedade só poderá valer-se de seus nomes civis, portanto. Ademais, devem ser necessariamente pessoas naturais. Disciplinam a sociedade em comandita simples os arts. 1.045 a 1.051 do CC.

Os sócios comanditários, que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, estão sujeitos às restrições específicas que lhes reserva a lei: não poderão praticar atos de gestão da sociedade, para se evitar a possibilidade de, agindo em nome dela, serem tomados por administradores e sócio de responsabilidade ilimitada. Poderão, contudo, receber poderes especiais de procurador na realização de negócios determinados.

Os comanditários têm, como os comanditados, direito de participar da distribuição dos lucros proporcionalmente às suas quotas, bem como tomar parte das deliberações sociais e fiscalizar a administração dos negócios da sociedade.

Morrendo sócio comanditado, dá-se a dissolução parcial da sociedade, a menos que o contrato social expressamente estipule o ingresso dos sucessores (CC, art. 1.028, I). Se falecer comanditário, a sociedade, em princípio, não se dissolve. Continuará com os sucessores, aos quais cabe indicar um representante (CC, art. 1.050). Apenas se previsto de modo expreso no contrato, os sobreviventes poderão liquidar as quotas do comanditário falecido. Varia, assim, de acordo com a espécie de sócio falecido, a natureza personalística ou capitalista da sociedade, no tocante as consequências da morte de sócio: entre os comanditados, ela é "de pessoas", salvo se o contrato dispuser em contrário, e, entre os comanditários, é "de capital", a menos que disposto em sentido diverso no contrato.

4. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

A sociedade em conta de participação (CC, arts. 991 a 996) possui características excepcionalmente próprias, no cenário das sociedades do direito brasileiro, seja por sua despersonalização, seja por seu caráter de sociedade secreta.

Quando duas ou mais pessoas se associam para um empreendimento comum, poderão fazê-lo na forma de sociedade em conta de participação, ficando um ou mais sócios em posição ostensiva e outro ou outros em posição oculta (chamam-se estes sócios *participantes*). Por não ter personalidade jurídica, a sociedade em conta de participação não assume em seu nome nenhuma obrigação.

Cabe ao sócio ou aos sócios ostensivos - estes em conjunto ou separadamente - assumir as obrigações da sociedade como obrigação pessoal. E, em se tratando de responsabilidade pessoal, não há que se falar de subsidiariedade ou limitação. Os sócios ostensivos, desta forma, respondem direta e ilimitadamente pelas obrigações que, em nome próprio, assumirem para o desenvolvimento da empresa.

Já os sócios participantes não respondem senão perante os ostensivos e na forma do que houver sido

contratado. Assim, os sócios desta categoria têm responsabilidade limitada ou ilimitada de acordo com o previsto no contrato firmado com o ostensivo.

Os sócios participantes não mantêm qualquer relação jurídica com os credores por obrigações decorrentes da empresa explorada pela C/P. Estes credores devem demandar o sócio ou sócios ostensivos, os quais, em regresso, e nas condições do contrato, poderão voltar-se contra os participantes. Do mesmo modo, os participantes não podem demandar os devedores da sociedade.

Além de despersonalizada, a sociedade em conta de participação é secreta, porque o contrato celebrado entre os sócios (de conjugação de esforços para a exploração de uma empresa) *não* pode ser registrado na Junta Comercial. Se os credores do sócio ostensivo têm eventualmente conhecimento da existência da sociedade em conta de participação, isto não desconstitui o caráter secreto, porque este não decorre do desconhecimento de sua existência pelo meio empresarial, mas da proibição do registro na Junta. Nada impede, por conseguinte, o registro do contrato da conta de participação no Registro de Títulos e Documentos, para melhor resguardo dos interesses dos contratantes, sendo certo que isto não conferirá personalidade jurídica à C/P.

Como sociedade despersonalizada e secreta, não adota nenhum nome empresarial.

Os bens empregados no desenvolvimento da empresa compõem um patrimônio especial. As obrigações pessoais do sócio ostensivo não relacionadas com a C/P não podem ser satisfeitas mediante execução de bens relacionados à C/P, exceto se o credor ignorava a existência da sociedade. Falindo o sócio ostensivo, a conta de participação deve ser liquidada; falindo o participante, os direitos decorrentes do contrato de sociedade em conta de participação podem integrar a massa, segundo as regras dos contratos bilaterais.

Sob o ponto de vista do direito tributário, a C/P é considerada uma sociedade personalizada, equiparada aos demais tipos societários.

São tão peculiares as características da C/P, que melhor seria classificá-la como uma espécie de contrato de investimento, chamado pela lei de "sociedade"; e não como um tipo societário.

Capítulo 13. SOCIEDADE LIMITADA

1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A sociedade limitada é o tipo societário de maior presença na economia brasileira. Introduzida no nosso direito em 1919, ela representa hoje mais de 95% das sociedades empresárias registradas nas Juntas Comerciais. Deve-se o sucesso a duas de suas características: a limitação da responsabilidade dos sócios e a contratualidade. Em razão da primeira, os empreendedores e investidores podem limitar as perdas, em caso de insucesso da empresa. Conforme se examinará à frente, os sócios respondem, em regra, pelo capital social da limitada. Uma vez integralizado todo o capital da sociedade, os credores sociais não poderão executar seus créditos no patrimônio particular dos sócios. Preservam-se os bens deste, assim, em caso de falência da limitada.

A segunda característica que motivou a larga utilização desse tipo societário é a contratualidade. As relações entre os sócios podem pautar-se nas disposições de vontade destes, sem os rigores ou balizamentos próprios do regime legal da sociedade anônima, por exemplo. Sendo a limitada contratual, e não institucional, a margem para negociações entre os sócios é maior.

A sociedade limitada pode ser pluripessoal ou unipessoal. Nesse último caso, é chamada, na lei, de "empresa individual de responsabilidade limitada" (EIRELI). Para fins didáticos, a limitada será estudada, em termos gerais, como uma sociedade pluripessoal. O exame da figura específica da limitada de um único sócio é feito a final (item 8).

A limitada é disciplinada em capítulo próprio do Código Civil (arts. 1.052 a 1.087). Este conjunto de normas, porém, não é suficiente para disciplinar a imensa gama de questões jurídicas relativas ao tipo societário. Outras disposições e diplomas legais, portanto, também se aplicam às sociedades limitadas.

Em princípio, nas omissões do capítulo do Código Civil referente às limitadas, aplicam-se as regras das sociedades simples, também dispostas neste mesmo código (art. 1.053, *caput*). Por exemplo, a regra de desempate nas deliberações sociais. Como a lei não prevê, especificamente para a sociedade limitada, nenhuma norma sobre o assunto, aplica-se o art. 1.010, § 2.º, do CC, que rege o desempate nas deliberações dos sócios das sociedades simples. Quer dizer, empatada a votação feita proporcionalmente ao valor das quotas, o desempate decorrerá da prevalência dos votos do maior número de sócios, independentemente da importância das participações societárias. Persistindo o empate, devem os sócios submeter o assunto à decisão do juiz.

O diploma legal de regência supletiva da limitada pode ser, porém, a lei das sociedades anônimas (LSA). Para isto, é necessário que os sócios contratem neste sentido. Em consequência, se o contrato social contemplar cláusula expressa, determinando a aplicação da lei das sociedades por ações aos casos não regulados no capítulo específico do Código Civil referente às limitadas, o regime das sociedades simples não se aplica. A regra do desempate pelo critério da quantidade de sócios, por exemplo, não existe na legislação das sociedades anônimas. Se o contrato social eleger, de modo expresso, a LSA como o seu regime de regência supletiva, o desempate deverá seguir os procedimentos do art. 129, § 2.º, da LSA: nova assembleia para discutir a questão em, no mínimo, 60 dias e, persistindo o empate, submissão da matéria ao juiz.

Em suma, se o contrato social da limitada é omissivo ou define a disciplina das sociedades simples como seu regime jurídico de aplicação subsidiária, aplicam-se-lhe os arts. 997 a 1.038 do CC, sempre que a matéria não estiver disciplinada nos arts. 1.052 a 1.087 do mesmo Código. Se, porém, os sócios estipularam expressamente no contrato social que o regime de regência supletiva de sua sociedade limitada será o das sociedades anônimas, nas matérias não reguladas pelos arts. 1.052 a 1.087 do CC, aplicam-se as normas da LSA.

A regência supletiva pelas normas das sociedades simples ou das anônimas importa, na verdade, a criação na lei de dois subtipos de limitadas, de que trato mais à frente (item 6).

De se notar que a lei das sociedades por ações, por sua abrangência e superioridade técnica, tem sido aplicada a todos tipos societários, inclusive a limitada, também por via analógica. Quer dizer, sendo o Código Civil lacunoso, poderá o juiz aplicar a LSA, mesmo que o regime de regência supletiva da limitada seja o das sociedades simples. Evidentemente, se o Código Civil não for omissivo, não há que se cogitar de aplicação *analógica* nem da lei das sociedades por ações nem de outra qualquer: neste caso, ou a LSA se aplica *supletivamente* (porque é esta a vontade dos sócios) ou *não se aplica* (porque a matéria está regulada no capítulo referente às sociedades simples). Por exemplo: o direito de os sócios substituírem a sociedade na promoção da responsabilidade judicial de administrador por prejuízo que causara a ela (LSA, art. 159, §§ 3.º e 4.º). Não há previsão nenhuma no Código Civil sobre o assunto, nem no capítulo referente à sociedade limitada nem na disciplina das sociedades simples. Se o contrato social elege a LSA como o diploma de regência subsidiária da limitada, a sua regra de substituição processual tem aplicação supletiva; caso contrário, aplica-se analogicamente.

Por fim, relembre-se que, em razão da natureza contratual das limitadas, a constituição e dissolução de sociedades deste tipo seguem sempre as regras do Código Civil. Mesmo que a regência supletiva seja a da LSA, porque assim quiseram os sócios no contrato social, o regime constitutivo e dissolutório da limitada será o das sociedades contratuais (CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112).

2. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade limitada, como diz o nome do tipo societário, está sujeita a limites. Se os bens do patrimônio social são insuficientes para responderem pelo valor total das dívidas que a sociedade contraiu na exploração da empresa, os credores só poderão responsabilizar os sócios, executando bens de seus patrimônios individuais, até certo montante. Alcançado este, a perda é do credor.

O limite da responsabilidade dos sócios, na sociedade limitada, é o total do capital social subscrito e não integralizado. Capital subscrito é o montante de recursos que os sócios se comprometem a entregar para a formação da sociedade; integralizado é a parte do capital social que eles efetivamente entregam. Assim, ao firmarem o contrato social, os sócios podem estipular que o capital social será de \$ 100, dividido em 100 quotas no valor de \$ 1 cada. Se *Antonio* subscreve 70 quotas e *Benedito*, 30, eles se comprometeram a entregar respectivamente \$ 70 e \$ 30 para a formação da sociedade.

Podem fazê-lo à vista, no ato da constituição, hipótese em que o capital integralizado será igual ao subscrito desde o início da sociedade. Mas, podem fazê-lo a prazo. Imagine que *Antonio* integraliza \$ 50, e assume o compromisso de integralizar o restante de suas quotas em 2 anos, enquanto *Benedito* integraliza os \$ 30 correspondentes às suas quotas no ato da constituição da limitada. No primeiro caso

(integralização à vista), o limite da responsabilidade dos sócios é *zero*; quer dizer, os credores não podem cobrar dos sócios nenhuma obrigação social. No segundo (integralização a prazo por um dos sócios), o limite é \$ 20, já que o capital social subscrito é \$ 100, e o integralizado, \$ 80 (\$ 50 por *Antonio* e \$ 30 por *Benedito*).

Os sócios, na limitada, têm responsabilidade *solidária* pela integralização do capital social. Em decorrência, no exemplo acima, os credores poderão cobrar o que falta à integralização do capital social tanto de *Antonio* como de *Benedito*. Claro que sendo este último responsabilizado pelos \$ 20 devidos por *Antonio*, terá ele direito de regresso contra o sócio titular das quotas não integralizadas.

Em suma, se o contrato social estabelece que o capital está totalmente integralizado, os sócios não têm nenhuma responsabilidade pelas obrigações sociais. Falindo a sociedade, e sendo insuficiente o patrimônio social para liquidação do passivo, a perda será suportada pelos credores.

A limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais pode parecer, à primeira vista, uma regra injusta, mas não é. Como o risco de insucesso é inerente a qualquer atividade empresarial, o direito deve estabelecer mecanismos de limitação de perdas, para estimular empreendedores e investidores à exploração empresarial dos negócios. Se o insucesso de certa empresa pudesse sacrificar a totalidade do patrimônio dos empreendedores e investidores (pondo em risco o seu conforto e de sua família, as reservas para futura educação dos filhos e sossego na velhice), é natural que eles se mostrariam mais reticentes em participar dela. O prejuízo seria de todos nós, já que os bens necessários ou úteis à vida dos homens e mulheres produzem-se em empresas. Lembre-se que assim é porque a Constituição Federal organiza a economia fundando-a na livre iniciativa.

Em suma, a limitação da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é a instrumentalização, no plano da lei ordinária, de uma norma constitucional. Deixar de aplicar a regra da limitação é desrespeitar, de modo reflexo, a própria Constituição.

Por outro lado, quanto maior o risco, maior a perspectiva de rentabilidade que o negócio deve apresentar, para atrair o interesse de empreendedores e investidores. Sem regras limitadoras de perdas e responsabilidade, os lucros empresariais deveriam ser maiores, para compensar o elevado risco de insucesso; em consequência, também seriam maiores os preços dos bens ou serviços adquiridos no mercado pelos consumidores. Se um país não possui direito comercial que ponha limites às perdas dos sócios em pelo menos um dos seus tipos societários, as mercadorias nele produzidas tendem a ser mais caras.

Também não há injustiça na regra da limitação da responsabilidade dos sócios porque os credores, ao negociarem os seus créditos, podem incluir nos preços uma taxa de risco associada à perda decorrente da falência da sociedade. Deste modo, se o banco vai emprestar dinheiro para uma limitada, deve exigir garantias adicionais (fiança ou aval) ou cobrar juros com taxa de risco mais elevada. Falindo a sociedade empresária, executará os bens dos fiadores ou avalistas, ou compensar-se-á do prejuízo pela taxa de risco de inadimplência.

A regra da limitação da responsabilidade dos sócios da sociedade limitada comporta as seguintes exceções, em que eles respondem subsidiária, porém ilimitadamente, pelas obrigações sociais:

a) os sócios que adotarem deliberação contrária à lei ou ao contrato social responderão ilimitadamente pelas obrigações sociais relacionadas à deliberação ilícita. Os sócios que dela

dissentirem deverão acautelar-se, formalizando a discordância, para não serem ilimitadamente responsabilizados (CC, art. 1.080);

b) a Justiça do Trabalho não tem aplicado a regra de limitação da responsabilidade dos sócios, baseando-se no princípio do direito do trabalho de que não se pode transferir ao empregado o risco da empresa;

c) se o sócio fraudar credores manipulando a separação patrimonial, poderá ser responsabilizado ilimitadamente por obrigação da sociedade, em decorrência da teoria da desconsideração da pessoa jurídica (CC, art. 50).

Nestes casos, não vigora a limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Não sendo uma hipótese excepcional das previstas acima, porém, o sócio não poderá ser atingido por obrigação da sociedade, além do limite legal do capital não integralizado.

3. DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Os sócios da sociedade limitada, normalmente, participam do dia a dia da empresa. Comparecem à sede nos dias úteis, inteiram-se dos negócios, controlam o movimento do caixa, conversam uns com os outros. Nesse contato cotidiano com os negócios e demais sócios, eles tomam várias deliberações referentes ao desenvolvimento da sociedade. Dispensa-se qualquer formalidade nesses casos.

Em relação a determinadas matérias, porém, em razão da maior importância para a sociedade e repercussão nos direitos dos sócios e de terceiros, a lei prevê algumas formalidades. São elas: *a)* designação e destituição de administradores; *b)* remuneração dos administradores; *c)* votação das contas anuais dos administradores; *d)* modificação do contrato social; *e)* operações societárias, dissolução e liquidação da sociedade; *f)* expulsão de minoritário.

Se pretenderem tratar de qualquer dessas matérias, os sócios devem reunir-se em *assembleia* e cumprir exigência relativa ao *quorum* deliberativo legalmente previsto para validade da decisão que tomarem.

A assembleia deve ser convocada mediante avisos publicados por três vezes na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de oito dias. A assembleia só poderá deliberar validamente se atenderem à convocação sócio ou sócios titulares de pelo menos três quartos do capital social. Caso não atendido esse *quorum* de instalação, deve-se proceder à segunda convocação, com três outras publicações de avisos e antecedência de cinco dias. Atendidas estas formalidades, a assembleia se instala validamente com qualquer número.

O funcionamento da assembleia deve observar rituais específicos, dirigidos pela mesa (composta por dois sócios, um presidente e o outro secretário), destinados a garantir o exercício do direito de voz e voto a todos os sócios presentes. Ao término dos trabalhos, é redigida ata, que reproduz com fidelidade o ocorrido, com as votações manifestadas e deliberações decorrentes.

É obrigatória a realização de uma assembleia a cada ano, para tomar as contas dos administradores, votar o balanço patrimonial e de resultados e eleger administradores, caso se tenha exaurido o mandato por prazo determinado. Se a sociedade possuir conselho fiscal, os seus membros serão eleitos também nessa oportunidade. É a assembleia anual ou ordinária dos sócios da limitada.

Se a sociedade tem no máximo dez sócios, o contrato social pode prever que as deliberações sobre as matérias indicadas serão adotadas em *reunião de sócios*, e não em assembleia. A diferença entre as duas modalidades de encontro não está só na designação. O contrato social é livre para dispor sobre a periodicidade, convocação, realização e registro da reunião dos sócios. Como diz a lei que as normas sobre a assembleia só se aplicam às reuniões, nas omissões do contrato social, entende-se que este pode disciplinar com ampla liberdade a instalação, funcionamento e assentamento da reunião. Pode prever, por exemplo, que a reunião dos sócios será convocada por mensagem eletrônica e instalada com qualquer número desde logo.

A assembleia ou reunião dos sócios pode sempre ser substituída por documento que explicita a deliberação adotada, desde que assinado pela *totalidade* dos sócios. Sempre que houver consenso entre os sócios relativamente às deliberações sociais que exigem a formalidade da lei, deverá ser menos custoso adotar o documento substitutivo.

A ata da assembleia dos sócios ou da reunião regulada no contrato social, ou, ainda, o documento assinado por todos devem ser levados a arquivamento na Junta Comercial.

Em geral, os sócios deliberam por maioria de votos dos sócios presentes à assembleia ou reunião, computados proporcionalmente ao valor das quotas que titularizam. Quem subscreveu maior parte do capital social, portanto, tem maior poder de interferência nas decisões de interesse da sociedade.

Em certos casos, porém, a maioria do capital social presente ao encontro de sócios não é suficiente para aprovar a matéria, devendo observar-se, então, o *quorum* deliberativo exigido por lei. São estes os casos: a) *unanimidade*, para designar administrador não sócio, se o capital social não está totalmente integralizado (CC, art. 1.061); b) *três quartos do capital social*, para modificação do contrato social, salvo nas matérias sujeitas a *quorum* diferente (arts. 1.071, V, e 1.076, I); c) *três quartos*, para aprovar incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou levantamento da liquidação (arts. 1.071, VI, e 1.076, I); d) *dois terços*, para designar administrador não sócio, se o capital social está totalmente integralizado (art. 1.061); e) *dois terços*, para destituir administrador sócio nomeado no contrato social, se não previsto neste um *quorum* diverso, maior ou menor (art. 1.063, § 1.º); f) *mais da metade do capital*, para designar administrador em ato separado do contrato social (art. 1.076, II); g) *mais da metade do capital*, para destituir administrador sócio designado em ato separado do contrato social (art. 1.076, II); h) *mais da metade do capital*, para destituir administrador não sócio (art. 1.076, II); i) *mais da metade do capital*, para expulsar sócio minoritário se permitido no contrato social (art. 1.085); j) *mais da metade dos presentes à assembleia ou reunião*, para aprovação das contas dos administradores, nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas (arts. 1.071, I e VII, e 1.076, III).

Quando a sociedade limitada é Microempresária ou Empresária de Pequeno Porte, a lei dispensa a realização de qualquer assembleia ou reunião, para a deliberação dos sócios (exceto no caso de expulsão de sócio minoritário, hipótese em que a assembleia ou reunião continuam indispensáveis). Além disso, a lei estabelece que, nas sociedades Microempresárias ou de Pequeno Porte, o *quorum* de deliberação será sempre o da maioria do capital social (Estatuto, art. 70).

4. ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe a uma ou mais pessoas, sócias ou não, designadas no contrato social ou em ato separado. Elas são escolhidas e destituídas pelos sócios, observando-se, em cada caso,

a maioria qualificada exigida por lei para a hipótese (item 3).

O mandato do administrador pode ser por prazo indeterminado ou determinado. O contrato social ou o ato de nomeação em separado definem, para cada administrador ou em termos gerais, se há prazo ou não para o término da função. Na Junta Comercial devem ser arquivados os atos de condução, recondução e cessação do exercício do cargo de administrador. Em caso de renúncia, que deve ser feita por escrito, o ato só produz efeitos em relação a terceiros, após arquivamento na Junta Comercial e publicação, mas, para a sociedade, é eficaz desde o momento em que dele tomou conhecimento.

Os administradores devem, anualmente, prestar contas aos sócios reunidos em assembleia anual (ou por outro modo previsto no contrato social). Junto com as contas, apresentarão aos sócios os balanços patrimoniais e de resultados que a sociedade limitada, na condição de empresária, é obrigada a levantar. O prazo para estas providências é de quatro meses seguintes ao término do exercício social.

No tocante aos débitos da sociedade enquadráveis como dívida ativa, de natureza tributária ou não tributária (Lei 6.830/80, art. 2.º), os administradores, sócios ou não, respondem por inadimplemento da sociedade limitada. É o que dispõe o art. 135, III, do CTN. Sendo ato administrativo e, portanto, presumivelmente verdadeiro, a Certidão da Dívida Ativa emitida contra a sociedade pode ser executada diretamente no patrimônio particular do administrador, a quem cabe demonstrar, por embargos do devedor, que o inadimplemento não teria importado descumprimento de lei ou contrato.

Quando a sociedade limitada está sujeita à regência supletiva do regime das sociedades simples, ela não responde pelos atos praticados em seu nome que forem evidentemente estranhos ao objeto social ou aos negócios que ela costuma desenvolver (CC, art. 1.015, parágrafo único, III). É a primeira manifestação, no direito positivo brasileiro, da teoria *ultra vires* (que, aliás, não é mais adotada em nenhum outro lugar no mundo, nem mesmo na Inglaterra, onde nasceu há mais de um século). Por esta teoria, a pessoa jurídica só responde pelos atos praticados em seu nome, quando compatíveis com o seu objeto. Se estranho às finalidades da pessoa jurídica, o ato deve ser imputado à pessoa natural que agiu em nome dela. Quando a sociedade limitada estiver sujeita à regência supletiva do regime das anônimas (porque assim previsto em contrato social), ela responderá por todos os atos praticados em seu nome, podendo, por certo, ressarcir-se dos prejuízos em regresso contra o administrador que excedeu os poderes.

5. CONSELHO FISCAL

O contrato social pode prever a instalação e funcionamento do conselho fiscal na limitada. Este órgão só se justifica nas sociedades em que houver número significativo de sócios afastados do cotidiano da empresa. Na generalidade das limitadas, não deve ser conveniente ou economicamente justificável sua instalação e funcionamento.

O conselho será composto por, no mínimo, três membros efetivos e respectivos suplentes, que podem ser sócios ou não. Há impedimento para os membros da administração da própria sociedade ou de outra, por ela controlada, empregados de ambas ou dos respectivos administradores, bem assim os cônjuges ou parentes até terceiro grau destes. O impedimento visa garantir a isenção dos fiscais no exercício de suas funções. O empregado está forçosamente subordinado ao administrador e não tem independência para fiscalizá-lo. O cônjuge pode ter interesse pessoal em ocultar irregularidades, e assim por diante. Para que o instrumento de fiscalização seja eficiente, a isenção do conselho fiscal deve ser completa.

Os membros do conselho fiscal serão escolhidos na assembleia anual (ou em reunião, se prevista em contrato social) pelo voto da maioria dos sócios presentes. A lei assegura aos que dissentirem dos fiscais escolhidos pela maioria o direito de eleger, em separado, um membro e respectivo suplente, desde que titularizem pelo menos um quinto do capital social. Se houver mais de um dissidente com quotas representando individualmente 20% ou mais do capital, cada um elegerá em separado o seu representante. Se dois ou mais minoritários possuírem juntos no mínimo um quinto do capital, poderão escolher um representante deles, caso discordem do conselho constituído pelos majoritários. Em qualquer caso de eleição segregada, o número de fiscais será aumentado para acomodar os eleitos pela maioria e pelos minoritários dissidentes.

O fiscal pode exercer suas funções individualmente, mas responde por abuso dos poderes de que está investido. O conselho poderá escolher, para auxiliá-lo no exame de livros, contas e demonstrativos, um contabilista, cuja remuneração será aprovada pelos sócios, em assembleia.

6. AS DUAS LIMITADAS

Pode-se dizer que, no Brasil, há dois subtipos de sociedade limitada, porque os sócios podem escolher entre dois diferentes regimes de regência supletiva (CC, art. 1.053 e parágrafo único).

Em outros termos, o Capítulo do Código Civil sobre sociedades limitadas (Parte Especial, Livro II, Título II, Subtítulo II, Capítulo IV) possui diversas lacunas. Não disciplina, por exemplo, o direito de retirada imotivado nas sociedades sem prazo, as consequências da morte de sócio, a distribuição do resultado e outros temas societários de real importância. Nestas matérias, a respeito das quais o Capítulo do CC sobre sociedade limitada é omissa, este tipo societário pode ser regido por dois diferentes conjuntos de normas legais: o correspondente ao Capítulo do CC sobre as sociedades simples (Parte Especial, Livro II, Título II, Subtítulo II, Capítulo I) ou à LSA.

A sujeição a um ou a outro regime de regência supletiva depende do que estiver previsto no contrato social; ou seja, depende do que os sócios contrataram. Se o contrato social for omissa quanto ao regime de regência supletiva ou eleger o das sociedades simples, naquelas matérias em que o Capítulo do CC sobre sociedade limitada for omissa, aplicam-se as regras do Capítulo do CC sobre sociedades simples. Caso o contrato social eleja como regime de regência supletiva o da sociedade anônima, naquelas matérias, a sociedade limitada sujeitar-se-á às normas da LSA.

Existem, assim, duas limitadas; ou melhor, dois subtipos de sociedades limitadas: *a)* o das sociedades limitadas sujeitas ao regime de regência supletiva das sociedades simples (subtipo I); *b)* o das sujeitas ao regime de regência supletiva das sociedades anônimas (subtipo II).

As sociedades do primeiro subtipo são limitadas de vínculo instável; as do segundo, limitadas de vínculo estável. Assim é em razão da mais relevante diferença entre os dois subtipos: o direito de retirada imotivada nas sociedades sem prazo. A existência deste direito nas limitadas de subtipo I faz com que o sócio possa, a qualquer momento e independente de motivação, sair da sociedade e requerer a apuração dos seus haveres; isto torna o vínculo entre os sócios, neste subtipo societário, mais instável do que o do outro subtipo, em que a retirada imotivada não é cabível.

As sociedades limitadas sujeitas à regência supletiva do Capítulo do CC sobre sociedades simples estabelecem entre os sócios um vínculo instável, que pode ser rompido com maior facilidade. Isto, em

função das hipóteses em que é cabível a *dissolução parcial* (ou, no dizer do CC, a resolução da sociedade em relação a um sócio), que estudaremos no próximo capítulo.

Nas sociedades do subtipo I, a dissolução parcial cabe em cinco casos: *a)* morte de sócio (CC, art. 1.028, *caput*); *b)* liquidação de quotas a pedido de credor de sócio (CC, art. 1.026); *c)* retirada motivada (CC, arts. 1.077 e 1.029, parte final); *d)* retirada imotivada (CC, art. 1.029, primeira parte); *e)* expulsão de sócio (CC, art. 1.085). Já na sociedade limitada de subtipo II, só cabe a dissolução parcial em duas hipóteses: retirada motivada e expulsão.

Não cabe, assim, a dissolução parcial do subtipo estável de sociedade pela vontade unilateral do sócio (retirada imotivada), nem a pedido de credor deste (liquidação de quota) ou por falecimento de qualquer um deles. Nela, o vínculo entre os integrantes da sociedade é mais estável porque não pode ser desfeito com tanta facilidade. Aproxima-se a estabilidade do vínculo dos sócios de limitada de subtipo II da do vínculo entre acionistas da sociedade anônima, embora neste último tipo ele seja ainda mais estável (já que não existe a hipótese de expulsão de acionista minoritário).

Além desta principal diferença entre os dois subtipos de limitada, três outras devem ser apontadas:

a) Desempate - Nas sociedades limitadas com vínculo societário instável, o desempate é feito, inicialmente, segundo o critério da quantidade de sócios (CC, art. 1.010, § 2.º). Apenas permanecendo o empate após a aplicação deste critério, caberá ao juiz desempatar a matéria. Já nas sociedades limitadas com vínculo societário estável, não há o critério de desempate pela quantidade de sócios. Prevalecerá, nestas, sempre a quantidade de quotas de cada sócio. Assim, empatada a deliberação, tenta-se o desempate em nova assembleia geral a se realizar com pelo menos 60 dias de intervalo; continuando o impasse, e não prevendo o estatuto a arbitragem, nem os sócios elegendo terceiro a quem encomendar a decisão, caberá ao juiz desempatar no interesse da sociedade (LSA, art. 129, § 2.º).

b) Destinação do resultado - Nas sociedades limitadas com vínculo societário instável, a maioria dos sócios delibera sobre a destinação do resultado, podendo livremente decidir pelo reinvestimento da totalidade dos lucros gerados ou pela distribuição de todo o resultado. Isto porque, nas normas de regência da sociedade simples, não estabelece a lei nenhuma obrigatoriedade de distribuição mínima de parte dos lucros entre os sócios ou de apropriação de reservas. Já as sociedades limitadas com vínculo societário estável devem prever, no contrato social, o percentual mínimo dos lucros sociais a ser distribuído anualmente entre os sócios. Caso seja omissa o instrumento contratual, pelo menos metade do lucro líquido ajustado deve obrigatoriamente ser distribuído entre os sócios como participação nos lucros (LSA, art. 202). Este é o piso, já que integra a distribuição obrigatória toda parcela do resultado que não for apropriado numa das reservas previstas em lei ou no contrato social.

c) Vinculação a atos estranhos ao objeto social - A sociedade limitada com vínculo instável, por se submeter ao art. 1.015, parágrafo único, III, do CC (regra constante do Capítulo das sociedades simples), não se vincula aos atos praticados em seu nome pelo administrador quando se tratar de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Trata-se de norma inspirada na vetusta teoria dos atos *ultra vires*. Já a sociedade limitada com vínculo estável, não se submetendo ao dispositivo referido, vincula-se a todos os atos praticados em seu nome por seus administradores, ainda que estranhos ao objeto social.

7. Sociedades Limitadas de Grande Porte

A sociedade empresária é classificada como "de grande porte" quando possui ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 ou receita bruta anual acima de R\$ 300.000.000,00 (Lei 11.638/2007, art. 3.º, parágrafo único). Se alcançar uma ou outra cifra num determinado exercício, a sociedade limitada passa a ser considerada "de grande porte" no subsequente.

Nesse caso, a sociedade limitada submete-se às mesmas regras que a lei fixa para a sociedade anônima relativamente à escrituração e elaboração das demonstrações financeiras. Vale dizer, ela fica obrigada a escriturar seus livros mercantis seguindo o regime de competência, não podendo usar mais o regime de caixa enquanto se classificar dessa maneira (LSA, art. 177). Além disso, ao término do exercício, a sociedade limitada de grande porte deve levantar as mesmas demonstrações financeiras a que se obrigam as companhias fechadas em geral, quais sejam: *balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do resultado do exercício* (art. 176, I a III). Por fim, caso o patrimônio líquido da sociedade limitada de grande porte seja de pelo menos R\$ 2.000.000.000,00, fica obrigada a levantar, também, a *demonstração de fluxos de caixa* (art. 176, § 6.º).

Nenhuma outra exigência reservada pela lei às sociedades anônimas se estende às limitadas de grande porte, em razão de sua classificação nessa categoria. A publicação das demonstrações financeiras ou o seu registro na Junta Comercial, por exemplo, não é legalmente exigida das sociedades limitadas, nem mesmo quando classificadas como "de grande porte". A exemplo do regime jurídico aplicável à generalidade das sociedades limitadas, as demonstrações contábeis são documentos internos, destinados exclusivamente aos sócios.

8. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (EIRELI)

A sociedade limitada unipessoal foi chamada, na lei brasileira, de *empresa individual de responsabilidade limitada* (EIRELI). A designação é infeliz, já que empresa é, tecnicamente, uma atividade, e não um sujeito de direito. Apesar disso, deve-se comemorar a introdução do instituto no nosso direito, em 2012, que representou um grande avanço. A maioria dos países já admite a sociedade limitada unipessoal há tempos, e a EIRELI tirou o nosso atraso na matéria.

São normas específicas da sociedade limitada unipessoal:

1ª) Na formação do nome empresarial, seja firma ou denominação, em vez da locução "limitada", deve-se acrescentar a sigla EIRELI;

2ª) O capital social deve ser de pelo menos 100 salários mínimos;

3ª) O capital social deve estar totalmente integralizado na constituição - significa dizer que, não havendo a hipótese de capital subscrito não integralizado, os credores nunca poderão, em caso de falência, demandar a responsabilização do único sócio da EIRELI em seu patrimônio pessoal;

4ª) Se o único sócio da EIRELI for uma pessoa natural, ela não poderá participar de outra sociedade unipessoal, mas poderá, porque não há proibição na lei, ser sócio de limitadas pluripessoais ou mesmo de sociedades de tipo diverso;

5ª) A EIRELI, como qualquer sociedade limitada, pode ser constituída pela assinatura, por seu único sócio, do ato constitutivo (CC, art. 980-A, *caput*) ou mediante transformação de registro de empresário individual (art. 968, § 3.º); mas poderá, também, ser constituída pela concentração das quotas sob a

titularidade de uma só pessoa (art. 980-A, § 3.º), como, por exemplo, no caso de falecer um de dois sócios, sendo o sobrevivente o herdeiro universal do falecido.

A lei não precisaria dispor a respeito, já que decorre naturalmente do direito das obrigações vigentes, mas se preocupou em esclarecer que a EIRELI pode receber, em cessão, direitos patrimoniais de autor ou de imagem, *inclusive* os titulados por seu único sócio. O famoso jogador de futebol pode, nesse sentido, constituir uma sociedade limitada unipessoal para fins de explorar economicamente sua imagem.

Tirante essas regras específicas, a EIRELI, como sociedade limitada que é, submete-se às regras deste tipo societário (CC, art. 980-A, § 6.º).

Capítulo 14. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONTRATUAL

1. INTRODUÇÃO

Dissolução é conceito que pode ser utilizado em dois sentidos diferentes: para compreender todo o processo de término da personalidade jurídica da sociedade empresária (sentido largo) ou para individuar o ato específico que desencadeia este processo ou que importa a desvinculação de um dos sócios (sentido estrito). Para contornar as dificuldades relacionadas à utilização de uma expressão única para identificação de dois institutos jurídicos distintos, não se fará aqui uso do conceito de dissolução senão em seu sentido estrito, reservando-se para designação do processo abrangido pelo seu sentido largo o termo "extinção".

Extinção é, aqui, entendida como o processo de término da personalidade jurídica da sociedade empresária, sendo a dissolução o ato que o desencadeia ou que desvincula da sociedade um dos sócios (para outros autores, "extinção" tem sentido diverso: é a consequência da dissolução em sentido largo).

A dissolução (sentido estrito) opera o desfazimento do ato constitutivo da sociedade empresária. Difere-se, como já visto, da invalidação e da ineficácia do referido ato (*Cap. 10*).

As sociedades se classificam em contratuais ou institucionais de acordo com o regime constitutivo e dissolutório a que se encontram submetidas. No presente capítulo, a atenção estará centrada na dissolução da sociedade contratual, postergando-se a da sociedade institucional para o momento oportuno (*Cap. 15*, item 15).

2. ESPÉCIES DE DISSOLUÇÃO

A tendência atual do direito comercial, no que diz respeito às questões envolvendo os sócios, é a de procurar preservar a empresa. Em razão dos múltiplos interesses que gravitam em torno da produção e circulação de bens e serviços, reservadas à empresa pela ordem constitucional, a sua existência e desenvolvimento deixa de ser assunto da exclusiva alçada dos investidores e empreendedores, seus sócios. Os mecanismos legais voltados ao reerguimento econômico da empresa insolvente, que o legislador instituiu na LF, têm o objetivo de atender a tais interesses. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, por sua vez, possibilita a coibição de fraudes perpetradas por meio da separação patrimonial sem comprometimento da exploração da atividade econômica a cargo da sociedade desconsiderada. São estes exemplos de penetração, no campo do direito comercial, do princípio da preservação da empresa.

Em decorrência deste princípio, considera-se que os assuntos particulares dos sócios, seus atos ilícitos, sua inaptidão para a vida de empreendedor, seus desentendimentos, devem ser equacionados e solucionados juridicamente com o mínimo de comprometimento da atividade econômica explorada pela sociedade. Este princípio, o da preservação da empresa, não pode ser ignorado, nos dias correntes, no estudo de qualquer questão de direito societário. Assim é, também, na dissolução.

Dentro desse quadro, é que a doutrina e jurisprudência, antes da entrada em vigor do Código Civil, criaram um instituto então ignorado pelo legislador e, aparentemente, paradoxal: a dissolução parcial da sociedade.

Quando os conflitos entre os sócios, ou entre estes e os sucessores de um deles, impossibilitam a preservação dos laços contratuais, deve-se tentar a compatibilização entre o fim destes laços e a continuidade da sociedade empresária ou, pelo menos, da empresa explorada. A dissolução, assim, não será da pessoa jurídica propriamente, mas dos vínculos contratuais que a originaram. Se houver dissolução de apenas parte destes vínculos, permanecendo a sociedade por força dos demais não dissolvidos, estar-se-á diante da dissolução *parcial*. Se, ao revés, dissolveram-se todos os vínculos contratuais e, por isso, a sociedade deixar de existir, então será o caso de dissolução *total*. Mas embora sejam os vínculos contratuais a se dissolverem, em parte ou totalmente, é costume, para simplificação, falar-se em dissolução da *sociedade*. Uma abreviação útil, que pode ser prestigiada.

Portanto, de acordo com a abrangência, tem-se dissolução total ou parcial. No Código Civil a *dissolução parcial* é chamada de *resolução da sociedade em relação a um sócio* (arts. 1.028 a 1.032, 1.085 e 1.086).

Além deste critério de classificação da dissolução, ela se distingue em judicial ou extrajudicial, de acordo com a natureza do ato dissolutório. Se a dissolução operou-se por deliberação dos sócios registrada em ata, distrato (quando total) ou alteração contratual (quando parcial), será a hipótese de dissolução extrajudicial; já, se ela se operou por sentença (em qualquer das duas extensões), será dissolução judicial.

A separação entre dissolução judicial e extrajudicial *não* tem em vista a causa que a operou, mas o instrumento da operação. Entenda-se: nem toda a dissolução extrajudicial tem por causa a vontade dos sócios, embora toda a dissolução causada pela vontade dos sócios seja extrajudicial. Com efeito, se a causa é, por exemplo, a inexecutibilidade do objeto social, pode ocorrer a dissolução judicial ou extrajudicialmente. No primeiro caso, se todos os sócios concordarem quanto à efetiva ocorrência da causa dissolutória, e no segundo, se um deles não concordar com a ocorrência e, então, negar-se a firmar o distrato, obrigando os demais a se socorrerem do Judiciário. Não foi a vontade dos sócios que deu causa à dissolução, mas a inexecutibilidade do objeto social, embora a concordância de todos quanto à efetiva ocorrência desta causa seja pressuposto inafastável da dissolução extrajudicial.

Os critérios de classificação de interesse do direito comercial, em síntese, são os que resultam na distinção entre dissolução total ou parcial, de um lado, e judicial ou extrajudicial, de outro.

3. CAUSAS DE DISSOLUÇÃO TOTAL

A dissolução de todos os vínculos que deram origem a uma sociedade contratual pode ser causada pelos seguintes fatores: *a)* vontade dos sócios (CC, art. 1.033, II e III); *b)* decurso do prazo determinado de duração (art. 1.033, I); *c)* falência (arts. 1.044, 1.051 e 1.087); *d)* exaurimento do objeto social (art. 1.034, II); *e)* inexecutibilidade do objeto social (art. 1.034, II); *f)* unipessoalidade por mais de 180 dias (art. 1.033, IV); *g)* causas contratuais (art. 1.035).

Para que se opere a dissolução total da sociedade contratual por vontade dos sócios, tendo sido ela contratada por prazo determinado, é necessária a unanimidade. Não basta, neste caso, apenas a maioria societária desejar para que a sociedade se dissolva. Nascida da vontade de todos os sócios, é possível a sua dissolução antes do prazo anteriormente acertado entre eles, desde que pela manifestação de vontade de todos os sócios. Se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, a vontade do sócio ou sócios representantes de mais da metade do capital social é suficiente para deliberar a dissolução. Neste último

caso, porém, a jurisprudência tem reconhecido, à luz do princípio da preservação da empresa, que um único sócio, ainda que minoritário, tem o direito de continuar a sociedade - admitindo nela outro sócio. A eficácia da dissolução da sociedade sem prazo por vontade da maioria pode, assim, ser questionada em juízo pelo minoritário dissidente.

O instrumento de distrato ou a ata da assembleia ou reunião em que a dissolução foi aprovada deverá declarar as importâncias repartidas entre os sócios e indicar a pessoa ou pessoas responsáveis pelo ativo e passivo social remanescente, bem como informar os motivos da dissolução.

Em razão do quórum do art. 1.076, I, do CC, as Juntas devem registrar o distrato assinado apenas pelo sócio ou sócios que representam pelo menos três quartos (3/4) do capital social. Contudo, o Judiciário tem reconhecido o direito de qualquer um dos sócios continuar explorando a empresa, de forma que o minoritário pode desconstituir aquele registro, em juízo, se quiser manter a empresa em funcionamento.

O decurso do prazo determinado de duração da sociedade contratual é também causa de dissolução. Os sócios podem concordar quanto ao decurso e firmar distrato, operando-se a dissolução extrajudicial. Se, no entanto, um dos sócios entender que não decorreu o prazo de duração da sociedade, e negar-se a firmar o distrato, os demais terão que recorrer ao Judiciário, para pleitear a dissolução judicial.

Se o prazo determinado de duração transcorrer e a sociedade não entrar em liquidação, considera a lei que ela foi prorrogada por tempo indeterminado, a menos que haja oposição de um sócio. A sociedade, contudo, não estará em situação regular e, embora não deva se dissolver, ficará sujeita à aplicação analógica das regras da sociedade em comum. Tanto a exploração da atividade *antes* do registro na Junta Comercial como a *posterior* ao encerramento do prazo de duração constante deste são irregulares. Para a continuidade da sociedade, em situação regular, é necessário o registro de alteração contratual prorrogando o prazo de sua duração, antes da fluência deste. Não é permitido o registro de prorrogação após o vencimento do prazo de duração (LRE, art. 35, IV).

Desse modo, a sociedade contratada por tempo determinado e não prorrogada em tempo útil se transforma em sociedade irregular caso continue a explorar a atividade empresarial a que se dedica. Mas há autores (Egberto Lacerda Teixeira, por exemplo) que consideram excessiva a sanção imposta à sociedade e aos sócios, de acordo com essa solução. Para eles, não seria correto equiparar a sociedade irregular àquela que, tendo sido regular, não foi tempestivamente prorrogada.

Para que tenha validade, a prorrogação deve ser decidida pela unanimidade dos sócios, porque somente por manifestação de vontade pode o sócio continuar vinculado contratualmente aos demais, após o decurso do prazo de duração do contrato originário. Não poderá haver prorrogação contra a vontade de um dos sócios, sendo-lhe possível solicitar a dissolução da sociedade em juízo.

A falência é outra causa de dissolução total da sociedade empresária. Trata-se de hipótese de dissolução necessariamente judicial, cuja caracterização e processamento são específicos, disciplinados por legislação própria. A falência do sócio da sociedade contratual, não é causa de dissolução total, como já foi no passado. Sendo sócio e sociedade pessoas distintas, não há por que dissolver esta em razão da falência daquele. As quotas sociais de titularidade do falido serão liquidadas ou arrecadadas pela massa e o valor apurado com sua liquidação ou alienação judicial servirá à satisfação dos credores admitidos.

Também é causa de dissolução total da sociedade contratual o exaurimento do objeto social. Trata-se de hipótese rara em que a sociedade é contratada exclusivamente para realizar uma determinada obra, operação ou serviço. Uma vez atendido o seu objetivo determinado, não há mais razão para continuar a pessoa jurídica.

A inexecuibilidade do objeto social (CC, art. 1.034, II, *in fine*) ocorre nos seguintes casos: *a*) inexistência de mercado para o produto ou serviço fornecido pela sociedade (falta de interesse dos consumidores); *b*) insuficiência do capital social para produzir ou circular o bem ou serviço referido como objeto no contrato social; *c*) a grave desinteligência entre os sócios, que impossibilite a continuidade de negócios comuns.

A unipessoalidade pode ser causa de dissolução total da sociedade empresária contratual. Sempre que, por alguma razão (sucessão por ato *inter vivos* ou *mortis causa* na titularidade das cotas sociais, dissolução parcial etc), todas as cotas representativas do capital social de sociedade contratual forem reunidas sob a titularidade de uma só pessoa, natural ou jurídica, e ela não requerer, na Junta Comercial, a transformação do registro em empresário individual ou EIRELI, a sociedade deverá ser dissolvida.

A dissolução não é imediata, assegurando-se ao sócio único o prazo de 180 dias para negociar o ingresso de mais uma pessoa na sociedade visando o restabelecimento da pluralidade de sócios. Vencido este prazo, sem o restabelecimento da pluralidade de sócios nem a transformação do registro, a sociedade contratual deve ser totalmente dissolvida.

Além destas causas, o próprio contrato social poderá prever outras, relacionadas com a particularidade do negócio ou da vontade dos sócios, por exemplo: não realização de um lucro mínimo, redução do número de sócios a limites prefixados etc.

4. CAUSAS DE DISSOLUÇÃO PARCIAL

A dissolução parcial da sociedade (ou como chama o Código Civil, a "*resolução da sociedade em relação a um sócio*") pode ser causada por: *a*) vontade dos sócios; *b*) morte de sócio; *c*) retirada de sócio; *d*) exclusão de sócio; *e*) falência de sócio; *f*) liquidação da quota a pedido de credor de sócio.

Por deliberação dos sócios, pode ser promovida a dissolução parcial da sociedade, com a saída de um deles, apurando-se os respectivos haveres. Não costuma haver conflitos entre os interessados, nesse caso. Estando todos de acordo com a dissolução parcial, o sócio que deixa a sociedade fica satisfeito com o valor recebido pela sua antiga participação e os que nela permanecem consideram este valor adequado.

Quando morre sócio de sociedade contratual, os seus sucessores (herdeiros ou legatários) não estão, em nenhuma hipótese, obrigados a ingressarem na sociedade. Eles podem requerer a dissolução parcial para receberem o valor da participação societária. Claro, Se os sucessores do sócio morto desejarem ingressar na sociedade (e, se esta for "de pessoas", nenhum dos sócios sobreviventes se opuser), não há nenhuma razão para a dissolução parcial. Nem mesmo eventual cláusula contratual dissolutória poderá impedir a continuidade da sociedade, se esta for a vontade dos interessados (sucessores e sócios sobreviventes).

A dissolução parcial é a solução jurídica que busca compatibilizar os interesses conflitantes dos sucessores de sócio morto que não desejam ingressar na sociedade ou de sócio sobrevivente, em

sociedade "de pessoa", que veta o ingresso deles. Mas inexistindo o conflito de interesses, a sociedade deve permanecer, com a cota do *de cujus* transferida a quem o suceder. O falecimento de sócio é causa de dissolução judicial, se não houver concordância entre as partes quanto à ocorrência de causa dissolutória (por exemplo, os sócios supérstites recusarem-se a proceder à apuração dos haveres), ou extrajudicial, quando houver essa concordância entre as partes.

A retirada de sócio também é causa de dissolução parcial da sociedade. Relembrando, este é direito que o sócio pode acionar a qualquer tempo, se a sociedade de que participa é contratada com prazo indeterminado. A retirada, neste caso, fica condicionada apenas à notificação aos demais sócios, com prazo de 60 dias, para que se providencie a alteração contratual. Quando a sociedade é contratada por prazo determinado, o sócio só tem direito de retirada provando justa causa em juízo ou, se for do tipo limitada, dissentindo de alteração contratual, incorporação ou fusão deliberadas pela maioria. Poderá operar-se judicial ou extrajudicialmente, exceto na hipótese de retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado, em que será necessariamente judicial a dissolução.

A exclusão de sócio, conforme já visto (*Cap. 11*, item 2), é causa de dissolução parcial. Quando tem por causa a exclusão de sócio, a dissolução pode ser judicial ou extrajudicial, em função de variáveis diversas. Se a exclusão é de sócio remisso, pode-se fazê-la extrajudicialmente em qualquer tipo de sociedade contratual (CC, art. 1.004). Se é motivada por falta grave no cumprimento de obrigação societária ou incapacidade superveniente, a dissolução será necessariamente judicial, em qualquer tipo de sociedade contratual (art. 1.030). Por fim, se a motivação é a prática por minoritários de atos graves, que põem em risco a continuidade da empresa, e sendo a sociedade limitada, a dissolução parcial poderá ser extrajudicial (deliberada em assembleia e formalizada em alteração contratual), se o contrato social expressamente o permitir; se omissão, será judicial (art. 1.085).

A falência de sócio também dá ensejo à dissolução parcial da sociedade contratual, uma vez que a lei, nesse caso, determina a apuração dos haveres do falido para pagamento à massa (CC, art. 1.030, parágrafo único).

Por fim, estabelece a lei que o credor do sócio pode pleitear na execução que promove para receber seu crédito, à falta de outros bens do executado, a liquidação da quota que este titulariza numa sociedade. Neste caso, o valor será apurado com base num balanço patrimonial especial, para ser depositado em dinheiro, pela sociedade, no juízo da execução nos 90 dias seguintes (CC, art. 1.026, parágrafo único). É uma alternativa que se abre ao credor do sócio relativamente à penhora das quotas sociais.

Estas causas de dissolução parcial não se aplicam a todas as sociedades contratuais. Se a sociedade limitada estiver sujeita à regência supletiva da LSA, ela só se dissolve parcialmente nas hipóteses de retirada motivada (dissidência em relação a alteração contratual, fusão ou incorporação da sociedade) ou expulsão.

5. LIQUIDAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES

À dissolução total seguem-se a *liquidação* e a *partilha*, enquanto à dissolução parcial segue-se a *apuração de haveres* e o *reembolso*. Entre uma e outra forma de dissolução não há, nem pode haver, qualquer diferença de conteúdo econômico. Quer dizer, o sócio deve receber, na dissolução parcial, a título de reembolso o mesmo valor que receberia, na dissolução total, a título de quota na partilha.

O objetivo da liquidação é a realização do ativo e o pagamento do passivo da sociedade. Poderá processar-se judicial ou extrajudicialmente, independentemente da forma assumida pela dissolução. Com efeito, os sócios podem não concordar com a ocorrência de causa dissolutória, forçando a dissolução judicial, mas podem estar concordes com a forma de se levar a cabo a liquidação, que será extrajudicial; como podem concordar com a ocorrência de causa dissolutória, firmando o respectivo distrato, mas não chegar a acordo quanto à liquidação, socorrendo-se, então, do Judiciário.

Durante a liquidação, a sociedade empresária sofre restrição em sua personalidade jurídica, estando autorizada apenas à prática dos atos tendentes à solução de suas pendências obrigacionais. Nesse período, o órgão responsável pela manifestação da vontade da pessoa jurídica não será mais o administrador, e sim o liquidante. Além disso, deverá aditar ao seu nome empresarial a expressão "em liquidação" (CC, art. 1.103 e parágrafo único).

Realizado o ativo e pago o passivo, o patrimônio líquido remanescente será partilhado entre os sócios, proporcionalmente à participação de cada um no capital social, se outra razão não houver sido acordada no contrato social ou em ato posterior. Concluída a partilha, encerra-se o processo de extinção da sociedade empresária, com a perda de sua personalidade jurídica.

Fran Martins defende que ainda há uma derradeira fase no processo extintivo, consistente no decurso do prazo prescricional das obrigações da sociedade dissolvida. Entende a maioria da doutrina, contudo, que essa lição não seria de todo acertada. Se a liquidação não foi completa e regular a ponto de restar pendente uma ou mais obrigações, isto não é ato imputável à sociedade, mas aos sócios e ao liquidante, que responderão, pessoalmente, pelos atos da liquidação irregularmente feita.

Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do *quantum* devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de mercado.

A sociedade deve apurar os haveres do sócio desvinculado (ou falecido) e pagar-lhe (ou a seus sucessores) o reembolso, que corresponde à parcela do patrimônio líquido social correspondente à proporção da cota dele em relação ao capital social. Se o sócio retirante, excluído ou falecido tinha 10% do capital social, o reembolso corresponderá a 10% do patrimônio líquido da sociedade.

O pagamento do reembolso deve ser feito nos prazos contratualmente previstos ou, na omissão do contrato, à vista.

6. DISSOLUÇÃO DE FATO

A dissolução de fato da sociedade empresária é lamentavelmente mais comum do que seria de se desejar. Os sócios, em vez de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem. Comportamento de todo irregular, que o meio empresarial conhece, amargamente, por "golpe na praça". Tal comportamento é causa de decretação da falência da sociedade (LF, art. 94, III, *f*). Mas, além disso, os sócios respondem pelos prejuízos decorrentes deste comportamento irregular. Com efeito, o procedimento extintivo da sociedade

empresária é prescrito pelo direito no resguardo dos interesses não apenas dos sócios, como também dos credores da sociedade. Se aqueles deixam de observar as normas disciplinadoras do procedimento extintivo, responderão pela liquidação irregular, de forma pessoal e, consequentemente, ilimitada. Não há dispositivo específico que preveja esta hipótese, mas basta a invocação da teoria clássica da responsabilidade civil por danos decorrentes de atos ilícitos, para se concluir pela possibilidade de responsabilização dos sócios da sociedade dissolvida de fato pelas obrigações pendentes, sem que tenha aplicação qualquer regra de limitação desta responsabilidade, visto se tratar de ato ilícito perpetrado pessoalmente por eles, sócios.

Capítulo 15. SOCIEDADES POR AÇÕES

1. INTRODUÇÃO

Duas são as sociedades por ações, também classificadas como institucionais: a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. No seu estudo, cuido primeiro das normas relativas à sociedade anônima (também chamada de "companhia"), que são gerais para as sociedades por ações, reservando item próprio para as especificidades da sociedade em comandita por ações.

A sociedade anônima sujeita-se às regras da Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades por Ações (LSA). O Código Civil é aplicável apenas nas omissões desta (art. 1.089). Já a sociedade em comandita por ações é referida nos arts. 1.090 a 1.092 do CC, e se submete, em caso de omissão dessas normas, à LSA.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOCIEDADE ANÔNIMA

As características gerais da sociedade anônima são quatro: *a)* o capital social é dividido em ações, respondendo o sócio pelo preço de emissão das que subscrever ou adquirir; *b)* a companhia se classifica como sociedade de capital; *c)* ela é sempre empresária; *d)* adota denominação na composição de seu nome empresarial.

Para fins didáticos, examino a primeira em separado (item 2.1) das demais (item 2.2).

2.1. Responsabilidade limitada do acionista

O capital social deste tipo societário é fracionado em unidades representadas por ações. Os seus sócios, por isso, são chamados de acionistas, e eles respondem pelas obrigações sociais até o limite do que falta para a integralização das ações de que sejam titulares. Nas expressões usadas pelo legislador: o acionista responde pelo *preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir* (LSA, art. 1.º).

Preço de emissão é um dos muitos valores que a ação de uma sociedade anônima pode ter. Se alguém indagar quanto vale uma ação de determinada companhia, a resposta não poderá ser dada sem o prévio esclarecimento a respeito de que valor está sendo feita a pergunta. A ação de uma sociedade anônima vale mais ou menos de acordo com os objetivos da avaliação.

Uma analogia pode ajudar o entendimento da questão. Uma casa tem também diversos valores: se o objetivo é o cálculo e pagamento do imposto de propriedade, o que interessa é o valor venal da casa; se for o pagamento de imposto de transmissão, é o valor declarado na escritura; mas nenhum destes terá qualquer importância no momento da negociação desse bem, hipótese em que será levado em conta apenas o valor de mercado. Com a ação ocorre algo semelhante. Em função do objetivo perseguido, o seu valor é diferente.

Assim, a ação tem ou pode ter os seguintes valores:

a) Valor nominal - o resultante da operação matemática de divisão do valor do capital social pelo número de ações é o valor nominal. O estatuto da sociedade pode expressar este valor ou não; no primeiro caso, ter-se-á ação com valor nominal, no segundo, ação sem valor nominal, apresentando, cada

uma, algumas vantagens próprias, que serão examinadas em seguida.

b) *Valor patrimonial* - o valor da participação do titular da ação no patrimônio líquido da companhia (constante de um *balanço patrimonial*). Resulta da operação matemática de divisão do patrimônio líquido pelo número de ações em que se divide o capital social. É o valor devido ao acionista em caso de liquidação da sociedade ou amortização da ação.

c) *Valor de negociação* - é o preço que o titular da ação consegue obter vendendo-a. O valor de negociação, a ser pago pelo comprador ao vendedor da ação, é definido por uma série de fatores econômicos, como as perspectivas de rentabilidade, o patrimônio líquido da sociedade, o desempenho do setor em que ela atua, a própria conjuntura macroeconômica etc.

d) *Valor econômico* - é o calculado por avaliadores de ativos, por meio de técnicas específicas (p. ex., a do "fluxo de caixa descontado"), e representa o valor que seria racional pagar por uma ação, tendo em vista as perspectivas de rentabilidade da companhia emissora.

e) *Preço de emissão* - é o preço pago por quem subscreve a ação, à vista ou parceladamente. Destina-se a mensurar a contribuição que o acionista dá para o capital social (e, eventualmente, para a reserva de capital) da companhia, bem como o limite de sua responsabilidade subsidiária.

O preço de emissão, quando da constituição da sociedade, é fixado pelos fundadores. Neste momento, o único critério delimitador do preço de emissão é o valor nominal das ações, caso existente. Se a companhia tem o seu capital social representado por ações com valor nominal, o preço de emissão não poderá ser inferior a este valor. E se for superior, a diferença, chamada *ágio*, constituirá a reserva de capital (LSA, art. 13, § 2.º).

No caso de aumento do capital social com emissão de novas ações, a companhia deve também atribuir-lhes o respectivo preço de emissão. Cabe a decisão à assembleia geral ou ao conselho de administração. A fixação do preço de emissão de ações emitidas por força de aumento do capital social deve obedecer a determinados critérios previstos em lei (art. 170, § 1.º), dos quais se ressalta o seguinte: não se poderá impingir aos antigos acionistas uma diluição injustificada do valor patrimonial de suas ações. Assim, sempre que as novas ações forem subscritas por preço inferior ao valor patrimonial das existentes, este sofrerá uma redução (*diluição*). Tal redução poderá ser justificada ou não. Quer dizer: se a companhia efetivamente necessita dos recursos provenientes da emissão das novas ações, os acionistas antigos devem suportar a diluição do valor patrimonial de sua participação. Mas se não existe tal necessidade ou se os recursos de que carece a sociedade poderiam ser obtidos por outros meios, não se justifica a diluição. Essa regra vigora para a sociedade por ações com ou sem valor nominal. O acionista de qualquer companhia não pode sofrer injustificadamente diluição do valor patrimonial de suas ações.

Note-se que o acionista de sociedade por ações *com* valor nominal encontra-se mais protegido contra essa diluição, mesmo justificada, do que o acionista de sociedade por ações exclusivamente *sem* valor nominal. Em razão da proibição de fixação do preço de emissão de novas ações abaixo do valor nominal, terá aquele acionista uma relativa garantia contra a diluição do valor patrimonial de suas ações.

2.2. Classificação, natureza e denominação

A sociedade anônima é uma sociedade de capital. As ações representativas de parcela do capital

social são livremente negociáveis. Nenhum dos acionistas pode impedir, por conseguinte, o ingresso de quem quer que seja no quadro de sócios. Por outro lado, será sempre possível a penhora da ação em execução promovida contra o acionista.

Além disso, falecendo o acionista, não poderá ser impedido o ingresso de seus sucessores na sociedade. Por se tratar de sociedade institucional, também não será possível aos sucessores do acionista morto pretender a dissolução parcial da sociedade anônima. Em regra, o herdeiro ou legatário de uma ação transforma-se, queira ou não, em acionista da sociedade anônima. A lei prevê uma única exceção, admitindo a dissolução parcial da sociedade anônima fechada (sem ações negociadas em Bolsa de Valores), quando acionistas titulares de pelo menos 5% do capital social provam que ela não está preenchendo o seu fim (CPC, art. 599, § 2.º).

A sociedade anônima é sempre empresária, qualquer que seja sua atividade econômica (CC, art. 982, parágrafo único; LSA, art. 2.º, § 1.º). Uma companhia constituída só por dentistas para a prestação de serviços de odontologia pelos próprios acionistas, embora tenha por objeto uma atividade não empresarial (CC, art. 966, parágrafo único), será empresária e estará sujeita ao regime jurídico-comercial, pela só adoção do tipo societário "anônima".

A companhia adota denominação, obrigatoriamente. Desta constará referência ao tipo societário, pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente (S/A ou Cia.), sendo que esta última expressão somente poderá ser utilizada no início ou no meio do nome empresarial. A menção ao ramo do comércio na denominação é essencial (CC, art. 1.160).

3. ESPÉCIES DE SOCIEDADE ANÔNIMA

Os títulos representativos da participação societária numa sociedade anônima são espécies de "valores mobiliários" (item 5) e denominam-se "ação". As espécies de sociedade anônima variam segundo os ambientes de negociação da ação.

As sociedades anônimas podem ser de duas espécies: *abertas* ou *fechadas*. As companhias abertas têm as ações (e demais valores mobiliários) de sua emissão admitidas à negociação no "mercado de valores mobiliários" (MVM), enquanto as fechadas não podem ter suas ações negociadas neste mercado.

O critério é meramente formal: basta a admissão dos valores mobiliários à negociação no MVM para que a sociedade emissora seja considerada aberta. É irrelevante se os valores mobiliários são efetivamente negociados. O MVM é um ambiente de negociação que tende a conferir maior liquidez às ações neles admitidas. As ações de companhias abertas costumam ser, em suma, mais facilmente negociáveis, atraindo com isto o interesse de um conjunto maior de investidores.

Para que a companhia tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no MVM, ela necessita de prévia autorização do governo, dada por uma autarquia denominada Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

O governo federal tem obrigação de acompanhar as sociedades anônimas abertas para proteção do investidor e tendo em vista o importante papel que elas desempenham na economia em geral. Em virtude desse interesse é que a LSA prevê determinadas regras de aplicação específica às companhias abertas.

O MVM (antigamente chamado de "mercado de capitais") é composto por dois ambientes de

negociação: a Bolsa de Valores e os mercados de balcão. A Bolsa de Valores é uma entidade privada (pode ser uma sociedade anônima, como é a BM&FBovespa, ou uma associação de corretores), que exerce o serviço público de manter o pregão dos valores mobiliários; sua criação depende de autorização do Banco Central e seu funcionamento é controlado pela CVM. Mercado de balcão compreende toda operação relativa a valores mobiliários realizada fora da Bolsa de Valores, por sociedade corretora e instituição financeira ou sociedade intermediária autorizadas. A companhia aberta pode estar registrada na CVM para ter os seus valores mobiliários negociados somente no mercado de balcão ou neste e na Bolsa.

Negociam-se valores mobiliários em dois diferentes mercados: *primário*, referente à subscrição de valores mobiliários, negócio jurídico entre o investidor (acionista, debenturista etc) e a sociedade emissora; e o *secundário*, que compreende a compra e venda, negócio jurídico entre os investidores, do qual não participa a sociedade emissora. As Ofertas Públicas Iniciais (I.P.O. na sigla em inglês) é exemplo de operação do mercado primário, enquanto o pregão das ações registra negócios do mercado secundário.

A Lei 7.913/89 atribui legitimidade ativa ao Ministério Público para propor, de ofício ou a pedido da CVM, ação civil pública para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado, decorrentes principalmente de práticas irregulares.

4. CONSTITUIÇÃO

O tema da constituição das companhias encontra-se fracionado em três níveis distintos: *a)* requisitos preliminares (arts. 80 e 81); *b)* modalidades de constituição (arts. 82 a 93); *c)* providências complementares (arts. 94 a 99). Não se trata, rigorosamente, de etapas da constituição, posto se inter cruzarem as medidas disciplinadas em cada uma destas seções.

Qualquer companhia, para constituir-se, deve atender a três requisitos preliminares:

a) Subscrição de todo o capital social por, pelo menos, duas pessoas. Todas as ações representativas do capital social devem ser subscritas como condição prévia para a constituição. A subscrição é contrato plurilateral complexo pelo qual uma pessoa se torna titular de ação emitida por sociedade anônima. É negócio jurídico irretratável.

b) Realização, como entrada, de, no mínimo, 10% do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Na subscrição a prazo em dinheiro, pelo menos 1/10 do preço da ação deve ser integralizado como entrada. Em se tratando de instituição financeira, a porcentagem sobe para 50% (LRB, art. 27).

c) Depósito das entradas em dinheiro no Banco do Brasil ou estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Este depósito deverá ser feito pelo fundador, até 5 dias do recebimento das quantias, em nome do subscritor e em favor da companhia em constituição. Concluído o processo de constituição, a companhia levantará o montante depositado; se este processo não se concluir em 6 meses do depósito, o subscritor é que levantará a quantia por ele paga.

A lei prevê duas modalidades de constituição de sociedade anônima, de acordo com a existência ou não de apelo ao público investidor: a constituição *por subscrição pública*, em que os fundadores buscam recursos para a constituição da sociedade junto aos investidores; e a constituição *por subscrição particular*, em que inexistente esta preocupação por parte dos fundadores.

A caracterização de emissão pública de ações configura-se nos seguintes casos: "a) a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; b) a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos, por meio de empregados, agentes ou corretores; c) a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação" (Lei 6.385/76, art. 19, § 3.º).

Sempre que o fundador de uma companhia pretender lançar mão de expedientes como os referidos, deverá observar as normas relativas à constituição por subscrição pública. Caso não pretenda lançar mão destes expedientes, deverá o fundador optar pela constituição por subscrição particular.

A constituição por subscrição pública é também denominada, doutrinariamente, de *constituição sucessiva*, por compreender várias etapas ou fases; e a constituição por subscrição particular, de *constituição simultânea*, por concentrar-se num único ato.

A constituição sucessiva tem início com o registro na CVM, cujo pedido deve estar instruído com o estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, o projeto dos estatutos e o prospecto. A CVM poderá condicionar a concessão do registro a alterações no prospecto ou no projeto de estatuto que não se revelarem satisfatórios. Se o estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, no entanto, não satisfizer aos critérios técnicos da CVM - revelando-se, segundo tais critérios, a inviabilidade ou temeridade da empresa -, não será o caso de se proceder a alterações nele, uma vez que este deve retratar uma realidade, e não dispor sobre ela, como é o caso dos outros dois instrumentos. Nesta hipótese, o único caminho a seguir é o indeferimento do registro. A CVM poderá, também, negar o registro baseada na inidoneidade dos fundadores.

Para requerer o registro junto à CVM, o fundador da companhia deverá, necessariamente, contratar uma instituição financeira para intermediar a colocação das ações no mercado. O prospecto deverá, inclusive, conter a assinatura dela.

Concedido o registro da emissão e da sociedade, na CVM, passa-se à segunda fase da constituição sucessiva, que compreende a subscrição das ações representativas do capital social. O investimento é oferecido ao público pela instituição financeira intermediária. Quem pretender subscrever ações dessa companhia deve procurar a instituição financeira para assinar o boletim ou a lista de subscrição, que instrumentalizam o negócio jurídico. Também será possível a subscrição por carta que atenda aos requisitos fixados no prospecto. Em uma ou outra hipótese, sendo em dinheiro a integralização, o subscritor pagará a entrada.

Quando todo o capital social estiver subscrito, os fundadores convocarão a assembleia de fundação para deliberar sobre a constituição da companhia e, se for o caso, avaliar os bens oferecidos para a integralização. Nesta assembleia, todas as ações, de qualquer espécie ou forma, conferirão ao seu titular o direito de voto. Confirmada a observância das formalidades legais e não se opondo subscritores representativos de mais da metade do capital social, será proclamada a sua constituição. Em seguida, elegem-se os primeiros administradores e fiscais. O projeto de estatuto somente poderá ser alterado, na assembleia de fundação, por deliberação unânime dos subscritores. Esta é a terceira e derradeira fase da constituição por subscrição pública.

Já a constituição por subscrição particular é significativamente mais simples. Poderá processar-se por deliberação dos subscritores reunidos em assembleia de fundação ou por escritura pública. Na primeira hipótese, todos os subscritores deverão assinar o projeto de estatuto; na segunda, todos

assinarão a escritura pública, que conterà os requisitos fixados em lei (LSA, art. 88, § 2.º).

Em relação à constituição, independentemente da modalidade, previu a lei algumas regras comuns: *a*) a escritura pública é dispensável para a incorporação de imóveis ao patrimônio social (LSA, art. 89); *b*) o subscritor poderá ser representado por procurador com poderes especiais, na assembleia de fundação ou na escritura pública (art. 90); *c*) a denominação da companhia, enquanto não concluído o seu processo de constituição, deverá ser aditada pela expressão "em organização" (art. 91); *d*) os fundadores e as instituições financeiras que participarem da constituição da companhia têm responsabilidade por todos os prejuízos decorrentes da inobservância de algum preceito legal e os fundadores responderão, solidariamente, pelos danos decorrentes de culpa ou dolo em atos anteriores à constituição (art. 92 e seu parágrafo único); *e*) os fundadores devem entregar aos primeiros administradores eleitos os papéis, documentos e livros pertinentes à constituição da companhia ou de propriedade desta (art. 93).

Na seção referente às providências complementares, que são comuns às duas modalidades de constituição, fixa a lei a necessidade de registro e publicação dos atos constitutivos da companhia. Somente após estas providências é que a sociedade anônima poderá dar início à exploração de suas atividades empresariais de forma regular.

Se houver incorporação de bem ao capital social, deverá ser providenciada, por seus primeiros administradores a transferência da titularidade desse bem para a companhia, por meio do registro público competente (se bem imóvel, o Registro de Imóveis; se marca, o registro no INPI etc.). A certidão dos atos constitutivos expedida pela Junta Comercial é documento hábil para instrumentalizar a transferência de propriedade ou titularidade.

5. VALORES MOBILIÁRIOS

Valores mobiliários podem ser definidos, inicialmente, como "títulos de investimento" que a sociedade anônima emite para obtenção dos recursos de que necessita. Além da ação, valor mobiliário representativo de unidade do capital social, que será objeto de estudo no próximo item, a companhia poderá emitir os seguintes principais valores mobiliários: *a*) debêntures (LSA, arts. 52 a 74); *b*) partes beneficiárias (arts. 46 a 51); *c*) bônus de subscrição (arts. 75 a 79); *d*) nota promissória (Inst. CVM 134/90).

As debêntures são definidas, pela doutrina, como títulos representativos de um contrato de mútuo, em que a companhia é a mutuária e o debenturista o mutuante. Os titulares de debêntures têm direito de crédito, perante a companhia, nas condições fixadas por um instrumento elaborado por esta, a "escritura de emissão". Nela, estabelece-se se o crédito do debenturista será monetariamente corrigido ou não, definem-se as garantias desfrutadas por eles, as épocas de vencimento da obrigação e demais requisitos determinados por lei (LSA, art. 59).

A comunidade de interesses dos debenturistas pode ser representada por um agente fiduciário, nomeado pela escritura de emissão. Sempre que as debêntures forem distribuídas, ou admitidas no MVM, a nomeação de agente fiduciário é obrigatória. Se a negociação das debêntures não se fizer no MVM, será facultativa a sua existência. Pode exercer a função de agente fiduciário dos debenturistas a pessoa natural que preencher os requisitos que a lei fixa para os administradores e a instituição financeira especialmente autorizada pelo Banco Central do Brasil, observados certos impedimentos (LSA, art. 66, § 3.º).

As debêntures, de acordo com a garantia oferecida aos seus titulares, podem ser de quatro espécies: a) com garantia real, em que um bem, pertencente ou não à companhia, é onerado (hipoteca de um imóvel, por exemplo); b) com garantia flutuante, que confere aos debenturistas privilégio geral sobre o ativo da companhia, pelo qual terão preferência sobre os credores quirografários em caso de falência da companhia emissora; c) quirografária, cujo titular concorre com os demais credores sem garantia integrantes da massa falida; d) subordinada (ou subquirografária), em que o titular tem preferência apenas sobre os acionistas, em caso de falência da sociedade emissora.

As debêntures podem ter a cláusula de conversibilidade em ações e podem ser nominativas ou escriturais.

As partes beneficiárias (PB) são definidas como títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, que conferem aos seus titulares direito de crédito eventual, consistente na participação nos lucros da companhia emissora (LSA, art. 46 e seu § 1.º). Somente a companhia fechada pode emitir estes valores mobiliários. Dos lucros da sociedade anônima não poderá ser destinado às partes beneficiárias mais que 10%.

As PB poderão ser alienadas ou atribuídas. A atribuição, por sua vez, poderá ser onerosa (em pagamento a prestação de serviços) ou gratuita (sem contrapartida em favor da emissora).

As PB terão a duração estabelecida pelos estatutos. No caso de atribuição gratuita, o prazo está limitado a 10 anos, salvo se a PB tiver sido emitida em favor de associação ou fundação beneficente de empregados da companhia.

Estes valores mobiliários podem conter também a cláusula de conversibilidade em ações, devendo, neste caso, ser constituída uma reserva especial para capitalização.

A alteração dos estatutos que importe em modificação ou redução das vantagens conferidas aos titulares das PB somente terá eficácia após sua aprovação no mínimo pela metade deles, reunidos em assembleia.

Os bônus de subscrição (BS) conferem aos seus titulares o direito de subscreverem ações da companhia emissora, se houver futuro aumento de capital social. O titular de um bônus não estará dispensado do pagamento do respectivo preço de emissão. São valores mobiliários emitidos pela sociedade anônima para alienação onerosa ou atribuição gratuita como vantagem adicional aos subscritores de suas ações ou debêntures.

Por fim, a CVM disciplinou, pela Instrução 134/90, a emissão de notas promissórias destinadas à distribuição pública. Trata-se de valor mobiliário destinado à captação de recursos para restituição a curto prazo (30 dias no mínimo e 360 no máximo). Conhecido por *Commercial Paper*, este valor mobiliário somente poderá ser negociado mediante endosso em preto com a cláusula sem garantia.

6. AÇÕES

As ações são valores mobiliários representativos de unidade do capital social de sociedade anônima, que conferem aos seus titulares um complexo de direitos, deveres e obrigações.

Classificam-se as ações segundo três critérios distintos: espécie, classe e forma.

Segundo a espécie, as ações são:

a) *Ordinárias* - aquelas que conferem aos seus titulares os direitos que a lei reserva ao acionista comum. São ações de emissão obrigatória. Não há sociedade anônima sem ações desta espécie. O estatuto não precisará disciplinar esta espécie de ação, uma vez que dela decorrem, apenas, os direitos normalmente concedidos ao sócio da sociedade anônima.

b) *Preferenciais* - ações que conferem aos seus titulares um complexo de direitos diferenciado, como, por exemplo, a prioridade na distribuição de dividendos ou no reembolso do capital, com ou sem prêmio etc. As ações preferenciais podem ou não conferir o direito de voto aos seus acionistas. Para serem negociadas no MVM, os direitos diferenciados das preferenciais devem ser pelo menos um de três definidos na LSA (art. 17, § 1.º).

O máximo de ações preferenciais sem direito a voto, ou com restrições a esse direito, tolerado por lei, é de 50% das ações emitidas (art. 15, § 2.º).

c) *De fruição* - são aquelas atribuídas aos acionistas cujas ações foram totalmente amortizadas. O seu titular estará sujeito às mesmas restrições ou desfrutará das mesmas vantagens da ação ordinária ou preferencial amortizada, salvo se os estatutos ou a assembleia geral que autorizar a amortização dispuserem em outro sentido.

Em relação às classes, as ações podem ser nelas distribuídas pelos estatutos, segundo os direitos, deveres ou obrigações que conferem aos acionistas. Cada classe será identificada por uma letra na sequência do alfabeto (A, B, C...).

As ações preferenciais se dividem em classes de acordo com o complexo de direitos ou restrições que, nos termos dos estatutos, forem conferidos aos seus titulares. As ações ordinárias, em tese, não deveriam ser divisíveis em classes, na medida em que se conceituam justamente por conferirem um mesmo conjunto de direitos aos seus titulares. No entanto, a lei possibilita aos estatutos da companhia fechada a previsão de classes de ações ordinárias, em função de sua conversibilidade em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira do acionista ou direito de eleger, em separado, membros dos órgãos de administração (art. 16). As ações ordinárias das companhias abertas não poderão ser divididas em classes (art. 15, § 1.º).

Quanto à forma, as ações são nominativas ou escriturais.

O critério de diferenciação entre uma forma ou outra leva em conta o negócio jurídico que opera a transferência de titularidade da ação; ou seja, a maneira pela qual ela é transmissível. As ações nominativas circulam mediante registro no livro próprio da sociedade emissora, denominado "Livro de Transferência de Ações Nominativas". Já as ações escriturais são mantidas, por autorização ou determinação dos estatutos, em contas de depósito em nome de seu titular. Essas ações são desprovidas de certificado e sua circulação se opera por lançamento da operação nos registros próprios da instituição financeira depositária, a débito da conta de depósito do alienante e a crédito da conta de depósito do adquirente.

Além da classificação, convém assentar mais três observações sobre as ações: a) limitação à circulação; b) certificado de ações; c) custódia de ações fungíveis.

Em princípio, por ser representativa de participação em sociedade de capital, a ação é livremente negociável. Contudo, os estatutos da companhia *fechada* podem estabelecer limites à livre circulação das ações, desde que não impeçam a sua negociação nem sujeitem o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração ou à maioria dos acionistas (LSA, art. 36). O exemplo mais corrente de aproveitamento dessa faculdade legal encontra-se na previsão do direito de preferência para a compra de ações, reconhecido aos demais acionistas da companhia. Nesse caso, aquele que pretender alienar suas ações estará obrigado a oferecê-las, inicialmente, aos demais integrantes do quadro de acionistas. A circulação das ações da companhia aberta, reforço, não poderá sofrer qualquer restrição por parte dos estatutos.

As ações nominativas são documentadas em um certificado, em regra de emissão da companhia, cujos requisitos se encontram fixados em lei (art. 24). Poderá, no entanto, a companhia contratar os serviços de escrituração e guarda dos livros de registro e transferência de ações, bem como os de expedição de certificados, de uma instituição financeira autorizada pela CVM, chamada pela lei de agente emissor de certificados. Nesta hipótese, caberá exclusivamente ao agente a prática dos atos relativos aos registros e emissão de certificados.

A lei possibilita, também, às instituições financeiras autorizadas para este fim, pela CVM, prestarem serviços de custódia de ações fungíveis, recebendo em depósito, como valores fungíveis, as ações de cada espécie, classe e companhia. Neste caso, a instituição financeira representará, perante a companhia, os titulares das ações depositadas em custódia, para recebimento de dividendos e ações bonificadas, bem como exercício de direito de preferência na subscrição de novas ações.

7. CAPITAL SOCIAL

O capital social de uma sociedade anônima, como ocorre em relação às demais sociedades empresárias, pode ser integralizado pelo acionista em dinheiro (hipótese mais comum), bens ou créditos.

Para a integralização do capital social em bens é necessário realizar-se a avaliação desses bens, feita com observância de determinadas regras (LSA, art. 8.º). Assim, devem ser contratados três peritos, ou uma empresa especializada, para a elaboração de um laudo fundamentado com indicação dos critérios e dos elementos de comparação utilizados e instruído pelos documentos relativos ao bem. Este laudo será objeto de votação por assembleia geral da companhia. Se o valor obtido pelo laudo pericial for aprovado pelo órgão social e aceito pelo subscritor, perfaz-se a integralização do capital social pelo bem avaliado. Qualquer bem, corpóreo ou incorpóreo (registro de marca, patente etc.), móvel ou imóvel, pode ser usado para a integralização do capital social da companhia. O bem transfere-se a título de propriedade, salvo estipulação diversa (usufruto, por exemplo), e a responsabilidade do subscritor equipara-se à do vendedor.

No tocante à integralização por créditos de que seja titular o subscritor, há de se observar a responsabilidade deste pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Mesmo em se tratando de cessão civil (em que, em regra, o cedente não responde pela solvência do devedor - art. 296 do CC), será sempre possível demandar o subscritor quando o devedor não honrar o título junto à companhia cessionária (LSA, art. 10, parágrafo único). A mesma responsabilidade tem o subscritor na hipótese de endosso "sem garantia", sendo ineficaz perante a companhia a cláusula exoneratória de responsabilidade do acionista-endossante. Além disso, o certificado de ação integralizada por transferência de crédito somente poderá ser expedido após a sua realização (LSA, art. 23, § 2.º).

O capital social pode ser aumentado. O aumento do capital social, no entanto, nem sempre decorre de ingresso de novos recursos na companhia. São hipóteses de aumento do capital social:

a) *Emissão de novas ações* - em que há ingresso de novos recursos no patrimônio social. O aumento é deliberado em assembleia geral extraordinária (LSA, art. 166, IV) e tem por pressuposto a realização de, pelo menos, 3/4 do capital social então existente (art. 170). Mas pode também ser feito por deliberação da assembleia geral ou do conselho de administração, nos limites do capital autorizado (LSA, art. 166, II).

b) *Valores mobiliários* - a conversão de debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações, bem como o exercício dos direitos conferidos por bônus de subscrição ou opção de compra, importam em aumento de capital social, com emissão de novas ações (LSA, art. 166, III).

c) *Capitalização de lucros e reservas* - a assembleia geral ordinária pode destinar uma parcela do lucro líquido ou de reservas para reforço do capital social, emitindo-se, ou não, novas ações (LSA, art. 169), mas sempre sem o ingresso de novos recursos.

O estatuto da companhia pode autorizar o aumento do capital social, dentro de certo limite, sem necessidade de sua alteração. A medida visa a agilizar o processo de decisão e emissão de novas ações. Este limite é chamado de capital "autorizado". O estatuto deverá, quando fixar o capital autorizado, definir se o órgão competente para decidir a emissão das novas ações será a assembleia geral ou o conselho de administração (LSA, art. 168).

O capital social da companhia pode, também, ser reduzido. Duas são as causas que a lei considera para permitir a redução: excesso do capital social, quando se constata o seu superdimensionamento; e irrealidade do capital social, quando houver prejuízo patrimonial (LSA, art. 173). Quando ocorre redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações (ou diminuição do valor destas, se não integralizadas, à importância das entradas já feitas), a lei busca proteger os interesses dos credores da companhia, sujeitando a eficácia da deliberação da assembleia geral ao transcurso do prazo de 60 dias após a publicação de sua correspondente ata. Durante este lapso temporal, os credores quirografários existentes à data da publicação terão direito de manifestar oposição à redução deliberada, hipótese em que o arquivamento da ata da assembleia geral fica condicionado ao pagamento ou ao depósito judicial do crédito do oponente. Ademais, nesta mesma hipótese, a aprovação da maioria de seus debenturistas, reunidos em assembleia especial, será necessária para a validade da pretendida redução (LSA, art. 174).

8. ÓRGÃOS SOCIAIS

Quatro são os principais órgãos da companhia: a assembleia geral, o conselho de administração, a diretoria e o conselho fiscal. Além destes, o estatuto poderá prever livremente a existência de órgãos técnicos de assessoramento ou de execução.

8.1. Assembleia geral

A assembleia geral é o órgão máximo da sociedade anônima, de caráter exclusivamente deliberativo, que reúne todos os acionistas com ou sem direito a voto. A assembleia geral pode ser ordinária (AGO) ou extraordinária (AGE).

Todos os acionistas, mesmo os que não têm direito a voto, podem participar da assembleia geral. Como se sabe, os acionistas titulares de ações preferenciais nominativas podem ter o direito de voto limitado ou suprimido pelo estatuto. Eles poderão exercer o direito a voto somente em casos excepcionalmente previstos, como a deliberação da constituição, eleição em separado de membros do conselho de administração ou fiscal, não pagamento de dividendos fixos ou mínimos etc. Salvo, pois, tais casos, os titulares das ações destas categorias terão apenas direito de voz na discussão das matérias em pauta (LSA, art. 125, parágrafo único).

A lei exige a realização de uma assembleia geral nos quatro meses imediatamente seguintes ao término do exercício social, para fins de apreciação de um conjunto de matérias específicas. Esta é a assembleia geral ordinária (AGO) que se realiza anualmente. Sua competência está restrita aos temas elencados no art. 132 da LSA, a saber: *a)* tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; *b)* deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; *c)* eleger os administradores e fiscais, se for o caso. Qualquer outro tema não poderá ser objeto de deliberação da assembleia geral ordinária, fazendo-se indispensável a convocação de uma AGE.

Fixa a lei um *quorum* para validade das deliberações da assembleia. Primeiro, cogita-se de um *quorum* de instalação, ou seja, que define a presença mínima de acionistas para validade dos trabalhos. O *quorum* de instalação é de 1/4 do capital social votante, em primeira convocação (LSA, art. 125). Em constando, porém, da pauta a apreciação de proposta de reforma dos estatutos, o *quorum* de instalação em primeira convocação passa a ser de acionistas representantes de 2/3, no mínimo, do capital social votante (art. 135). Independentemente da pauta, a AGO ou AGE se instala, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas.

O *quorum* de *deliberação* diz respeito à aprovação ou rejeição de cada matéria discutida e votada em assembleia. Para a aprovação, é necessária, em regra, a convergência dos votos de mais da metade do total de ações com direito a voto *presentes* à assembleia, descontados os proferidos em branco. É este o sentido do conceito de *maioria absoluta* constante do art. 129 da LSA. Existem, entretanto, hipóteses em que a lei fixa um *quorum* mais elevado para a deliberação. Trata-se do *quorum* qualificado do art. 136, que impõe, para a aprovação das matérias nele elencadas, a concordância de acionistas que representem metade, no mínimo, do *capital social votante*. Para a deliberação de assunto listado pelo legislador neste dispositivo, é *necessária* a aprovação de acionistas titulares de, no mínimo, 50% das ações com direito a voto.

Note-se bem que o percentual do *quorum* qualificado de deliberação é necessário para a aprovação, mas nem sempre será *suficiente*: no caso de a proposta contar com a aprovação de metade dos acionistas com direito a voto e com a reprovação da outra metade, ocorrerá empate. O desempate será alcançado aplicando-se o art. 129, § 2.º, da LSA.

O *quorum* de deliberação, simples ou qualificado, poderá ser aumentado pelos estatutos da companhia fechada, mas não pode ser alterado no caso de sociedade anônima aberta.

8.2. Conselho de Administração

O conselho de administração é órgão, em regra, facultativo. Trata-se de colegiado de caráter deliberativo, ao qual a lei atribui parcela da competência da assembleia geral, com vistas a agilizar a tomada de decisões de interesse da companhia. Este órgão só é obrigatório nas sociedades anônimas

abertas, nas de capital autorizado e nas de economia mista (LSA, arts. 138, § 2.º, e 239).

Cabe ao estatuto fixar, observado o mínimo legal de três, o número de conselheiros, podendo optar pela fixação de mínimo ou máximo permitidos. Deve, também, fixar o prazo de duração do mandato de seus integrantes, nunca superior a 3 anos; e estabelecer normas regimentais do órgão, notadamente no que se refere à escolha e substituição de seu presidente, substituição de seus membros, convocação, instalação, funcionamento e deliberação. O conselho delibera por maioria de votos, se o estatuto não prevê *quorum* qualificado para uma ou mais matérias (art. 140) e somente pessoa natural é elegível para o cargo de conselheiro (art. 146).

Quem elege e pode, a qualquer tempo, destituir os membros do conselho de administração é a assembleia geral.

8.3. Diretoria

A diretoria é órgão de representação legal da companhia e de execução das deliberações da assembleia geral e do conselho de administração. O estatuto deverá prever, em relação à diretoria: *a*) número de membros, nunca inferior a dois, ou o mínimo e máximo permitidos; *b*) duração do mandato, não superior a 3 anos; *c*) modo de substituição dos diretores; *d*) atribuições e poderes de cada diretor (art. 143).

Os diretores precisam ser, necessariamente, pessoas naturais. Se houver conselho de administração, os diretores são eleitos por este órgão; não havendo, pela assembleia geral. São, a qualquer tempo, destituíveis pelo órgão competente para a eleição. Até 1/3 dos membros do conselho de administração poderá integrar, também, a diretoria.

A representação legal cabe àquele diretor ao qual for atribuída esta competência específica pelo estatuto, ou, omisso este, por deliberação do conselho de administração. Se inexistir previsão estatutária nem deliberação do conselho, a representação legal competirá a qualquer dos diretores da companhia (LSA, art. 144).

Tanto os integrantes do conselho de administração quanto os da diretoria são, sempre, reelegíveis (LSA, arts. 140, III, e 143, III).

8.4. Conselho Fiscal

O conselho fiscal é órgão de existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo, composto de no mínimo três, e, no máximo, cinco membros, acionistas ou não.

Quando se tratar de órgão que, pelo estatuto, tem funcionamento facultativo, este deverá ocorrer por deliberação da assembleia geral, por proposta de acionista que represente, na sociedade fechada, 10% das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto (art. 161, § 2.º); nas abertas, os percentuais são menores, fixados pela CVM em função do capital social.

Os mesmos requisitos, impedimentos e deveres que a lei estabelece para os administradores são extensíveis aos membros do conselho fiscal. Além disso, não pode ser eleito fiscal o membro de órgão de administração, empregado da companhia ou de sociedade por ela controlada, ou do mesmo grupo, bem como o cônjuge ou parente até terceiro grau de administrador da companhia (LSA, art. 162 e § 2.º).

Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com restrições desse direito, poderão eleger, em separado, um membro do conselho fiscal. Igual direito têm os acionistas minoritários que representem 10% ou mais do capital votante. Assim, se o conselho fiscal tinha três membros, o órgão passa a ter cinco se ambos os grupos minoritários exercerem os seus direitos de eleição de fiscal em separado, em virtude do disposto no art. 161, § 4.º, da LSA.

O conselho fiscal é órgão destinado à fiscalização dos órgãos de administração, atribuição que exerce para a proteção dos interesses da companhia e de todos os acionistas. Sua competência vem detalhada no art. 163 da LSA.

9. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Sob a rubrica de "administradores", a lei reúne tanto o membro do conselho de administração quanto o da diretoria (LSA, arts. 145 a 160).

São os seguintes os deveres impostos por lei aos administradores:

a) *Dever de diligência* - pelo qual o administrador deve empregar, no desempenho de suas atribuições, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo, costumeiramente, emprega na administração de seus próprios negócios (LSA, art. 153). Para melhor nortear o cumprimento deste dever, determina a lei que o administrador exerça suas atribuições com vistas à realização dos fins e interesses da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa (art. 154, *caput*).

b) *Dever de lealdade* - o administrador não pode usar, em proveito próprio ou de terceiro, informação pertinente aos planos ou interesses da companhia e à qual teve acesso em razão do cargo que ocupa, agindo sempre com lealdade para com aquela (LSA, art. 155). Deve, pois, abster-se de intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da sociedade anônima, bem como na deliberação que a respeito tomar o órgão no qual tenha assento (art. 156). O descumprimento do dever de lealdade pode caracterizar, em alguns casos, crime de concorrência desleal (LPI, art. 195, XI e § 1.º).

c) *Dever de informar* - o administrador de companhia aberta tem o dever de informar, imediatamente, à Bolsa de Valores e divulgar pela imprensa qualquer deliberação dos órgãos sociais ou fato relevante que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários de emissão da companhia (LSA, art. 157, § 4.º). Outro aspecto do dever de informar diz respeito aos interesses que o administrador de companhia aberta possua nos negócios sociais, os quais têm os acionistas o direito de conhecer (LSA, art. 157 e § 1.º).

O administrador não é responsável pelas obrigações assumidas pela companhia por ato regular de gestão, mas responderá por ato ilícito seu, pelos prejuízos que causar, com culpa ou dolo, ainda que dentro de suas atribuições ou poderes, ou com violação da lei ou do estatuto (LSA, art. 158). A companhia pode promover a responsabilização judicial de seu administrador, por prejuízo que este lhe tenha causado, necessariamente mediante prévia deliberação da assembleia geral. A deliberação poderá ser tomada em assembleia ordinária, ou, se constar da ordem do dia, ou tiver relação direta com matéria em apreciação, pela assembleia extraordinária. Em qualquer caso, o administrador será destituído do cargo de administração e substituído, nos termos estatutários.

Se os órgãos de administração retardarem a propositura da competente ação por mais de 3 meses,

qualquer acionista poderá fazê-lo em nome da companhia. É hipótese de substituição processual derivada (LSA, art. 159, § 3.º). Se, porém, a assembleia geral decidiu não promover a responsabilização do administrador, os acionistas que possuam ações representativas de 5% ou mais do capital social poderão, em nome da companhia, promover a ação judicial. É hipótese de substituição processual originária (art. 159, § 4.º).

A ação para responsabilização dos administradores prescreve em 3 anos, contados da data da publicação da ata da assembleia geral que votar o balanço referente ao exercício em que o ilícito ocorreu. O mesmo prazo conta-se, no entanto, da prescrição da ação penal ou da sentença penal definitiva, caso o fato ensejador da ação de responsabilidade civil deva ser objeto de apuração na esfera criminal (LSA, arts. 287, II, *b*, 2 e 288).

Além da responsabilidade civil e penal, têm os administradores responsabilidade de caráter administrativo perante a CVM. Esta autarquia pode impor-lhes, por infração a dever prescrito na legislação do anonimato, sanções que variam de multa ou advertência até suspensão do exercício do cargo ou inabilitação (Lei 6.835/76, art. 11).

Até aqui, estudamos os deveres e responsabilidades dos administradores em relação à própria sociedade anônima que administram. Eles, no entanto, também podem ser responsabilizados por danos que causam a terceiros, no exercício da função. Os consumidores, por exemplo, têm ação contra os administradores que conduziram a companhia fornecedora à falência ou inatividade, em decorrência de má administração (CDC, art. 28). Os administradores de operadoras de planos de assistência à saúde respondem subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais de consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, bem como pelas obrigações fiscais e trabalhistas da sociedade (Lei 9.656/98, art. 35-J).

10. O ACIONISTA

O dever principal do acionista é o de pagar o preço de emissão das ações que subscrever (LSA, art. 106). O vencimento das prestações será o definido pelo estatuto ou pelo boletim de subscrição. Se omissos tais instrumentos, os órgãos da administração procederão à chamada dos subscritores, por avisos publicados na imprensa, por três vezes pelo menos, estabelecendo prazo não inferior a 30 dias para o pagamento. O acionista que deixar de pagar a prestação devida, no prazo assim fixado, estará constituído em mora independentemente de qualquer interpelação. Nesta situação, deverá pagar o principal de seu débito, acrescido de juros, correção monetária e multa estatutária de, no máximo, 10%. Estas três parcelas são devidas apenas se existir previsão estatutária.

A companhia poderá promover, contra o acionista em mora (chamado pela lei de "remisso"), a cobrança judicial do devido, por ação de execução, servindo o boletim de subscrição, acompanhado, se for o caso, da chamada, como título executivo extrajudicial. Poderá, também, optar pela venda das ações subscritas pelo acionista remisso em Bolsa. Esta regra, porque a venda referida se faz mediante leilão especial, também se aplica às companhias fechadas. Do produto arrecadado nessa venda serão descontadas as despesas com a operação e os juros, correção monetária e multa previstos em estatuto, ficando o saldo à disposição do ex-acionista. A lei faculta à companhia promover a venda em Bolsa mesmo após o ajuizamento da execução judicial, assim como promover esta em caso de se revelar frustrada a venda em leilão especial da Bolsa. Baldadas, no entanto, ambas as providências, a companhia pode declarar a caducidade das ações, apropriando-se das entradas porventura já realizadas. Se, então, possuir fundos ou reservas (exceto a legal) disponíveis, poderá integralizar a ação, para vendê-la, se e

quando desejar. Se não possuir fundos ou reservas suficientes para a integralização, terá a companhia o prazo de 1 ano para conseguir um comprador para as ações em questão, findo o qual, o capital social deverá ser reduzido, por decisão da assembleia geral, em importância correspondente.

O art. 109 da LSA elenca os direitos essenciais do acionista, a saber:

a) *Participação nos resultados sociais* - o acionista tem direito de receber o dividendo, que é a parcela dos lucros sociais que lhe cabe, bem como participar do acervo da companhia, em caso de liquidação (art. 109, I e II). Este direito não pode ser exercido se a sociedade anônima é devedora do INSS, já que a lei proíbe a distribuição de lucros nas sociedades com débito previdenciário (Lei 8.212/91, art. 52).

b) *Fiscalização da gestão dos negócios sociais* - a legislação do anonimato prevê formas de fiscalização direta e indireta dos negócios sociais. Do primeiro caso é exemplo a exibição dos livros sociais aos acionistas que representem 5% ou mais do capital social, nos casos de violação da lei ou do estatuto ou fundada suspeita de grave irregularidade (art. 105); do segundo, é exemplo o conselho fiscal.

c) *Direito de preferência* - os acionistas têm direito de preferência na subscrição de ações e de valor mobiliário conversível em ação, segundo os critérios do art. 171, § 1.º, da LSA. Trata-se de um direito cedível.

d) *Direito de retirada* - o acionista dissidente de determinadas deliberações da assembleia geral (arts. 136, I a VI, e IX, 136-A, 221, 230 e 252) ou de companhia cujo controle foi desapropriado (art. 236, parágrafo único) tem o direito de se retirar da sociedade, recebendo o reembolso de suas ações (art. 45). A base para o cálculo do reembolso é o valor patrimonial das ações do acionista dissidente. Assim, o acionista que se retira terá direito de receber da sociedade, por ação que titulariza, a importância equivalente à divisão do patrimônio líquido da companhia pelo número de ações. Em princípio, o patrimônio líquido da sociedade é o constante do último balanço aprovado. Pode-se verificar, no entanto, a defasagem desse valor, caso em que inevitavelmente ocorreria uma injustiça (em desfavor do dissidente, se o valor histórico é inferior ao atual, ou em desfavor da sociedade, se é superior). Para evitar a injustiça contra o acionista dissidente, a lei admite que ele peça o levantamento de um balanço especial (LSA, art. 45, § 2.º); para evitar a injustiça contra a sociedade, ela faculta aos estatutos a previsão de pagamento, a título de reembolso, do valor econômico das ações (LSA, art. 45, §§ 3.º e 4.º).

O direito de voto, conforme já assinalado, não é direito essencial, posto existirem ações que não o conferem a seus titulares. A lei disciplina o exercício do direito de voto, e coíbe o voto abusivo e o conflitante. Voto abusivo é aquele em que o acionista tem em vista causar dano à companhia ou a outro acionista, ou obter, para si ou para outrem, vantagem indevida e da qual resulte ou possa resultar prejuízo para a sociedade ou outro acionista. O acionista responde, civilmente, pelos danos que causar com o voto abusivo. Já o voto conflitante, cuja caracterização dispensa qualquer elemento subjetivo, vem elencado em lei. O acionista não pode votar nas deliberações sobre o laudo de avaliação de bens com os quais pretende integralizar suas ações, nem na aprovação das suas contas como administrador, nem nas questões que possam beneficiá-lo de modo particular ou nas que tiver interesse conflitante com o da companhia (LSA, art. 115, § 1.º). A decisão tomada em função de voto conflitante é anulável, sem prejuízo da responsabilidade civil do acionista por eventuais danos decorrentes.

11. ACORDO DE ACIONISTAS

Os acionistas podem, livremente, compor seus interesses por acordo que celebrem entre si. Terão, em decorrência, a proteção que a lei dispensa aos contratos em geral. Caso, entretanto, tais acordos versem sobre três temas determinados, a seguir referidos, e estejam arquivados na sede da companhia, tais acordos estarão sujeitos a uma proteção especificamente liberada pela LSA.

Assim, se o acordo tem por objeto o exercício do poder de controle ou do direito de voto, a compra e venda de ações ou a preferência de sua aquisição, o seu arquivamento junto à companhia impede que ela pratique atos que contrariem o conteúdo do acordo. Se um acionista concordou em conceder direito de preferência a outro, mas vendeu suas ações a terceiro, descumprindo o acordo arquivado na companhia, esta não poderá registrar a transferência de titularidade das ações. Não há, no entanto, como a própria sociedade tornar efetivo o direito de preferência, por parte do acionista prejudicado. Este deve se socorrer do Poder Judiciário que, substituindo a vontade do acionista alienante, concederá a preferência ao demandante.

No tocante ao acordo de acionista que tenha por objeto o exercício do direito de voto, não pode ocorrer a venda deste, fato tipificado como crime. O acordo de acionista, assim, só pode versar sobre o exercício do "voto-vontade" (eleição de administradores, aumento de capital social etc). O "voto-verdade" (votação das contas dos administradores ou do laudo de avaliação de bens para integralização do capital social) não pode ser objeto de acordo de acionistas, porque importaria em venda de voto.

12. PODER DE CONTROLE

O acionista (ou grupo de acionistas vinculados por acordo de voto) titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria de votos na assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores e usa, efetivamente, desse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia é considerado o "acionista controlador" (LSA, art. 116). Para a sua configuração, é necessária a convergência destes dois elementos: ser maioria societária (não no sentido de necessariamente titularizar a maior parte do capital social, mas no de possuir ações que lhe garantam a maioria nas decisões tomadas pelas 3 últimas assembleias) e fazer uso dos direitos decorrentes desta situação para dirigir a sociedade.

O acionista controlador responde pelos danos que causar por abuso de poder, exemplificando a lei o exercício abusivo do poder de controle no art. 117. Dentre as hipóteses ali encontradas, destacam-se o desvio de finalidade da companhia, a liquidação de sociedade próspera, a eleição de administrador ou fiscal sabidamente inapto, moral ou tecnicamente etc. Se de qualquer destes atos, ou outros que configurem abuso de poder, decorrer dano à companhia, seus acionistas e empregados, ou à comunidade em que atua, o controlador responderá pela respectiva indenização.

Para responsabilizar o controlador pelos danos advindos do exercício abusivo do poder de controle, não é necessário provar a sua intenção. Entende a doutrina que exigir tal prova (diabólica) poderia significar o esvaziamento do direito à indenização reconhecido pelo legislador, dada a extrema dificuldade de sua produção.

Cabe mencionar, ainda, outras hipóteses em que a lei imputa responsabilidade ao controlador da sociedade anônima. Por exemplo, ele pode ser responsabilizado, em caso de dolo ou culpa, se a sociedade anônima é instituição financeira, na hipótese de decretação, pelo Banco Central, do regime de administração especial temporária (Decreto-lei 2.321/85, art. 15), liquidação extrajudicial ou

intervenção (Lei 9.447/97). Igual responsabilidade tem o controlador de seguradora, entidade de previdência privada aberta e companhia de capitalização (Lei 10.190/2001).

As ações que dão sustentação ao poder de controle costumam ser negociadas por valor substancialmente maior que o das demais, inclusive ordinárias emitidas pela mesma sociedade. A diferença é chamada, no mercado, de "prêmio de controle". Quando alguém adquire ações que lhe possibilitam passar a controlar a sociedade anônima, não está apenas acrescentando ao seu patrimônio o direito de participar dos seus dividendos e resultados, mas também vários outros, como o de eleger os administradores, definir a estratégia geral da empresa, reestruturar a sociedade, aumentar o capital social, estabelecer a destinação não vinculada dos resultados etc. É racional e justo que, em razão disso, pague mais pelas ações de sustentação do controle.

Algumas vezes, porém, no "prêmio de controle" está embutida retribuição a valor agregado à companhia não pelo controlador, mas por minoritários. Se a sociedade havia captado recursos no mercado de capitais, com a emissão de ações preferenciais não votantes, pouco antes da alienação do controle, o caixa elevado da companhia decorrente desta operação certamente será considerado na negociação do preço das ações do controlador. A liquidez da companhia, no entanto, é valor agregado pelos que subscreveram as preferenciais, e não pelo controlador. Está ocorrendo apropriação, via "prêmio de controle", de valor que o controlador não agregou ao negócio.

Para evitar esta distorção, os acionistas minoritários devem condicionar o ingresso na sociedade à *cláusula de saída conjunta*, no estatuto ou em acordo de acionistas (em inglês, *tag along*). Quando prevista esta cláusula, o controlador não pode vender suas ações isoladamente. Quer dizer, só poderá vendê-las a quem se comprometa a adquirir também as dos beneficiados pela cláusula. Viabiliza-se, deste modo, a distribuição do "prêmio de controle" entre os acionistas com direito de saída conjunta.

Nas companhias abertas, a cláusula de saída conjunta está prevista na lei em favor dos acionistas com direito a voto. Nelas, a alienação das ações que dão sustentação ao poder de controle só pode ser feita mediante condição (suspensiva ou resolutiva) de o adquirente adquirir, por oferta pública, as demais ações com direito a voto daquela sociedade, pagando no mínimo 80% do preço pago pelas do controlador (LSA, art. 254-A). Os preferencialistas sem direito a voto só têm direito de saída conjunta se previsto como vantagem estatutária.

13. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A LSA estabelece o dever de a companhia levantar, ao término do exercício social, um conjunto de demonstrações contábeis, com vistas a possibilitar o conhecimento, pelos acionistas e por terceiros, de sua situação patrimonial, econômica e financeira, bem como dos resultados positivos ou negativos alcançados pela empresa.

Essas demonstrações não são úteis apenas para o direito societário comercial. Servem também a finalidades preceituadas pela legislação tributária. São instrumentos valiosos, por outro lado, para a administração da sociedade e o controle gerencial, desempenhando, desse modo, funções não jurídicas também. O estudo dessas demonstrações pelo direito comercial restringe-se aos dados relevantes para o tratamento das relações entre os acionistas e destes com os órgãos de administração.

Exercício social é o período de um ano definido pelos estatutos (LSA, art. 175). Para a sua fixação,

pode-se optar por qualquer lapso anual, embora, na grande maioria dos casos, e por estrito critério de conveniência, defina-se o fim do exercício social em 31 de dezembro. No ano em que a companhia foi constituída ou em que houve alteração estatutária, o exercício social poderá ser menor ou maior.

Findo o exercício social, a diretoria deve providenciar o levantamento das demonstrações financeiras. Quando a companhia é fechada, são quatro instrumentos contábeis a serem providenciados: *a) balanço patrimonial; b) lucros ou prejuízos acumulados; c) resultado do exercício; d) fluxos de caixa* (LSA, art. 176, I a IV). Sendo aberta a companhia, exige-se, além dessas demonstrações, também a do "valor adicional" (art. 176, V). Tais demonstrações, chamadas pela lei de *financeiras*, devem basear-se na escrituração mercantil da sociedade anônima e serão publicadas para oportuna apreciação na Assembleia Geral Ordinária (art. 132, I), juntamente com o relatório dos administradores.

Na escrituração mercantil da companhia, prevê a lei, deverá ser observado o regime de *competência*. Trata-se de conceito fundamental da Contabilidade, pelo qual se define que as apropriações contábeis das operações e as mutações patrimoniais decorrentes serão feitas no exercício correspondente ao da constituição da obrigação e não ao de sua liquidação. Não se admite, portanto, a adoção do regime de *caixa* (também denominado regime de *gestão*), em que a apropriação contábil coincide com o pagamento da obrigação e não com o seu nascimento.

O *Balanço Patrimonial* é a demonstração financeira que informa o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da sociedade anônima. Tem importância jurídica, por exemplo, no cômputo do reembolso pelo valor patrimonial das ações.

A *Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados* informa as parcelas dos lucros aferidos pela companhia e não distribuídos aos acionistas ou os prejuízos não absorvidos por sua receita. É instrumento de grande importância para a definição da política empresarial de investimentos, a ser adotada na sociedade.

A *Demonstração do Resultado do Exercício* apresenta dados sobre o desempenho da companhia durante o último exercício e possibilita ao acionista avaliar não somente o grau de retorno de seu investimento, como a eficiência dos atos da administração. Os seus elementos contábeis básicos são a receita e a despesa, discriminadas de acordo com a respectiva natureza (receita bruta e líquida, despesa operacional e não operacional etc.).

A *Demonstração dos Fluxos de Caixa* visa a evidenciar os ingressos e desembolsos do caixa da sociedade anônima, isto é, suas disponibilidades líquidas. Quando a sociedade anônima é fechada e possui o patrimônio líquido inferior a R\$ 2.000.000,00, a lei a dispensa de levantar essa demonstração contábil.

A *Demonstração de Valor Adicionado*, por fim, é a medida contábil da riqueza gerada pela companhia. Só as companhias abertas estão obrigadas ao seu levantamento, e trata-se de instrumento de pouco interesse para os profissionais do direito.

14. LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS

O resultado do exercício, revelado na respectiva demonstração financeira, tem a sua destinação em parte definida pela lei. Desse modo, após a absorção de prejuízos acumulados, a provisão para o Imposto de Renda (LSA, art. 189) e o pagamento das participações estatutárias de empregados,

administradores e partes beneficiárias (art. 190), o lucro líquido gerado pela empresa durante o último exercício terá dois possíveis destinos: ficará em mãos da própria sociedade ou será distribuído entre os acionistas, a título de dividendos. Aliás, uma parcela dos lucros permanecerá obrigatoriamente na companhia (por meio da reserva legal) e outra será necessariamente distribuída aos acionistas (dividendo obrigatório), restando à Assembleia Geral Ordinária deliberar quanto à destinação do restante do resultado, aprovando ou rejeitando a proposta da diretoria (LSA, art. 192). Para tanto, abrem-se três alternativas: constituição de reserva de lucro, distribuição de dividendos ou capitalização (aumento ao Capital social).

Há seis categorias de reservas de lucro.

a) reserva *legal* - ela é constituída por 5% do lucro líquido, desde que não ultrapasse 20% do capital social (LSA, art. 193). A companhia deve obrigatoriamente manter esta reserva, que somente poderá ser utilizada para aumento do capital social ou absorção de prejuízos.

b) reserva *estatutárias* - como o nome indica, é definida pelos estatutos para o atendimento de necessidades específicas da sociedade anônima, ou por cautelas próprias dos seus acionistas.

c) reserva para *contingências* - é destinada à compensação, em exercício futuro, de diminuição de lucro derivada de evento provável, como, por exemplo, a condenação da sociedade anônima em demanda judicial. A reversão dessa reserva será feita no exercício em que ocorrer o evento ou afastar-se a possibilidade de sua verificação.

d) reserva de *incentivos fiscais* - ela se destina a excluir da base de cálculo dos dividendos a parcela do lucro da sociedade proveniente de doações ou subvenções governamentais para investimento.

e) reserva de *retenção de lucros* - esta reserva tem o objetivo de atender às despesas previstas em orçamento de capital previamente aprovado em Assembleia Geral. Normalmente é utilizada para prover recursos para investimentos em exercícios futuros.

f) reserva de *lucros a realizar* - visa a impedir a distribuição entre acionistas de recursos que somente irão ingressar no caixa da sociedade em exercícios futuros, embora devam estar já contabilizados em razão da adoção legal do regime de competência.

Além das reservas de lucro, há, ainda, a de capital.

Na reserva de capital, encontram-se contas que, embora não integrem o capital social da companhia, guardam alguma relação com ele. Devem ser classificadas como reservas de capital contas como as seguintes: ágio na subscrição de novas ações e o produto da venda de partes beneficiárias e bônus de subscrição, doações (LSA, art. 182, § 1.º). Estes recursos somente poderão ser utilizados pela companhia em determinadas situações, como, por exemplo, para a absorção de prejuízos, após o exaurimento dos lucros acumulados e das reservas de lucros, utilizando-se a legal por último (art. 189, parágrafo único), o resgate de partes beneficiárias ou o pagamento de dividendos preferenciais, se prevista tal possibilidade pelos estatutos (art. 200, III e V).

Os dividendos obrigatórios são a parcela do lucro líquido da sociedade que a lei determina seja distribuído entre os acionistas (LSA, art. 202). Inovação interessante da lei brasileira de 1976, os dividendos obrigatórios asseguram aos acionistas minoritários algum retorno de seus investimentos,

impedindo que o controlador reinvesta na própria companhia todos os resultados gerados.

A parcela mínima dos lucros a ser necessariamente distribuída entre os acionistas será a definida pelo estatuto. Na hipótese de omissão deste, prevê a lei a distribuição de pelo menos metade do lucro líquido ajustado. Além do percentual do lucro líquido da sociedade previsto no estatuto (ou na lei), também deve ter a destinação de dividendo obrigatório a parcela deste lucro não apropriada em reservas legais ou estatutárias (LSA, art. 202, § 6.º).

A distribuição do dividendo obrigatório somente não será feita em duas hipóteses: se os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária que a situação financeira da companhia não é compatível com o seu pagamento; ou por deliberação da Assembleia Geral de companhia fechada, se não houver oposição de qualquer dos acionistas presentes. Nestas situações, os lucros não distribuídos constituirão reserva *especial*, e serão atribuídos aos acionistas se e quando o possibilitar a situação financeira da companhia.

Os dividendos prioritários são os devidos aos titulares de ações preferenciais; podem ser, de acordo com a previsão estatutária, fixos ou mínimos.

Os dividendos prioritários fixos atribuem ao acionista o direito ao recebimento de determinado valor, estipulado em moeda nacional ou em percentual do capital social ou do preço de emissão. Já os dividendos prioritários mínimos atribuem o direito ao recebimento de valor nunca inferior a certa importância ou percentual. Desse modo, o acionista titular de ação preferencial com direito a dividendo fixo poderá receber menos ou mais que o pago aos acionistas titulares de ação ordinária, enquanto o beneficiado por dividendo mínimo receberá valor igual ou superior ao pago às ordinárias.

O dividendo prioritário deve ser apropriado contabilmente após a constituição da reserva legal, mas antes da constituição das demais reservas de lucro. Por outro lado, poderá o estatuto estipular o pagamento de dividendos prioritários à conta de reserva de capital, regulando a matéria. Se o pagamento dos dividendos prioritários consumir toda a parcela dos lucros destinada à distribuição entre os acionistas, os titulares de ações ordinárias não receberão qualquer soma naquele exercício. Essa situação não contraria a previsão legal dos dividendos obrigatórios, desde que aos titulares de ações preferenciais tenha sido pago o percentual correspondente do lucro líquido ajustado definido pelos estatutos.

Por fim, lembre-se que a legislação previdenciária proíbe a sociedade anônima de distribuir dividendos entre os acionistas enquanto se encontrar em débito perante o INSS (Lei 8.212/91, art. 52). Em se verificando a hipótese, no entanto, a autarquia previdenciária *não* terá direito de reclamar dos acionistas os valores que estes receberam indevidamente. A sanção para o descumprimento da proibição legal, no caso, é apenas a imposição de uma multa a ser suportada pela companhia. Assim, se a fiscalização do INSS constatar, pelo exame da escrituração de uma sociedade anônima, que ela distribuiu lucros a despeito da existência de débito previdenciário, esta - e não os acionistas - será apenada.

15. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Diz o art. 219 da LSA que a sociedade anônima se extingue pelo encerramento da liquidação, que se segue à dissolução, ou pela incorporação, fusão e cisão com versão de todo patrimônio em outras sociedades.

A sociedade anônima, em virtude de sua natureza institucional, está sujeita ao regime dissolutório previsto nos arts. 206 a 218 da LSA. Segundo este regime, a dissolução da companhia pode dar-se de pleno direito, por decisão judicial ou por decisão de autoridade administrativa competente. São causas determinantes da primeira modalidade de dissolução o término do prazo de duração, os casos previstos em estatuto, a deliberação da assembleia geral por acionistas detentores de, no mínimo, metade das ações com voto, por unipessoalidade incidente, e, finalmente, pela extinção da autorização para funcionar. São causas da dissolução judicial a anulação da constituição da companhia, proposta por qualquer acionista, a irrealizabilidade do objeto social, provada em ação proposta por acionista que represente 5% ou mais do capital social, e, finalmente, a falência.

Deve-se acentuar que a dissolução por vontade dos acionistas não exige a unanimidade, decorrência natural do caráter institucional da sociedade anônima. Esta dissolução poderá ser decidida por quem represente metade, pelo menos, do capital votante (LSA, art. 136, VII). À dissolução segue-se a liquidação, que será judicial sempre que aquela o for e mais nas hipóteses de pedido de qualquer acionista, ou do representante do Ministério Público, quando a liquidação amigável não for processada a contento.

Se a liquidação for irregular, poderá ser responsabilizado o liquidante, ou mesmo o acionista, prescrevendo a correspondente ação judicial em 1 ano, contado da publicação da ata de encerramento da liquidação (LSA, art. 287, I, *b*).

16. TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO

Os procedimentos de reorganização das empresas que envolverem pelo menos uma sociedade anônima devem atender à disciplina da LSA. Não havendo na operação sociedade deste tipo, a disciplina é a do CC (arts. 1.113 a 1.122). São quatro operações, pelas quais as sociedades mudam de tipo, aglutinam-se ou dividem-se, procurando os seus sócios e acionistas dotá-las do perfil mais adequado à realização dos negócios sociais.

A transformação é a operação de mudança de tipo societário: a sociedade limitada torna-se anônima, ou vice-versa. Pode dizer respeito aos cinco tipos de sociedades personalizadas do direito brasileiro e não acarreta a dissolução e liquidação do ente societário. Aliás, a transformação não extingue a pessoa jurídica da sociedade, nem cria outra nova. É o mesmo sujeito de direito coletivo anterior à transformação que permanece.

O procedimento da transformação deve obedecer às mesmas formalidades preceituadas para a constituição da sociedade do tipo resultante. A sua deliberação exige a aprovação unânime de todos os sócios ou acionistas (inclusive os titulares de ações preferenciais sem voto), salvo se o ato constitutivo já admite a possibilidade da transformação. Na hipótese de previsão contratual ou estatutária da transformação da sociedade, no entanto, os sócios dissidentes poderão exercer o direito de retirada (LSA, art. 221).

A incorporação é a operação pela qual uma sociedade absorve outra ou outras, as quais deixam de existir; a fusão consiste na união de duas ou mais sociedades, para dar nascimento a uma nova; e a cisão é a transferência de parcelas do patrimônio social para uma ou mais sociedades, já existentes ou constituídas na oportunidade. Estas três operações submetem-se a regras comuns de procedimento, cabendo a deliberação ao órgão societário competente para alteração do ato constitutivo.

A incorporação não se confunde com a incorporação de ações. Esta última está disciplinada no art. 252 da LSA e importa a conversão de sociedade anônima em subsidiária integral. Na incorporação de ações, todas as ações do capital social de uma companhia são transferidas ao patrimônio de uma sociedade empresária, que passa à condição de sua única acionista. É indispensável que essa sociedade, detentora de todo o capital social da anônima, seja brasileira.

Tem início a incorporação, a fusão ou a cisão com versão patrimonial para sociedade existente com a formalização de um protocolo pelos órgãos de administração das sociedades envolvidas ou seus sócios. Se uma sociedade anônima for interessada na operação, a lei exige também a apresentação à Assembleia Geral de justificação (LSA, art. 225). Em seguida, procede-se à avaliação do patrimônio a ser vertido, mediante perícia técnica, de modo a assegurar a equivalência entre o seu valor e o capital a realizar.

A lei faculta o direito de retirada aos acionistas cuja sociedade foi incorporada em outra. Note-se que o acionista da sociedade incorporadora não tem esse direito, na hipótese em que discorda da operação. Também no caso de fusão de sociedades terão os dissidentes direito de retirada. Deve-se atentar, contudo, que há certas condições para o recesso, isto é, o acionista só poderá retirar-se da companhia se, sendo aberta a sociedade, as ações desta não compuserem índices gerais de bolsas de futuro ou se mais da metade das ações estiver em mãos do controlador. Nessas duas situações, consideram-se ilíquidas as ações emitidas pela companhia (isto é, são ações difíceis de se negociarem, mesmo no MVM), e por isso o acionista não tem uma real alternativa econômica ao reembolso. Na cisão, só há direito de retirada se a operação societária acarretar a participação do acionista em sociedade com objeto essencial diferente ou dividendos obrigatórios menores que os da cindida, ou integrante de grupo a que não pertencia a cindida.

Os direitos dos credores, nessas operações, estão claramente definidos. Na transformação eles continuam titularizando as mesmas garantias dadas pelo tipo societário anterior, até integral satisfação de seus créditos. Assim, a transformação de sociedade em nome coletivo em comandita por ações não impede que o credor anterior à operação responsabilize os sócios ilimitadamente. Na incorporação e na fusão, o credor prejudicado pela nova situação da sociedade devedora poderá pleitear em juízo a anulação da operação. Falindo a sociedade incorporadora ou a resultante de fusão, os credores anteriores poderão requerer no juízo falimentar a separação das massas. Finalmente, na cisão, define a lei a solidariedade entre as sociedades resultantes da operação por todas as obrigações da cindida. Se o instrumento da cisão estabelecer que as sociedades resultantes obrigar-se-ão somente pelas dívidas a elas transferidas, o credor poderá opor-se a essa definição de distribuição de responsabilidades no prazo de 90 dias (LSA, art. 233).

A incorporação, a fusão ou a cisão de sociedade anônima emissora de debêntures não poderão ocorrer sem a prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia, a menos que se assegure o resgate do valor mobiliário nos 6 meses seguintes à operação (LSA, art. 231).

A incorporação e a fusão de sociedades estão condicionadas à aprovação pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica sempre que pelo menos um dos grupos envolvidos tiver faturamento bruto anual ou volume de negócios no País igual ou maior que R\$ 400.000.000,00 e o outro, maior ou igual a R\$ 30.000.000,00 (LIOE, art. 88).

17. GRUPOS DE SOCIEDADE E CONSÓRCIO

A associação de esforços empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns,

pode resultar em três diferentes situações: os grupos *de fato*, os *de direito* e os *consórcios*.

Os grupos de fato se estabelecem entre sociedades coligadas ou entre controladora e controlada. Coligadas são aquelas em que uma tem influência significativa sobre a outra, sem, contudo, controlá-la. Já controladora é aquela que detém o poder de controle de outra companhia. Em regra, a lei veda a participação recíproca entre a sociedade anônima e suas coligadas ou controladas, abrindo exceção somente para as hipóteses em que a companhia pode adquirir as próprias ações (LSA, arts. 244 e 30, § 1.º, *b*).

Uma hipótese específica de controle de sociedade por outra se revela na constituição de *subsidiária integral*, a única sociedade unipessoal originária admitida pelo direito brasileiro. A outra previsão legal de unipessoalidade diz respeito à sociedade anônima com mais de um sócio no momento da constituição, mas que, temporariamente, tem todas as suas ações reunidas nas mãos de uma só pessoa (LSA, art. 206, I, *d*). Subsidiária integral é, de acordo com a previsão legal, a sociedade anônima constituída por escritura pública cujo único acionista é uma sociedade. Esta última pode ser de qualquer tipo (anônima ou não), mas necessariamente brasileira.

Em relação aos grupos de fato, preocupou-se o legislador, basicamente, em garantir maior transparência nas relações entre as coligadas e entre as controladas e sua controladora, por meio de regras próprias sobre as demonstrações financeiras (LSA, arts. 247 a 250).

Grupo de direito, ao seu turno, é o conjunto de sociedades cujo controle é titularizado por uma brasileira (a sociedade comandante, ou *holding*) e que, mediante convenção acerca de combinação de esforços ou participação em atividades ou empreendimentos comuns, formalizam essa relação interempresarial. Os grupos devem possuir *designação*, da qual constará palavra identificadora da sua existência ("grupo" ou "grupo de sociedades": art. 267 da LSA), e devem estar devidamente registrados na Junta Comercial.

Registre-se que o grupo não tem personalidade jurídica própria, sendo apenas uma relação interempresarial formalizada. Por outro lado, entre as sociedades integrantes do mesmo grupo não há, em regra, solidariedade, exceto perante as autoridades antitruste (LIOE, art. 33) e pelas dívidas trabalhistas (CLT, art. 2.º, § 2.º) e previdenciárias (Lei 8.212/91, art. 30, IX). Não há, também, em regra, subsidiariedade entre as sociedades de um mesmo grupo, salvo quanto às obrigações relacionadas a contrato de consumo (CDC, art. 28, § 2.º). Os grupos podem contar com estrutura administrativa própria, consistente em órgãos colegiados e cargos de direção-geral.

Por fim, se duas sociedades quiserem combinar seus esforços e recursos para o desenvolvimento de empreendimento comum, elas podem contratar a formação de um consórcio. As consorciadas respondem pelas obrigações especificadas no instrumento de consórcio, já que este não tem personalidade jurídica própria. Não há, por outro lado, solidariedade presumida entre elas, exceto nas obrigações relacionadas com os direitos do consumidor (CDC, art. 28, § 3.º) e nas licitações (Lei 8.666/93, art. 33, V).

O acionista que discorda da deliberação da assembleia geral, no sentido de vir a companhia a participar de grupo societário, tem direito de retirada se as ações que titulariza não possuírem liquidez (LSA, art. 137, II). A falta de liquidez das ações se caracteriza, de acordo com a lei, em duas hipóteses: *a*) quando as ações de emissão da sociedade anônima a que pertence o dissidente não integram índice geral de bolsa de futuro; *b*) se mais da metade das ações emitidas pela sociedade aberta se encontra centralizada em mãos dos controladores. Desse modo, se as ações têm liquidez e são, portanto,

facilmente negociáveis nos mercados abertos de capital, o acionista não terá direito de recesso, exatamente porque as poderá vender no MVM.

18. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

A sociedade de economia mista é a sociedade anônima cujo capital social é constituído por recursos provenientes, em parte majoritária, do poder público e, em parte minoritária, dos particulares. Sua constituição depende de lei, que poderá, evidentemente, estabelecer normas diferentes das previstas pela legislação do anonimato. Tais normas, no entanto, aplicam-se, tão somente, à sociedade de economia mista em particular. As companhias de economia mista abertas estão, por outro lado, sujeitas ao controle e fiscalização da CVM.

A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem as mesmas responsabilidades do acionista controlador, porém a própria lei ressalva que a orientação dos negócios sociais pode ser feita de molde a atender ao interesse público que justificou a criação da sociedade. O que há, em particular, é a possibilidade de comprometimento dos recursos sociais em atividades relativamente deficitárias, importando em diminuição global do lucro líquido da sociedade, em virtude da realização do bem comum que inspirou a sua constituição. O acionista particular de sociedade de economia mista está ciente, ao ingressar no quadro associativo da companhia, desta particularidade, ou seja, de que, eventualmente, seja obrigado a suportar ligeira diminuição na rentabilidade de seu investimento, por força do atendimento de interesse maior que o seu. É claro que esta diminuição não poderá ser de tal porte que implique a descaracterização do investimento feito como negócio de conteúdo privado. Não cabe ao acionista suprir, com o seu patrimônio, graves defasagens na prestação do serviço público. O acionista controlador poderá, portanto, vir a ser responsabilizado pelos demais acionistas particulares da sociedade de economia mista, sempre que, em decorrência do cumprimento do disposto no art. 238 da LSA, desenvolver atividade empresarial altamente deficitária. A fundamentação deste entendimento se vale, inclusive, da responsabilidade objetiva da Administração Pública.

As sociedades de economia mista terão conselho de administração obrigatoriamente e o conselho fiscal em funcionamento permanente (arts. 239 e 240).

19. SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES

O derradeiro tipo societário é a sociedade em comandita por ações, à qual se aplicam todas as normas relativas à sociedade anônima, com as alterações previstas nos arts. 1.090 a 1.092 do CC (LSA, arts. 280 a 284). Algumas dessas alterações têm em vista a peculiar posição em que se encontram os diretores da sociedade em comandita por ações. São desta categoria as seguintes disposições legais:

a) *Responsabilidade dos diretores* - o acionista diretor da sociedade em comandita por ações (também chamado gerente) tem responsabilidade ilimitada pelas obrigações da sociedade (art. 1.091). Por essa razão, somente o acionista poderá fazer parte da diretoria. Ademais, os diretores serão nomeados pelo estatuto, por prazo indeterminado, e somente podem ser destituídos por deliberação de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social.

b) *Nome empresarial* - a sociedade em comandita por ações pode adotar firma ou denominação, sendo que, no primeiro caso, não poderá compor seu nome empresarial aproveitando o nome civil de acionista que não seja diretor. Em ambas as hipóteses, o nome empresarial deverá conter expressão

identificativa do tipo societário (CC, art. 1.161).

c) *Deliberações sociais* - ainda em razão da responsabilidade ilimitada dos diretores, a assembleia geral não tem poderes para, sem a anuência destes, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar o seu prazo de duração, aumentar ou reduzir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias (art. 1.092).

Feitas as ressalvas, portanto, aplicam-se às sociedades em comandita por ações todas as demais normas pertinentes às sociedades anônimas, tais as relativas às espécies, forma e classe de ações, debêntures, partes beneficiárias, constituição e dissolução, poder de controle, direitos essenciais do acionista, e assim por diante.

TERCEIRA PARTE - DIREITO CAMBIÁRIO

(Autor)

Fábio Ulhoa Coelho

Capítulo 16. TEORIA GERAL DO DIREITO CAMBIÁRIO

1. CONCEITO DE TÍTULO DE CRÉDITO

Os títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem com a própria obrigação, porque a representam.

Uma determinada obrigação pode ser representada por diferentes instrumentos jurídicos. Se uma pessoa, agindo com culpa, provoca danos em bens de propriedade alheia com o seu automóvel, deste ato ilícito surgirá a obrigação de indenizar os prejuízos causados. Se devedor e credor estiverem de acordo quanto à existência da obrigação e também quanto à sua extensão (o valor da indenização devida), esta pode ser representada por um título de crédito - cheque, nota promissória ou letra de câmbio, no caso. Se as partes concordam quanto à existência da obrigação, mas não têm condições de mensurar sua extensão, ou chegar a um acordo sobre esta, a mesma obrigação de indenizar os danos provenientes do acidente poderia ser representada por um "reconhecimento de culpa". Se, porém, não concordam sequer com a existência da obrigação (o motorista do veículo entende não ter agido com culpa, por exemplo), a obrigação de indenizar somente poderá ser documentada por outro título jurídico - uma decisão judicial que julgue procedente a ação de ressarcimento promovida pelo prejudicado.

Nestes exemplos, uma mesma e única obrigação, a de indenizar os danos decorrentes do ilícito, foi representada por três documentos jurídicos distintos: título de crédito, reconhecimento de culpa e sentença judicial. Outros poderiam ser lembrados. O que interessa acentuar, de início, é esta natureza do título de crédito, esta sua essencialidade de instrumento representativo de obrigação.

As obrigações representadas em um título de crédito ou têm origem extracambial (como no exemplo acima ou no caso de um contrato de compra e venda, mútuo etc.) ou têm origem exclusivamente cambial (como na obrigação do avalista).

Da circunstância de ser representada determinada obrigação por um ou outro instrumento decorrem consequências jurídicas bem distintas. O credor de obrigação representada por um título de crédito tem direitos, de conteúdo operacional, diversos do que teria se a mesma obrigação não se encontrasse representada por um título de crédito. Basicamente, há duas especificidades que beneficiam o credor por um título de crédito: ele possibilita uma negociação mais fácil do crédito representado e a cobrança judicial deste é mais eficiente e célere. A estas circunstâncias especiais costuma a doutrina se referir como os atributos dos títulos de crédito chamados respectivamente de negociabilidade (facilidade de circulação do crédito) e executividade (maior eficiência na cobrança).

Voltando ainda ao mesmo exemplo, o credor da indenização, se a tiver representada num título de crédito, poderá utilizar o crédito em seu giro econômico com mais facilidade - poderá, por exemplo, oferecê-lo como garantia em empréstimo bancário ou pagar seus próprios credores com o título, endossando-o. A mesma facilidade não existirá se o crédito estiver representado por sentença judicial ou por documento de reconhecimento de culpa. E em caso de inadimplemento do devedor, o credor de um título de crédito não precisa promover a prévia ação de conhecimento, para somente depois poder executar o seu crédito. Os títulos de crédito são definidos em lei como títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 784, I), e, assim, possibilitam a execução imediata do valor devido. Este mesmo direito, de conteúdo operacional, não teria o credor cujo crédito estivesse representado pelo documento de reconhecimento de culpa.

O conceito de título de crédito mais corrente, elaborado pelo jurista italiano Vivante, é o seguinte: "Documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado". Deste conceito é possível extraírem-se os princípios gerais do regime jurídico-cambial, do direito cambiário.

2. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO CAMBIÁRIO

Três são os princípios que informam o regime jurídico-cambial: cartularidade, literalidade e autonomia.

Cartularidade. Para que o credor de um título de crédito exerça os direitos por ele representados é indispensável que se encontre na posse do documento (também conhecido por "cártula"). Sem o preenchimento dessa condição, mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer seus direitos. Por isso é que se diz, no conceito de título de crédito, que ele é um documento *necessário* para o exercício do direito nele mencionado. Em virtude desse princípio, não é possível promover a execução judicial do crédito representado instruindo-se a petição inicial com cópia xerográfica do título de crédito. A execução (assim também o pedido de falência baseado na impontualidade do devedor) somente poderá ser ajuizada acompanhada do original do título de crédito, da própria cártula, como garantia de que o exequente é o credor, de que ele não negociou o seu crédito. Este é o princípio da cartularidade.

Ultimamente, o direito tem criado algumas exceções ao princípio da cartularidade, em vista da informalidade que caracteriza os negócios comerciais. Assim, a Lei das Duplicatas admite a execução judicial de crédito representado por este tipo de título sem a sua apresentação pelo credor (LD, art. 15, § 2.º) (*Cap.* 22, item 4). Outro importante fato que tem interferido com a atualidade desse princípio é o desenvolvimento da informática no campo da documentação de obrigações comerciais, com a criação de títulos de crédito eletrônicos, que não são cartulares.

Literalidade. Segundo o princípio da literalidade, não terão eficácia para as relações jurídico-cambiais os atos jurídicos não instrumentalizados pela própria cártula a que se referem. O que não se encontra expressamente consignado no ter do título de crédito não produz efeitos nas relações jurídico-cambiais. Um aval concedido em instrumento apartado da nota promissória, por exemplo, não produzirá os efeitos de aval, podendo, no máximo, gerar efeitos na órbita do direito civil, como fiança. A quitação pelo pagamento de obrigação representada por título de crédito deve constar do próprio título, sob pena de não liberar o devedor da obrigação.

Autonomia. Pelo princípio da autonomia, entende-se que as obrigações representadas por um mesmo

título de crédito são independentes entre si. Se uma dessas obrigações for nula ou anulável, eivada de vício jurídico, tal fato não comprometerá a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito. Se o comprador de um bem a prazo emite nota promissória em favor do vendedor e este paga uma dívida dele, perante terceiro, transferindo-lhe o crédito representado pela nota promissória, caso o bem vendido venha a ser restituído ao vendedor em razão de vício redibitório, o comprador não se libera da obrigação de pagar o título junto ao terceiro. Deverá, ao contrário, pagá-lo e, em seguida, demandar ressarcimento perante o vendedor da compra e venda frustrada.

O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios: abstração e inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. São subprincípios porque, embora formulados diferentemente, nada acrescentam à disciplina decorrente do princípio da autonomia.

O subprincípio da abstração é uma formulação derivada do princípio da autonomia que dá relevância à ligação entre o título de crédito e a relação, ato ou fato jurídicos que deram origem à obrigação por ele representada; o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, por sua vez, é, apenas, o aspecto processual do princípio da autonomia, ao circunscrever as matérias que poderão ser arguidas como defesa pelo devedor de um título de crédito executado.

Os três princípios do direito cambiário não são produtos do engenho do legislador e dos juristas, apenas. Ao contrário, decorrem de um longo processo histórico, em que os comerciantes vêm desenvolvendo e aprimorando os mecanismos de tutela do crédito comercial. Neste sentido, entende-se como um determinado empresário credor pode receber, com segurança, em pagamento por parte de seu devedor, um título de crédito de que este seja o titular, de responsabilidade de um desconhecido. Com efeito, há um complexo aparato jurídico estruturado (o regime jurídico-cambial) que garante ao empresário credor: *a*) aquela pessoa que lhe transfere o título (o seu devedor) não poderá cobrá-lo mais (princípio da cartularidade); *b*) todas as relações jurídicas que poderão interferir com o crédito adquirido são apenas aquelas que constam, expressamente, do título e nenhuma outra (princípio da literalidade); e *c*) nenhuma exceção pertinente à relação da qual ele não tenha participado terá eficácia jurídica quando da cobrança do título (princípio da autonomia).

Tendo, então, estas garantias, o empresário se sentirá seguro em receber em pagamento de seu crédito um título devido por alguém que desconhece. Desta forma, o direito protege o próprio crédito comercial e possibilita a sua circulação com mais facilidade e segurança, contribuindo para o desenvolvimento da atividade comercial.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

A classificação dos títulos de crédito se faz por quatro principais critérios, a saber: *a*) quanto ao modelo; *b*) quanto à estrutura; *c*) quanto às hipóteses de emissão; *d*) quanto à circulação.

O primeiro desses critérios distingue os títulos de crédito entre aqueles de *modelo livre* e os de *modelo vinculado*. No primeiro grupo, de que são exemplos a letra de câmbio e a nota promissória, estão os títulos de crédito cuja forma não precisa observar um padrão normativamente estabelecido. Os seus requisitos devem ser cumpridos para que se constituam títulos de crédito, mas a lei não determina um modelo formal específico para eles.

Já o grupo dos títulos de modelo vinculado, em que se encontram o cheque e a duplicata mercantil,

reúne aqueles em relação aos quais o direito definiu um padrão para o preenchimento dos requisitos específicos. Um cheque somente será um cheque se lançado no formulário próprio fornecido pelo próprio banco sacado. Mesmo que se lancem em um instrumento diverso todos os requisitos que a lei estabelece para o cheque, este documento não será título de crédito, não produzirá os efeitos jurídicos do cheque.

No tocante ao critério pertinente à estrutura, os títulos de crédito serão *ordem de pagamento* ou *promessa de pagamento*. No primeiro caso, o saque cambial dá nascimento a três situações jurídicas distintas: a de quem dá a ordem, a do destinatário da ordem e a do beneficiário da ordem de pagamento. No caso da promessa, apenas duas situações jurídicas distintas emergem do saque cambial: a de quem promete pagar e a do beneficiário da promessa. A letra de câmbio, o cheque e a duplicata mercantil são ordens de pagamento, ao passo que a nota promissória é uma promessa de pagamento.

Quanto às hipóteses de emissão, os títulos de crédito ou são *causais* ou *não causais* (também chamados de *abstratos*), segundo a lei circunscreva, ou não, as causas que autorizam a sua criação. Um título causal somente pode ser emitido se ocorrer o fato que a lei elegera como causa admissível para sua emissão, ao passo que um título não causal pode ser criado por qualquer causa, para representar obrigação de qualquer natureza. A duplicata mercantil é título causal, porque somente pode ser criada para representar obrigação decorrente de compra e venda mercantil. Já o cheque e a nota promissória podem ser emitidos para representar obrigações das mais diversas naturezas.

Finalmente, em relação ao negócio jurídico que opera a transferência da titularidade do crédito representado pela cártula, ou seja, quanto à circulação, os títulos de crédito podem ser *ao portador* ou *nominativos*. Os títulos ao portador não identificam o credor e são, por isso, transmissíveis por mera tradição (nome técnico para a entrega de bem móvel); enquanto os títulos nominativos identificam o credor e, portanto, sua transferência pressupõe, além da tradição, a prática de um negócio jurídico-cambial.

Os títulos de crédito nominativos ou são *à ordem* ou *não à ordem*. Os nominativos com a cláusula "à ordem" circulam mediante tradição acompanhada de endosso, e os com a cláusula "não à ordem" circulam com a tradição acompanhada de cessão civil de crédito. Endosso e cessão civil são atos jurídicos de transferência da titularidade de crédito, que se diferenciam quanto aos efeitos (*Cap. 18*, item 3).

No Código Civil, o conceito de títulos nominativos é diverso. Seriam desta categoria os títulos em que o nome do favorecido consta de registros do emitente (art. 921) e cuja circulação depende de alterações neste registro. Não há, no direito brasileiro, nenhum título de crédito que atenda a essa condição.

4. TÍTULOS DE CRÉDITO NO CÓDIGO CIVIL

O Código Civil contém normas sobre títulos de crédito (arts. 887 a 926) que se aplicam na hipótese de lacuna na lei específica (art. 903). Portanto, não têm aplicação as disposições do Código Civil quando o título de crédito está disciplinado exaustivamente por lei própria. A letra de câmbio e a nota promissória não se submetem a essas disposições porque a Lei Uniforme de Genebra (LU) as disciplina por completo. Assim também o cheque, disciplinado inteiramente pela lei respectiva (LC). A duplicata igualmente não se submete às prescrições do Código Civil porque a lei correspondente a submete ao regime legal aplicável à Letra de Câmbio, que, como visto, é exaustivo (LD, art. 25).

É importante ressaltar essa distinção porque o Código Civil contempla disposições diversas das que tradicionalmente se encontra no direito cambiário, principalmente em relação à circulação. O endosso, por exemplo, quando aplicável o Código Civil, não importa, em princípio, responsabilidade do endossante (art. 914). A regra contida na lei aplicável à letra de câmbio e demais títulos acima referidos, no entanto, é exatamente a oposta, que vincula, em regra, o endossante ao pagamento do título (LU, art. 15; LC, art. 21).

Por enquanto, o Código Civil tem aplicação apenas a três títulos de crédito típicos, que não foram disciplinados completamente pelas respectivas leis de regência: o *Warrant* Agropecuário, o Conhecimento de Depósito Agropecuário (Lei 11.076/04) e a Letra de Arrendamento Mercantil (Lei 11.882/08).

Alguns autores consideram o Código Civil aplicável também em mais uma hipótese, a dos títulos criados pelos próprios interessados, independentemente de previsão legal (*atípicos* ou *inominados*). Citam como exemplo o FICA (ou *vaca-papel*), que tem sido utilizado para documentar a obrigação de entrega de cabeças de gado no Centro-Oeste. Os títulos criados pelos próprios interessados não são inválidos como documentos representativos de obrigação, mas é questionável sua regência pelo direito cambiário.

Capítulo 17. LETRA DE CÂMBIO

1. INTRODUÇÃO

No estudo do direito cambiário, preferem os autores seguir uma linha didática que, por ser útil, será adotada também aqui. Trata-se de examinar inicialmente a letra de câmbio, esmiuçando as particularidades dos diversos atos cambiários com a devida profundidade, para, em seguida, apresentar os demais títulos de crédito, fazendo referência apenas àqueles aspectos que eles têm de específicos. Assim, o estudo da letra de câmbio é feito concomitantemente com o das regras gerais relativas à constituição e exigibilidade do crédito cambiário. Tais regras, respeitadas as especificidades de cada título, aplicam-se à nota promissória, ao cheque, às duplicatas e aos demais títulos de crédito.

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O Brasil é signatário de uma convenção internacional para a adoção de uma lei uniforme sobre letra de câmbio e nota promissória, a Convenção de Genebra, firmada em junho de 1930.

Com a adesão do Brasil a esta convenção, em agosto de 1942, criou-se, no direito cambiário nacional, uma séria controvérsia quanto à legislação vigente no País, posto que o assunto encontrava-se disciplinado por um diploma interno, o Decreto 2.044, de 1908. Tal diploma, de indiscutível qualidade técnica, não tinha sido revogado expressamente por nenhuma lei ordinária e, ademais, para integral cumprimento do convencionado em Genebra, seria necessário que se elaborasse um projeto de lei para apreciação do Poder Legislativo, o qual, se aprovado, introduziria no ordenamento jurídico nacional o regramento previsto pela mencionada convenção. Somente após a sanção dessa Lei, é que teria o Brasil dado cumprimento ao compromisso internacional assumido em Genebra. Até lá, a letra de câmbio e a nota promissória continuariam a ser disciplinadas pela nossa antiga legislação cambial.

Mas em vez de proceder conforme seria de rigor pela boa técnica jurídica, enviando ao Poder Legislativo um projeto de lei que incorporasse as regras da Lei Uniforme de Genebra, o Poder Executivo, em 1966, baixou um decreto determinando que se cumprisse a Convenção. A estranhíssima forma de criar direito recebeu a simpatia do STF, cuja jurisprudência pacificou-se, no início dos anos 1970, em torno da tese de que a Lei Uniforme de Genebra sobre letra de câmbio e nota promissória havia ingressado no direito interno, inobstante a falta de lei ordinária.

Contudo, nem todos os dispositivos da Lei Uniforme entraram em vigor no Brasil. Valendo-se de possibilidade oferecida pela própria convenção, o Brasil assinalou determinadas *reservas*. Isto quer dizer que o estado brasileiro havia-se reservado o direito de introduzir *parcialmente* o texto da Lei Uniforme em seu ordenamento interno. Em virtude destas reservas, o texto ficou lacunoso. Por outro lado, não houve lei qualquer que o revogasse expressamente o Decreto 2.044/1908. Teria, então, ocorrido uma revogação tácita com a superveniência de lei disciplinando a mesma matéria. Neste sentido, permanecem vigentes as disposições do referido diploma interno pertinente a assunto omitido na Lei Uniforme, seja por ausência de regramento, seja em decorrência de reserva assinalada pelo Brasil.

Assim, entende-se em vigor a legislação acerca de letra de câmbio e nota promissória resultante de uma "colcha de retalhos" costurada com dispositivos da Lei Uniforme de Genebra (LU) e da legislação interna (Decreto 2.044/1908). Define-se a legislação aplicável à letra de câmbio e nota promissória a

partir dos seguintes critérios:

a) Em princípio, vigora a Lei Uniforme que consta como Anexo I da Convenção de Genebra sobre Letra de Câmbio e Nota Promissória, de junho de 1930 (LU).

b) Em virtude de reservas assinaladas pelo Brasil, *não* vigoram no direito nacional os seguintes dispositivos da LU: art. 10 (reserva do art. 3.º do Anexo II); terceira alínea do art. 41 (reserva do art. 7.º do Anexo II); números 2 e 3 do art. 43 (reserva do art. 10 do Anexo II); quinta e sexta alíneas do art. 44 (reserva do art. 10 do Anexo II).

c) Em virtude da reserva constante do art. 5.º do Anexo II, assinalada pelo Brasil, o art. 38 da LU deve ser completado nos termos da reserva, ou seja: as letras de câmbio pagáveis no Brasil devem ser apresentadas ao aceitante no próprio dia do vencimento.

d) A taxa de juros por mora no pagamento de letra de câmbio ou nota promissória não é a constante dos arts. 48 e 49, mas a mesma devida em caso de mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (CC, art. 406), por força da reserva do art. 13 do Anexo II, assinalada pelo Brasil.

e) Permanecem vigorantes, por omissão originária ou derivada da LU, os seguintes dispositivos do Decreto 2.044/1908: art. 3.º, relativo aos títulos sacados incompletos; art. 10, sobre pluralidade de sacados; art. 14, quanto à possibilidade de aval antecipado; art. 19, II, em decorrência da reserva do art. 10 do Anexo II; art. 20, em virtude da reserva do art. 5.º do Anexo II, salvo quanto às consequências da inobservância do prazo nele consignado; art. 33, acerca da responsabilidade civil do oficial do cartório de protesto; art. 36, pertinente à ação de anulação de títulos; art. 48, quanto aos títulos prescritos; art. 54, I, referente à expressão "nota promissória", em virtude da reserva do art. 19 do Anexo II.

As regras do Código Civil aplicam-se apenas se idênticas as da lei específica do título de crédito, revestindo-se, assim, de caráter supletivo (art. 903).

Capítulo 18. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO CAMBIÁRIO

1. SAQUE

A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Isto significa que do seu saque, de sua criação, decorre o surgimento de três situações jurídicas distintas. São três diferentes complexos de direitos e obrigações que nascem juntamente com o título.

Em primeiro lugar, tem-se a situação jurídica daquele que *dá* a ordem de pagamento, que determina que certa quantia seja paga por uma pessoa a outra. Quem se encontra nesta situação é chamado de *sacador*.

Em segundo lugar, há a situação jurídica daquele *para quem* a ordem é dirigida, o destinatário da ordem. Ele deverá, nas condições estabelecidas, realizar o pagamento ordenado. A pessoa nesta situação é denominada *sacado*.

Finalmente, existe a situação jurídica do *beneficiário* da ordem de pagamento, aquele em favor de quem se fez dita ordem, e que, por isso, é o credor da quantia mencionada no título. Quem se encontre nesta terceira situação jurídica é conhecido como *tomador*.

São três situações jurídicas distintas, que surgem com a prática de um ato cambial chamado *saque*.

Saque é o ato de criação, de emissão da letra de câmbio. Após este ato cambial, o tomador estará autorizado a procurar o sacado para, dadas certas condições, receber dele a quantia referida no título.

Mas o saque produz outro efeito também: o de vincular o sacador ao pagamento da letra de câmbio. O sacado é que se encontra na posição de destinatário da ordem de pagamento; ele é que, em princípio, deverá pagar o título. No entanto, se não o fizer, ou se não se realizarem as condições de sua vinculação ao título, o tomador poderá cobrar a letra de câmbio do próprio sacador. Este, ao praticar o saque, tornou-se codevedor do título (LU, art. 9.º).

Embora o saque crie três situações jurídicas distintas, a lei faculta que a mesma pessoa ocupe mais de uma dessas situações. Assim, a letra poderá ser sacada em benefício do próprio sacador (a mesma pessoa ocupando simultaneamente as situações jurídicas de sacador e tomador); ou ainda sobre o próprio sacador (a mesma pessoa ocupando simultaneamente as situações jurídicas de sacador e sacado) (LU, art. 3.º).

A lei estabelece determinados requisitos para a letra de câmbio. São elementos indispensáveis à produção, pelo documento, dos efeitos cambiais previstos por lei. Ao documento a que falte algum desses requisitos não se pode aplicar a disciplina do regime jurídico-cambial.

São requisitos da letra de câmbio:

a) a expressão "letra de câmbio" inserta no próprio texto do título, não bastando constar fora do texto, mesmo que com destaque; tal expressão deverá ser na língua empregada na redação do título (LU, art. 1.º, n. 1);

b) o mandato puro e simples (ou seja, não sujeito a nenhuma condição) de pagar quantia determinada (LU, art. 1.º, n. 2);

c) o nome do sacado (LU, art. 1.º, n. 3) e sua identificação pelo número de sua Cédula de Identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, do Título Eleitoral ou da Carteira Profissional (Lei 6.268/75, art. 3.º);

d) o lugar do pagamento ou a indicação de um lugar ao lado do nome do sacado, que será tomado como lugar do pagamento e como domicílio do sacado (LU, art. 1º, n. 5, c/c o art. 2.º, terceira alínea);

e) o nome do tomador, o que quer dizer que não se admite letra de câmbio sacada ao portador (LU, art. 1.º, n. 6);

f) local e data do saque, podendo ser a indicação deste local substituída por menção de um lugar ao lado do nome do sacador (LU, art. 1.º, n. 7, c/c o art. 2.º, última alínea); e

g) assinatura do sacador (LU, art. 1.º, n. 8).

A época do vencimento deve também constar da letra, mas sua falta não descaracterizará o instrumento como título de crédito porque a lei dispõe que a letra será à vista neste caso (LU, art. 2.º, segunda alínea).

Alguns autores distribuem os requisitos legais da letra de câmbio em essenciais ou não essenciais, incluindo nesta última categoria aqueles que, nos termos do art. 2º da LU, podem ser substituídos ou supridos. Não há, no entanto, maior interesse nesta classificação.

Se o sacador - como, de resto, qualquer outro obrigado cambial - não souber ou não puder assinar, somente poderá praticar o ato cambial por procurador nomeado por instrumento público e com poderes especiais. Por outro lado, não se admite, em relação à letra de câmbio, a utilização de chancela mecânica.

Os requisitos da letra de câmbio - assim também de qualquer título de crédito - não precisam constar do instrumento no momento do saque (CC, art. 891). Ela poderá ser sacada e até mesmo circular incompleta. Os requisitos devem estar totalmente cumpridos antes da cobrança ou do protesto do título. Entende-se que o portador de boa-fé é procurador do sacador para completar a letra de câmbio emitida com omissões. Claro, se preencher o título em desacordo com o avençado ou com a realidade dos fatos, o portador age de má-fé e deixa de ser considerado procurador do emitente do título.

2. ACEITE

O sacado de uma letra de câmbio naturalmente não tem nenhuma obrigação cambial pelo só fato de o sacador ter-lhe endereçado a ordem de pagamento. Estará vinculado ao pagamento do título apenas se concordar em atender à ordem que lhe foi dirigida. O sacado, em nenhuma hipótese, está obrigado a cumprir o ordenado por esta espécie de título de crédito.

O ato cambial pelo qual o sacado concorda em acolher a ordem incorporada pela letra se chama "aceite". Nada o obriga a aceitar a letra de câmbio, nem sequer a prévia existência de obrigação perante o sacador ou o tomador. O sacado somente assumirá obrigação cambial, pelo aceite, se o desejar. É o

aceite ato de sua livre vontade. Se, por acaso, é ele devedor do sacador ou do tomador, por obrigação derivada de ato, negócio, fato ou relação jurídica diversa, caberá evidentemente a ação própria para a cobrança do devido, mas não existe nenhuma forma de obrigá-lo juridicamente à prática do aceite. Quer dizer, ele pode até ser devedor, mas só mediante sua vontade (expressa pelo aceite) a dívida poderá ser representada por uma letra de câmbio.

O aceite resulta da simples assinatura do sacado lançada no anverso do título, mas poderá ser firmado também no verso, desde que identificado o ato praticado pela expressão "aceito" ou outra equivalente.

O aceitante é o devedor principal da letra de câmbio. Isto significa que, no vencimento, o credor do título deverá procurar inicialmente o aceitante para cobrar o valor devido. Somente na hipótese de recusa de pagamento pelo devedor principal, é que o credor poderá cobrar o título dos coobrigados, mesmo assim em determinadas condições. Cada título de crédito tem o seu devedor principal, em relação ao qual se aplica esta regra.

Como o sacado não está obrigado a aceitar a letra de câmbio, a recusa do aceite é comportamento lícito. A lei, no entanto, reserva para a recusa do aceite uma determinada consequência, com vistas a resguardar os interesses do tomador do título. Trata-se do *vencimento antecipado* (LU, art. 43). Se o sacado não aceitar a ordem de pagamento que lhe foi dirigida, o tomador (ou o credor do título, se ele já tiver circulado) poderá cobrar o título de imediato do sacador, porque o vencimento originariamente fixado para a cambial é antecipado com a recusa do aceite.

Igual consequência ocorre quando a recusa é parcial, ou seja, no caso de aceite limitativo ou modificativo. Do primeiro tipo é o aceite em que o sacado concorda em pagar apenas uma parte do valor do título; já modificativo é o aceite em que o sacado adere à ordem alterando parte das condições fixadas na letra, como, por exemplo, adiando o vencimento. Nas duas hipóteses, ocorre aceite parcial; mas ocorre também recusa parcial do aceite. Estabelece, então, a lei que, em virtude do aceite limitativo ou modificativo, o aceitante se vincula ao pagamento do título nos exatos termos de seu aceite (LU, art. 26), mas se opera o vencimento antecipado da letra de câmbio, que poderá, por isto, ser cobrada de imediato do sacador.

Para evitar que a recusa do aceite produza o vencimento antecipado da letra de câmbio, o sacador inserir a cláusula "não aceitável" (salvo nas hipóteses proibidas pelo art. 22 da LU). Uma letra de câmbio com esta cláusula não poderá ser apresentada ao sacado para aceite. O credor somente poderá apresentar o título ao sacado no seu vencimento, e para pagamento, portanto. Com este expediente, a negativa do sacado em acolher a ordem que lhe fora dirigida não importará em nenhuma consequência prática excepcional em relação ao sacador, porque a recusa do aceite só poderá ocorrer no vencimento do título, época em que ele já deveria estar preparado para a eventualidade de honrá-lo. Uma solução intermediária, prevista em lei também, é a proibição pelo sacador de apresentação da letra para aceite antes de uma determinada data. Com isto, a eventual recusa do aceite e consequente vencimento antecipado do título ficam postergados para a data escolhida pelo sacador. Também é possível ao sacador fixar um prazo máximo para a apresentação ao sacado, forçando assim a pronta definição se haverá ou não aceite.

A letra de câmbio, salvo nas hipóteses em que o sacador define um prazo diverso, deve ser apresentada pelo tomador ao sacado até o máximo previsto em lei. Se se tratar de letra de câmbio à vista, o tomador deverá procurar o sacado até o máximo de 1 ano após o saque (art. 34). Neste caso, no

entanto, a letra não é, a rigor, apresentada a aceite, mas propriamente para pagamento. Nada impede, contudo, que a letra à vista seja aceita pelo sacado e, em seguida, paga. Já a letra de câmbio a certo termo da vista (o vencimento se opera com o transcurso de lapso temporal em que a data do aceite é o termo *a quo*), o tomador deverá apresentá-la ao sacado para aceite até o prazo de 1 ano após o saque (art. 23). Neste tipo de letra de câmbio, não é possível ao sacador inserir a cláusula "não aceitável" (art. 22). A letra de câmbio a certo termo da data (o vencimento se opera com o transcurso de lapso temporal em que a data do saque é o termo *a quo*) e a letra de câmbio em data certa devem ser apresentadas a aceite pelo tomador até o vencimento fixado para o título (art. 21). A inobservância desses prazos pelo credor acarreta a perda do direito de cobrança do título contra os coobrigados (art. 53).

A letra de câmbio não aceita não pode ser protestada por falta de pagamento. Neste caso, o título só admite protesto por falta de aceite, em que o protestado é o sacador do título (Lei 9.492/97, art. 21, § 5.º). Assim é porque o sacado não tem nenhuma obrigação e a falta do aceite corresponde à frustração de ordem dada pelo sacador.

Apresentado o título ao sacado, este tem o direito de pedir que ele lhe seja reapresentado no dia seguinte (LU, art. 24). É o chamado prazo de respiro, que se destina a possibilitar ao sacado a realização de consultas ou a meditação acerca da conveniência de aceitar ou recusar o aceite.

3. ENDOSSO

A letra de câmbio é título sacado, em regra, com a cláusula "à ordem". Isto significa que o seu credor pode negociar o crédito por ela representado mediante um negócio jurídico trasladador da titularidade do crédito, de efeitos cambiais, chamado *endosso*. Conceitua-se, então, endosso como o ato cambiário que opera a transferência do crédito representado por título "à ordem". É claro, a alienação do crédito fica ainda condicionada à tradição do título, em decorrência do princípio da cartularidade.

A cláusula "à ordem" pode ser expressa ou tácita. Ou seja, basta que não tenha sido inserida a cláusula "não à ordem" na letra de câmbio para que ela seja transferível por endosso (LU, art. 11).

O alienante do crédito documentado por uma cambial é chamado de *endossante* ou *endossador*; o adquirente, de *endossatário*. Com o endosso, o endossante evidentemente deixa de ser credor do título, posição jurídica que passa a ser ocupada pelo endossatário. Também é evidente que somente o credor pode alienar o crédito, e, portanto, somente o credor pode ser endossante.

O primeiro endossante de qualquer letra de câmbio será sempre o tomador; o segundo endossante necessariamente o endossatário do tomador; o terceiro, o endossatário do segundo endossante e assim sucessivamente. Não há qualquer limite para o número de endossos de um título de crédito; ele pode ser endossado diversas vezes, como pode, simplesmente, não ser endossado (aliás, a hipótese mais comum hoje).

O endosso produz, em regra, dois efeitos: *a*) transfere a titularidade do crédito representado na letra, do endossante para o endossatário; *b*) vincula o endossante ao pagamento do título, na qualidade de coobrigado (LU, art. 15). Há endossos que não produzem um ou outro destes efeitos, conforme se estudará em seguida.

O endosso pode ser de duas espécies: "em branco", quando não identifica o endossatário, ou "em preto", quando o identifica. Resulta o endosso da simples assinatura do credor do título lançado no seu

verso, podendo ser feita sob a expressão "Pague-se a Antonio Silva" (endosso em preto), ou simplesmente "Pague-se" (endosso em branco), ou sob outra expressão equivalente. O endosso poderá também ser feito no anverso do título, mas, neste caso, é obrigatória a identificação do ato cambiário praticado, ou seja, não poderá o endossante se limitar a assinar a letra.

O endosso em branco transforma a letra, necessariamente sacada nominativa, em título ao portador. O endossatário de um título por endosso em branco poderá transferir o crédito nele representado por mera tradição, hipótese em que não ficará coobrigado.

A lei veda ao endossante limitar o endosso a uma parte do valor da letra, considerando nulo o endosso parcial (LU, art. 12; CC, art. 912, parágrafo único). Além disso, o endosso condicional (em que a transferência do crédito fica subordinada a alguma condição, resolutiva ou suspensiva) não é nulo, mas a condição será ineficaz porque a lei a considera não escrita (art. 12).

A doutrina costuma reunir sob a rubrica de endosso impróprio aquele que não produz o efeito de transferir a titularidade do crédito documentado pela letra de câmbio, mas legitima a posse sobre a cártula exercida pelo seu detentor. Com efeito, em determinadas circunstâncias, poderá o credor da letra transferir legitimamente a sua posse a terceiro sem transferir-lhe a titularidade do crédito representado. No caso de o credor da letra incumbir a seu procurador o recebimento do título, deverá praticar ato cambiário específico destinado a legitimar a posse do mandatário. Caso tal ato não seja praticado, na própria letra, o devedor que efetuar o pagamento não se liberará validamente, em virtude da aplicação dos princípios da cartularidade e da literalidade. O endosso impróprio que legitima a posse do procurador do credor é o *endosso-mandato* (LU, art. 18; CC, art. 917).

Outro exemplo de endosso impróprio é o *endosso-caução*, em que a letra, considerada bem móvel, é onerada por penhor em favor do credor do endossante. No endosso-caução, o crédito não se transfere para o endossatário, que é investido na qualidade de credor pignoratício do endossante. Cumprida a obrigação garantida pelo penhor, deve a letra retornar ao endossante. Somente na eventualidade de não cumprimento da obrigação garantida, é que o endossatário por endosso-caução apropria-se do crédito representado pela letra. O endossatário por endosso-caução não pode endossar o título, salvo para praticar o endosso-mandato (LU, art. 19; CC, art. 918).

Já o endosso que não produz o efeito de vincular o endossante ao pagamento do título é o chamado endosso "sem garantia" (LU, art. 15). Com esta cláusula, o endossante transfere a titularidade da letra sem se obrigar ao seu pagamento. A regra, como visto, é a da vinculação do endossante (lembre-se que o art. 914 do CC não se aplica em razão do art. 903 do mesmo Código); o ato do endossante de inserir no endosso a cláusula "sem garantia", porém, afasta a vinculação prevista na LU.

O negócio jurídico trasladador da titularidade de crédito de efeitos não cambiais é a cessão civil de crédito. Esta difere do endosso em dois níveis: quanto à extensão da responsabilidade do alienante do crédito perante o adquirente e quanto aos limites de defesa do devedor em face da execução do crédito pelo adquirente.

Quanto ao primeiro aspecto, acentue-se que o endossante responde, em regra, tanto pela existência do crédito quanto pela solvência do devedor. Em outros termos, o endossatário poderá executar o crédito contra o endossante, caso o devedor não tenha realizado o pagamento deste. Já o cedente responde, em regra, apenas pela existência do crédito e não pela solvência do devedor (CC, arts. 295 e 296). No tocante ao segundo aspecto, o devedor poderá defender-se, quando executado pelo cessionário, arguindo

matérias atinentes a sua relação jurídica com o cedente (CC, art. 294), mas não poderá defender-se, quando executado pelo endossatário, arguindo matérias atinentes a sua relação jurídica com o endossante (princípio da autonomia das obrigações cambiais e subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, referidos no art. 17 da LU e 916 do CC).

Há alguns endossos que produzem efeitos de cessão civil de crédito. Ou seja, endossos em que o endossante não responde, em regra, pela solvência do devedor e em que o endossatário não adquire obrigação autônoma. São duas as hipóteses de endossos com efeitos de cessão civil de crédito, a saber: a) endosso praticado após o protesto por falta de pagamento ou do transcurso do prazo legal para a extração desse protesto (LU, art. 20); b) endosso de letra de câmbio com a cláusula "não à ordem" (art. 11).

Em relação a esta última hipótese de endosso com efeitos de cessão civil de crédito, faz-se necessário observar que a letra pode ser emitida com a cláusula "não à ordem", ou seja, transmissível mediante apenas cessão civil de crédito. Essa cláusula pode ser inserida pelo sacador e, assim, desnaturar todo e qualquer endosso que venha a ser feito na letra de câmbio, ou pode ser inserida por um endossante, proibindo que o título seja novamente endossado. A forma de inserir na cártula tal proibição é por meio da cláusula "não à ordem"; um título com esta cláusula só pode ser transferido por cessão civil de crédito e não mais pelo endosso, com as consequências advindas das já examinadas diferenças entre um e outro negócio jurídico. Por esta razão é que a lei estabelece que o endosso de uma letra na qual foi inserida a cláusula "não à ordem" tem, a rigor, os efeitos de cessão civil (art. 11). Ademais, como forma de se desestimular situações como estas, o endossante que inserir a cláusula "não à ordem" em seu endosso, ou seja, que proibir novos endossos da letra, não garante o seu pagamento senão para o seu próprio endossatário (LU, art. 15). Quem adquirir o crédito representado por uma letra de câmbio endossada com a cláusula "não à ordem" ao alienante não terá a garantia nem deste, que é cedente, nem do endossante anterior, que proibira novos endossos.

4. AVAL

O pagamento de letra de câmbio pode ser, total ou parcialmente, garantido por aval. Por este ato cambial de garantia, uma pessoa, chamada *avalista*, garante o pagamento do título em favor do devedor principal ou de um coobrigado. O devedor em favor de quem foi garantido o pagamento do título é chamado de *avalizado*.

O avalista é responsável da mesma forma que o seu avalizado (LU, art. 32; CC, art. 899). Isto não significa, contudo, uma atenuação do princípio da autonomia. A obrigação do avalista é autônoma em relação à do avalizado, como esclarece a própria lei. Eventual nulidade da obrigação do avalizado não compromete a do avalista. Quando a lei equiparou as responsabilidades de um e de outro coobrigado, pretendeu apenas prescrever que o avalista responde pelo pagamento do título perante todos os credores do avalizado; e, uma vez realizando o pagamento, poderá voltar-se contra o avalizado e todos os devedores do avalizado.

Questão altamente controvertida surge da autorização legal do aval antecipado, constante do art. 14 do Decreto 2.044/1908. Teria o avalista antecipado do sacado que recusa o aceite alguma obrigação cambial? Uma leitura precipitada da LU, atinente à equiparação da responsabilidade do avalista à do respectivo avalizado, poderia dar a entender que, inexistindo obrigação por parte do avalizado (o sacado, lembre-se, não tem qualquer responsabilidade cambial antes do aceite), também inexistiria por

parte do avalista. Não se poderá, contudo, esquecer o princípio da autonomia das obrigações cambiais. O avalista antecipado de sacado que recusa o aceite responde pelo valor do título na exata medida em que assumiu, com o aval, uma obrigação autônoma, independente de qualquer outra representada no mesmo título de crédito.

O aval resulta da simples assinatura do avalista no anverso da letra de câmbio, sob alguma expressão identificadora do ato praticado ("Por aval" ou equivalente) ou não. Se o avalista pretender firmar o verso do título, somente poderá fazê-lo identificando o ato praticado.

O aval pode ser "em branco" ou "em preto". Do primeiro tipo é o aval que não identifica o avalizado; do segundo, o que o identifica. O aval em branco é dado em favor do sacador (LU, art. 31). É ele o avalizado pelo aval em branco.

O ato de garantia de efeitos não cambiais é a fiança, que se distingue do aval quanto à natureza da relação com a obrigação garantida. A obrigação do fiador é acessória em relação à do afiançado (CC, art. 837), ao passo que a obrigação do avalista é autônoma, independente da do avalizado (LU, art. 32). Como consequência desta distinção, a lei concede ao fiador o benefício de ordem (CC, art. 827), inexistente para o avalista.

Capítulo 19. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CAMBIÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Classificam-se os devedores dos títulos de crédito em duas categorias: o "devedor principal" (que, na letra de câmbio, é o aceitante) e os "coobrigados" (que, nesta espécie de título, são o sacador e os endossantes). Os avalistas se enquadram em um ou outro grupo em função da classificação do respectivo avalizado.

Para tornar-se exigível o crédito cambiário contra o devedor principal, basta o vencimento do título; já em relação aos coobrigados, é condição necessária também a negativa de pagamento do título vencido por parte do devedor principal. Esta é a diferença entre as duas categorias de devedores.

Em virtude do princípio da literalidade, a comprovação da negativa de pagamento pelo devedor principal deve ser feita por protesto do título. Estar o título protestado é, assim, condição da exigibilidade do crédito cambiário em face dos coobrigados. O protesto do título também é condição de exigibilidade desse crédito na hipótese de recusa do aceite. Para produzir o efeito de tornar exigível o título contra o coobrigado, o protesto deve ser providenciado pelo credor dentro do prazo estabelecido por lei.

Assim, para o título de crédito ser exigível do devedor principal, seu protesto não é necessário; já, os coobrigados não estão vinculados ao pagamento do título, se este não foi protestado ou o foi fora do prazo legal.

O coobrigado que paga o título de crédito tem o direito de regresso contra o devedor principal e contra os *coobrigados anteriores*. As obrigações representadas por um título de crédito só se extinguem, todas, com o pagamento pelo devedor principal.

Para se identificarem os coobrigados da letra de câmbio na *cadeia de anterioridade das obrigações cambiais*, adotam-se os seguintes critérios: *a)* o sacador é anterior aos endossantes; *b)* os endossantes são dispostos na cadeia de acordo com o critério cronológico; *c)* o avalista se insere na posição imediatamente posterior ao respectivo avalizado.

Organizando os devedores da letra de câmbio de acordo com esses critérios, na cadeia de anterioridade, será possível definir quem, dentre eles, é credor, em regresso, de quem.

2. VENCIMENTO

O vencimento de um título de crédito se opera com o ato ou fato jurídico predeterminado por lei como necessário a tornar o crédito cambiário exigível.

Há duas espécies de vencimento: o *ordinário*, que se opera pelo decurso do tempo ou pela apresentação ao sacado da letra à vista; e o *extraordinário*, que se opera por recusa do aceite ou pela falência do aceitante (Decreto 2.044/1908, art. 19, I).

Em relação à última hipótese, note que somente a falência do aceitante da letra de câmbio produz o

seu vencimento antecipado. Alguns autores entendem que a falência de qualquer coobrigado importaria também o vencimento extraordinário do título de crédito. A melhor forma de examinar o assunto, contudo, não é essa. A falência de um coobrigado produz apenas o vencimento da obrigação cambiária de que ele é devedor, permanecendo as demais obrigações com o vencimento inalterado. Apenas a falência do aceitante, que é o devedor principal, tem por consequência o vencimento antecipado de *todas* as obrigações cambiais, ou seja, do título mesmo, e não apenas de uma das obrigações nele documentadas. A falência do avalista do aceitante também não é causa de vencimento extraordinário da letra de câmbio.

Para a contagem de prazos, o art. 36 da LU estabelece as seguintes regras, aplicáveis a todos os títulos de crédito:

a) o mês se conta pelo mês, ou seja, o vencimento da letra de câmbio a certo termo da vista ou da data, fixado em mês ou meses, operar-se-á no mesmo dia do aceite ou do saque, respectivamente, no mês de pagamento; inexistindo, nesse mês, o referido dia, o vencimento se dará no último dia do mês;

b) meio mês significa o lapso de 15 dias; se o prazo de vencimento das letras de câmbio a certo termo da vista ou da data houver sido fixado em mês ou meses inteiros mais meio mês, computar-se-ão inicialmente os meses inteiros para, somente após, adicionar os 15 dias. Assim, o vencimento de uma letra de câmbio sacada para um mês e meio da vista, cujo aceite foi datado de 27 de fevereiro de ano não bissexto, recairá em 11 de abril (não em 14 de abril) do mesmo ano. Também uma letra de câmbio sacada em 31 de janeiro de ano não bissexto para vencimento em um mês irá vencer no dia 28 de fevereiro;

c) o vencimento designado para o início, meados ou fim de determinado mês ocorrerá nos dias 1º, 15 e no último dia do referido mês, respectivamente.

Questão interessante diz respeito à falta de data do aceite, em letra de câmbio sacada a certo termo da vista. A contagem do prazo de vencimento, nesse caso, ficaria impossibilitada se a lei não previsse fórmulas de sanar a falta de data. Em primeiro lugar, importa recuperar a ideia de que o título incompleto pode ser completado pelo portador de boa-fé. Assim, o credor da letra de câmbio poderá simplesmente datar o aceite, escrevendo no título a data em que ele efetivamente ocorreu. Poderá, no entanto, optar pelo protesto do título. A lei prevê um protesto específico para as letras de câmbio a certo termo da vista, cujo aceite não se encontra datado, que é o *protesto por falta de data* (LU, art. 24). O aceitante é intimado para vir datar a letra em cartório, considerando-se, em caso de não comparecimento, como data do aceite a do protesto. Finalmente, se a letra de câmbio nessas condições não se encontrar protestada, a lei faculta ao credor considerar o aceite como feito no último dia do prazo de apresentação (art. 35), ou seja, 1 ano após o saque, computando-se, então, a partir do término desse prazo o lapso do vencimento da cambial.

3. PAGAMENTO

Pelo pagamento, extinguem-se uma, alguma ou todas as obrigações representadas por um título de crédito. Se o pagamento é feito por um coobrigado ou pelo avalista do aceitante, são extintas a obrigação de quem pagou e mais as dos coobrigados *posteriores*; se o pagamento é feito pelo aceitante da letra de câmbio, extinguem-se todas as obrigações cambiais.

O pagamento da letra de câmbio deve ser feito no prazo da lei, que difere segundo o lugar de sua realização. Para a letra de câmbio pagável no exterior, o credor deve apresentar o título ao aceitante no

dia do vencimento ou num dos dois dias úteis seguintes (LU, art. 38). Já se a letra de câmbio é pagável no Brasil, o credor deverá apresentá-la ao aceitante para pagamento no dia do vencimento ou, recaiando este num dia não útil, no primeiro dia útil seguinte (art. 5.º do Anexo II da Convenção de Genebra, c/c o art. 20 do Decreto 2.044/1908).

Se não for observado o prazo de apresentação para pagamento, o credor *não* perderá o direito ao crédito cambiário. Mas, nessa hipótese, qualquer devedor poderá depositar em juízo, por conta do credor, o valor do título. Responderá, portanto, o credor de letra de câmbio não apresentada tempestivamente para pagamento pelo ressarcimento das despesas de eventual depósito judicial feito pelo devedor principal ou por um coobrigado. Somente na hipótese de letra de câmbio com a cláusula "sem despesas", que dispensa o protesto para fins de conservação do direito de crédito contra os coobrigados, ou parte deles, é que a inobservância do prazo de apresentação para pagamento importa consequência distinta, que é a perda do direito de crédito contra todos os coobrigados (LU, art. 53).

Para fins cambiais, considera-se útil o dia em que há expediente bancário, independentemente de ser, ou não, feriado local ou nacional (Lei 9.492/97, art. 12, § 2.º).

O pagamento de uma cambial deve cercar-se de cautelas próprias. Em virtude do princípio da cartularidade, o devedor que paga a letra de câmbio deve exigir que lhe seja entregue o título. Em decorrência do princípio da literalidade, deverá exigir a quitação dada no próprio título. Se não observar tais cautelas específicas e a letra for endossada a portador de boa-fé, o devedor não poderá furtar-se a fazer novo pagamento, por força do princípio da autonomia das obrigações cambiais. É claro que, em seguida, poderá reaver o que pagou a mais de quem se beneficiou do enriquecimento indevido. O endossante que pagar uma letra poderá riscar o seu endosso e os endossos posteriores.

Tem-se admitido o pagamento parcial da letra de câmbio, desde que observadas algumas cautelas: *a)* somente o aceitante poderá optar pelo pagamento parcial, que não poderá ser recusado pelo credor; *b)* o título permanece em posse do credor, que nele deve lançar quitação parcial; *c)* os coobrigados e o avalista do aceitante podem ser cobrados pelo saldo não pago, sendo necessário o protesto para a responsabilização do sacador, endossantes e seus avalistas.

Uma obrigação cambial é de natureza quesível, ou seja, cabe ao credor a iniciativa para a obtenção da satisfação do crédito. Deve ele procurar o devedor para receber o valor do título ou avisá-lo do local onde poderá ser feito o pagamento. Ao contrário do que ocorre com o devedor de obrigação portátil, ao devedor cambial não cabe a iniciativa para a solução da pendência. De qualquer forma, a inobservância da cláusula quesível ou portátil não invalida o pagamento.

O devedor de uma letra de câmbio deve negar-se a efetuar o pagamento ao portador do título sempre que ocorrer justa causa para essa oposição. O revogado parágrafo único do art. 23 do Decreto 2.044/1908 oferece alguns exemplos dessa espécie de causa: extravio da letra, falência ou incapacidade do portador. Se pagar uma letra sem essa cautela, o devedor não ficará validamente desobrigado (LU, art. 40). Assim, se a falência do credor era do conhecimento do obrigado cambial, e, no entanto, ele efetuou o pagamento do título ao falido, a massa poderá reclamar novo pagamento daquele devedor.

4. PROTESTO

A falta de aceite, de data do aceite ou de pagamento de uma letra de câmbio deve ser provada por

protesto cambial, um ato formal de responsabilidade do portador do título.

O protesto por falta de aceite é extraído contra o sacador, cuja ordem de pagamento não foi aceita. O sacado não pode figurar como protestado neste caso, pela circunstância de se encontrar absolutamente livre de qualquer obrigação cambiária. Mas quem será intimado para eventualmente vir aceitar a letra em cartório é naturalmente o sacado.

Já o protesto por falta de data do aceite ou por falta de pagamento é extraído contra o aceitante, este sim um devedor cambial.

A lei estabelece para o protesto os seguintes prazos: para o protesto por falta de aceite, o portador deverá entregar o título em cartório até o fim do prazo de apresentação ao sacado (exceto se a letra foi apresentada no último dia e o sacado solicitou o prazo de respiro, quando a apresentação ao cartório deve ocorrer até o dia seguinte); para o protesto por falta de pagamento, o credor deverá entregar o título em cartório num dos 2 dias úteis seguintes àquele em que ele for pagável (LU, art. 44). Alguns doutrinadores entendem vigente a lei interna na disciplina desse prazo e consideram que o portador deve encaminhar o título ao cartório já no primeiro dia útil seguinte ao do vencimento (Decreto 2.044/1908, art. 28).

Se não forem observados os prazos fixados em lei para a extração do protesto, o portador do título perderá o direito de crédito contra os coobrigados da letra - ou seja, contra o sacador, endossantes e seus respectivos avalistas (LU, art. 53) -, permanecendo, portanto, apenas com o direito de crédito contra o devedor principal (aceitante da letra de câmbio) e seu avalista.

Em caso de perda do prazo para protesto por falta de aceite, é claro, o portador somente conservará o direito de crédito contra eventual avalista antecipado do sacado.

Diante dessas consequências da lei, a doutrina costuma chamar de *necessário* o protesto contra os coobrigados e de *facultativo* o protesto contra o devedor principal e seu avalista.

Tais consequências não se aplicam no caso de a letra de câmbio ou um ato cambiário específico contemplarem a cláusula "sem despesas". A inserção desta cláusula pelo sacador dispensa o protesto para a conservação do direito de crédito cambiário contra qualquer devedor do título; já a inserção em endosso ou aval dispensa o protesto para a conservação do direito de crédito apenas em relação ao endossante ou ao avalista em questão (LU, art. 46).

A cláusula "sem despesas" transforma em facultativo o protesto obrigatório (contra todos os coobrigados ou parte deles). O portador de letra de câmbio com cláusula dessa espécie somente perde o direito de crédito contra os coobrigados a que ela se refere se deixar de apresentar o título ao aceitante, para pagamento, no prazo da lei (art. 53).

O cancelamento do protesto pode ter por base o pagamento posterior do título, hipótese em que se processa administrativamente perante o próprio cartório de protesto, mediante entrega, pelo interessado, do título protestado (a posse do documento faz presumir a quitação). Caso este não possa ser exibido, o interessado poderá obter o cancelamento do protesto apresentando anuência do credor originário ou endossante. Se o cancelamento se fundar em causa diversa do pagamento posterior, e as pessoas que figurarem no instrumento de protesto não consentirem, somente por ordem judicial poderá ser efetuado (Lei 9.492/97, art. 26).

5. AÇÃO CAMBIAL

Se o título não for pago no vencimento, o credor poderá promover a execução judicial do crédito contra qualquer devedor cambial, observadas as condições de exigibilidade.

A letra de câmbio vem definida, pela lei processual, juntamente com a nota promissória, o cheque e a duplicata, como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I), cabendo, pois, a execução do crédito correspondente.

Mas, para o exercício do direito de cobrança por via de execução, fixou a lei prazos prescricionais. A execução da letra de câmbio deve ser ajuizada (LU, art. 70):

a) em 3 anos a contar do vencimento, para o exercício do direito de crédito contra o devedor principal e seu avalista;

b) em 1 ano a contar do protesto - ou do vencimento, no caso da cláusula "sem despesas" - para o exercício do direito de crédito contra os coobrigados, ou seja, contra o sacador, endossantes e respectivos avalistas; e

c) em 6 meses a contar do pagamento, ou do ajuizamento da execução cambial, para o exercício do direito de regresso por qualquer um dos coobrigados.

Após a prescrição da ação de execução, ninguém poderá ser acionado em virtude da letra de câmbio. No entanto, se a obrigação que se encontrava representada pelo título de crédito tinha origem extracambial, o seu devedor poderá ser demandado por ação de conhecimento própria (Decreto 2.044/1908, art. 48), na qual a letra servirá apenas como um elemento probatório. O coobrigado cuja obrigação tenha-se originado exclusivamente no título de crédito (como é, em geral, o caso do avalista), após a prescrição da execução, não poderá ser responsabilizado pelo pagamento da letra em nenhuma hipótese.

Essa ação de conhecimento prescreverá de acordo com a disposição de lei aplicável à espécie, e, inexistindo regra específica, no prazo geral de dez anos (CC, art. 205).

A execução cambial compreende o pagamento do principal do título acrescido de juros moratórios, à taxa pactuada entre as partes, além das despesas (LU, art. 48), além de correção monetária a partir do vencimento.

Se o título teve o vencimento antecipado por recusa do aceite, o seu valor será reduzido de acordo com as taxas bancárias vigentes no domicílio do portador à data da execução.

Capítulo 20. NOTA PROMISSÓRIA

1. REQUISITOS

A nota promissória é uma promessa de pagamento que uma pessoa faz em favor de outra.

Com o saque da nota promissória, surgem duas situações jurídicas distintas: a situação daquele que promete pagar quantia determinada e a daquele que se beneficia de tal promessa. A pessoa que se encontra na primeira situação é chamada de subscritor, sacador ou emitente; a que se encontra na segunda posição é o beneficiário ou sacado.

A nota promissória deve atender aos requisitos (LU, arts. 75 e 76):

- a) a expressão "nota promissória" (Decreto 2.044/1908, art. 54, I) constante do próprio texto do título, na língua empregada para a sua redação (LU, art. 75, n. 1);
- b) a promessa, incondicional, de pagar quantia determinada (art. 75, n. 2);
- c) o nome do beneficiário da promessa, o que significa a impossibilidade da nota promissória sacada ao portador (art. 75, n. 5);
- d) a data do saque (art. 75, n. 6);
- e) o local do saque ou a menção de um lugar ao lado do nome do subscritor, que se considera, também, o domicílio deste (art. 75, n. 6, e a terceira alínea do art. 76);
- f) a assinatura do subscritor (art. 75, n. 7), bem como a sua identificação pelo número da Cédula de Identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do Título de Eleitor ou da Carteira Profissional (Lei 6.268/75, art. 3.º).

Além desses requisitos, deve a nota promissória especificar a data e local do pagamento, entendendo-se, em caso de omissão, que se trata de título pagável à vista no local do saque ou no designado ao lado do nome do subscritor (LU, art. 76, alíneas segunda e terceira).

2. REGIME JURÍDICO

A nota promissória está sujeita às mesmas normas aplicáveis à letra de câmbio, com algumas exceções (LU, arts. 77 e 78). Assim, tudo o quanto a lei prescreve acerca de endosso, aval, vencimento, pagamento, protesto, execução e demais temas, relativamente às letras de câmbio é aplicável também à nota promissória.

As exceções são as seguintes:

- a) A nota promissória é uma promessa de pagamento enquanto a letra de câmbio é uma ordem de pagamento; por isso, não se aplicam as normas relativas à letra de câmbio incompatíveis com a natureza de promessa da nota promissória. Assim, não existe aceite de nota promissória; tampouco ocorre o vencimento antecipado do título por recusa de aceite, nem se admite a cláusula "não aceitável" etc.

b) O subscritor da nota promissória é o seu devedor principal. Por essa razão, a lei prevê que a sua responsabilidade é idêntica à do aceitante da letra de câmbio (art. 78). Em consequência, o protesto é facultativo para o exercício do direito de crédito contra o subscritor, a execução prescreve em 3 anos etc.

c) O aval em branco da nota promissória favorece o subscritor (art. 77, *in fine*).

As notas promissórias, embora não admitam aceite, podem ser emitidas com vencimento a certo termo da vista. Nesta hipótese, o credor deverá apresentar o título ao visto do emitente no prazo de 1 ano do saque (LU, art. 23), sendo a data desse visto o termo *a quo* do lapso temporal do vencimento. A nota promissória desta espécie pode ser protestada por falta de data (art. 78, segunda alínea).

Depois da prescrição da pretensão à execução da nota promissória, o credor pode promover ação monitória em face do emitente no prazo de 5 anos, contados do vencimento do título (STJ, Súmula 504).

Em suma, observadas as especificidades da nota promissória acima mencionadas, estará este título sujeito ao mesmo regime jurídico da letra de câmbio quanto à constituição e exigibilidade do crédito cambiário.

Capítulo 21. CHEQUE

1. INTRODUÇÃO

O cheque é uma ordem de pagamento à vista, sacada contra um banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador em mãos do sacado ou decorrente de contrato de abertura de crédito entre eles.

O elemento essencial do conceito de cheque é a sua natureza de *ordem à vista*, que não pode ser descaracterizada por acordo entre as partes. Qualquer cláusula inserida no cheque com o objetivo de alterar esta sua essencial característica é considerada não escrita e, portanto, ineficaz (Lei 7.357/85 - LC, art. 32). Desta forma, a emissão de cheque com data futura não produz nenhum efeito cambial, porque reconhecer eficácia na pós-datação importaria tratamento do cheque como um título de crédito a prazo. O cheque pós-datado (alguns dizem erroneamente "pré-datado") é pagável em sua apresentação, à vista, mesmo que ela ocorra em data anterior à indicada como sendo a de emissão do título (art. 32, parágrafo único).

O sacado de um cheque (o banco) não tem, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação cambial. O credor do cheque não pode responsabilizá-lo pela inexistência ou insuficiência de fundos. O banco sacado não garante o pagamento do cheque, nem pode garanti-lo, porque a lei proíbe o aceite do título (LC, art. 6.º) bem como o endosso (art. 18, § 1.º) e o aval de sua parte (art. 29). A instituição financeira sacada só responde pelo descumprimento de algum dever legal, como o pagamento indevido de cheque, a falta de reserva de numerário para liquidação no prazo de apresentação de cheque visado, o pagamento de cheque cruzado diretamente ao portador não cliente, o pagamento em dinheiro de cheque para se levar em conta etc. Ou seja, o banco responde por ato ilícito que venha a praticar, mas não pode assumir qualquer obrigação cambial referente a cheques sacados por seus correntistas.

Os fundos disponíveis em conta-corrente pertencem, até a liquidação do cheque, ao correntista-sacador. Mesmo que o cheque já tenha sido emitido, enquanto não for liquidado, os fundos em conta-corrente pertencem ao depositante. Outro credor do correntista poderá, então, executar seu crédito sobre os recursos disponíveis em conta-corrente, mesmo que já tenha sido emitido cheque com base na provisão correspondente aos fundos existentes na data da emissão.

O cheque deve atender aos seguintes requisitos legais:

- a) a expressão "cheque" inserta no próprio texto do título na língua empregada para a sua redação (art. 1.º, I);
- b) a ordem incondicional de pagar quantia determinada (art. 1.º, II); observe-se que a inexistência ou insuficiência de fundos não desnatura o cheque como um título de crédito (art. 4.º, *in fine*);
- c) a identificação do banco sacado (art. 1.º, III); não vale, no Brasil, como cheque o título emitido contra sacado que não seja banco (art. 3.º);
- d) o local de pagamento ou a indicação de um ou mais lugares ao lado do nome do sacado ou, ainda, a menção de um local ao lado do nome do emitente (arts. 1.º, IV, e 2.º, I e II);

e) data de emissão (art. 1.º, V);

f) assinatura do emitente, ou seu mandatário com poderes especiais, admitido o uso de chancela mecânica ou processo equivalente (art. 1.º, VI, e parágrafo único). O emitente deve ser identificado pelo número de sua Cédula de Identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, do Título Eleitoral ou da Carteira Profissional (Lei 6.268/75, art. 3.º).

O local de emissão também deve constar do título, mas, em sua ausência, entende-se que o cheque foi emitido no local designado ao lado do nome do emitente (LC, art. 2.º, II).

O cheque é título de modelo vinculado, cuja emissão somente pode ser feita em documento padronizado, fornecido pelo banco sacado ao correntista. O lançamento de todos os requisitos legais em qualquer outro documento não configura a emissão de cheque, não gerando efeitos cambiais.

O cheque de valor superior a R\$ 100,00 deve adotar, necessariamente, a forma nominativa e pode conter a cláusula "à ordem" ou a cláusula "não à ordem". A sua circulação, portanto, segue o regramento da circulação da letra de câmbio, salvo três diferenças: *a) o cheque* não admite endosso-caução, em razão da natureza de ordem de pagamento à vista; *b) o endosso* feito pelo sacado é nulo como endosso, valendo apenas como quitação (salvo se o sacado tiver mais de um estabelecimento e o endosso feito por um deles em cheque a ser pago por outro estabelecimento) (art. 18, §§ 1.º e 2.º); *c) o endosso* feito após o prazo para apresentação ("tardio") gera os efeitos de cessão civil de crédito (art. 27).

No tocante ao aval, a lei estabelece que o aval em branco (sem identificação do avalizado) favorece o emitente (art. 30, parágrafo único); além disso, proíbe-se o aval por parte do sacado (art. 29). No mais, aplica-se o mesmo regime reservado ao aval da letra de câmbio.

O devedor principal de um cheque é o emitente.

2. MODALIDADES DE CHEQUE

A LC prevê as seguintes modalidades de cheque: *a) visado; b) administrativo; c) cruzado; d) para se levar em conta.*

O cheque visado é aquele em que o banco sacado lança declaração de suficiência de fundos, a pedido do emitente ou do portador legitimado. Somente o cheque nominativo ainda não endossado comporta esta certificação. O visamento não equivale ao aceite, porque não vincula o banco ao pagamento do título independentemente da existência de provisão de fundos. A única obrigação que lhe compete em virtude do visamento é de reservar, da conta-corrente do emitente, em benefício do credor, quantia equivalente ao valor do cheque durante o prazo de apresentação (LC, art. 7.º, § 1.º).

Claro está que, se o banco não proceder à obrigação legal de reservar, da conta do correntista, numerário suficiente para a liquidação do cheque visado, responderá pelo pagamento do valor do cheque ao credor, se os fundos não existiam ou deixaram de existir. Isto não significa, contudo, que o sacado do cheque tenha alguma obrigação cambial, porque se trata aqui de responsabilidade decorrente da inobservância de determinação legal. Tanto é assim que o sacado não poderá ser protestado, nem executado nesta hipótese, cabendo ao credor apenas ação de indenização. Uma vez condenado a pagar o cheque irregularmente visado, o banco terá direito de cobrar o valor do cheque do emitente.

O cheque administrativo é aquele sacado pelo banco contra um de seus estabelecimentos. Sacador e sacado se identificam no cheque administrativo (LC, art. 9.º, III). Esta modalidade de cheque somente pode ser emitido na forma nominativa.

Uma das espécies mais conhecidas de cheque administrativo é o cheque de viajante (*traveller's check*). Trata-se de uma ordem de pagamento à vista que um banco emite contra qualquer um de seus estabelecimentos e que deve ser firmado pelo credor em dois momentos distintos: na aquisição e na liquidação. Foi largamente utilizado no passado, para dar maior segurança aos viajantes, que não precisam transportar dinheiro.

O cheque cruzado se destina a possibilitar, a qualquer tempo, a identificação da pessoa em favor de quem foi liquidado. Resulta da aposição, pelo emitente ou pelo portador, no anverso do título, de dois traços transversais, no interior dos quais poderá, ou não, ser designado um banco determinado. Na falta de qualquer designação, ou sendo esta genérica, ter-se-á cruzamento *em branco* ou *geral*; em havendo a identificação de um específico banco, ter-se-á cruzamento *em preto* ou *especial*.

O cheque com cruzamento em branco somente pode ser pago a um banco ou a um cliente do sacado mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial somente pode ser pago ao banco cujo nome consta do cruzamento ou, sendo este também o sacado, a um cliente dele, mediante depósito em conta. Dessa forma, se o credor do cheque não for correntista do banco sacado, deverá, necessariamente, proceder à liquidação do título por meio de depósito junto ao banco em que possua conta, providência que implicará no registro do nome da pessoa em favor de quem o cheque é pago.

O cruzamento gera efeitos apenas perante o sacado, que não poderá pagar o cheque cruzado com inobservâncias dessas regras. É claro que se ele não tiver fundos e for cobrado do emitente ou de coobrigado, o pagamento poderá ser feito em dinheiro.

O cheque para se levar em conta tem o mesmo objetivo que o cruzado. Destinam-se as duas modalidades a possibilitar a identificação da pessoa em favor de quem o cheque é liquidado. O cheque com a cláusula "para ser creditado em conta", inserida pelo emitente ou pelo portador, não pode ser pago em dinheiro. Sua liquidação será feita somente por lançamento contábil por parte do banco sacado. Não é admitido o pagamento direto de cheque desta modalidade.

Como acontece com o cruzamento, a cláusula específica do cheque para levar em conta gera efeitos somente perante o sacado, que está obrigado a observar as normas de liquidação pertinentes. Um cheque para se levar em conta sem suficiente provisão de fundos pode ser pago em dinheiro por qualquer devedor do título diretamente ao seu credor.

O cheque com a cláusula "para ser creditado em conta" emitido na forma nominativa prescinde de endosso quando depositado em conta-corrente do favorecido.

3. PAGAMENTO DO CHEQUE

O cheque deve ser apresentado a pagamento no prazo, definido em lei, de: a) 30 dias a partir da emissão, se for cheque da mesma praça; e b) 60 dias da emissão, se for cheque de praças distintas. Entende-se por cheque da mesma praça, para fins de definição do prazo de apresentação, aquele em que o local designado como sendo o de emissão é o mesmo município onde se encontra a agência pagadora do sacado, sendo de praças distintas aquele em que não coincidem o município do local que consta como

sendo de emissão e o da agência pagadora.

Trata-se de um critério formal. Não interessa, a rigor, o local efetivo da emissão, mas o que consta do título. A comparação deste local com o do pagamento possibilita a classificação do cheque como "de mesma praça" ou "de praças diferentes" e a consequente definição do prazo de apresentação.

O credor que não observar o prazo para apresentar o cheque ao sacado está sujeito às seguintes consequências: *a)* perda do direito de executar os coobrigados do cheque, ou seja, os endossantes e avalistas de endossantes em qualquer hipótese; *b)* perda de executar o cheque contra o emitente, se havia fundos durante o prazo de apresentação e eles deixaram de existir, em seguida ao término deste prazo, por culpa não imputável ao correntista (por exemplo, falência do banco) (LC, art. 47, II, e seu § 3.º).

O cheque não apresentado durante o prazo legal pode ser pago pelo sacado, desde que não se encontre prescrito e haja suficiente provisão de fundos em seu poder (LC, art. 35, parágrafo único). A inobservância do prazo de apresentação, portanto, não desconstitui o título de crédito como ordem de pagamento à vista, mas importa as graves sanções acima mencionadas.

O pagamento do cheque pode ser sustado, prevendo a lei duas modalidades de sustação:

a) revogação - também chamada de *contraordem*. Trata-se de ato exclusivo do emitente do cheque, praticado por carta ou notificação judicial ou extrajudicial, em que exponha as razões motivadoras do ato. Esta modalidade de sustação do pagamento gera efeitos apenas após o término do prazo de apresentação e, evidentemente, caso o cheque não tenha sido, ainda, liquidado. Em outros termos, equivale a ato cambial que limita ao prazo de apresentação previsto em lei a eficácia do cheque como ordem de pagamento (LC, art. 35); e

b) oposição - ato que pode ser praticado pelo emitente ou pelo portador legitimado do cheque, mediante aviso escrito, fundado em relevante razão de direito (extravio ou roubo do título, falência do credor etc.). Produz efeitos a partir da cientificação do banco sacado desde que anterior à liquidação do título (LC, art. 36).

A sustação (por revogação ou oposição) pode configurar crime de fraude no pagamento por cheque, se o emitente ou o portador presumivelmente legitimado agirem dolosa e fraudulentamente, provocando dano ao portador do cheque (CP, art. 171, § 2.º, VI).

Em ambas as hipóteses de sustação, o sacado não pode questionar a ordem, devendo limitar-se a cumpri-la caso se encontrem presentes os pressupostos formais. Se estiver ocorrendo abuso de direito pelo emitente ou portador legitimado, isso será objeto de conhecimento judicial, por ação própria, da qual o banco sequer é parte. Da mesma forma, se houver crime de fraude no pagamento por meio de cheque no ato de sustação praticado, não cabe ao banco decidir, mas ao Poder Judiciário.

O cheque pode servir, também, como instrumento de prova de pagamento e de extinção da obrigação, desde que observados os elementos exigidos pelo art. 28 da LC. Assim, o endosso de um cheque nominativo liquidado pelo banco sacado é prova do recebimento, pelo credor, do valor do cheque. Se, por outro lado, o cheque indicar a obrigação a cujo pagamento se refere, nas mesmas condições - vale dizer: nominativo e liquidado pelo banco sacado -, o título prova a extinção da obrigação. Os mesmos efeitos tem o cheque nominativo com a cláusula "para se levar em conta" depositado em conta-corrente do favorecido, independentemente de endosso (art. 46, *caput*, *in fine*).

O cheque não é papel de curso forçado. Ou seja, ninguém está obrigado a recebê-lo contra a vontade. Não existe no direito brasileiro nenhuma hipótese de aceitação obrigatória desse título de crédito.

4. CHEQUE SEM FUNDOS

O pagamento feito por cheque tem efeito *pro solvendo*. Deste modo, até a liquidação não se extingue a obrigação a que se refere. Por exemplo, o pagamento de aluguel por cheque sem fundos não impossibilita a retomada do bem locado mediante o despejo do locatário, ainda que eventual quitação fornecida pelo locador não faça menção ao cheque. Da mesma forma, a instituição financeira proprietária fiduciária não perde o direito de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária em garantia, caso o pagamento da prestação pelo fiduciante tenha sido feito com cheque sem fundos.

As partes, no entanto, podem pactuar que o pagamento de determinada obrigação por cheque tenha efeito *pro soluto*, hipótese em que, não tendo fundos o cheque, restará ao credor da obrigação apenas a titularidade do direito cambial. Se o aluguel é pago com cheque ao qual locador e locatário atribuíram efeito *pro soluto*, não caberá o despejo por falta de pagamento na eventualidade de inexistência de fundos.

O cheque sem fundos deve ser protestado pelo credor no prazo fixado em lei para sua apresentação a pagamento, para fins de conservação do direito creditício contra os coobrigados do título. Para o exercício do direito creditício contra o emitente e seu avalista, o protesto não é necessário. O cheque, como acontece com a letra de câmbio e a nota promissória, pode conter a cláusula "sem despesas", pela qual se dispensa o credor de protestar o título para conservação do direito creditício contra um ou mais coobrigados (LC, art. 50). O protesto do cheque poderá ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente (Lei 9.492/97, art. 6.º).

O protesto do cheque pode ser substituído por uma declaração (escrita, datada e com indicação do dia da apresentação) feita pelo banco sacado ou pela câmara de compensação, no sentido de serem insuficientes os fundos disponíveis. O credor de cheque do qual conste uma declaração assim poderá exercer o seu direito creditício contra todos os devedores do cheque, independentemente de protesto, se o apresentou a pagamento dentro do prazo legal. Note-se, contudo, que esta declaração substitui o protesto apenas para os fins de conservação do direito creditício. Para o pedido de falência de empresário fundado em emissão de cheque sem fundos, o protesto do título é indispensável.

A execução do cheque sem fundos prescreve contra qualquer devedor (principal ou coobrigado) no prazo de 6 meses contados do término do prazo de apresentação a pagamento (LC, art. 59). Um cheque de mesma praça emitido hoje, se não tiver fundos, poderá ser executado no prazo correspondente aos próximos 30 dias *mais* 6 meses. Se for cheque de praças diferentes, nos próximos 60 dias *mais* 6 meses. O termo *a quo* do prazo de prescrição é sempre o término do prazo de apresentação. Outra observação: lembre-se que os dias contam-se pelos dias e os meses pelos meses, de modo que nem sempre será matematicamente correto computar-se o prazo de 7 ou 8 meses.

No caso de cheque pós-datado apresentado antes da data lançada como sendo a de emissão, considera-se emitido o título na data da apresentação a pagamento, para fins de cálculo do prazo prescricional. Computam-se, então, 30 ou 60 dias, conforme seja cheque da mesma ou de praças diferentes e, em seguida, somam-se os 6 meses.

O direito de regresso de um coobrigado contra outro (ou contra o devedor principal ou seu avalista) prescreve em 6 meses contados do dia em que ele pagou o título ou, se executado, da data da distribuição da execução judicial (art. 59, parágrafo único).

Após o decurso do prazo prescricional do cheque, será admissível ação com base no locupletamento sem causa, no prazo de 2 anos (LC, art. 61). Embora se cuide de ação de conhecimento, seu fundamento é cambial. Qualquer coobrigado cambial que se locupletou indevidamente em função da prescrição do cheque pode ser responsabilizado, mas ele não poderá opor exceções pessoais ao demandante de boa-fé.

Em face do emitente do cheque prescrito, poderá o credor preferir a monitória à ação por locupletamento sem causa. Terá, então, o prazo de 5 anos, contados do dia seguinte à data que consta do título (STJ, Súmula n. 503).

Prescrita a ação de enriquecimento ilícito, nenhuma outra ação será possível com base no título de crédito. Poderá, no entanto, o credor por obrigação de origem extracambiária promover a ação correspondente a seu título, que prescreverá no prazo que a lei específica estabelecer ou nos termos do art. 205 do CC. A LC dispõe que, salvo prova de novação, a emissão ou transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não pagamento (art. 62).

Na execução do cheque sem fundos, o credor terá direito à importância do título acrescida de: *a*) juros legais a partir da apresentação a pagamento; *b*) despesas com protesto, avisos e outras; *c*) correção monetária (LC, art. 52, IV).

A emissão de cheque sem fundos é tipificada como crime de fraude por pagamento de cheques (CP, art. 171, § 2.º, VI), com pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Trata-se de crime modalidade dolosa, não incorrendo em qualquer ilícito penal aquele que emite cheque sem fundos por culpa (por exemplo, com negligência no controle do saldo). O pagamento do cheque até o recebimento da denúncia importa extinção de punibilidade. A fraude é elemento do tipo, de sorte que o conhecimento pela vítima da insuficiência de fundos disponíveis importa a descaracterização da emissão como crime (por esta razão, a emissão de cheque pós-datado sem fundos não é conduta típica). Finalmente, é crime de dano, sendo imprescindível para a sua ocorrência, que tenha a vítima sofrido um prejuízo patrimonial. O pagamento de obrigação cambial (representada por duplicata, letra de câmbio, nota promissória ou outro título de crédito) mediante cheque sem fundos não caracteriza o crime porque não importa qualquer prejuízo para a vítima (ela era credora de um título antes de receber o cheque sem fundos, mas continuou credora do mesmo título após recebê-lo).

CAPÍTULO 22. DUPLICATAS

1. DUPLICATA MERCANTIL

A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro. Já o Código Comercial de 1850 previa que, nas vendas por atacado, o vendedor era obrigado a extrair em duas vias uma relação das mercadorias vendidas, as quais eram assinadas por ele e pelo comprador, ficando cada via com um dos contratantes. A via da fatura assinada pelo comprador que permanecia em mãos do vendedor era título de efeitos cambiais, documento hábil para a cobrança judicial do preço da venda. Esta fatura, ou conta, é a origem da duplicata mercantil. Ao longo do tempo, este título de crédito vem sendo alterado, por vezes em função dos interesses do Fisco sobre a atividade comercial.

A duplicata está disciplinada pela Lei 5.474/68 (LD), que obriga, nas vendas mercantis a prazo entre partes domiciliadas no Brasil, a emissão pelo vendedor de uma fatura para apresentação ao comprador. Fatura é a relação de mercadorias vendidas, discriminadas por sua natureza, quantidade e valor. Venda a prazo, para os fins do disposto nessa lei, é aquela cujo pagamento parcelou-se em período não inferior a 30 dias ou cujo preço deva ser pago integralmente em 30 dias ou mais, sempre contados da data da entrega ou despacho da mercadoria. Pelo disposto na LD, portanto, o comerciante estava obrigado a emitir fatura sempre que se tratasse de venda a prazo, sendo-lhe facultada a emissão desta nas vendas não a prazo (art. 1.º).

Em 1970, por convênio celebrado entre o Ministério da Fazenda e as Secretarias Estaduais da Fazenda, com vistas ao intercâmbio de informações fiscais, possibilitou-se aos comerciantes a adoção de um instrumento único de efeitos comerciais e tributários: a *nota fiscal-fatura* (NF-fatura). O comerciante que adota este sistema pode emitir uma única relação de mercadorias vendidas, em cada operação que realizar, produzindo, para o direito comercial, os efeitos da fatura mercantil e, para o direito tributário, os da nota fiscal.

O comerciante que utiliza NF-fatura não poderá, no entanto, deixar de emitir o documento em qualquer operação que realize, mesmo em se tratando de venda não a prazo. A distinção prevista pela LD entre hipóteses de emissão facultativa ou obrigatória da relação de mercadorias vendidas perde, assim, sentido prático em relação aos comerciantes que utilizam a NF-fatura, porque a emissão desta é sempre obrigatória.

Da fatura - ou da NF-fatura - o vendedor poderá extrair um título de crédito denominado duplicata. Se a emissão da fatura é facultativa ou obrigatória de acordo com a natureza da venda e se a emissão da NF-fatura é sempre obrigatória, a emissão da duplicata mercantil, por sua vez, é sempre facultativa. O vendedor não está obrigado a emitir o título em nenhuma situação.

Mas não poderá emitir também letra de câmbio diante de expressa vedação legal (LD, art. 2.º). A compra e venda mercantil poderá ser representada por nota promissória ou por cheque, que são títulos sacados pelo comprador. Ao vendedor, no entanto, a lei só permite a emissão da duplicata mercantil, nenhum outro título.

A duplicata mercantil deve ser emitida com base na fatura ou na NF-fatura. Logo, sua emissão se dá após a de uma destas relações de mercadorias vendidas. Embora a lei não fixe prazo específico máximo para a emissão do título, deve-se entender que ele não poderá ser sacado após o vencimento da obrigação ou da primeira prestação.

São os seguintes os requisitos da duplicata mercantil:

a) a expressão "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem (art. 2.º, § 1.º, I);

b) o número da fatura - ou da NF-fatura - da qual foi extraída (art. 2.º, § 1.º, II);

c) a data certa do vencimento ou a declaração de ser o título à vista (art. 2.º, § 1.º, III), de onde se conclui que a lei não admite duplicata a certo termo da vista ou da data;

d) o nome e o domicílio do vendedor e do comprador (art. 2.º, § 1.º, IV), devendo ser o comprador identificado também pelo número da Cédula de Identidade, inscrição no Cadastro de Pessoa Física, do Título Eleitoral ou da Carteira Profissional (Lei 6.268/75, art. 3.º);

e) a importância a pagar, em algarismos e por extenso (art. 2.º, § 1.º, V);

f) o local de pagamento (art. 2.º, § 1.º, VI);

g) a cláusula "à ordem", não se admitindo a emissão de duplicata mercantil com cláusula "não à ordem", somente passível de inserção no título por endosso (art. 2.º, § 1.º, VII);

h) a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la destinada ao aceite do comprador (art. 2.º, § 1.º, VIII);

i) a assinatura do emitente (art. 2.º, § 1.º, IX), podendo ser utilizada a rubrica mecânica (Lei 6.304/75).

A duplicata mercantil é título de modelo vinculado, devendo ser lançada em impresso próprio do vendedor, confeccionado de acordo com o padrão previsto na Resolução n. 102 do Conselho Monetário Nacional (LD, art. 27). Em princípio, não configura duplicata, nem gera efeitos cambiais, o documento que preencha todos os requisitos acima, mas não observe o padrão legal.

O comerciante que emite duplicata mercantil está obrigado a escriturar um livro específico, denominado "Livro de Registro de Duplicatas" (LD, art. 19). Trata-se de livro obrigatório especial, cuja ausência acarreta as consequências já examinadas no campo civil e penal. Em razão desta escrituração, cada duplicata mercantil tem um número de ordem, que não coincide necessariamente com o número da fatura ou NF-fatura correspondente, em razão da facultatividade de emissão do título de crédito. Se não forem coincidentes, no entanto, o número de ordem da duplicata será sempre inferior ao da fatura ou NF-fatura.

Não admite a lei a emissão de duplicata representativa de mais de uma fatura, ou NF-fatura. Além disso, sendo o preço parcelado, será possível ao vendedor optar pelo saque de uma única duplicata, em que se discriminem os diversos vencimentos, ou pela emissão de um título para cada parcela. Nesta última hipótese, as duplicatas terão o mesmo número de ordem, discriminadas pelo acréscimo de uma letra na sequência do alfabeto.

Deve ser ressaltado, enfim, que muitas das regras acerca da duplicata mercantil estão em completo desuso em razão da utilização do suporte eletrônico pelos comerciantes, prestadores de serviços, bancos e cartórios de protesto. A emissão do título em papel, seu envio ao sacado e posterior devolução, por exemplo, simplesmente não existem mais. A triplicata caiu em completo desuso, porque sua emissão cabia na hipótese de perda ou extravio da duplicata, fato que nunca acontece com os registros eletrônicos. Assim, as regras examinadas neste capítulo dizem respeito à duplicata em suporte papel, e devem ser ajustadas para o caso de utilização do suporte eletrônico (*Cap. 23, item 5*).

2. CAUSALIDADE DA DUPLICATA MERCANTIL

A duplicata mercantil é título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram vinculados à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico-cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exequente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referentes à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título ou não.

A duplicata mercantil é título causal no sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de determinada causa prevista por lei. Ao contrário dos títulos não causais (que alguns também chamam de *abstratos*, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador (a compra e venda mercantil) se encontra presente, está autorizada a emissão da duplicata mercantil.

Até o advento da Lei 8.137/90, era considerado crime a emissão e o aceite de duplicata simulada, ou seja, aquela que não correspondesse a uma efetiva compra e venda mercantil. Com a mudança da redação do art. 172 do CP, feita por aquela lei, o comportamento típico passou a ser a emissão de duplicata mercantil que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade. Como se percebe, o bem jurídico tutelado pela norma penal em foco não é mais o crédito comercial, e sim os interesses dos consumidores.

A duplicata simulada não produz também efeitos cambiais. O credor por obrigação representada em título com esta característica deverá promover ação de conhecimento para provar a existência da obrigação. A duplicata irregular, no caso, servirá, apenas, como um elemento probatório.

3. ACEITE

A duplicata mercantil deve ser remetida pelo vendedor ao comprador, num certo prazo da lei (LD, art. 6.º). Recebendo a duplicata, o comprador pode proceder de acordo com uma das seguintes cinco possibilidades: *a*) assinar o título e devolvê-lo ao vendedor no prazo de 10 dias do recebimento; *b*)

devolver o título ao vendedor, sem assinatura; c) devolver o título ao vendedor acompanhado de declaração, por escrito, das razões que motivam a recusa em aceitá-lo; d) não devolver o título e comunicar ao vendedor o seu aceite, desde que eventual instituição financeira cobradora esteja de acordo; e) não devolver o título, simplesmente.

Qualquer que seja o comportamento do comprador, isto em nada altera a sua responsabilidade cambial, já definida previamente em lei.

A duplicata mercantil é título de *aceite obrigatório*, ou seja, a vinculação ao título como devedor principal independe da vontade do sacado (comprador). Ao contrário do que ocorre com a letra de câmbio, em que o sacado não tem nenhuma obrigação de aceitar a ordem que lhe foi endereçada, na duplicata mercantil o sacado está, em regra, vinculado à aceitação da ordem, só podendo recusá-la em situações previamente definidas em lei.

Quando se afirma que o aceite da duplicata é obrigatório não se pretende que ele não possa ser recusado, mas, sim, que a sua recusa somente poderá ocorrer em determinados casos legalmente previstos. Situação diametralmente oposta à do sacado da letra de câmbio, que pode sempre recusar-se a assumir a obrigação cambial, mesmo que seja devedor do sacador ou do tomador.

A recusa de aceite da duplicata mercantil só é admissível nos casos previstos pelo art. 8.º da LD, ou seja, por motivo de: a) avaria ou não recebimento de mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por conta e risco do comprador; b) vícios na qualidade ou quantidade das mercadorias; c) divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Em qualquer uma destas três hipóteses, e somente nelas, poderá o comprador recusar o aceite e, portanto, não assumir obrigação cambial. É claro que as partes poderão discutir em juízo a ocorrência destas causas, confirmando ou desconstituindo o ato de recusa do comprador.

Em função do seu caráter obrigatório, o aceite da duplicata mercantil pode ser discriminado em três categorias:

a) *Aceite ordinário* - resulta da assinatura do comprador aposta no local apropriado do título de crédito.

b) *Aceite por comunicação* - resulta da retenção da duplicata mercantil pelo comprador autorizado por eventual instituição financeira cobradora, com a comunicação, por escrito, ao vendedor, de seu aceite.

c) *Aceite por presunção* - resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, desde que não tenha havido causa legal motivadora de recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor.

Como se pode perceber, dos cinco comportamentos que o comprador pode ter diante do recebimento de uma duplicata remetida pelo vendedor, apenas a sua devolução não assinada e acompanhada de declaração de recusa do aceite é que pode, se efetivamente havia causa para a recusa, liberá-lo da obrigação cambial documentada pela duplicata mercantil. A recusa na devolução do título ou a sua devolução não assinada são comportamentos que em nada interferem com a obrigação do sacado de pagar a duplicata.

No tocante aos demais atos constitutivos do crédito cambiário, aplicam-se à duplicata as normas relativas à letra de câmbio (LD, art. 25). Observe-se somente que o aval em branco da duplicata é prestado em favor daquele cuja assinatura estiver acima da do avalista, ou, se inexistir uma assinatura assim situada, em favor do comprador; se os avais em branco são superpostos, consideram-se simultâneos (os obrigados são coavalistas do sacador) e não sucessivos (os obrigados não são avalistas de avalistas) (Súmula 189 do STF); em relação ao endosso, é importante notar que, por ser a duplicata sempre sacada pelo vendedor em seu próprio favor, é ele necessariamente o primeiro endossante desse título de crédito, circunstância relevante na interpretação das normas relativas à exigibilidade do crédito cambiário; finalmente, anote-se que o devedor principal da duplicata mercantil é o sacado, ou seja, o comprador das mercadorias.

4. EXIGIBILIDADE DA DUPLICATA

A duplicata pode ser protestada por falta de aceite, de devolução ou de pagamento (Lei 9.492/97, art. 21).

Qualquer que seja a causa do protesto, se o comprador não restituiu o título ao vendedor, ele será feito *por indicações do credor* fornecidas ao cartório de protesto (LD, art. 13, § 1.º). Trata-se de exceção ao princípio da cartularidade, porque permite o exercício de direitos cambiários sem a posse do título. No protesto feito por indicações, estas naturalmente substituem a exibição da cártula.

O protesto deve ser efetuado na praça de pagamento constante da duplicata e no prazo de 30 dias a contar do vencimento. A inobservância do prazo legal para encaminhamento do título a cartório de protesto acarreta a perda, por parte do credor, do direito creditício contra os coobrigados (endossantes e seus avalistas). Contra o devedor principal do título (sacado) e seu avalista, não é necessário o protesto, ou seja, a inobservância do prazo legal para se promover o protesto da duplicata não importa a perda do direito creditício (LD, art. 13, §§ 3.º e 4.º).

A lei não elenca o sacador dentre os coobrigados em relação aos quais o protesto é necessário porque seria redundante. Como visto, o sacador da duplicata ou é o credor do título (e, neste caso, não tem sentido falar-se em perda ou conservação de direito creditício contra ele próprio) ou é necessariamente o endossante do título, já que a duplicata é ordem de pagamento obrigatoriamente sacada em favor do respectivo sacador. Donde se conclui que o protesto é condição de exigibilidade do crédito cambiário contra o sacador, o vendedor das mercadorias, no caso de ele ter endossado a duplicata.

A execução da duplicata possui, também, algumas particularidades. Inicialmente, deve-se atentar para o fato de que a modalidade do aceite praticado define os requisitos de constituição do título executivo. De acordo com o tipo de aceite ocorrido (ordinário, por comunicação ou por presunção), a execução judicial poderá ser manejada a partir de determinados pressupostos.

Assim, se o aceite foi o ordinário (resultante da assinatura do comprador lançada no campo apropriado da duplicata), bastará o título de crédito para a constituição do título executivo. O seu protesto será necessário ou facultativo exclusivamente em função da categoria a que pertence o devedor (necessário contra o coobrigado, facultativo contra o devedor principal).

Caso o aceite praticado tenha sido o por comunicação, o título executivo será a própria carta enviada pelo comprador ao vendedor, em que se informa o aceite e a retenção da duplicata. Nos termos do art.

7.º, § 2.º, da LD, esta comunicação substitui a cártula no protesto e na execução. Atente-se para a circunstância de que o aceite por comunicação impede a circulação do título. A epístola que comunica o aceite somente é documento substitutivo da cártula nas hipóteses de protesto e execução. O vendedor das mercadorias, neste caso, não pode circular com o crédito representado pela duplicata. Para este fim, a comunicação não substitui o título retido. Portanto, como a duplicata aceita por comunicação não pode circular, não há que se cogitar do protesto como condição de exigibilidade do crédito cambiário. O vendedor pode protestar a comunicação apenas como forma de forçar o pagamento da duplicata, mas não precisa fazê-lo para ajuizamento da execução.

Finalmente, em relação ao aceite por presunção (o comprador não assina a duplicata, retendo-a ou devolvendo-a, mas recebendo as mercadorias adquiridas), a constituição do título executivo depende da reunião dos seguintes elementos:

a) *protesto cambial* - a duplicata deve ser protestada, seja com a exibição do título, seja por indicações. No primeiro caso, a cártula é elemento constitutivo do título executivo, devendo ser acompanhada do respectivo instrumento de protesto; no segundo caso, o próprio instrumento de protesto será o título executivo; e

b) *comprovante de entrega da mercadoria* - a constituição do título executivo, na hipótese de aceite por presunção, compreende obrigatoriamente a prova escrita de recebimento da mercadoria pelo comprador.

A execução de duplicata aceita por presunção está prevista no art. 15, II, da LD, que fixa tais requisitos. O mesmo dispositivo menciona, contudo, a inexistência de regular recusa do aceite (alínea c), que deve ser entendida como condição negativa de exigibilidade do crédito cambiário representado por duplicata. Ou seja: cabe ao executado, em embargos, a alegação e prova desta condição. Se acaso o aceite foi regularmente recusado, ou seja, no prazo, forma e pelos motivos da lei (LD, arts. 7.º e 8.º), o comprador, demonstrando isto em embargos, verá desconstituído o título executivo do credor.

Claro está, no entanto, que o comprovante da entrega da mercadoria é elemento constitutivo do título executivo na execução do devedor principal que praticou o aceite por presunção. A execução de duplicata não assinada pelo comprador, promovida contra coobrigado, prescinde deste elemento, devendo unicamente ter sido protestada no prazo da lei. A execução da duplicata contra o avalista do sacado, por sua vez, independe do comprovante de recebimento de mercadorias e também do protesto no prazo legal. Em outros termos: o comprovante de recebimento das mercadorias adquiridas só é elemento constitutivo do título executivo, juntamente com o protesto, quando se tratar de execução de duplicata não assinada promovida contra o comprador.

Por esta razão, o endossatário de duplicata não assinada pelo comprador deve exigir que lhe seja entregue o documento comprobatório do recebimento da mercadoria ou uma cópia autêntica do mesmo, para, oportunamente, se for necessário, poder executar o título contra o devedor principal. Também o credor tem o direito de solicitar, a qualquer tempo, do vendedor das mercadorias, o fornecimento deste documento ou de sua cópia autêntica. Igual direito tem o coobrigado que paga a duplicata assim caracterizada, para fins de exercício do direito de regresso contra o comprador.

Acentue-se que o protesto cambial que a lei define como condição de exigibilidade da duplicata não assinada (quando acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias) não precisa ter sido providenciado necessariamente nos 30 dias seguintes ao do vencimento, *quando o executado for o*

sacado. Mesmo o protesto extemporâneo supre a exigência legal nesta hipótese específica.

A competência para o processamento da execução é do juízo da praça de pagamento ou do domicílio do devedor. A pretensão da execução prescreve em 3 anos, a contar do vencimento do título, contra o devedor principal (o sacado) e seus avalistas; em 1 ano a partir do protesto, contra os coobrigados (sacador, endossantes e seus avalistas); e em 1 ano, para o exercício do direito de regresso, contado do dia do pagamento do título.

5. TÍTULOS DE CRÉDITO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Lei das Duplicatas prevê, ainda, dois outros títulos de crédito além da duplicata mercantil. Trata-se da duplicata de prestação de serviços (arts. 20 e 21) e da conta de serviços (art. 22).

A duplicata de prestação de serviços pode ser emitida por pessoa, natural ou jurídica, que se dedique a atividade econômica desta natureza. Trata-se de título de crédito de regime jurídico absolutamente idêntico ao da duplicata mercantil. Apenas duas especificidades a registrar: *a)* a causa que autoriza a sua emissão não é a compra e venda mercantil, mas a prestação de serviços; *b)* o protesto por indicações depende da apresentação, pelo credor, de documento comprobatório da existência do vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços. Encontra-se o prestador de serviços que opera com o título obrigado à escrituração do Livro de Registro de Duplicatas, devendo emitir fatura discriminatória dos serviços prestados sempre que pretender emitir duplicata representativa do crédito decorrente. Aplicam-se quanto aos demais aspectos desse título as normas pertinentes à duplicata mercantil. Assim, é a duplicata de prestação de serviços título de aceite obrigatório. O sacador somente deixará de ter responsabilidade cambial se ocorrer uma das hipóteses descritas no art. 21 da LD e houver, em consequência, a regular recusa.

Outro título de crédito por prestação de serviços previsto na Lei das Duplicatas é a Conta de Serviços, que pode ser emitida pelo profissional liberal e pelo prestador de serviço eventual. Neste caso, estará o emitente dispensado de proceder a qualquer escrituração especial. Deve o credor elaborar a Conta, discriminando os serviços prestados por sua natureza e valor, além de mencionar a data e o local do pagamento e o vínculo contratual que originou o crédito. Em seguida, deverá registrar a Conta no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e enviá-la ao comprador dos serviços. Se o devedor não efetuar o pagamento, no prazo, o credor poderá protestar a Conta e executá-la. A Conta de Serviços precisa necessariamente estar protestada para constituir título executivo e deverá ou conter a assinatura do devedor ou vir acompanhada do comprovante da realização dos serviços. Trata-se, no entanto, de título de crédito impróprio, não suscetível de circulação cambial.

Capítulo 23. TÍTULOS DE CRÉDITO IMPRÓPRIOS E TÍTULOS DE CRÉDITO ELETRÔNICOS

1. INTRODUÇÃO

O regime jurídico-cambial caracteriza-se por três princípios (cartularidade, literalidade e autonomia). Embora presentemente tais princípios estejam passando por um processo de revisão, em muito provocado pela utilização do suporte eletrônico, o certo é que eles ainda se aplicam *grosso modo* aos títulos de crédito. A própria conceituação de título de crédito, conforme visto, gravita em torno deles, de sorte a se poder afirmar ser título de crédito o documento representativo de obrigação pecuniária sujeito a tais princípios.

Alguns instrumentos jurídicos, por outro lado, se encontram sujeitos a uma disciplina legal que aproveita *em parte* os elementos do regime jurídico-cambial. Mas tais instrumentos não podem ser considerados títulos de crédito, embora se encontrem disciplinados por regime jurídico próximo ao das cambiais, justamente porque não se aplicam em sua disciplina totalmente os elementos caracterizadores do direito cambiário. Costumam-se denominar tais instrumentos pela expressão "*títulos de crédito impróprios*".

Distinguem-se os instrumentos jurídicos chamados de títulos de crédito impróprios em quatro categorias.

Na primeira, encontram-se os *títulos de legitimação*, que asseguram ao seu portador a prestação de um serviço ou acesso a prêmios em certame promocional ou oficial. Por exemplo: o bilhete de metrô, o passe de ônibus, o ingresso de cinema, os cupões premiados do tipo "Achou, ganhou", o volante sorteado da loteria numérica etc. A estes se aplicam os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, mas eles não são títulos executivos.

As demais categorias serão examinadas em seguida, com maior atenção, em razão de suas peculiaridades. Anote-se, antes, que alguns autores adotam conceito mais elástico de título de crédito impróprio, incluindo nesta categoria o cheque (por se tratar de ordem de pagamento à vista e, portanto, não representar operação de crédito), assim como todos os títulos causais, incluindo as duplicatas. Segundo este entendimento, apenas a letra de câmbio e a nota promissória seriam títulos de crédito.

2. TÍTULOS REPRESENTATIVOS

Sob esta denominação costuma-se designar o instrumento jurídico que representa a titularidade de mercadorias custodiadas, vale dizer, que se encontram sob os cuidados de alguém diferente do proprietário. Além desta função meramente documental, tais instrumentos exercem também a de título de crédito, por instrumentalizarem a mais fácil negociação da mercadoria custodiada por seu proprietário.

São desta categoria os títulos armazeneiros (Conhecimento de Depósito e *Warrant*, gerais ou agropecuários) e o Conhecimento de Frete. Estes títulos representam mercadorias custodiadas e possibilitam, em algumas condições, a negociação delas pelo proprietário.

O Conhecimento de Depósito e o *Warrant* gerais são títulos de emissão de armazéns-gerais,

representativos de mercadorias neles depositadas (Decreto 1.102/03). Sua emissão depende de solicitação do depositante e substituem o recibo de depósito.

Os títulos de emissão dos armazéns-gerais são criados juntos e a mercadoria depositada somente pode ser entregue, em regra, a quem exiba ambos os documentos. Contudo, embora tenham origem e finalidade comuns, o Conhecimento de Depósito e o *Warrant* podem circular separadamente. A livre disponibilidade da mercadoria depositada somente é alienada ao adquirente dos dois títulos.

Quem for endossatário apenas do Conhecimento de Depósito passa a ser o proprietário da mercadoria depositada, mas sua propriedade é limitada porque lhe falta o atributo da onerabilidade (possibilidade de oferecer o bem em garantia de dívida). O endossatário apenas do Conhecimento de Depósito pode alienar a mercadoria depositada e, em geral, exercer todos os direitos de proprietário, salvo instituir sobre ela uma garantia pignoratícia.

Já o endosso em separado do *Warrant* importa a constituição de direito real de garantia em favor do endossatário. O endosso do *Warrant* deve ser mencionado no Conhecimento de Depósito para que o endossatário deste saiba que está adquirindo mercadoria onerada, dada em garantia pignoratícia de obrigação assumida pelo endossante.

A liberação de mercadoria depositada em armazém-geral, quando emitidos estes títulos representativos, poderá ser feita apenas ao legítimo portador dos dois. Esta regra admite apenas duas exceções: *a)* liberação em favor do titular do Conhecimento de Depósito endossado em separado, antes do vencimento da obrigação garantida pelo endosso do *Warrant*, desde que deposite junto ao armazém-geral o valor desta obrigação; *b)* execução da garantia pignoratícia, após o protesto do *Warrant*, mediante leilão realizado no próprio armazém.

Por sua vez, o Conhecimento de Depósito Agropecuário (CDA) e o *Warrant* Agropecuário (WA) são emitidos por armazéns aparelhados material e juridicamente falando para o depósito de produtos agrícolas e pecuários. Além das mesmas características dos títulos armazeneiros gerais, o CDA e o WA podem servir de lastro para operações no mercado financeiro e de capitais.

O Conhecimento de Frete é o título representativo de mercadorias transportadas (Decreto 19.473/30; CC, art. 744). Sua emissão cabe às empresas de transporte por água, terra ou ar. A finalidade originária deste instrumento é a prova do recebimento da mercadoria pela empresa transportadora e da obrigação que ela assume de entregá-la no destino. O Conhecimento de Frete, no entanto, possibilita ao proprietário da mercadoria despachada negociá-la mediante endosso do título. Em algumas circunstâncias, no entanto, a lei veda a negociabilidade do Conhecimento de Frete: inclusão de cláusula "não à ordem" no título, transporte de mercadoria perigosa ou de cargas destinadas a armazéns-gerais (Decreto 51.813/63, art. 91). Em se tratando de Conhecimento de Frete negociável, o seu endosso transfere a propriedade da mercadoria transportada. Neste caso, o transportador deverá entregá-la, no destino, ao portador legitimado do Conhecimento de Frete.

Os títulos representativos não se encontram, como se pode perceber, inteiramente sujeitos ao regime jurídico-cambial, porque possuem finalidade originária diversa da dos títulos de crédito. Estes se destinam a representar obrigação pecuniária; já os títulos representativos têm por objeto mercadorias custodiadas. Somente em caráter subsidiário, como no penhor destas mercadorias, os títulos representativos podem referir-se a obrigações pecuniárias.

3. TÍTULOS DE FINANCIAMENTO

Há alguns instrumentos cedulares representativos de crédito decorrente de financiamento aberto por instituição financeira. Se houver garantia de direito real do pagamento do valor financiado, por parte do mutuário, esta garantia é constituída no próprio título, independentemente de qualquer outro instrumento jurídico. Os títulos de financiamento são importantes meios de incremento de atividades econômicas. Podem ser também utilizados no financiamento da aquisição da casa própria.

Nesta categoria de títulos de crédito impróprios se enquadram: Cédula e Nota de Crédito Rural (Decreto-Lei 167/67), relacionadas ao financiamento das atividades agrícolas e pecuárias; Cédula e Nota de Crédito Industrial (Decreto-Lei 413/69), referentes ao financiamento da indústria; Cédula e Nota de Crédito Comercial (Lei 6.840/80), destinadas ao financiamento de atividade comercial ou de prestação de serviços; Cédula e Nota de Crédito à Exportação (Lei 6.313/75), pertinentes ao financiamento da produção de bens para a exportação, da própria exportação e de atividades complementares; e a Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), destinada a representar créditos derivados de operações com imóveis (Lei 10.931/2004, arts. 18 a 25).

Tais títulos costumam chamar-se "Cédula de Crédito" quando o pagamento do financiamento a que se referem é garantido por hipoteca ou penhor (direito real de garantia sobre bem imóvel e móvel, respectivamente). Inexistindo garantia de direito real, o título é comumente denominado "Nota de Crédito" (à exceção da CCI, que, mesmo não garantida por direito real, continua a chamar-se *cédula*).

Os títulos de financiamento não se enquadram completamente no regime jurídico-cambial por força de algumas peculiaridades, como a possibilidade de endosso parcial, mas, principalmente, em razão do princípio da cedularidade, estranho ao direito cambiário. Por este princípio, a constituição dos direitos reais de garantia se faz no próprio instrumento de crédito, na própria Cédula, não sendo necessário mais nenhum outro documento.

4. TÍTULOS DE INVESTIMENTO

Os instrumentos jurídicos desta categoria de título de crédito impróprio se destinam à captação de recursos pelo emitente. Representam *grosso modo* a parcela de contrato de mútuo que o sacador do título celebra com os seus portadores. Sob o ponto de vista destes, o negócio tem o sentido de um investimento, emprego de capital no desenvolvimento de certa atividade econômica com o intuito lucrativo. Existem alguns tipos de títulos com este perfil, mas que se enquadram em conceito distinto, com regime jurídico próprio, como as debêntures, que são espécie de "valor mobiliário".

Entre os títulos de investimento, podem ser lembrados: a letra de câmbio financeira, ou cambial financeira (LMC), emitida ou aceita por sociedades de fins econômicos, inclusive as instituições financeiras; os Certificados de Depósito Bancário (LMC), emitidos pelos bancos de investimento de natureza privada para os depósitos com prazo superior a 18 meses; o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), emitido pelas companhias securitizadoras de créditos imobiliários (Lei 9.514/97, art. 6º); a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), emitida por bancos com lastro em créditos imobiliários (Lei 10.931/2004, art. 12); a Letra de Arrendamento Mercantil (LAM), de emissão das sociedades de arrendamento mercantil (Lei 11.882/2008, art. 2º).

5. TÍTULOS DE CRÉDITO ELETRÔNICOS

Os títulos de crédito, como qualquer outro documento jurídico, têm tido cada vez mais o suporte eletrônico (chamado também de *virtual*, *desmaterializado* ou *despapelizado*).

Alguns ambientes de negociação de títulos de crédito admitem sua circulação apenas mediante registros eletrônicos, feitos pelos interessados com direito de acesso ao sistema. Um dos mais conhecidos ambientes é a *CETIP S.A. Mercados Organizados* (CETIP), fato que tem contribuído para a difusão da expressão "*títulos cetipados*" como referência aos que são registrados e negociados neste ambiente eletrônico. Os títulos cetipados são, assim, espécie de título de crédito eletrônico.

Há hoje, então, dois suportes possíveis para qualquer título de crédito: o suporte papel (cártula) e o suporte eletrônico (sistema informatizado). Na verdade, os títulos podem ser criados em suporte papel e só por meio dele serem negociados; ou criados em papel e passarem a ser negociados no suporte eletrônico.

Criou-se, em decorrência, a figura da *transmutação de suporte*. O título é um só, mas tem o suporte papel durante certo tempo e, depois, o eletrônico. Por exemplo, um banco recebe de empresa que contraiu empréstimo uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em papel. Se quiser negociar esse crédito com um fundo de investimento, por força da regulação bancária, deverá obrigatoriamente registrá-lo em ambiente eletrônico de negociação. Se optar pela CETIP, essa CCB será "cetipada". Quer dizer, a cártula (suporte papel) ficará guardada nos arquivos do banco credor e toda e qualquer negociação daquela CCB só poderá ser feita, a partir de então, mediante registros eletrônicos no ambiente mantido pela CETIP. O suporte papel deixa de ter momentaneamente qualquer significado jurídico. Se alguém lançar neste pedaço de papel um endosso, este ato não terá nenhuma validade para o direito cambiário, porque qualquer transmissão do título deverá ser feita necessariamente no ambiente eletrônico, enquanto for este o suporte do título.

Se aquela CCB for paga no vencimento, o título não voltará a ser papelizado. Encerrou sua função ostentando o suporte eletrônico. Pode-se jogar ao lixo o papel guardado que outrora servira de suporte. Mas, se não houver o cumprimento da obrigação pela empresa emitente, o último credor da CCB precisará pedir ao banco custodiante que lhe entregue a cártula para promover a ação judicial.

A sistemática da transmutação de suporte está prevista na lei em relação a três títulos de crédito específicos: *Warrant Agropecuário* (WA), *Conhecimento de Depósito Agropecuário* (CDA) e *Cédula de Produto Rural* (CPR). E há um título de crédito que só admite o suporte eletrônico, desde a origem, que é a *Letra de Arrendamento Mercantil* (LAM).

Os princípios do direito cambiário não se amoldam completamente aos títulos de crédito eletrônicos. A *cartularidade*, por exemplo, é inteiramente inaplicável, inconciliável com esse suporte. Não há nada, no meio eletrônico, parecido com a ideia de *posse da cártula*. Em relação à *literalidade*, é possível um paralelo: o que não consta do registro eletrônico não produz efeitos cambiários. Por fim, é completa a sujeição dos títulos de crédito eletrônicos ao princípio da *autonomia das obrigações cambiárias*, e aos seus subprincípios da *inoponibilidade* e da *abstração*.

QUARTA PARTE - DIREITO FALIMENTAR

(Autor)

Fábio Ulhoa Coelho

Capítulo 24. TEORIA GERAL DO DIREITO FALIMENTAR

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a garantia dos credores é representada pelos bens do patrimônio do devedor. Isto quer dizer que, em ocorrendo o inadimplemento de qualquer, o credor poderá promover, perante o Poder Judiciário, a execução de tantos bens do patrimônio do devedor quantos bastem à integral satisfação de seu crédito. A execução processar-se-á, em regra, individualmente, com um exequente se voltando contra o devedor para dele haver o cumprimento da obrigação devida.

Quando, porém, o devedor tem, em seu patrimônio, bens de valor inferior à totalidade de suas dívidas, quando ele deve mais do que possui, a regra da individualidade da execução torna-se injusta. Isto porque não dá aos credores de uma mesma categoria de crédito chances iguais de receberem seus créditos. Aquele que se antecipa na propositura da execução possivelmente receberá a totalidade do seu crédito, enquanto os que se demoram (até porque eventualmente nem tinha ainda vencido a respectiva obrigação) muito provavelmente não receberão nada, porque encontrarão o patrimônio do devedor já totalmente exaurido.

Para se evitar essa injustiça, conferindo as mesmas chances de realização do crédito a todos os credores de uma mesma categoria, o direito afasta a regra da individualidade da execução e prevê, na hipótese, a obrigatoriedade da execução concursal, isto é, do concurso de credores (antigamente denominada execução "coletiva"). Se o devedor possui em seu patrimônio menos bens que os necessários ao integral cumprimento de suas obrigações, a execução destes não poderá ser feita de forma individual, mas terá que ser concursal. Ou seja, deve ser feita mediante uma execução que abranja a totalidade dos credores, a totalidade dos bens, todo o passivo e todo o ativo do devedor.

Isto é o que se entende por *par conditio creditorum*, princípio básico do direito falimentar. Os credores do devedor que não possui condições de saldar integralmente suas obrigações devem receber do direito um tratamento *paritário*, dando-se aos que integram uma mesma categoria iguais chances de efetivação de seus créditos.

Desta forma o direito tutela o crédito e especialmente o crédito comercial, possibilitando que melhor desempenhe sua função na economia e, conseqüentemente, na sociedade. As pessoas se sentem menos inseguras em facilitar o crédito quando podem contar com esse tratamento paritário na hipótese de vir o devedor a encontrar-se em situação patrimonial que o impeça de honrar totalmente seus compromissos.

A falência é a execução concursal do devedor empresário. Quando o devedor com bens no

patrimônio insuficientes para o pagamento das dívidas não exerce profissionalmente atividade empresária, a execução concursal chama-se *execução contra credor insolvente* e é, naturalmente, diversa da falência. O direito falimentar refere-se, assim, ao conjunto de regras jurídicas pertinentes à execução concursal do devedor empresário, que são diferentes das aplicáveis ao devedor civil (não empresário).

A falência, como um regime diferenciado de execução concursal do empresário, importa liberar tratamento mais benéfico ao devedor exercente de atividade econômica sob a forma de empresa que o concedido as pessoas em geral. E isto se pode perceber pelas seguintes diferenças exemplificativas entre um e outro regime:

a) *Recuperação da empresa* - faculdade aberta pela lei exclusivamente aos devedores que se enquadram no conceito de empresário ou sociedade empresária, a recuperação judicial possibilita a reorganização das empresas exploradas pelo devedor, com maior ou menor sacrifício dos credores, de acordo com plano aprovado ou homologado judicialmente. Por meio do plano de recuperação da empresa, o devedor pode postergar o vencimento de obrigações, reduzir seu valor ou beneficiar-se de outros meios aptos a impedir a instauração da execução concursal. O devedor civil não tem nenhuma medida com esta extensão. Na melhor das hipóteses, a lei prevê a possibilidade de suspensão da execução concursal se o devedor obtiver a anuência de todos os credores (CPC/1973, art. 783; CPC, art. 1.052).

b) *Extinção das obrigações* - o devedor empresário em regime de execução concursal tem as suas obrigações julgadas extintas com o rateio entre os quirográficos de mais de 50% do devido após a realização de todo o ativo (LF, art. 158, II); ao passo que as obrigações do devedor civil, em regime de execução concursal, somente se extinguem com o pagamento integral do devido (CPC/1973, art. 774; CPC, art. 1.052). Um empresário que entra em falência com um patrimônio de valor suficiente para pagar 100% dos credores com preferência e mais de 50% dos quirografários poderá obter a declaração de extinção das obrigações logo após a realização de seu ativo e rateio do produto apurado. Se, em seguida, adquirir novos bens, os credores existentes ao tempo da falência não terão direito de executar seus créditos no patrimônio recomposto; já o devedor civil na mesmíssima situação poderia ter o seu patrimônio reconstituído executado até o integral pagamento do passivo, salvo o decurso do prazo de 5 anos do encerramento do processo de insolvência (CPC/1973, art. 778; CPC, art. 1.052).

Estas são duas das diferenças entre o regime de execução concursal civil (execução contra devedor insolvente) e o comercial (falência). Além delas, há diferenças no campo do direito das obrigações, processual e penal.

Para que se instaure o processo de execução concursal da *falência*, é necessária a concorrência de três pressupostos: a) devedor empresário; b) insolvência; c) sentença declaratória da falência. Os dois primeiros pressupostos são examinados neste capítulo, enquanto o último é objeto do capítulo seguinte.

2. DEVEDOR SUJEITO À FALÊNCIA

Por ser o regime de execução concursal do devedor empresário, em princípio, estará sujeito à falência todo e qualquer exercente de atividade empresarial.

O profissional que o direito considera empresário, pessoa natural ou jurídica, é o executado no regime de execução concursal falimentar. Como visto anteriormente (*Cap. 1*), empresário é quem exerce

atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços (CC, art. 966). Neste conceito, enquadram-se os que exploram atividade dos mais variados segmentos: supermercado, hotel, atacadista de gêneros alimentícios, varejista de roupas, fábrica de calçados, estacionamento, agência de publicidade, concessionária de automóveis, construtora, restaurante, editora, livraria, indústria química, farmácia etc. A lei não considera empresários os profissionais liberais, artistas e, quando não registrado no Registro de Empresas, o explorador de atividade rural (agricultura, pecuária, extrativismo etc.) (CC, arts. 966, parágrafo único, e 971).

Sempre que o devedor é legalmente empresário, a execução concursal de seu patrimônio faz-se pela falência. Em outros termos, quando o devedor explora sua atividade econômica de forma empresarial - caracterizada pela conjugação dos fatores de produção: investimento de capital, contratação de mão de obra, aquisição de insumos, desenvolvimento ou compra de tecnologia -, não sendo capaz de honrar suas obrigações no vencimento (ou estando presentes outros fatos tipificados em lei), o juiz deve instaurar um processo de execução concursal destinado à satisfação dos credores, no quanto for possível. Este processo é a falência.

Em determinados textos legais, está explícito o não cabimento do regime jurídico-falimentar por se tratar de devedor civil, não empresário. É o caso das cooperativas, em que a lei, ao fixar que ditas pessoas jurídicas não se sujeitam à falência, limita-se, a rigor, ao mero esclarecimento de algo que decorre já da própria inexistência de natureza empresarial nelas. Mesmo se a lei fosse silente acerca do assunto, não estariam as cooperativas sujeitas ao direito falimentar.

Em situação bastante diferente se encontram, no entanto, algumas categorias de empresários, que o legislador, por razões várias, determinou fossem excluídas total ou parcialmente do regime jurídico-falimentar.

Por exclusão total do regime falimentar entende-se a disposição de lei que reserva, para a hipótese em que o devedor empresário tem menos bens em seu patrimônio do que o necessário ao pagamento de seus débitos, um processo ou procedimento de execução concursal diverso do falimentar. E por exclusão parcial a disposição legal que estabelece um processo ou procedimento de execução concursal do devedor empresário *alternativos* ao falimentar. O empresário excluído totalmente da falência não poderá, em nenhuma hipótese, submeter-se ao processo falimentar como forma de execução concursal. Já o empresário excluído parcialmente da falência, em determinados casos discriminados por lei, poderá ter a falência decretada.

Estão totalmente excluídos do regime falimentar: *a)* as empresas públicas e sociedades de economia mista (LF, art. 2.º, I), que são sociedades exercentes de atividade econômica controladas direta ou indiretamente por pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Territórios ou Municípios); *b)* as câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, sujeitos de direito cujas obrigações são sempre ultimadas e liquidadas de acordo com os respectivos regulamentos, aprovados pelo Banco Central (as garantias conferidas pelas câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira destinam-se, por lei, prioritariamente, à satisfação das obrigações assumidas no serviço típico dessas entidades) (LF, art. 193); *c)* as entidades fechadas de previdência complementar (LC 109/2001, art. 47).

Entre os empresários parcialmente excluídos do regime falimentar, podem ser lembradas: *a)* as instituições financeiras, às quais destinou o legislador o processo de liquidação extrajudicial (Lei 6.024/74), sob a responsabilidade do Banco Central; *b)* as sociedades arrendadoras que tenham por

objeto exclusivo a exploração de *leasing*, sujeitas ao mesmo regime de liquidação extrajudicial previsto para as instituições financeiras (Res. BC 2.309/96); c) as sociedades que se dediquem à administração de consórcios, fundos mútuos e outras atividades assemelhadas e se sujeitam a procedimento de liquidação extrajudicial idêntico ao das instituições financeiras (Lei 5.768/71, art. 10); d) as seguradoras, que devem ter a falência requerida pelo liquidante nomeado pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), quando frustrada a liquidação extrajudicial (isto é, se o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos metade dos credores quirografários) ou se surgirem nesta indícios de crime falimentar (LS, art. 26); e) as entidades abertas de previdência complementar (LC 109/2001, art. 73) e as de capitalização (Decreto-Lei 261/67, art. 4.º), nas mesmas condições que as seguradoras; f) as operadoras de planos privados de assistência à saúde, submetidas ao regime de liquidação extrajudicial pela ANS (Agência Nacional de Saúde), e que só podem falir nas mesmas condições das seguradoras (Lei 9.656/98, art. 23).

Todos os empresários parcialmente excluídos do regime falimentar podem ter a sua falência decretada, observadas as condições específicas legalmente previstas. Por exemplo: a falência de instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial deve ser requerida pelo próprio liquidante, autorizado pelo Banco Central, se o ativo não alcançar metade do passivo quirografário ou se houver indícios de crime falimentar.

3. INSOLVÊNCIA

O estado patrimonial em que se encontra o devedor que possui o ativo inferior ao passivo é denominado *insolvência*. O devedor em insolvência é que se encontra sujeito à execução concursal de seu patrimônio, como imperativo da *par conditio creditorum*. Mas é necessário atentar-se para o fato de que o segundo pressuposto da falência não é a insolvência entendida em sua acepção econômica, ou seja, como um estado patrimonial. É, isto sim, a insolvência entendida em um sentido jurídico preciso estabelecido na Lei de Falências (Lei 11.101/05 - LF).

Desta forma, para que o devedor empresário seja submetido à execução por falência, é rigorosamente indiferente a inferioridade do ativo em relação ao passivo. Nem se faz necessário provar o estado patrimonial de insolvência do devedor, para que se instaure a execução concursal falimentar; nem, por outro lado, se livra da execução concursal o devedor empresário que lograr demonstrar eventual superioridade de seu ativo em relação ao passivo, ao contrário do que ocorre com o devedor civil (CPC/1973, art. 756, II; CPC, art. 1.052).

Para fins de instauração da execução por falência, a insolvência não se caracteriza por um determinado estado patrimonial, mas sim pela ocorrência de um dos fatos previstos em lei. Em outros termos, a insolvência se caracteriza, para o direito falimentar, quando o empresário for injustificadamente impontual no cumprimento de obrigação líquida (LF, art. 94, I), incorrer em execução frustrada (art. 94, II) ou praticar ato de falência (art. 94, III). Se restar caracterizada a impontualidade injustificada, a execução frustrada ou o ato de falência, mesmo que o empresário tenha o seu ativo superior ao passivo, será decretada a falência; ao revés, se não ficar demonstrada nenhuma destas hipóteses, não será instaurada a falência ainda que o passivo do devedor seja superior ao ativo. A insolvência que a lei considera pressuposto da execução por falência é meramente presumida. Os comportamentos discriminados pelo art. 94 da LF são geralmente praticados por quem se encontra em insolvência, e esta é a presunção legal que orienta a matéria.

A impontualidade injustificada deve se referir a obrigação líquida. Para fins de decretação da falência, entende-se por "líquida" a obrigação representada por título executivo, judicial ou extrajudicial. Qualquer dos títulos que legitimem a execução individual, de acordo com a legislação processual, pode servir de base à obrigação a que se refere a impontualidade caracterizadora da insolvência. Trata-se de critério formal da lei: a impontualidade é considerada de obrigação líquida quando documentada por título executivo.

Há, no entanto, algumas obrigações que, mesmo líquidas, não podem servir de base à impontualidade injustificada. São as que não podem ser reclamadas na falência, como as obrigações gratuitas, por exemplo (LF, art. 5.º, I).

Quando, por outro lado, se fala em impontualidade *injustificada*, tem-se em mira a inexistência de relevante razão para o inadimplemento da obrigação líquida. Está claro que o devedor empresário não terá a sua falência decretada por sua impontualidade, se tiver fundados motivos para não pagar determinado título. Se a obrigação estava prescrita, se inexistente ou nula, o inadimplemento não importará em caracterização da impontualidade motivadora da falência. A própria lei sugere uma lista de hipóteses de impontualidade *justificada* (LF, art. 96).

A prova da impontualidade é o protesto do título. Qualquer que seja o documento representativo da obrigação a que se refere a impontualidade injustificada, ele deve ser protestado. Se for título de crédito, o protesto cambial, mesmo que extemporâneo, basta para a caracterização da impontualidade do devedor. Os demais títulos, caracterizados na lei como "documentos de dívida" (por exemplo: sentença judicial, certidão da dívida ativa etc.), também devem ser protestados. Nenhum outro meio de prova testemunhal ou documental é apto a demonstrar a impontualidade de que cogita a LF.

Só caracteriza a impontualidade injustificada, para fins de falência, se o valor dos títulos em atraso for de pelo menos 40 salários mínimos. Se o valor do débito do empresário é inferior a esse limite legal, o credor pode cobrá-lo ou executá-lo, mas não poderá pedir falência em razão do inadimplemento. Credores do mesmo empresário cujos créditos individualmente considerados não alcançam 40 salários mínimos, mas cuja soma alcança, podem se reunir em litisconsórcio para requererem a falência do devedor (LF, art. 94, § 1.º).

Em suma, para que se encontre tipificado o comportamento descrito pelo art. 94, I, da LF, e, portanto, seja possível a instauração da execução concursal por falência, é necessário que o devedor empresário tenha sido impontual, sem relevante razão jurídica, no cumprimento de obrigação documentada em título executivo de valor superior a 40 salários mínimos. Dita impontualidade deverá ser provada necessariamente pelo protesto do título correspondente.

A frustração da execução (tríplice omissão) caracteriza-se, por sua vez, pela inexistência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora por parte do empresário, quando é ele executado individualmente por algum credor (LF, art. 94, II). Nesse caso, a execução deve ser encerrada e o credor, munido de certidão judicial que ateste a verificação da tríplice omissão, ingressa com o pedido de falência. O título, nesse caso, não precisa estar protestado e pode ter valor inferior a 40 salários mínimos.

Em relação aos atos de falência, de que trata o art. 94, III, da LF, deve-se considerar que são todos comportamentos que, pressupostamente, revelam a insolvência entendida como estado patrimonial do devedor empresário. São atos de falência:

a) *Liquidação precipitada* - se o empresário promove a liquidação da empresa de forma abrupta incorre no tipo legal; também estará praticando ato de falência o empresário que emprega meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos, como a contratação de empréstimos a juros excessivos ou a venda de instrumentos indispensáveis ao exercício de sua empresa (art. 94, III, a).

b) *Negócio simulado* - se o empresário tenta retardar pagamentos ou fraudar credores por meio de negócio simulado, estará incorrendo em comportamento tipificado como ato de falência (art. 94, III, b).

c) *Alienação irregular de estabelecimento* - o empresário que aliena estabelecimento empresarial sem o consentimento de seus credores, salvo se conservar em seu patrimônio bens suficientes para responder pelo passivo, estará incurso no tipo legal de ato de falência (art. 94, III, c).

d) *Simulação de transferência de estabelecimento* - incorre em ato de falência o empresário que muda o local do estabelecimento com o intuito de fraudar a legislação, frustrar a fiscalização ou prejudicar credores (art. 94, III, d).

e) *Garantia real* - para tipificação desta hipótese de ato de falência, elegeu o legislador a instituição de garantia real em favor de um credor. Necessário, contudo, que esta instituição se opere posteriormente à constituição do crédito. Não há ato de falência se obrigação e garantia real são concomitantes. A incoincidência entre um e outro é que revela o intuito de fraudar a *par conditio creditorum* (art. 94, III, e).

f) *Abandono do estabelecimento empresarial* - sem que tenha o empresário constituído procurador bastante, com recursos suficientes, para a quitação de suas obrigações, o abandono do estabelecimento empresarial importa caracterização de ato de falência (art. 94, III, f).

g) *Descumprimento do plano de recuperação judicial* - o empresário beneficiado com a recuperação judicial que não cumpre o estabelecido no respectivo plano pratica ato de falência e deve ver instaurada a execução concursal de seu patrimônio (art. 94, III, g).

Capítulo 25. PROCESSO FALIMENTAR

1. INTRODUÇÃO

O processo de falência compreende três etapas distintas: *a)* pedido de falência, também conhecido por etapa pré-falencial, que tem início com a petição inicial de falência e se conclui com a sentença declaratória da falência; *b)* etapa falencial propriamente dita, que se inicia com a sentença declaratória da falência e se conclui com a de encerramento da falência (objetiva o conhecimento judicial do ativo e passivo do devedor, a realização do ativo apurado e o pagamento do passivo admitido); e *c)* reabilitação, que compreende a declaração da extinção das responsabilidades civis do devedor falido.

O processo falimentar se desdobra em incidentes, ações, medidas e providências várias. Antes de examiná-los, cabe referência a três questões gerais: aplicação supletiva do CPC, competência jurisdicional e universalidade do juízo falimentar.

Supletividade do CPC. Por se tratar de um processo, aplica-se à falência, em caso de omissão da LF, as disposições comuns de direito processual, civil ou penal, conforme o caso. A legislação adjetiva geral é supletiva do direito falimentar em caso de omissão deste. Claro está que, em prevendo a LF determinada disciplina, o socorro ao processo geral é incabível. Desse modo, se o advogado quer definir, por exemplo, o recurso contra certa decisão proferida no processo falimentar, ele deve primeiro consultar a LF. Se encontrar disposição expressa a respeito - por exemplo, o cabimento do agravo contra a sentença declaratória da falência -, guia-se por ela; não a encontrando, deve buscar no CPC a resposta à questão.

Competência. A competência para os processos de falência, de recuperação judicial e homologação de recuperação extrajudicial, bem como para seus incidentes, é do juízo do *principal estabelecimento* do devedor (LF, art. 3.º). Por principal estabelecimento se entende não a sede estatutária ou contratual, a que vem mencionada no ato constitutivo, nem o maior estabelecimento, física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o principal estabelecimento sob o ponto de vista econômico. O juiz do local onde se encontra tal estabelecimento é o competente para o processo falimentar. Nas comarcas em que há mais de um juízo cível, a distribuição do primeiro pedido de falência ou de recuperação judicial referente a determinado empresário previne a competência para apreciação dos pedidos seguintes.

Universalidade. O juízo da falência é universal. Isto significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução concursal por falência (LF, art. 76). É a chamada aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu à lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou a massa falida.

Mas o direito contempla cinco exceções à universalidade do juízo falimentar:

- a)* ações não reguladas pela lei falimentar em que a massa falida for autora ou litisconsorte ativa (LF, art. 76);
- b)* reclamações trabalhistas, para as quais é competente a Justiça do Trabalho (CF, art. 114; LF, art.

76);

c) execuções tributárias (CTN, art. 187); a exceção alcança também a execução dos créditos não tributários inscritos na dívida ativa, inclusive os previdenciários;

d) ações de conhecimento em que é parte ou interessada a União Federal, hipótese em que a competência é da Justiça Federal (CF, art. 109, I); claro está que a competência para o processo da falência *não* se desloca para a Justiça Federal, se a União tiver interesse na cobrança de um crédito. Não se encontra sujeita à universalidade do juízo falimentar a ação de conhecimento referente à obrigação ilíquida de que seja ré a massa falida e em que tenha interesse a União ou entidade autárquica ou empresa pública federal;

e) ação que demanda obrigação ilíquida (LF, art. 6.º, § 1.º).

Certa jurisprudência entende que a universalidade do juízo falimentar é mais simples, de sorte a serem atraídas para ele todas as ações reguladas pela Lei de Falências, continuando aquelas que não se regulam por este diploma a tramitar perante o juízo competente de acordo com as regras gerais do processo civil.

2. PEDIDO DE FALÊNCIA

A lei falimentar impõe ao próprio empresário devedor o dever de requerer a autofalência quando não atender as condições legais para obter a recuperação judicial (LF, art. 105). O descumprimento desse dever não acarreta sanção nenhuma e, por isso, a previsão da lei é ineficaz. Raramente o empresário requer a autofalência, mesmo na presença dos pressupostos legais.

Além do próprio devedor, contudo, atribui à lei a legitimidade ativa concorrente ao cônjuge sobrevivente, aos herdeiros e ao inventariante. Cabe o pedido também ao sócio da sociedade devedora, mesmo que limitada ou anônima (art. 97).

Mas, regra geral, é o credor que tem mais interesse na instauração do processo de execução coletiva. Até porque o pedido de falência tem se revelado um eficaz instrumento de cobrança. A despeito do que afirma a maioria da doutrina e da jurisprudência, fato é que o credor, ao ajuizar o pedido de falência, em função da impontualidade do devedor, quer mais o recebimento de seu crédito e menos - consideravelmente menos - a falência do devedor. A forma de entender esta ação judicial, esta etapa do processo falimentar, que melhor se ajusta à realidade, é, portanto, considerando-a uma espécie de cobrança judicial. Contudo, esta não é a forma que corresponde àquilo que o legislador deixou assente no texto legal. O credor, segundo o que imagina a lei, teria o interesse na instauração do processo de execução concursal. Este seria o seu objetivo, que o devedor, cumprindo em juízo a obrigação devida, acabaria por frustrar.

Em relação ao credor, estabelece a lei alguns requisitos para o exercício do direito de ação. A legitimidade ativa do credor, em dois casos, é condicionada ao atendimento desses requisitos. Assim, o credor empresário deve provar a regularidade do exercício da empresa, exibindo a inscrição individual ou o registro dos atos constitutivos da sociedade empresária (art. 97, § 1.º); e o credor não domiciliado no País deve prestar caução (art. 97, § 2.º).

Ressalvados estes casos, o credor possui a legitimidade ativa para o pedido de falência

independentemente do atendimento de requisitos específicos. Assim, o credor civil não necessita demonstrar a regularidade no exercício de sua atividade econômica para legitimar-se no pedido, e o residente no Brasil está dispensado de caução.

O credor para legitimar-se ao pedido de falência deve exhibir o seu título, mesmo que não vencido. De início, a hipótese parece referir-se somente ao pedido fundado em ato de falência, visto que a impontualidade e a execução frustrada pressupõem o vencimento. Contudo, ela também se aplica ao pedido de falência fundado no art. 94, I, da LF, quando o credor deve exhibir o seu título não vencido e também a prova da impontualidade do devedor relativamente a obrigação de que terceiro seja credor, por meio de certidão de protesto. Não é necessário que o requerente da falência tenha o seu título vencido, mesmo quando o pedido se funda na impontualidade injustificada ou execução frustrada, desde que estas tenham ocorrido em relação a outro título.

O pedido de falência segue rito diferente em função de seu autor. Quando pedido pelo próprio devedor, segue o rito da autofalência abrigado nos arts. 105 a 107; nos demais casos, o rito previsto no art. 98 da LF.

Quando se trata de autofalência, o pedido do devedor deve vir instruído com o balanço patrimonial, a relação dos credores e o contrato social ou, se inexistente, a relação dos sócios e outros indicados por lei (art. 105). O contrato social pode ou não encontrar-se registrado, resultando disto que a lei concede legitimidade ativa para a autofalência também aos empresários irregulares. Juntamente com o pedido, o devedor depositará em cartório os livros mercantis, que serão encerrados pelo juiz para serem oportunamente entregues ao administrador judicial da falência. Não estando o pedido adequadamente instruído, o juiz determinará sua emenda (art. 106); caso contrário, proferirá a sentença declaratória da falência, sem prévia oitiva do Ministério Público (art. 107).

Quando requerida a falência por terceiros (credor, sócio da sociedade devedora, inventariante etc.), o rito prevê a citação do empresário devedor para responder no prazo de 10 dias (LF, art. 98). Sua resposta só pode consistir na contestação, já que não prevê a lei a reconvenção ou o reconhecimento da procedência do pedido.

Se o pedido de falência baseia-se na impontualidade injustificada ou execução frustrada, o devedor pode elidi-lo depositando em juízo, no prazo da resposta, o valor correspondente ao total do crédito em atraso, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Abrem-se, então, quatro alternativas:

a) *o requerido só contesta*. Nesse caso, se o juiz acolhe as razões da defesa, profere a sentença denegatória da falência e condena o requerente nas verbas de sucumbência (e, eventualmente, em indenização por perdas e danos - item 4); não as acolhendo, deve proferir a sentença declaratória da falência;

b) *o requerido contesta e deposita*. Aqui, o juiz deve apreciar a contestação. Se acolher as razões da defesa, profere a sentença denegatória da falência, condena o requerente nas verbas de sucumbência e eventuais perdas e danos, bem como determina o levantamento do depósito pelo requerido. Se as desacolher, profere igualmente a sentença denegatória da falência, mas imputa ao requerido os ônus de sucumbência e autoriza o levantamento do depósito em favor do requerente. Quer dizer, não há reconhecimento da procedência do pedido em razão do depósito elisivo, quando acompanhado este da

contestação;

c) *o requerido só deposita*. Agora, o juiz profere a sentença denegatória da falência, impõe ao requerido a sucumbência e determina o levantamento do depósito em favor do requerente. Como o depósito está desacompanhado de contestação, tem o mesmo efeito do reconhecimento da procedência do pedido;

d) *o requerido deixa transcorrer o prazo sem contestar ou depositar*. O juiz profere a sentença declaratória da falência, instaurando a execução concursal do patrimônio do devedor.

A lei não prevê o depósito elisivo se o fundamento do pedido diz respeito à prática de ato de falência. Mas deve ser admitido também nessa hipótese, porque com o depósito do valor do seu crédito, perde o requerente o interesse na instauração do concurso de credores.

3. SENTENÇA DECLARATÓRIA DA FALÊNCIA

A declaração por sentença da falência é pressuposto inafastável da instauração do processo de execução concursal do devedor empresário.

Apesar do nome, a sentença declaratória da falência tem caráter predominantemente constitutivo. Após o juiz a prolatar, a pessoa, os bens, os atos jurídicos e os credores do empresário falido são submetidos a regime jurídico específico, diverso do regime geral do direito obrigacional. É a sentença de falência que introduz o falido e seus credores no regime jurídico-falimentar - isto demonstra o caráter constitutivo do ato judicial.

A sentença declaratória da falência tem o conteúdo genérico de qualquer sentença judicial e mais o específico que a LF prescreve. Assim, deverá o juiz, ao julgar procedente o pedido de falência, atentar-se tanto ao disposto no art. 489 do CPC quanto ao art. 99 da LF. Pelo primeiro, a sentença declaratória da falência deverá conter o relatório, os fundamentos da decisão e o dispositivo legal que a embasa, como ocorre com qualquer sentença judicial. Pelo segundo, deverá conter a identificação do devedor, a localização de seu estabelecimento principal e, se for o caso, a designação dos sócios de responsabilidade ilimitada ou dos representantes legais da sociedade falida; o termo legal da falência, se possível; a nomeação do administrador judicial e outros elementos indicados na lei. Além disso, o juiz pode, na sentença que declara a falência, determinar medidas cautelares no interesse da massa, como o sequestro de bens.

O termo legal da falência é o lapso temporal anterior à decretação da quebra que tem importância para a ineficácia de determinados atos do falido perante a massa. Este período é fixado pelo juiz, em regra, na sentença declaratória da falência, não podendo retrotrair por mais de 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento. Se o falido não foi protestado (autofalência ou pedido não fundado em impontualidade injustificada), o termo legal não poderá retrotrair por mais de 90 dias da petição inicial e se é o caso de convolação da recuperação judicial em falência, por mais de 90 dias do requerimento da recuperação. Caso o juiz, ao decretar a falência, não tenha ainda os elementos para a determinação do termo legal, poderá deixar a fixação deste para outra oportunidade.

A sentença declaratória da falência deve ser publicada no órgão oficial e, se a massa comportar, em jornal de grande circulação.

Da sentença declaratória da falência cabe o recurso de agravo. O prazo para interposição assim como o processamento do agravo são os previstos pela legislação comum (LF, art. 189).

4. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA FALÊNCIA

O juiz, ao julgar improcedente o pedido de falência, deve examinar o comportamento do requerente. Se ocorreu dolo manifesto de sua parte, quando do ajuizamento daquele, o juiz deve, na própria sentença denegatória da falência, condená-lo ao pagamento de indenização em favor do requerido (art. 101). Para garantir a eficácia da medida é que o credor domiciliado no exterior deve prestar caução como condição para legitimar-se ao pedido (art. 97, § 2.º).

Se não houver dolo manifesto no comportamento do requerente, o juiz não pode condená-lo. Mas mesmo nessa hipótese, o requerido prejudicado poderá demandar o requerente em ação própria. Idêntica ação cabe em caso de culpa ou abuso de direito pelo requerente (art. 101, § 2.º).

Qualquer que seja a hipótese, tenha o requerente agido ou não com dolo, culpa ou abuso, ele deve pagar as verbas de sucumbência, especificamente o reembolso das despesas e os honorários de advogado (CPC, art. 85).

Se, porém, a denegação da falência não tiver por fundamento a improcedência do pedido, mas a elisão provocada pelo depósito do valor da obrigação em atraso, o juiz determinará o levantamento deste em favor do requerente e condenará o requerido no reembolso das despesas e honorários de advogado. Estas verbas serão apuradas em liquidação da sentença denegatória.

A sentença que denega o pedido de falência pode ser objeto de recurso de apelação (art. 100), no prazo e segundo o processo previsto no CPC (art. 198).

5. ADMINISTRAÇÃO DA FALÊNCIA

Para a administração da massa falida, atribui a lei determinadas funções ao magistrado, ao representante do Ministério Público e aos órgãos da falência (administrador judicial, assembleia dos credores e comitê dos credores).

Ao juiz compete presidir a administração da falência, superintendendo as ações do administrador judicial. É o juiz, em última análise, o administrador da falência, cabendo-lhe autorizar a venda antecipada de bens (art. 113), o pagamento dos salários dos auxiliares do administrador judicial (art. 22, III, *h*), aprovar a prestação de contas do administrador judicial (art. 154) e outros atos definidos em lei, de conteúdo exclusivamente administrativo.

Já o representante do Ministério Público intervém no feito, no exercício de suas funções constitucionais de fiscal da lei. Em diversas oportunidades, no transcorrer dos vários procedimentos em que se desdobra a falência, prevê a LF a intervenção do representante do Ministério Público (arts. 8.º, 9.º, 30 e 132, *p. ex.*).

Embora, portanto, sejam agentes públicos inespecíficos do processo falimentar, o juiz e o representante do Ministério Público têm, nesse processo, funções de cunho administrativo ao lado de suas funções próprias, institucionais.

Os órgãos da falência são três: administrador judicial, assembleia dos credores e comitê de credores.

O administrador judicial, como mencionado, é agente criado por lei para o desempenho de certas atribuições relacionadas exclusivamente com a administração da falência. O administrador judicial é o agente auxiliar do juiz, que, em nome próprio (portanto, com responsabilidade), deve cumprir as funções cometidas pela lei. Além de auxiliar do juiz, o administrador judicial é também o representante da comunhão de interesses dos credores (a massa falida "subjética"). Para fins penais, o administrador judicial é considerado funcionário público.

A escolha do administrador judicial na falência cabe ao juiz e deve recair sobre profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou, ainda, pessoa jurídica especializada (art. 21).

A função do administrador judicial é indelegável, mas ele poderá contratar profissionais para auxiliá-lo, solicitando prévia aprovação do juiz, inclusive quanto aos salários que a massa falida irá pagar. Quando se trata de advogado, deve-se distinguir entre o contratado para a defesa dos interesses da massa e o contratado para a representação processual do próprio administrador judicial, porque somente os honorários do primeiro podem ser pagos pela massa falida.

O administrador judicial pode deixar suas funções por substituição ou destituição. No primeiro caso, não há sanção infligida ao administrador judicial, mas apenas uma providência destinada à melhor administração da falência. Já a destituição é sanção imposta ao administrador judicial que não cumpriu a contento com suas obrigações ou tem interesses conflitantes com os da massa. O administrador judicial *substituído*, em determinadas hipóteses, pode voltar a ser nomeado administrador judicial em outra falência; já a pessoa *destituída* do cargo de administrador judicial não poderá mais ser escolhida para a mesma função em qualquer outra falência nos 5 anos seguintes (LF, art. 30). São causas para a substituição a renúncia motivada, morte, incapacidade civil ou falência; são causas da destituição a inobservância de prazo legal ou o interesse conflitante com o da massa. Quando ocorre a recusa da nomeação ou a falta de assinatura do compromisso no prazo da lei, o juiz deve nomear outra pessoa para o cargo de administrador judicial. Não é, propriamente, o caso de substituição, embora o legislador o entenda como tal.

O administrador judicial responde civilmente por má administração ou por infração à lei. Até o encerramento do processo falimentar, somente a massa tem legitimidade ativa para responsabilizá-lo (após, evidentemente, sua substituição ou destituição). Durante este prazo, o credor não pode acionar o administrador judicial individualmente, cabendo-lhe apenas requerer a destituição dele. Mas, uma vez encerrado o processo de falência, qualquer credor prejudicado por má administração ou infração à lei poderá promover a responsabilização do antigo administrador judicial, desde que tenha requerido, no momento oportuno, a sua destituição.

Dentre os atos processuais de responsabilidade do administrador judicial, devem ser destacados quatro de importância para o desenvolvimento do processo falimentar. São eles:

a) *Verificação dos créditos* - disciplinada nos arts. 7.º a 20 da LF, a verificação dos créditos na falência é feita pelo administrador judicial, cabendo ao juiz decidir apenas as impugnações apresentadas pelos credores ou interessados.

b) *Relatório inicial* - previsto no art. 22, III, e, da LF, este ato deve examinar as causas e

circunstâncias que acarretaram a falência, bem como apresentar uma análise do comportamento do falido com vistas a eventual caracterização de crime falimentar, por ele ou outra pessoa, antes ou depois da decretação da quebra. O relatório é apresentado nos 40 dias seguintes à assinatura do termo de compromisso.

c) *Contas mensais* - o administrador judicial deve, até o décimo dia de cada mês, apresentar ao juiz para juntar aos autos a prestação de contas relativa ao período mensal anterior. Nela deve estar especificada com clareza a receita e despesa da massa falida (art. 22, III, *p*).

d) *Relatório final* - previsto no art. 155 da LF, deve ser elaborado pelo administrador judicial no prazo de 10 dias contados do término da liquidação e do julgamento de suas contas. Contém o valor do ativo e do produto de sua realização, bem como o do passivo e dos pagamentos feitos, e, se não foram totalmente extintas as obrigações do falido, o saldo cabível a cada credor, especificando justificadamente as responsabilidades com que continua o falido. Este relatório final é o documento básico para a extração das certidões judiciais representativas do crédito remanescente perante o empresário falido.

O administrador judicial deve prestar contas de sua administração em três hipóteses: ordinariamente, a cada mês e ao término da liquidação, e, extraordinariamente, quando deixa as suas funções (substituição ou destituição). A prestação de contas será autuada em separado e julgada após aviso aos credores e ao falido, para eventual impugnação no prazo de 10 dias, e oitiva, em 5 dias, do Ministério Público. Havendo impugnação, ouve-se a respeito o administrador judicial. Em seguida, as contas são julgadas pelo juiz. Tendo ocorrido alcance, o juiz pode, na sentença que o reconhecer, decretar a indisponibilidade ou o sequestro dos bens do administrador judicial, para garantia da indenização da massa.

A assembleia de credores, na falência, tem competência para: a) aprovar a constituição do comitê de credores e eleger os seus membros; b) adotar modalidades extraordinárias de realização do ativo do falido; e c) deliberar sobre assuntos de interesse geral dos credores (LF, art. 35, II). É órgão integrado por todos os credores do falido.

Finalmente, o comitê de credores é composto por um representante dos credores trabalhistas, dos titulares de direitos reais de garantia e privilégios especiais, dos quirografários e dos microempresários e empresários de pequeno porte (cada qual com dois suplentes) eleitos pela assembleia. Sua função mais importante é a de fiscalizar o administrador judicial (LF, art. 27, I, *a*).

6. APURAÇÃO DO ATIVO

Proferida a sentença declaratória da falência, tem início o processo falimentar propriamente dito. Instaura-se, com esta decisão judicial, a execução coletiva do devedor empresário.

O objetivo inicial do processo falimentar é a definição do ativo e do passivo do devedor. Para o cumprimento deste objetivo, a LF prevê determinados atos ou medidas judiciais. A definição do ativo do empresário envolve atos como a arrecadação de todos os bens na posse do falido, bem como de seus documentos e escrituração mercantil (art. 108), providência que auxilia também na definição do passivo; e medidas judiciais como o pedido de restituição (art. 85) ou os embargos de terceiros (art. 93). A definição do passivo do devedor falido se opera por medidas judiciais como as habilitações e impugnações de crédito (arts. 7.º a 20).

A arrecadação dos bens do falido e o pedido de restituição e embargos de terceiro serão tratados quando do exame do regime jurídico dos bens do falido (*Cap. 26*). Por ora, interessa cuidar da principal medida do processo falimentar, que é a verificação de crédito.

7. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO

A verificação dos créditos é tarefa do administrador judicial. Para cumpri-la, deve levar em conta não só a escrituração e os documentos do falido como todos os elementos que lhe forem fornecidos pelos credores. Havendo divergência entre o administrador judicial e um ou mais credores acerca dos próprios créditos que titularizam, ou o de outros, cabe ao juiz decidir o conflito.

O ponto de partida da verificação dos créditos é a publicação da relação dos credores. Quando se trata de autofalência, entre os documentos que a lei determina sejam apresentados pelo devedor requerente encontra-se a lista dos credores com discriminação do valor do crédito e a classificação de cada um deles. Na falência decretada a pedido de credor ou sócio dissidente, ao falido é determinado que elabore e apresente a relação dos credores nos 5 dias seguintes, sob as penas do crime de desobediência. Se atendida a lei, portanto, os autos da falência, quando decretada esta ou alguns dias depois, devem conter uma relação dos credores. Se o falido não a tiver entregue (preferindo, por exemplo, responder pelo crime de desobediência a elaborá-la), a relação dos credores deve ser providenciada pelo administrador judicial.

Uma vez juntada aos autos a relação dos credores, providencia-se sua publicação no *Diário Oficial*. Aliás, se, no momento da publicação da sentença declaratória, já se encontra a relação nos autos, ambas são publicadas simultaneamente por edital (quer dizer, na íntegra). Nos 15 dias seguintes à publicação da relação, os credores devem conferi-la.

Os que não se encontram relacionados devem apresentar a habilitação de seus créditos perante o administrador judicial. Estão dispensados da habilitação apenas o credor fiscal (porque não participa de concurso) e, se foi o caso de convolação de recuperação judicial em falência, os titulares de créditos remanescentes daquela que tinham sido definitivamente incluídos no respectivo quadro geral de credores.

Os credores que se encontram na relação publicada, mas discordam da classificação ou do valor atribuído aos seus créditos, devem suscitar a divergência, também junto ao administrador judicial.

A apresentação da habilitação ou divergência deve ser feita por escrito e conter o nome e a qualificação do credor, a importância exata que atribui ao crédito, a atualização monetária até a data da decretação da falência, bem como sua origem, prova, classificação e eventual garantia.

O administrador judicial, diante das habilitações e divergências suscitadas, acolhe as que considerar pertinentes e promove a republicação do quadro de credores. Nos 10 dias seguintes à republicação, os sujeitos legitimados podem apresentar a impugnação da relação elaborada pelo administrador judicial. Estão legitimados para impugnar a relação qualquer credor, o comitê, o falido, sócio ou acionista da falida ou o promotor de justiça.

Cada impugnação apresentada à relação dos credores é autuada em separado. As autuações serão feitas em função dos objetos impugnados, de modo que se reúnam nos mesmos autos todas as impugnações referentes ao mesmo crédito, independentemente de quem seja o impugnante. Após autuar as impugnações, o cartório providencia a intimação dos credores impugnados. Eles terão 5 dias para

contestarem a impugnação, juntarem documentos e indicarem as provas que pretendem produzir.

Em seguida à contestação da impugnação (ou ao decurso do respectivo prazo), intimam-se o falido ou o representante legal da sociedade falida e o comitê, se existente, para no prazo comum de 5 dias se manifestarem. Vencido o prazo de manifestação do devedor e do comitê, o administrador judicial deve exarar seu parecer em 5 dias contados da respectiva intimação.

Retornando os autos de impugnação de crédito com o parecer do administrador judicial, serão todos promovidos à conclusão. Aquelas impugnações em que não se impõe a dilação probatória são, então, julgadas desde logo. O juiz decide se a relação de credores republicada está correta ou se tem razão o impugnante. Em relação às demais, o juiz fixa os aspectos controvertidos, decide as questões processuais pendentes e determina as provas a serem produzidas (nomeia perito, designa audiência de instrução e julgamento etc.). Concluída a dilação probatória, o juiz julga a impugnação, acolhendo-a ou rejeitando-a.

Contra a sentença proferida na impugnação de crédito cabe agravo.

8. LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO FALIMENTAR

A liquidação tem início tão logo instaurado o processo falimentar.

São dois os seus objetivos: a realização do ativo (venda dos bens arrecadados e cobrança dos devedores do falido) e o pagamento do passivo (satisfação dos credores admitidos, de acordo com a natureza do seu crédito e as forças da massa).

A venda dos bens arrecadados pode ser feita englobada ou separadamente, em leilão, por propostas ou pregão, atendendo ao melhor interesse da massa. Se da venda do estabelecimento empresarial desarticulado resultar preço superior ao da venda conjunta, aquela deverá preferir a esta; se a feita em leilão deve produzir melhores frutos que a venda por proposta, deve-se optar por aquela modalidade de realização do ativo. É tudo uma questão de conveniência, com vistas à otimização dos recursos existentes.

Compete ao juiz decidir entre estas alternativas da lei, vendendo os bens englobada ou separadamente, em leilão ou por propostas. Trata-se de decisão discricionária de sua parte segundo o que ele entender mais favorável a massa.

A venda por leilão deve atender às normas específicas da Lei de Falências. Assim, a intimação do representante do Ministério Público é da essência do ato, sendo nula a hasta realizada sem a observância desta obrigação legal.

A venda por proposta deve ser amplamente divulgada, por publicações no *Diário Oficial* e em jornal de grande circulação. Os interessados apresentarão ao escrivão suas propostas em envelopes lacrados, que serão abertos pelo juiz em dia e hora previamente designados e constantes das publicações relativas a venda.

Finalmente, o pregão consiste numa combinação entre as duas modalidades anteriores. Se, ao abrir as propostas, verificar o juiz que é pequena a diferença entre as maiores propostas (até 10%), intimará os proponentes para um leilão, entre eles, de lances orais (art. 142, § 5.º).

Estas são as modalidades de venda dos bens que a lei prevê. Em princípio, a venda dos bens do falido somente pode ser feita dentro do quadro de alternativas que a conjugação dessas modalidades oferece (todos os bens em leilão, alguns em leilão, outros por propostas etc.). Para que a realização do ativo se processe por forma diversa dessas (realização extraordinária), exige a lei a autorização do juiz, a pedido do administrador judicial ou comitê (art. 144) ou a concorrência da vontade de credores representantes de pelo menos 2/3 do passivo admitido presente em assembleia geral convocada para esse fim.

Poderá ser adotada como realização extraordinária, por exemplo, a constituição de sociedade para continuação do negócio do falido ou a cessão do ativo a terceiro por preço negociado. Qualquer que seja a solução pretendida pelos órgãos da falência, no entanto, se não estiver compreendida no quadro de alternativas oferecidas pela lei, será indispensável a autorização ou homologação do juiz (arts. 144 e 145). Essa homologação diz respeito à legalidade da solução deliberada e não ao seu mérito.

Nas sociedades com sócios de responsabilidade ilimitada, os bens destes são arrecadados pelo administrador judicial juntamente com os sociais (arts. 81 e 190). Chegando, contudo, o momento da liquidação, deverão ser vendidos, em primeiro lugar, os bens da sociedade, para, somente no caso de ser o produto desta venda insuficiente ao pagamento dos credores, ser promovida, em seguida, a venda de tantos bens do patrimônio do sócio quantos bastem ao pagamento do saldo. Esta ordem deverá ser rigorosamente observada em decorrência da regra da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade falida.

Se o acionista ou o sócio da sociedade anônima ou limitada não houver integralizado totalmente o capital social, caberá ao administrador judicial promover a ação de integralização. Esta ação pode ser proposta independentemente da prova de insuficiência dos bens sociais. Não se trata, contudo, de revogação da regra da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Também nesta hipótese, os bens da sociedade falida devem ser vendidos antes dos penhorados em execução da decisão da ação de integralização. Se acaso o produto apurado na venda daqueles bastar ao pagamento dos credores, não serão vendidos os bens dos sócios. A dispensabilidade da prova de insuficiência dos bens sociais é mera condição processual de antecipação da propositura da ação.

A realização do ativo não compreende apenas a venda dos bens. Também a cobrança, amigável ou judicial, dos créditos do falido deverá ser promovida pelo administrador judicial. Poderá, em relação àqueles que considere de difícil liquidação, oferecer um abatimento, *desde que* autorizado pelo juiz da falência, após oitiva do comitê de credores e do falido (art. 22, § 3.º).

O dinheiro resultante da venda dos bens do falido deverá ser depositado em conta bancária da massa falida pelo administrador judicial. As quantias assim depositadas serão movimentadas por meio de cheques assinados pelo administrador judicial ou por mandado expedido pelo juiz.

Com o apurado na venda dos bens da massa serão pagos tanto os credores do falido, admitidos de acordo com o procedimento já examinado, quanto os créditos extraconcursais que vêm elencados no art. 84 da LF. Entre uns e outros, há uma ordem legal que será examinada oportunamente. Esta ordem deve ser rigorosamente observada pelo administrador judicial nos pagamentos.

Exaurido o produto da venda dos bens arrecadados, o administrador judicial deve apresentar a prestação de contas (art. 154) e, após o julgamento destas, o relatório final (art. 155). Deste relatório constará o valor do ativo e o do apurado com a sua venda, o do passivo e o dos pagamentos realizados,

especificando-se em relação a cada credor o crédito residual, se houver. Este documento servirá de base à extração de certidões, caso algum credor queira cobrar o saldo do falido que recompuser o patrimônio ou de terceiro garante.

Se o administrador judicial não apresentar o relatório final em 10 dias do julgamento de suas contas, será feita a sua intimação pessoal para que o apresente, sob pena de crime de desobediência.

Em seguida à apresentação desta peça processual, o juiz profere sentença declarando o encerramento do processo de falência. Ela é publicada por edital e pode ser questionada por recurso de apelação (art. 156). Os livros do falido ser-lhe-ão devolvidos para a devida guarda no prazo regular.

9. REABILITAÇÃO DO FALIDO

Após a sentença de encerramento da falência, termina o processo falimentar propriamente dito. Contudo, o falido poderá ter interesse em promover posteriormente sua reabilitação. Aliás, para voltar a exercer atividade empresarial, o falido deve obtê-la necessariamente. A reabilitação compreende a extinção das responsabilidades civis e penais do falido.

No campo do direito civil, deverá o falido requerer a declaração, por sentença, da extinção das obrigações. Esta ocorre nas seguintes hipóteses:

a) pagamento dos créditos ou novação daqueles com garantia real (art. 158, I);

b) rateio de mais de 50% do passivo quirográfico, após a realização de todo o ativo e o pagamento da totalidade do devido aos credores com preferência, sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir-se este percentual (art. 158, II);

c) decurso do prazo de 5 anos após o encerramento da falência, se o falido ou o representante legal da sociedade falida não incorreu em crime falimentar (art. 158, III);

d) decurso do prazo de 10 anos após o encerramento da falência, se houve condenação do falido ou do representante legal da sociedade falida por crime falimentar (art. 158, IV); ou

e) prescrição das obrigações anteriormente ao decurso desses prazos decadenciais (art. 158). A declaração da falência suspende a fluência dos prazos prescricionais das obrigações do falido, os quais recomeçam a fluir do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Se antes de 5 ou 10 anos do encerramento (conforme o caso) ocorrer a prescrição, extingue-se a obrigação correspondente.

O pagamento é causa de extinção das obrigações que pode ocorrer *antes* ou *depois* da sentença de encerramento da falência. O rateio de mais de 50% do passivo, após a realização de todo o ativo, por sua vez, é causa que se verifica necessariamente *antes* do encerramento da falência. Já as demais causas elencadas ocorrem sempre *após* o encerramento. Por levantamento da falência se compreende a ocorrência de causa extintiva de obrigação anteriormente ao encerramento da falência.

O falido deverá apresentar requerimento de declaração de extinção das obrigações, acompanhado da prova de quitação dos tributos relativos ao exercício da atividade empresarial (CTN, art. 191). Após, ouvidas as partes e, se for o caso, o representante do Ministério Público, o juiz proferirá sentença. Se for o caso de levantamento de falência, o juiz declarará encerrado o processo na mesma sentença que julgar

extintas as obrigações do falido.

Se o falido não estiver sendo processado penalmente ou tiver sido absolvido por sentença definitiva, estará reabilitado com a simples extinção das obrigações, e poderá voltar a explorar atividade empresarial. Se, no entanto, for condenado por crime falimentar, deverá ainda requerer a reabilitação penal. Esta somente pode ser concedida após o transcurso de 2 anos contados do cumprimento da pena (CP, art. 94). A declaração por sentença da extinção das obrigações é condição da reabilitação penal.

O falido reabilitado civil e criminalmente, na forma examinada, pode voltar a explorar atividade empresarial. Se não requereu sua reabilitação, os efeitos da inabilitação limitam-se a 5 anos contados da extinção da punibilidade (LF, art. 181, § 1.º).

Capítulo 26. PESSOA E BENS DO FALIDO

1. RESTRIÇÕES PESSOAIS E REGIME PATRIMONIAL DO FALIDO

O falido não é um incapaz. Apenas que a sua capacidade jurídica sofre restrição no tocante ao direito de propriedade. A partir da decretação da falência, o devedor perde o direito de administrar e dispor de seu patrimônio. Não perde a propriedade de seus bens, senão após a venda deles na liquidação, durante o processo falimentar.

A administração de seus bens compete aos órgãos da falência a partir da decretação da quebra.

Pessoalmente, fica o falido sujeito a determinadas restrições. Não sendo incapaz, poderá praticar todos os atos da vida civil não patrimoniais, como o casamento, a adoção, o reconhecimento de filhos etc. A validade desses atos não depende da cientificação, autorização ou assistência do juiz da falência ou do administrador judicial.

Não pode o falido ausentar-se do lugar da falência, sem razão justificadora e autorização do juiz. Quando for autorizado a ausentar-se, deve constituir procurador com poderes para representá-lo nos atos processuais (LF, art. 104, III). Outra restrição pessoal diz respeito ao sigilo à correspondência relativa aos assuntos da empresa. A partir da decretação da quebra, são as agências postais cientificadas para que entreguem ao administrador judicial a correspondência endereçada ao falido. O administrador judicial deve entregar ao falido, de imediato, a correspondência de conteúdo estranho ao seu giro comercial (LF, art. 22, III, *d*).

Além das restrições ao direito de ir e vir e ao sigilo na correspondência empresarial, o falido fica também impedido de se reestabelecer como empresário, enquanto não for reabilitado (LF, art. 102).

Ao falido impõe a lei o dever de colaborar com a administração da falência, auxiliando o administrador judicial na arrecadação dos bens, informando as declarações de crédito, examinando e dando parecer nas contas do administrador judicial etc.

Estas restrições do falido se estendem ao representante legal da sociedade falida.

Quanto aos bens do falido, eles serão arrecadados. A arrecadação é o ato judicial de constrição dos bens do patrimônio do devedor específico do processo falimentar (equivale a penhora, na execução individual).

O administrador judicial deve arrecadar todos os bens de propriedade do falido, mesmo que se achem na posse de terceiros (a título de locação ou comodato, por exemplo). A arrecadação deve também abranger todos os bens na posse do falido, mesmo os que não são de sua propriedade. Claro, os bens que não pertencerem ao falido serão restituídos aos seus proprietários, que devem ingressar na falência com o pedido de restituição.

Não são arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis, segundo a definição da lei processual civil (CPC, art. 833), nem os gravados com cláusula de inalienabilidade. Também não poderão ser arrecadados os bens da meação do cônjuge, nem as substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, as quais deverão ser retiradas do estabelecimento empresarial do falido

e depositadas pelas autoridades sanitárias competentes (Lei 11.343/2006, art. 69, I a III).

A guarda e conservação dos bens arrecadados são da responsabilidade do administrador judicial (LF, art. 108, § 1.º), podendo o falido ser nomeado depositário. As despesas decorrentes (seguro, conservação, armazenamento, impostos etc) são de responsabilidade da massa falida. Se, entre os bens arrecadados, houver algum de fácil deterioração ou custosa ou arriscada guarda, poderá ser vendido antes da liquidação dos demais, devendo o administrador judicial representar ao juiz para este fim. Sobre o pedido de venda imediata se manifestarão o falido e o comitê de credores (LF, art. 113).

2. CONTINUAÇÃO PROVISÓRIA DA EMPRESA DO FALIDO

Na sentença declaratória da falência, o juiz deve se pronunciar sobre a continuação provisória das atividades do falido ou a lacração do seu estabelecimento (LF, arts. 99, VI e XI, e 109). Não são medidas de adoção obrigatória. Inexistindo razões tanto para autorizar a continuação provisória das atividades do falido como para a lacração do estabelecimento, o juiz pode simplesmente denegar as duas medidas.

A continuação provisória das atividades do falido se justifica em casos excepcionais, quando ao juiz parecer que a manutenção da empresa em funcionamento pode ser a solução mais interessante aos propósitos da falência. Se pela tradição da marca explorada, ou pela particular relevância social e econômica da empresa, parecer ao magistrado que o encerramento da atividade agravará não só o prejuízo dos credores como poderá produzir efeitos deletérios a economia regional, local ou nacional, convém que ele autorize a continuação provisória dos negócios.

Caberá ao administrador judicial a gerência da atividade durante a continuação provisória. Investe-se ele, nesse caso, de amplos poderes de administração da empresa explorada pelo falido.

A continuação provisória convém que seja breve, muito breve. Decretada a medida, devem-se acelerar os procedimentos de realização do ativo, para que logo se defina o novo titular da atividade. O provisório que tende a se eternizar não tem sentido lógico nem jurídico; falta-lhe base na lei.

3. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO

Serão arrecadados pelo administrador judicial todos os bens de posse do falido. Dentre estes, poderá ser encontrado um bem que, embora possuído por ele, não seja de sua propriedade. Um bem do qual fosse comodatário ou locatário, por exemplo. É claro que este bem não poderá ser objeto de alienação judicial para satisfação dos credores do falido, porque não integra o seu patrimônio.

Para a defesa do direito do proprietário sobre o bem arrecadado, a LF prevê duas medidas judiciais: o pedido de restituição (art. 85) e os embargos de terceiro (art. 93). O locador ou o comodante do bem arrecadado deve pedir sua restituição, enquanto aquele que não possui nenhuma relação jurídica com o falido, mas tem bens de seu patrimônio arrecadados, deve oferecer embargos de terceiro. Julgada procedente a medida proposta, o bem indevidamente arrecadado será destacado da massa.

Não há outra forma de o proprietário ser reintegrado na posse do bem. Pelo esquema legal, cabe exclusivamente ao juiz decidir se um bem encontrado na posse do falido é, ou não, da propriedade dele e deve ser vendido na falência. O pedido de restituição ou embargos de terceiro são, no entanto, meios de cognição sumária, em que a coisa julgada somente opera em relação a natureza da posse que a massa

falida exerce sobre o bem. A decisão do pedido de restituição não compreende o conhecimento judicial da propriedade do referido bem, senão para os fins de se decidir se é justa ou não a posse exercida pela massa sobre a coisa arrecadada. Se restar apurado, posteriormente à concessão da restituição, que o bem era, na verdade, do domínio do falido, a massa poderá promover a competente ação (revocatória, possessória ou reivindicatória) para reavê-lo, sem que o reivindicante possa invocar coisa julgada.

O art. 85, parágrafo único, da LF prevê uma hipótese de pedido de restituição com fundamento diverso do referido no *caput* do mesmo dispositivo. Trata-se da reclamação de coisas vendidas a crédito e entregues ao falido nos 15 dias anteriores ao pedido de falência, se ainda não alienadas. O espírito da medida é a coibição do comportamento, no mínimo desleal, do empresário que, às vésperas da quebra, continua a assumir compromissos que, sabe, dificilmente poderá honrar. A propriedade do bem não se transmite porque a lei considera ineficaz a compra feita em tais circunstâncias, podendo, por isso, o vendedor reclamar a restituição.

Para que tenha este direito, contudo, o vendedor deve requerer a restituição antes da venda judicial do bem arrecadado. Uma vez feita a venda, desconstitui-se o direito a restituição, cabendo ao vendedor habilitar seu crédito e concorrer na massa.

O vendedor que requerer a restituição deverá também provar que as mercadorias foram entregues a partir do décimo quinto dia anterior ao da distribuição do pedido de falência acolhido. Discute-se se as mercadorias entregues entre a distribuição e o acolhimento do pedido de falência poderiam ser reclamadas. A admissão do pedido de restituição, nesse caso, é compatível com a finalidade do instituto, mas como o vendedor já tinha, naquele interregno, condições de saber da situação precária do comprador e podia ter obstado a entrega das mercadorias (LF, art. 119, I), nega-se com frequência a restituição.

Cabe igualmente a restituição em favor do terceiro de boa-fé alcançado pela declaração judicial de ineficácia de negócio jurídico praticado pelo falido (LF, art. 136).

Por disposição expressa de lei (Decreto-Lei 911, de 1969, art. 7.º), cabe o pedido de restituição da coisa alienada com garantia fiduciária por parte da instituição financeira proprietária fiduciária. Trata-se de simples especificação de comando normativo já encontrado no próprio art. 85, *caput*, da LF.

Deferido o pedido, o bem será restituído em espécie, ou seja, a própria coisa encontrada em posse do falido será entregue ao seu proprietário. A restituição será feita em dinheiro em duas situações: *a)* se o objeto a restituir é dinheiro; *b)* se o bem reclamado se perdeu. Como a restituição em dinheiro é desembolso da massa, deverá ser feita em imediata execução do julgado no pedido restituidório, não concorrendo o crédito do reclamante com os credores do falido. Os titulares de direito a restituição, ainda que tenha esta de se realizar em dinheiro, não entram na classificação dos credores e titularizam crédito extraconcursal.

São exemplos de restituição de dinheiro: *a)* a contribuição à Seguridade Social devida pelo empregado do falido e por este retida (Lei 8.212/91, art. 51, parágrafo único); *b)* as importâncias antecipadas ao exportador pela instituição financeira com base em contrato de câmbio (LMC, art. 75, § 3.º).

Na Lei 9.514/97, sobre o sistema de financiamento imobiliário, encontra-se hipótese de pedido de restituição de *título*, na falência do cedente de direitos creditícios oriundos da alienação de imóveis (art. 20).

4. PATRIMÔNIO SEPARADO

Cada vez mais, a lei tem previsto hipótese de patrimônio separado (também chamado *de afetação* ou *segregado*) para proteger interesses de credores na falência de alguns empresários. O patrimônio separado não integra a massa falida e continua a ser gerido e liquidado tendo em vista unicamente o objetivo que inspirou sua constituição.

O primeiro exemplo a considerar é o da incorporação de edifícios. A incorporação pode ser submetida ao *regime de afetação*, ficando o terreno, suas acessões, bens e direitos a ela vinculados apartados do patrimônio do incorporador. A instituição do patrimônio separado, aqui, faz-se por averbação no Registro de Imóveis do termo firmado pelo incorporador. A falência do incorporador não atinge o patrimônio de afetação das incorporações (Lei 4.591/64, arts. 31-A a 31-F).

Outro exemplo encontra-se na securitização de recebíveis imobiliários. A companhia securitizadora pode instituir o *regime fiduciário* sobre os créditos imobiliários que lastreiam a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Tais créditos passam, então, a constituir um patrimônio separado, inconfundível com o da companhia securitizadora (Lei 9.514/97, arts. 9.º a 16). Pelas obrigações desta, inclusive em caso de concurso de credores, não respondem os créditos que lastreiam os CRI em regime fiduciário, protegendo-se assim os interesses dos investidores que detêm esses títulos.

O terceiro exemplo é o das Câmaras de compensação e liquidação financeira integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) (Lei 10.214/2001, art. 2.º, parágrafo único). Atuam como instrumentos de diluição do risco sistêmico das entidades financeiras (bancos e outros agentes econômicos), que se encontrava altamente concentrado, antes da instituição do SPB, no Banco Central. Essas Câmaras são chamadas pelos operadores do mercado financeiro de *clearings*, e há diversas em operação: *Clearings* de Câmbio e de Derivativos da Bolsa de Mercadorias e Futuro, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos - Visanet, Redecard S.A., Tecnologia Bancária S.A. - Tecban, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - Cetip (Comunicado BACEN n. 9.419) etc.

As Câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de liquidação responsáveis por operações sistemicamente importantes (quem os define é o Banco Central) assumem a posição de parte contratante na liquidação das obrigações realizadas por seu intermédio, garantido assim o adimplemento destas e a liquidez do sistema que operam, e são obrigados a constituírem um patrimônio separado ("especial") com os bens e direitos necessários ao cumprimento das obrigações correspondentes.

Os bens e direitos integrantes de patrimônios especiais de Câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação financeira não podem ser penhorados, arrestados, sequestrados, apreendidos ou objeto de nenhum outro ato de constrição judicial; a não ser para o cumprimento de obrigação assumida pela própria Câmara ou prestador de serviço enquanto parte contratante. Essa proteção contra a constrição judicial também alcança os bens dados em garantia pelos participantes.

Por outro lado, a falência de qualquer participante de operação no âmbito de *clearing*, inclusive desta, não afeta minimamente a compensação ou liquidação das obrigações nela albergadas. Continuarão essas obrigações a serem compensadas e liquidadas de acordo com o disposto no regulamento específico de cada sistema, também no que diz respeito a realização das garantias dadas. Somente se houver saldo resultante da efetiva compensação e liquidação, ele será entregue à massa falida ou poderá ser objeto de

Plano de recuperação judicial ou extrajudicial (LF, art. 194).

O derradeiro exemplo de patrimônio separado aqui recolhido é o das contribuições pagas às administradoras de consórcio pelos consorciados e destinadas ao lastreamento dos créditos dos contemplados. Esses recursos não pertencem à administradora do consórcio, mas aos integrantes do respectivo grupo. Tanto assim que, após o encerramento do grupo, os saldos devem ser restituídos aos antigos consorciados. Nenhuma obrigação da administradora pode ser executada com constrição dos recursos constituintes desse patrimônio separado.

Capítulo 27. REGIME JURÍDICO DOS ATOS E CONTRATOS DO FALIDO

1. ATOS INEFICAZES

Um empresário, ao perceber que se encontra em situação pré-falencial, pode-se ver tentado a livrar-se da decretação da quebra ou de suas consequências por meios ilícitos, fraudando os credores ou a finalidade da execução coletiva (*par conditio creditorum*). Poderá simular atos de alienação de bens de seu patrimônio ou instituir em favor de credor quirografário uma garantia real em troca de alguma vantagem indevida. Para coibir estes comportamentos, a LF considera determinados atos praticados pelo falido antes da quebra como ineficazes perante a massa falida.

Os atos ineficazes não produzem qualquer efeito jurídico perante a massa. Não são atos nulos ou anuláveis, mas ineficazes. A sua validade não é comprometida. Por isso, os atos referidos pela LF são ineficazes *diante da massa falida*, mas produzem amplamente todos os efeitos perante os demais sujeitos de direito. Por exemplo: uma das hipóteses, que em seguida será examinada, é a ineficácia de renúncia de herança, em determinadas condições; uma vez arrecadados bens do acervo renunciado suficientes à integral satisfação dos débitos do falido, não poderá este reclamar o saldo de quem se beneficiou pela renúncia (o irmão do falido, por exemplo), porque a renúncia permanece válida e plenamente eficaz entre o renunciante e o beneficiário; apenas em relação à massa falida, o ato não produziu efeitos.

O termo legal da falência, fixado pelo juiz, tem utilidade na definição da ineficácia de alguns atos praticados pelo falido. Alguns autores costumam tomar a expressão "período suspeito" como sinônima de termo legal da falência; outros preferem chamar de suspeito todo o lapso temporal, relativo à ineficácia dos atos do falido, que for diferente do termo legal.

Outra questão preliminar é o emprego pela lei de duas expressões diferentes para designar os atos ineficazes perante a massa falida. Os atos do art. 129 da LF foram denominados "ineficazes", enquanto os do art. 130, de "revogáveis". Há diferenças substantivas entre um e outro conjunto de atos, mas não são pertinentes à ineficácia diante da massa falida. Tanto os atos que o legislador chamou de "ineficazes" quanto os que ele chamou de "revogáveis" não produzem qualquer efeito perante a massa falida. O que diferencia um conjunto de atos do outro não é a suspensão da eficácia com preservação da validade (sanção comum a ambos), e, sim, as condições em que esta suspensão pode ocorrer e o meio processual adequado para a declarar.

Desta forma, pode-se dizer que tanto os atos ineficazes em sentido estrito (art. 129) quanto os revogáveis (art. 130) são ineficazes, em sentido largo, perante a massa falida.

Os atos do art. 129 têm, em regra, as seguintes marcas: a ineficácia é condicionada à prática do ato em certo lapso temporal, mas prescinde de fraude. Tenha ou não havido intuito fraudulento, o ato listado no art. 129 será ineficaz perante a massa falida se praticado dentro do prazo da lei. É irrelevante se o falido agiu ou não com fraude para que se suspenda a eficácia.

Há somente um ato que, independentemente da época em que ocorreu e da comprovação de fraude, será ineficaz: a alienação irregular de estabelecimento empresarial (inc. VIII).

Nas hipóteses do art. 129, é irrelevante a indagação acerca de qualquer elemento subjetivo, atinente

às motivações das partes. Se houve ou não intuito fraudulento, é indiferente. Daí a noção de que o art. 129 lista os casos de *ineficácia objetiva*.

Encontram-se no art. 129 da LF os seguintes atos objetivamente ineficazes perante a massa falida:

a) dentro do termo legal da falência, o pagamento de dívida não vencida, por qualquer meio extintivo do direito (exemplo: cessão, compensação etc.), inclusive o pactuado entre as partes quando da constituição da obrigação;

b) dentro do termo legal da falência, o pagamento de dívida vencida, por qualquer meio extintivo do direito, salvo o pactuado entre as partes quando da constituição da obrigação;

c) dentro do termo legal da falência, a constituição de direito real de garantia em relação a obrigação assumida antes daquele período. Sendo coincidentes o surgimento da obrigação e a constituição da garantia, não há ineficácia, mesmo se ocorrido o ato durante o termo legal da falência;

d) desde 2 anos antes da declaração da falência, os atos a título gratuito, com exceção das gratificações pagas a empregados, por integrarem estas o salário;

e) desde 2 anos antes da declaração da falência, a renúncia de herança ou legado;

f) registro de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, realizado posteriormente à decretação da falência, salvo prenotação anterior; neste caso, o credor beneficiário da garantia deve se habilitar como quirografário, e o adquirente terá direito a receber o preço pago ou o obtido na venda judicial (o que for menor);

g) alienação do estabelecimento empresarial, sem a anuência expressa ou tácita de todos os credores, salvo se conservou o devedor, em seu patrimônio, bens suficientes para garantia do pagamento das dívidas.

Os atos referidos nos incs. I a III e VI do art. 129 da LF (letras *a* a *c* e *f* acima) não são ineficazes se tiverem sido praticados com base no plano de recuperação da empresa judicialmente aprovado (art. 131).

Há, na Lei das Sociedades por Ações, a previsão de uma hipótese específica de ineficácia objetiva. Trata-se do reembolso à conta do capital social, quando o acionista dissidente não foi substituído, em relação aos credores da sociedade falida anteriores à retirada (LSA, art. 45, § 8.º).

Já os atos do art. 130 se caracterizam diferentemente. Aqui não tem relevância a época em que foi praticado, próxima ou distante da decretação da falência, mas é imprescindível o falido e o terceiro contratante tenham agido com fraude para ocorrer a suspensão da eficácia perante a massa. Independentemente da época em que o ato foi realizado, se ele objetivou fraudar credores ou a finalidade da execução coletiva, não produzirá seus efeitos perante a massa falida.

Assim, um ato referido no art. 129, mas praticado fora do prazo correspondente, será ineficaz caso provado que as partes agiram com fraude.

As hipóteses do art. 130 são de *ineficácia subjetiva*, porque se caracterizam pela motivação fraudulenta das partes.

2. DECLARAÇÃO JUDICIAL DA INEFICÁCIA

A declaração judicial de ineficácia objetiva faz-se por vários modos (LF, art. 129, parágrafo único).

Em primeiro lugar, pode resultar de simples despacho exarado no processo de falência. O juiz, diante de qualquer informação relevante contida nos autos (relatório do administrador judicial, petição de credor, manifestação do Ministério Público, documentos juntados etc.), profere o despacho declarando o negócio jurídico ineficaz perante a massa dos credores. Determinará também as providências decorrentes, como a arrecadação de bens. Essa decisão pode ser dada de ofício ou por provocação de órgão da falência ou interessado.

A declaração da ineficácia objetiva pode resultar também de sentença acolhendo matéria de defesa suscitada pela massa falida. Imagine que o credor de obrigação constituída por negócio jurídico ineficaz demande a massa em juízo para cobrar o que pretende ser o seu direito. Na contestação, a massa poderá alegar a ineficácia objetiva. Uma vez acolhida a alegação pela sentença que julgar improcedente a ação, resta declarada a ineficácia.

Finalmente, a ineficácia objetiva pode resultar também do julgamento de qualquer ação, autônoma ou incidental, promovida pela massa falida, em que for pleiteada sua declaração. A massa falida pode, por exemplo, mover ação para reivindicar o bem indevidamente apartado do patrimônio do falido do sujeito que o titula, fundamentando seu pedido na ineficácia do negócio jurídico praticado.

Já a ineficácia subjetiva deve ser declarada judicialmente, numa ação própria, chamada *revocatória* (LF, arts. 132 a 135). Trata-se de ação de conhecimento específica do processo falimentar.

O administrador judicial tem legitimidade ativa para a ação revocatória, concorrente com qualquer credor e com o representante do Ministério Público. Por outro lado, tem legitimidade passiva todos os que figuraram no ato ou que, em decorrência deste, foram pagos, garantidos ou beneficiados. Também serão demandados terceiros contratantes, salvo se não tinham conhecimento da fraude. Os herdeiros e legatários dessas pessoas também estão legitimados como demandados para a ação revocatória (art. 133).

O juízo competente para a ação revocatória é o da falência.

A massa falida decai do direito à ação revocatória em 3 anos a contar da decretação da falência. O administrador judicial não responde pelas consequências advindas da decadência do direito, em vista da legitimidade concorrente de qualquer credor e do Ministério Público.

Da decisão que julga a revocatória cabe o recurso de apelação (art. 135, parágrafo único).

3. EFEITOS DA FALÊNCIA QUANTO AOS CONTRATOS DO FALIDO

Com a sentença declaratória da falência, os contratos do falido passam a se submeter a regras específicas do direito falimentar. Em outros termos, o regime jurídico dos contratos de qualquer empresário muda segundo ele esteja falido, ou não.

A falência autoriza a resolução dos contratos bilaterais (LF, art. 117). Por contratos bilaterais, para

os fins falimentares, entendem-se aqueles que nenhuma das partes deu início ainda ao cumprimento das obrigações assumidas. Excluem-se deste conceito, portanto, e da possibilidade de serem resolvidos pela decretação da falência, aqueles contratos que, embora definidos como bilaterais para os fins de direito obrigacional comum, já tiveram a sua execução iniciada por uma das partes.

Para o direito civil, a compra e venda é típico contrato bilateral. Se, porém, o vendedor já entregou as mercadorias vendidas (antes do prazo que autoriza a sua restituição), cumprindo assim integralmente as suas obrigações, mas o comprador não pagou ainda o preço delas, se este falir, o contrato de compra e venda não será considerado bilateral pelo direito falimentar. Não será bilateral, na falência, porque já teve seu cumprimento iniciado com a entrega das mercadorias pelo vendedor. Este contrato, portanto, não é suscetível de resolução pela massa falida. O vendedor deverá simplesmente habilitar o seu crédito e aguardar o pagamento.

O contrato unilateral também pode ser resolvido pelo administrador judicial, nas mesmas condições (LF, art. 118).

Em suma, a falência do contratante pode provocar a resolução: *a)* do contrato em que ambas as partes assumem obrigações, se a sua execução ainda não teve início por qualquer uma delas; e *b)* do contrato que importa obrigações para só um dos contratantes.

Se a falência não importar a resolução do contrato, as partes devem dar-lhe integral cumprimento. Compete ao administrador judicial e ao comitê de credores a decisão quanto ao cumprimento ou à resolução do contrato. Esses órgãos deverão decidir a partir do que entendem seja o mais conveniente para a massa.

Diz a lei que a resolução do contrato é cabível se puder reduzir ou evitar o aumento do passivo ou colaborar para a manutenção e preservação do ativo da massa falida (arts. 117 e 118). A decisão do administrador judicial autorizado pelo comitê é definitiva, não podendo os demais credores ou o contratante com o falido pleitearem a revisão do que eles decidiram.

Se o contratante desejar, pode interpelar o administrador judicial, nos 90 dias seguintes ao de sua investidura na função, para que este se posicione quanto ao cumprimento ou não do contrato. O silêncio do administrador judicial no prazo de 10 dias importará a resolução do contrato, assegurado ao contratante apurar, por ação própria, a indenização a que tem direito. Se vitorioso, a indenização constituirá crédito quirografário.

A resolubilidade dos contratos do falido, nestas condições, é a regra geral. Ao lado dela, o legislador estabeleceu regras específicas pertinentes a determinadas categorias de contrato. São as seguintes:

a) O vendedor poderá obstar a entrega de coisa vendida ao falido, ainda não pagas nem recebidas (desde que não tenha havido a revenda sem fraude por tradição simbólica, ou seja, feita com base em fatura ou conhecimento de transporte) (art. 119, I).

b) Na venda pelo falido de coisa composta resolvida pelo administrador judicial, o comprador pode pleitear perdas e danos, desde que coloque à disposição da massa as partes já recebidas (art. 119, II).

c) Na venda a prazo de coisa móvel pelo falido, o administrador judicial pode optar pela resolução do contrato, ficando obrigado a restituir ao comprador o valor das prestações pagas (art. 119, III).

d) Na compra com reserva de domínio de bem móvel pelo falido, se o administrador judicial resolver o contrato, o vendedor pode reivindicar o bem (LF, art. 119, IV).

e) Na compra e venda a termo que tenha cotação em Bolsa ou mercado, não se executando o contrato, prestará o contratante ou a massa a diferença entre as cotações do dia do contrato e o da liquidação (art. 119, V).

f) O compromisso de compra e venda de bens imóveis não pode ser resolvido pelo administrador judicial; na falência do vendedor, o compromisso será cumprido e, na do adquirente, os seus direitos de promitente serão arrecadados e liquidados (LF, art. 119, VI; Lei 6.766/79, art. 30).

g) Se o estabelecimento empresarial do falido encontra-se em imóvel locado, o administrador judicial pode resilir o contrato a qualquer tempo, sem pagar multa ou outro consectário. Se a falência é do locador, o contrato continua. Neste caso, enquanto o bem não for alienado, o locatário paga o aluguel à massa falida (art. 119, VII).

h) As contas-correntes do falido serão encerradas no momento da declaração da falência. Apurado o saldo credor da massa, será pago pelo contratante; se o saldo é credor do outro contratante, ele o habilita na falência (art. 121).

Em suma, a falência não provoca necessariamente a resolução dos contratos do falido. Quando se verifica, decorre de decisão do administrador judicial, autorizado pelo comitê, em vista do proveito para a massa falida (redução ou não aumento do passivo e preservação ou manutenção do ativo). Nas demais hipóteses, observadas as regras específicas que a Lei de Falências estabelece, o contrato deve ser cumprido pelo contratante nos mesmos termos em que seria caso não houvesse sido decretada a quebra.

Frise-se que, se as partes pactuaram cláusula de resolução por falência, esta será eficaz, não podendo o administrador judicial desrespeitá-la. Neste caso, o contrato se resolve, não por força da falência propriamente, mas pela vontade das partes contratantes que a elegeram como causa de resolução do vínculo contratual.

Os contratos de trabalho em que o falido figura como empregador não se resolvem com a falência, mas a cessação das atividades da empresa é causa de resolução desses contratos. Assim, salvo na hipótese de continuação provisória da empresa pelo falido (LF, art. 99, XI), a cessação da atividade econômica decorrente da quebra resolve a relação contratual empregatícia. Neste caso, o empregado pode reclamar as verbas indenizatórias pertinentes.

Os créditos em moeda estrangeira serão convertidos em moeda nacional pelo câmbio do dia em que for declarada a falência (LF, art. 77), sendo que somente por este valor de conversão poderão ser eles reclamados. Trata-se de exceção à regra geral da conversão de valores entre diferentes moedas, que se faz pela cotação do dia do pagamento (como, por exemplo, no art. 75, § 1.º, da LMC). O *objetivo da exceção no caso de falência* é possibilitar a definição precisa do passivo do falido.

Em outros termos, se o falido havia celebrado contrato de câmbio ou qualquer outro vinculado a moeda estrangeira, os riscos da oscilação cambial passam a ser do credor, que terá direito ao valor convertido em moeda nacional na data da decretação da quebra, sendo irrelevante o valor de conversão à época do pagamento.

Por fim, outro efeito da falência consiste na suspensão da prescrição das obrigações do falido, que voltam a fluir apenas com o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência (arts. 6.º e 157). Não se suspende, no entanto, a prescrição das obrigações de que era credor o falido. Prazos decadenciais, mesmo das obrigações devidas pelo falido, não se suspendem também.

Capítulo 28. REGIME JURÍDICO DOS CREDORES DO FALIDO

1. CREDORES ADMITIDOS

A falência, por ser processo de execução concursal de devedor empresário, compreende todos os credores do falido, civis ou comerciais.

A lei só exclui da falência: *a)* credor por obrigações a título gratuito (LF, art. 5.º, I); e *b)* crédito por despesas individualmente feitas para ingresso na massa falida subjetiva, salvo custas em litígio com esta (inc. II).

A partir do início da verificação dos créditos e até o fim do processo falimentar (ou antes, se houver decisão judicial que não o admita na massa ou dela o exclua), o credor tem os seguintes direitos no processo falimentar:

a) intervir, como assistente, em qualquer ação ou incidente em que a massa seja parte ou interessada;

b) fiscalizar a administração da massa;

c) requerer e promover, no processo de falência, o que for do interesse dos credores, tendo direito à indenização pelas despesas que fizer na defesa do interesse geral da massa (desde que ela tenha auferido vantagem e até o limite desta);

d) examinar, sempre que desejar e independentemente de autorização judicial, os livros e demais documentos da massa.

Os credores podem constituir procurador para representá-los na falência. Se o mandatário for advogado, basta a outorga de procuração com a cláusula *ad judicium*. A procuração com a cláusula *ad negotia* habilita o outorgado a representar o credor apenas nos atos que independem de advogado, como a declaração tempestiva de crédito.

Os credores debenturistas serão representados pelo agente fiduciário (LSA, art. 68, § 3.º, *d*). Caso não exista, os debenturistas se reunirão em assembleia para eleger um representante. Os debenturistas são os únicos credores que podem fazer a declaração coletiva de crédito, dispensando-se a apresentação de todos os títulos originais.

2. EFEITOS DA FALÊNCIA QUANTO AOS CREDORES

A sentença declaratória da falência produz quatro principais efeitos em relação aos credores: *a)* formação da massa falida subjetiva; *b)* suspensão das ações individuais contra o falido (art. 6.º); *c)* vencimento antecipado dos créditos (art. 77); *d)* suspensão da fluência dos juros (art. 124).

A massa falida subjetiva é o sujeito de direito despersonalizado voltado à defesa dos interesses gerais dos credores de empresário falido. Por vezes, na defesa desses interesses, age a massa falida como *sucessora* do falido, cobrando judicial ou amigavelmente os devedores; em outras ocasiões, a massa falida age na defesa dos interesses gerais dos credores *contra* o próprio falido, como na ação revocatória. No primeiro caso, sendo sucessora do falido, não terá mais direitos que os ele titulava antes

da quebra.

A massa falida objetiva é o conjunto de bens arrecadados do falido. Não se confunde com a massa falida subjetiva, que é a comunhão de interesses dos credores. A lei chama as duas simplesmente de massa falida, mas são figuras diversas, referindo-se uma (massa objetiva) a um objeto de direito e outra (massa subjetiva) a um sujeito de direito.

A suspensão das ações individuais dos credores contra o falido é consequência da sentença declaratória da falência. Ela dá início ao processo de execução *concursal* do devedor empresário, sendo despropositado que os credores continuassem a buscar *individualmente* a cobrança dos seus créditos.

Há exceções à regra de suspensão das execuções individuais. São as seguintes: *a*) as ações que versam sobre quantia ilíquida, coisa certa, prestação ou abstenção de fato (art. 6.º, § 1.º), inclusive reclamações trabalhistas; e *b*) as execuções fiscais fundadas em certidão da dívida ativa para cobrança de crédito tributário, não tributário ou parafiscal (CTN, art. 187).

Não se incluem nas exceções as execuções individuais promovidas pelo credor com direito real de garantia ou com privilégio geral ou especial.

As ações e execuções que não se suspendem com a falência terão prosseguimento com a massa falida. Ela será representada pelo administrador judicial. Tais ações não serão atraídas ao juízo universal da falência (*Cap.* 25, item 1). Para eficiente resguardo de seus interesses, o autor de ação judicial não suspensa deverá solicitar ao juiz reserva (LF, art. 6.º, § 3.º).

Outro efeito da sentença declaratória da falência é o vencimento antecipado dos créditos contra o falido. Do valor deles serão abatidos os juros legais (LF, art. 77). Excetua-se deste efeito as obrigações sujeitas à condição suspensiva, cujos credores devem participar da verificação dos créditos. Neste caso, contudo, o pagamento é postergado até que se verifique a condição.

Finalmente, a quebra acarreta a suspensão da fluência de juros. Apenas os juros devidos à data da quebra podem ser habilitados na falência. Os juros posteriores à falência serão pagos apenas após o pagamento de todos os credores, caso restem recursos na massa (LF, art. 124). Excetua-se desta regra as obrigações com garantia real, em relação à qual serão pagos os juros posteriores à decretação, sempre que o possibilitar o valor da venda do bem dado em garantia. Também os credores debenturistas são mencionados como exceção, mas se cuida apenas dos titulares de debêntures com garantia real.

O pagamento da correção monetária não segue a regra estabelecida para os juros. A correção monetária não representa qualquer acréscimo ao valor devido, uma vez que apenas atualiza a expressão em moeda do mesmo valor; deverá ser paga, então, junto com o principal.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS

Os credores do falido não são tratados igualmente. A natureza do crédito influi na definição de uma *ordem* de pagamento, que deve ser rigorosamente observada pelo administrador judicial na liquidação.

A ordem é a seguinte:

a) os créditos extraconcursais (LF, art. 84), como a remuneração do administrador judicial, as

despesas com a arrecadação e administração dos bens do falido, as custas judiciais, bem como os correspondentes às restituições em dinheiro etc.;

b) créditos por acidentes de trabalho e créditos trabalhistas, compreendendo toda a sorte de pagamentos devidos pelo empresário aos seus empregados (CLT, art. 449, § 1.º); nessa mesma classe, estão os créditos dos representantes comerciais (Lei 4.886/65, art. 44);

c) créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado (art. 83, II);

d) dívida ativa, de natureza tributária ou não tributária, excetuadas as multas (CTN, art. 186; Lei 6.830/80, art. 4.º, § 4.º; LF, art. 83, III);

e) créditos com privilégio especial (art. 83, IV);

f) créditos com privilégio geral (art. 83, V);

g) créditos quirografários (art. 83, VI);

h) as multas contratuais e penas pecuniárias por infração à legislação penal ou administrativa, incluindo as tributárias (art. 83, VII); e

i) créditos subordinados (art. 83, VIII).

A preferência dos créditos trabalhistas (derivados da relação empregatícia) está limitada ao valor de 150 salários mínimos por credor. O que ultrapassar esse limite é reclassificado como crédito quirografário. Por outro lado, para a proteção dos trabalhadores de menor renda, a lei determina que o administrador judicial proceda à *antecipação* do devido a título de salários vencidos nos 3 meses anteriores à quebra, desde que limitados a 5 salários mínimos por credor trabalhista. Essa antecipação deve ser feita mesmo que não tenham sido ainda atendidos os credores extraconcursais (LF, art. 151).

Os créditos com garantia real são aqueles em que a satisfação do direito do credor encontra-se garantida, por exemplo, por uma hipoteca incidente sobre imóvel do falido ou penhor sobre bem móvel dele. A preferência está limitada ao valor do bem onerado. Vendido este na liquidação da falência, destina-se o produto da venda à satisfação do credor titular da garantia. Se os recursos aferidos pela massa com a venda do bem gravado não forem suficientes ao pagamento integral do crédito garantido, o saldo concorrerá juntamente com os quirografários.

São credores por dívida ativa a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias. Esta dívida pode ter origem tributária ou não. Estabelece a lei uma ordem interna de pagamento entre os credores desta categoria. Assim, primeiro são satisfeitos os créditos da União e suas autarquias; em seguida, os dos Estados, Distrito Federal, Territórios e suas autarquias, conjuntamente e *pro rata*; finalmente, os Municípios e suas autarquias, conjuntamente e *pro rata* (Lei 6.830/80, art. 29, parágrafo único). São exemplos de créditos incluídos nesta categoria: impostos, taxas, contribuição devida à Seguridade Social (Lei 8.212/91, art. 51), anuidade de órgão profissional (Conselho Regional dos Representantes Comerciais Autônomos, p. ex.) e outros.

Gozam da mesma prioridade da dívida ativa federal os chamados créditos parafiscais: contribuições para entidades privadas que desempenham serviço de interesse social, como o SESC, SESI etc., ou o

devido a programa social administrado por órgão do governo, como o PIS e o FGTS.

São exemplos de credores com privilégio especial: *a)* o credor por benfeitorias necessárias ou úteis sobre a coisa beneficiada (CC, art. 964, III); *b)* o autor da obra, pelos direitos do contrato de edição, sobre os exemplares dela na falência do editor (CC, art. 964, VII); *c)* os credores titulares de direito de retenção sobre a coisa retida (LF, art. 83, IV, *c*); *d)* os titulados por microempreendedores individuais (MEI), microempresários e empresários de pequeno porte (LF, art. 83, IV, *d*); *e)* os subscritores ou candidatos à aquisição de unidade condominial sobre as quantias pagas ao incorporador falido (Lei 4.591/64, art. 43, III); *f)* o credor titular de Nota de Crédito Industrial sobre os bens referidos pelo art. 17 do Decreto-Lei 413/69; *g)* crédito do comissário (CC, art. 707); *h)* os segurados e beneficiários credores de indenização ajustada ou a ajustar sobre as reservas técnicas, fundos especiais ou provisões da seguradora ou resseguradora falidas (Decreto-Lei 73/66, com a redação dada pela LC n. 126/2007) e outros.

Por sua vez, são exemplos de crédito com privilégio geral, além dos mencionados no art. 965 do CC, o decorrente de debêntures com garantia flutuante (LSA, art. 58, § 1.º) e os honorários de advogado (EOAB, art. 24).

Os créditos quirografários correspondem à grande massa das obrigações do falido. São dessa categoria os credores por títulos de crédito, indenização por ato ilícito (salvo acidente de trabalho), contratos empresariais em geral etc. Após o pagamento desses créditos, restando ainda recursos na massa, deve o administrador judicial atender às multas contratuais e penas pecuniárias por infração à lei, inclusive multas tributárias.

Por crédito subordinado (ou "subquirografário") entende-se aquele que é pago somente após a satisfação dos credores sem qualquer garantia, prevendo a lei duas hipóteses: *a)* os créditos dos sócios ou administradores sem vínculo empregatício (LF, art. 83, VIII, *b*); *b)* crédito por debêntures subordinadas emitidas pela sociedade anônima falida (LSA, art. 58, § 4.º).

Por força das exceções ao princípio da universalidade do juízo falimentar, ou das referentes à suspensão das ações individuais contra o falido, pode ocorrer de um credor ser satisfeito com inobservância da ordem estabelecida. Nesta hipótese, terá o preterido direito creditício contra aquele que recebeu indevidamente, no valor do que lhe caberia, segundo a natureza de seu crédito e as forças da massa.

Capítulo 29. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. VIABILIDADE DA EMPRESA

Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada. A reorganização de atividades econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o ônus da reorganização das empresas recai na sociedade brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços se destina a socializar os efeitos da recuperação das empresas.

Por ser a sociedade brasileira como um todo que arca, em última instância, com os custos da recuperação das empresas, é necessário que o Judiciário seja criterioso ao definir quais merecem ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das empresas em um valor absoluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer custo. Na maioria dos casos, se a crise não encontrou uma solução de mercado, o melhor para todos é a falência, com a realocação em outras atividades econômicas produtivas dos recursos materiais e humanos anteriormente empregados na da falida.

Em outros termos, somente as empresas *viáveis* devem ser objeto de recuperação judicial (ou mesmo a extrajudicial). Para que se justifique o sacrifício da sociedade brasileira presente, em maior ou menor extensão, em qualquer recuperação de empresa não derivada de solução de mercado, o empresário que a postula deve se mostrar digno do benefício. Deve mostrar, em outras palavras, que tem condições de devolver à sociedade brasileira, se e quando recuperado, pelo menos em parte o sacrifício geral feito para salvá-la.

O exame da viabilidade deve ser feito em função de vetores como a importância social, a mão de obra e tecnologia empregadas, o volume do ativo e passivo, o tempo de existência da empresa e seu porte econômico.

2. MEIOS DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA

A lei contempla lista exemplificativa dos meios de recuperação da atividade econômica (LF, art. 50). Nela, encontram-se instrumentos financeiros, administrativos e jurídicos que normalmente são empregados na superação de crises em empresas. Os administradores da sociedade empresária interessada em pleitear o benefício em juízo devem analisar, junto com o advogado e demais profissionais que os assessoram no caso, se entre os meios indicados há um ou mais que possam mostrar-se eficazes no reerguimento da atividade econômica.

Como se trata de lista exemplificativa, outros meios de recuperação da empresa em crise podem ser examinados e considerados no plano de recuperação. Normalmente, aliás, os planos deverão combinar dois ou mais meios, tendo em vista a complexidade que cerca as recuperações empresariais.

A lista legal compreende: a) dilação do prazo ou revisão das condições de pagamentos; b) operação societária, como fusão, incorporação ou cisão; c) alteração do controle societário, com ou sem transferência total do poder a grupos mais capacitados; d) reestruturação da administração, com

substituição dos administradores ou redefinição dos órgãos; e) concessão de direitos societários extrapatrimoniais aos credores, como o direito de veto (*golden share*); f) reestruturação do capital; g) transferência ou arrendamento do estabelecimento empresarial; h) renegociação das obrigações ou do passivo trabalhistas; i) dação em pagamento ou novação das principais dívidas do empresário em crise; j) constituição de sociedade de credores, para revitalizar a empresa; l) realização parcial do ativo, visando o levantamento de recursos financeiros para investimento ou quitação de dívidas; m) equalização de encargos financeiros; n) usufruto de empresa; o) administração compartilhada, para arejar a direção da empresa com novas ideias; p) emissão de valores mobiliários, quando houver mercado para operações financeiras como as de securitização; q) adjudicação de bens a credores para diminuir o passivo.

3. ÓRGÃOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperação judicial (RJ) é um processo peculiar, em que o objetivo buscado - a reorganização da empresa, em benefício do empresário devedor, dos credores e empregados e da economia (local, regional ou nacional) - pressupõe a prática de atos judiciais não somente pelo juiz, Ministério Público e partes, como também de alguns órgãos específicos previstos em lei.

São três os órgãos específicos da recuperação judicial: assembleia geral dos credores, administrador judicial e o comitê.

3.1. Assembleia geral

A assembleia dos credores é o órgão colegiado e deliberativo responsável pela manifestação do interesse da vontade predominantes entre os credores sujeitos aos efeitos da RJ. De maneira geral, nenhuma recuperação de empresa se viabiliza sem o sacrifício ou agravamento do risco, pelo menos em parte, dos direitos de credores. Por esse motivo, em atenção aos interesses daqueles sem cuja colaboração a reorganização fatalmente se frustra, a lei reserva à assembleia geral dos credores (AGC) as mais importantes deliberações relacionadas ao reerguimento da atividade econômica em crise.

A AGC pode ser convocada pelo juiz (nas hipóteses legais ou sempre que considerar conveniente) e pelos credores (desde que a soma de seus créditos represente pelo menos 25% do total do passivo do recuperando). O anúncio da convocação da assembleia deve ser publicado no *Diário Oficial* e em jornal de grande circulação, com a antecedência mínima de 15 dias da data de sua realização. Para instalarem-se validamente os trabalhos da assembleia, é exigida a presença de credores titulares de mais da metade do passivo (em cada classe). Caso não seja alcançado, terá lugar a segunda convocação, observado o intervalo mínimo de 5 dias. Em segunda convocação, os trabalhos se instalam validamente com qualquer número de credores.

Compete à AGC: a) aprovar, rejeitar e revisar o plano de recuperação judicial; b) aprovar a instalação do comitê e eleger seus membros; c) manifestar-se sobre o pedido de desistência da recuperação judicial; d) eleger o gestor judicial, quando afastados os diretores da sociedade empresária requerente; e) deliberar sobre qualquer outra matéria de interesse dos credores (LF, art. 35, I, a a f).

Em princípio, todos os credores admitidos na recuperação judicial têm direito a voz e voto na assembleia. São credores admitidos os que se encontram na *última* lista publicada (relação de credores apresentada pelo devedor com a petição inicial, a organizada pelo administrador judicial ou a

consolidação do quadro geral). Está admitida e integra a assembleia dos credores a pessoa natural ou jurídica cujo nome consta do rol - dentre os três que se elaboram ao longo da verificação de créditos - que tiver sido publicado por último. Cada credor presente na assembleia terá o voto proporcional ao valor do seu crédito admitido na RJ. Desconsidera-se, por esta razão, o valor das despesas que individualmente fizeram para tomar parte do processo. Em relação ao valor do crédito prevalece o constante da última relação de credores.

Na AGC, há cinco instâncias de deliberação. De acordo com a matéria em apreciação, varia o conjunto de credores aptos a votar.

A instância de maior abrangência é o plenário. Sempre que a matéria não disser respeito à constituição do comitê ou plano de reorganização, cabe a deliberação ao plenário. Tem essa instância, portanto, competência residual. Se não houver na lei nenhuma previsão específica reservando a apreciação da matéria a outra ou outras instâncias, o plenário deliberará pela maioria de seus membros, computados os votos proporcionalmente aos seus valores, independentemente da natureza do crédito titularizado. O pedido de desistência da RJ, por exemplo, será votado na plenária, de acordo com este quorum de deliberação, e não nas classes.

O *quorum* geral de deliberação no plenário é o de maioria computada com base no valor dos créditos dos credores admitidos presentes à assembleia. Desse modo, se a AGC se realiza em segunda convocação, com a presença de apenas 10 credores, somam-se os créditos deles e calcula-se o peso proporcional do direito de cada um. Devem ser desprezadas as proporções dos créditos. Os percentuais assim encontrados norteiam a quantidade de votos atribuídos a cada credor.

Se um deles titularizar sozinho 51% da soma dos créditos dos presentes, então ele compõe isolado a maioria e faz prevalecer sua vontade e interesse, mesmo contra os dos demais. Assim será, inclusive, mesmo que o seu crédito represente parcela ínfima do passivo, se os credores ausentes titularizavam a parte substancial deste.

As quatro outras instâncias deliberativas da AGC correspondem às classes em que a lei dividiu os credores. Quando a deliberação versa sobre o plano de recuperação ou a composição do comitê de credores, o plenário não tem competência, cabendo às classes a aprovação ou rejeição.

Na votação atinente ao plano de recuperação, a primeira classe compõe-se pelos credores trabalhistas; a segunda, pelos titulares de direitos reais de garantia; a terceira, por titulares de privilégio (geral ou especial), os quirografários e subordinados; e a quarta classe reúne os credores microempresários e empresários de pequeno porte (LF, art. 41).

Na apreciação de matéria atinente à constituição e composição do comitê, as instâncias classistas da assembleia se organizam um pouco diferente: os credores titulares de privilégio especial compõem a mesma classe dos que titulam garantia real (LF, art. 26).

O plano de recuperação deve ser apreciado e votado nas classes da AGC (o plenário não delibera a respeito) e, em cada uma delas, deve receber a aprovação de mais da metade dos credores presentes. Neste caso, a votação considera apenas o número de credores, e despreza o valor dos créditos e seus pesos proporcionais. Além da aprovação "por cabeça" em cada uma das quatro classes, a aprovação do plano depende também de votação favorável segundo a proporção dos créditos em duas das quatro classes: a dos credores *com garantia real* (classe II) e a dos *titulares de privilégio, quirografários e*

subordinados (classe III).

3.2. Comitê

O comitê é órgão facultativo da recuperação judicial. Sua constituição e operacionalização dependem do tamanho da atividade econômica em crise. Ele deve existir apenas nos processos em que a sociedade empresária devedora explora empresa grande o suficiente para absorver as despesas com o órgão. Quem decide se o órgão deve ou não existir são os credores da sociedade em recuperação judicial, reunidos na AGC.

Qualquer das instâncias classistas da assembleia pode aprovar a instalação do comitê. Aprovada a instalação, reúnem-se as classes de credores para cada uma eleger 1 membro titular e 2 suplentes. Na eleição dos membros do comitê, observam-se os mesmos impedimentos para o exercício da função de administrador judicial (item 3.3).

A principal competência do comitê é fiscal. Quer dizer, cabe aos membros desse órgão fiscalizar tanto o administrador judicial como o devedor em RJ, antes e depois de concedida esta. Para tanto, os membros do comitê têm livre acesso às dependências, escrituração e documentos do devedor. Sempre que constatar qualquer fato que considere irregular, o comitê, por voto da maioria dos seus membros, deve encaminhar ao juiz da RJ requerimento fundamentado das providências que entender pertinentes.

Além da competência fiscal, por cujo exercício presta contas mensais, o comitê pode eventualmente exercer também três outras: elaboração de plano de recuperação alternativo ao apresentado pelo devedor; deliberação sobre as alienações de bens do ativo permanente; e autorização de endividamentos necessários à continuação da atividade empresarial, quando tiver sido determinado pelo juiz o afastamento dos administradores.

Nas recuperações judiciais em que não houver comitê, por ser injustificável (a dimensão da empresa ou a complexidade do passivo não o recomenda) ou inviável (quando não há credores interessados em exercer a função), as atribuições do órgão são exercidas pelo administrador judicial. Exceto nas matérias em que houver incompatibilidade, como, por exemplo, a fiscalização do próprio administrador judicial. Neste caso, cabe ao juiz exercer a atribuição legal inicialmente reservada ao comitê.

3.3. Administrador judicial

Em toda recuperação judicial, como auxiliar do juiz e sob sua direta supervisão, atua um profissional na função de administrador judicial. Ele é pessoa da confiança do juiz, por ele nomeado no despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial.

O administrador judicial deve ser pessoa idônea, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contador ou pessoa jurídica especializada. Estão, porém, impedidos de exercer a função os que anteriormente não a desempenharam a contento. Quem, nos 5 anos anteriores, exerceu a função de administrador judicial ou membro de comitê em processos de falência ou recuperação judicial e dela foi destituído, deixou de prestar contas ou teve reprovadas as que prestou, está impedido de ser nomeado para a função. Também há impedimento que veda a nomeação de pessoas com vínculo de parentesco ou afinidade até terceiro grau com qualquer dos representantes legais da sociedade empresária requerente da RJ, amigo, inimigo ou dependente destes.

Na recuperação judicial, as funções do administrador judicial variam de acordo com dois vetores: caso o comitê exista ou não; e caso tenha sido ou não decretado o afastamento dos administradores da empresa em recuperação.

De acordo com o primeiro vetor, uma vez instalado o comitê, ao administrador judicial caberá basicamente proceder à verificação dos créditos, presidir a assembleia dos credores e fiscalizar o recuperando. Não havendo comitê, o administrador assumirá também a competência reservada pela lei a esse órgão colegiado, exceto se houver incompatibilidade.

Pelo segundo vetor, o administrador judicial é investido no poder de administrar e representar a sociedade empresária requerente da RJ quando o juiz determinar o afastamento dos seus diretores, enquanto não for eleito o gestor judicial pela AGC. Somente nesse caso particular tem ele a prerrogativa de se imiscuir por completo na intimidade da empresa e tomar as decisões administrativas atinentes à exploração do negócio. Não tendo o juiz afastado os diretores ou administradores da sociedade empresária requerente da RJ, o administrador judicial será mero fiscal, o responsável pela verificação dos créditos e o presidente da AGC.

4. PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O processo da recuperação judicial divide-se em três fases bem distintas.

Na primeira, que se pode chamar de *fase postulatória*, o empresário ou a sociedade empresária em crise apresenta seu requerimento de RJ. Ela se inicia com a petição inicial de recuperação judicial e se encerra com o despacho judicial mandando processar o pedido.

Na segunda fase, a que se pode referir como *deliberativa*, após a verificação de crédito, discute-se e aprova-se um plano de reorganização. Tem início com o despacho que manda processar a RJ e se conclui com a decisão homologatória do plano aprovado pela AGC.

A derradeira etapa do processo, chamada de *fase de execução*, compreende a fiscalização do cumprimento do plano aprovado. Começa com a decisão concessiva da recuperação judicial e termina com a sentença de encerramento do processo.

4.1. Fase postulatória

Para pedir a recuperação judicial, é necessário estar sujeito à falência. Apenas o empresário e a sociedade empresária têm legitimidade para o pedido. As sociedades em comum, de economia mista, cooperativa ou simples não podem pleitear a recuperação judicial exatamente porque nunca podem ter a falência decretada.

Atender a esta condição, porém, não basta, porque a lei obsta a determinadas categorias de empresário ou sociedade empresária o acesso à RJ. Estão excluídas da recuperação judicial, por razões ligadas à regulação econômica, as instituições financeiras, integrantes do sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários no mercado de capitais, corretoras de câmbio (Lei 6.024/74, art. 53), seguradoras (Decreto-Lei 73/66, art. 26) e as operadoras de planos privados de assistência à saúde (Lei 9.656/98, art. 23) e concessionárias de energia elétrica (Lei 12.767/12).

Por outro lado, a recuperação judicial tem lugar apenas se o titular da empresa em crise quiser. Se

credores, trabalhadores, sindicatos ou órgão governamental tiver um plano para a reorganização da atividade econômica em estado pré-falencial, não poderá dar início à RJ contra a vontade do devedor.

Para legitimar-se ao pedido de recuperação judicial, contudo, não basta ser exercente de atividade econômica exposta ao risco de falência e não se encontrar entre as exceções legais. O devedor precisa atender também a mais *quatro* requisitos: *a)* não pode estar falido; *b)* deve estar regularmente estabelecido há mais de 2 anos; *c)* não pode ter obtido o mesmo benefício há menos de 5 anos; *d)* não pode ter havido condenação pela prática de crime falimentar.

Se quem pleiteia a recuperação judicial é empresário individual, cabem ainda mais três observações: *a)* a lei legitima o devedor pessoa natural que, embora falido, teve suas responsabilidades declaradas extintas por sentença definitiva; *b)* ele não está legitimado se, nos 5 anos anteriores, requereu RJ, obteve-a e deixou de cumpri-la, tendo a quebra decretada; *c)* na hipótese de morte do empresário individual, a recuperação judicial pode ser pedida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros ou inventariante.

Exige-se do devedor interessado em obter a RJ o atendimento a diversas condições: algumas formais, outras, materiais. É necessário, por exemplo, que torne acessíveis aos credores certas demonstrações contábeis, para possibilitar a verificação de sua situação patrimonial. De outro lado, ela deve ter um plano viável de recuperação da atividade em estado crítico. Em consequência, a lei determina que a petição inicial esteja instruída com certos elementos e documentos, sem os quais não se consideram atendidas as condições para a obtenção do benefício.

Compõe obrigatoriamente a instrução da petição inicial de RJ: exposição das causas; demonstrações contábeis e relatório da situação da empresa; relação dos credores; relação dos empregados; atos constitutivos (contrato social, se limitada; estatuto, se anônima) devidamente atualizados; lista dos bens de sócio ou acionista controlador e administradores; extratos bancários e de investimentos; certidões de protesto; relação das ações judiciais em andamento.

Estando em termos a documentação exigida para a instrução da petição inicial, o juiz proferirá o despacho mandando processar a RJ. Note-se que esse despacho não se confunde com a ordem de autuação ou outros despachos de mero expediente. Não se confunde também com a decisão concessiva da recuperação judicial, que virá após a aprovação do plano pelos credores. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de dois fatores - a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém, que a empresa em crise é viável e, portanto, tem o direito ao benefício. Só a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial.

No despacho de processamento da recuperação judicial, o juiz nomeia o administrador judicial, determina a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor (ressalvadas as exceções da lei) e a intimação do Ministério Público e comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a requerente estiver estabelecida. Publica-se o despacho em edital na imprensa oficial, de que deve constar também a data, o local e a hora para os quais foi convocada a assembleia geral dos credores.

Dos efeitos do despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial cabe examinar com mais vagar os relacionados à suspensão das ações ou execuções em trâmite contra o requerente. Lembro que os pedidos de falência suspendem-se pela tão só impetração regular da RJ no prazo de contestação (LF, art. 95). Quanto a esses, portanto, o despacho mandando processar o pedido não tem maiores

implicações. São as demais ações e execuções que terão sua tramitação suspensa com o processamento da recuperação judicial.

Mas há exceções na lei. Continuam, assim, a tramitar: (*i*) ações de qualquer natureza (civil ou trabalhista) que demandam quantias ilíquidas; (*ii*) reclamações trabalhistas; (*iii*) execuções fiscais, caso não concedido o parcelamento (CTN, art. 155-A, §§ 3.º e 4.º); (*iv*) execuções promovidas por credores absolutamente não sujeitos à recuperação judicial: bancos titulares de crédito derivado de antecipação aos exportadores (ACC), proprietário fiduciário, arrendador mercantil ou o vendedor ou promitente vendedor de imóvel ou de bem com reserva de domínio.

É temporária a suspensão das ações e execuções em virtude do despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial. Cessa esse efeito quando verificado o primeiro dos seguintes fatos: aprovação do plano de recuperação *ou* decurso do prazo de 180 dias.

4.2. Fase de deliberação

A fase de deliberação do processo de recuperação judicial inicia-se com o despacho de processamento. O principal objetivo dessa fase é a votação do plano de recuperação. Para que essa votação se realize, porém, deve ser processada previamente a verificação dos créditos (ver *Cap. 25*, item 7).

A mais importante peça do processo de recuperação judicial é o plano de recuperação judicial (ou de "reorganização da empresa"). Depende exclusivamente dele a realização ou não dos objetivos associados ao instituto, quais sejam, a preservação da atividade econômica e o cumprimento de sua função social. Se o plano de recuperação é consistente, há chances de a empresa se reestruturar e superar a crise em que mergulhara. Terá, nesse caso, valido a pena o sacrifício imposto diretamente aos credores e, indiretamente, a toda a sociedade brasileira. Mas se o plano for inconsistente, limitado a um papelório destinado a cumprir mera formalidade processual, então o futuro do instituto é a completa desmoralização.

Note-se, um bom plano de recuperação não é, por si só, garantia absoluta de reerguimento da empresa em crise. Fatores macroeconômicos globais ou nacionais, acirramento da concorrência no segmento de mercado em causa ou mesmo imperícia na sua execução podem comprometer a reorganização pretendida. Mas, um plano ruim é garantia absoluta de fracasso da RJ.

O plano de recuperação deve indicar pormenorizada e fundamentadamente o meio ou meios pelos quais a sociedade empresária devedora deverá superar as dificuldades que enfrenta. No tocante à alteração das obrigações do recuperando, a lei se preocupou em estabelecer quatro balizas: *a*) os empregados com direitos vencidos na data da apresentação do pedido de recuperação judicial devem ser pagos no prazo máximo de 1 ano, devendo ser quitados os saldos salariais em atraso em 30 dias; *b*) deve-se buscar o parcelamento do crédito fiscal; *c*) se o plano prevê a alienação de bens onerados (hipotecados ou empenhados), a supressão ou substituição da garantia real depende da expressa aprovação do credor que a titulariza; *d*) nos créditos em moeda estrangeira, sua conversão para a moeda nacional depende de expressa concordância do titular do crédito.

Portanto, com a exceção feita aos créditos referidos nas quatro balizas acima, todos os demais sujeitos aos efeitos da RJ podem ser objeto de amplas alterações no valor, na forma de pagamento, nas condições de cumprimento da obrigação etc.

O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, contados da publicação do despacho de deferimento do processamento. Se nenhum credor objetar, ele está aprovado. Havendo objeção, convoca-se a AGC.

Cabe à assembleia dos credores, tendo em vista o proposto pela devedora e eventual proposta alternativa que lhe tenha sido submetida, discutir e votar o plano de recuperação. Três podem ser os resultados da votação na AGC: a) aprovação do plano de recuperação, por deliberação nas classes que atendeu ao *quorum* da lei; b) apoio ao plano de recuperação, por deliberação nas classes que *quase* atendeu a esse *quorum*; c) rejeição do plano do devedor e, se apresentado, também do alternativo do comitê.

Em qualquer caso, o resultado será submetido ao juiz, mas variam as decisões judiciais possíveis em cada um deles. No primeiro, o juiz limita-se a homologar a aprovação do plano pelos credores, não podendo deixar de fazê-lo por razões atinentes ao *mérito* do aprovado pela AGC; no segundo, ele terá a discricionariedade para aprovar ou não o plano que quase alcançou o *quorum*; no terceiro, deve decretar a falência do requerente da RJ.

4.3. Fase de execução

Concedida a recuperação judicial, encerra-se a fase de deliberação e tem início a de execução.

Durante a derradeira fase do processo de recuperação judicial, dá-se cumprimento ao plano de recuperação aprovado em juízo. Em princípio, é imutável esse plano. Se a sociedade beneficiada dele se desviar nos dois anos seguintes à aprovação, deve ter a falência decretada. Tem sido admitido, porém, em casos muito excepcionais a revisão pela AGC do plano de recuperação, quando considerável mudança na economia impede o seu cumprimento, não havendo culpa do devedor.

O devedor em recuperação judicial não tem suprimida sua capacidade ou personalidade jurídica. Continua existindo como sujeito de direito apto a contrair obrigações e titularizar crédito. Sofre uma única restrição: os atos de alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente só podem ser praticados se úteis à recuperação judicial. A utilidade do ato é presumida em termos absolutos se previsto no plano de recuperação judicial aprovado em juízo. Nesse caso, o bem pode ser vendido ou onerado, independentemente de qualquer outra formalidade ou anuência. Mas, se a alienação ou oneração não constar do plano de recuperação homologado ou aprovado pelo juiz, a utilidade do ato para a RJ deve ser apreciada pelos órgãos desta. Assim, a alienação ou oneração só poderá ser praticada mediante prévia autorização do juiz, ouvido o comitê.

Durante toda a fase de execução, a sociedade empresária agregará ao seu nome a expressão "em recuperação judicial", para conhecimento de todos que com ela se relacionam negocial e juridicamente. A omissão dessas expressões implica responsabilidade civil direta e pessoal do administrador que tiver representado a sociedade em recuperação no ato em que ela se verificou. Será, outrossim, levado à inscrição na Junta Comercial o deferimento do benefício.

Se os administradores da sociedade em RJ eleitos pelos sócios ou acionista controlador estão se comportando lícita e utilmente, não há razões para removê-los da administração. Caso contrário, o juiz determinará seu afastamento. Determinando a destituição da administração da sociedade empresária requerente do benefício, o juiz deve convocar a AGC para a eleição do *gestor judicial*, a quem será atribuída a administração da empresa em recuperação.

De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral dos credores.

5. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Quando a crise alcança microempresa ou empresa de pequeno porte, a RJ pode seguir algumas regras específicas. O devedor, desde logo, deve optar entre submeter-se às regras estabelecidas para a generalidade dos empresários ou pela apresentação de um Plano Especial (esta última alternativa tem sido a mais comum).

Optanto pela apresentação de Plano Especial de recuperação, o devedor terá direito ao parcelamento das dívidas existentes na data da distribuição do pedido.

As obrigações sujeitas ao Plano Especial poderão ser pagas em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 180 dias da data da distribuição do pedido de recuperação judicial. O número exato de parcelas será definido na proposta que o microempresário ou empresário de pequeno porte apresenta com o pedido de recuperação judicial.

Caso o devedor opte por apresentar o Plano Especial, o procedimento da RJ será bastante simplificado. A assembleia geral dos credores, por exemplo, não será convocada para deliberar sobre o Plano Especial, cabendo sua aprovação ou rejeição exclusivamente ao juiz. Se mais da metade de cada classe de credores manifestar objeção ao plano, o juiz deve decretar a falência do devedor.

Inicia-se o processo com a petição do devedor expondo as razões da crise e apresentando proposta de renegociação do passivo, dentro das balizas legais indicadas. Normalmente, a proposta é apresentada pela hipótese mais favorável ao devedor proponente, quer dizer, contemplando a divisão do passivo em 36 parcelas. Apresentado e recebido o pedido de recuperação judicial, o juiz já decide de pronto, homologando a proposta apresentada ou decretando sua falência. Há, também, a alternativa de determinar a retificação do Plano Especial, quando desconforme com os parâmetros da lei, hipótese em que a decretação da falência caberá se e quando desobedecida a determinação judicial.

Cabe aos credores eventualmente interessados a iniciativa de suscitar em juízo suas objeções, cujo conteúdo só pode versar sobre a adequação da proposta à lei. Se suscitada, o juiz determinará ao requerente que se manifeste, oportunidade em que poderá ser superado o desentendimento, mediante revisão da proposta por acordo entre as partes. Se, porém, for questionada a objeção, o juiz decidirá o conflito, homologando a RJ ou decretando falência.

Com a sentença de homologação da proposta de parcelamento, operam-se os efeitos do benefício, como a suspensão das ações e execuções e a novação das obrigações compreendidas no Plano Especial.

6. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA

Dá-se a convolação da recuperação judicial em falência em quatro hipóteses: a) deliberação dos credores reunidos em assembleia, pelo voto da maioria simples do plenário, quando a situação de crise econômica, financeira ou patrimonial da sociedade devedora é de suma gravidade e que não há sentido

em qualquer esforço de reorganização; *b*) não apresentação do plano pelo devedor no prazo, que não pode ser prorrogado; *c*) rejeição do plano pela assembleia dos credores; *d*) descumprimento do plano de recuperação.

Convolada a recuperação judicial em falência, por qualquer razão, os credores quirografários *posteriores* à distribuição do pedido serão reclassificados como credores extraconcursais (LF, art. 67, *caput*). Já os quirografários *anteriores* à recuperação judicial serão reclassificados como privilegiados, desde que tenham continuado a conceder crédito à empresa em dificuldade (LF, art. 67, parágrafo único). O objetivo dessas reclassificações é estimular os agentes econômicos (principalmente os fornecedores de insumo e crédito) a continuar atendendo à demanda por crédito proveniente da empresa em recuperação judicial, apesar do agravamento do risco.

Capítulo 30. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

1. REQUISITOS DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Muitas vezes pode ocorrer de a recuperação judicial depender da revisão de determinados créditos, cujos titulares resistem a qualquer proposta de renegociação. Se esses credores representam uma minoria do passivo da empresa em crise, não é justo que se frustre a recuperação pela falta do apoio deles. A recuperação representa a possibilidade de todos os credores virem a receber seus créditos, em razão do sacrifício que eles (ou parte deles) concordam em suportar. A negativa de uma parcela minoritária dos credores em aderir ao plano de recuperação não deve comprometer a chance de superação da crise. Para evitar o comprometimento, a LF prevê que o plano de recuperação extrajudicial apoiado pela maioria dos credores atingidos pode ter seus efeitos estendidos aos demais, mesmo contra a vontade desses (hipótese em que a homologação judicial é *obrigatória*).

Para simplesmente procurar seus credores (ou parte deles) e tentar, em conjunto com eles, encontrar uma saída negociada para a crise, o empresário não precisa atender a nenhum dos requisitos da lei para a recuperação extrajudicial. Estando todos os envolvidos de acordo, assinam os instrumentos de novação ou renegociação e assumem, por livre manifestação da vontade, obrigações cujo cumprimento espera-se que proporcione o reerguimento do devedor. Quando a lei estabelece requisitos para a recuperação extrajudicial, ela está se referindo apenas ao devedor que pretende oportunamente levar o acordo à homologação judicial. Se essa não é necessária (porque todos os atingidos aderiram ao plano) nem conveniente (porque não tem interesse o devedor em arcar com as despesas do processo), é irrelevante o preenchimento ou não das condições legalmente estabelecidas.

Os requisitos legais para a homologação do plano de recuperação extrajudicial são de duas ordens: subjetivos (dizem respeito ao requerente) e objetivos (são pertinentes ao plano submetido à homologação).

Assim, o devedor que precisa ou pretende requerer a homologação da recuperação extrajudicial deve preencher os seguintes requisitos: *a)* atender às mesmas condições estabelecidas pela lei para o acesso à recuperação judicial; *b)* não se encontrar em tramitação nenhum pedido de recuperação judicial dele (LF, art. 161, § 3.º, primeira parte); *c)* não lhe ter sido concedida, há menos de 2 anos, recuperação judicial ou extrajudicial (art. 161, § 3.º, segunda parte).

De outro lado, são cinco os requisitos objetivos: *a)* não pode ser previsto no plano o pagamento antecipado de nenhuma dívida (LF, art. 161, § 2.º, primeira parte); *b)* todos os credores sujeitos ao plano devem receber tratamento paritário, vedado o favorecimento de alguns ou o desfavorecimento apenas de parte deles (art. 161, § 2.º, segunda parte); *c)* o plano não pode abranger senão os créditos constituídos até a data do pedido de homologação (art. 163, § 1.º, *in fine*); *d)* do plano só pode constar a alienação de bem gravado ou a supressão ou substituição de garantia real se o credor garantido (hipotecário, pignoratício etc.) concordar expressamente (art. 163, § 4.º); *e)* o plano de recuperação não pode estabelecer o afastamento da variação cambial nos créditos em moeda estrangeira sem contar com a anuência expressa do respectivo credor (art. 163, § 5.º).

2. HOMOLOGAÇÃO FACULTATIVA

Na lei, há duas hipóteses distintas de homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial. A primeira, que denomino *facultativa*, é a homologação do plano que conta com a adesão da totalidade dos credores atingidos pelas medidas nele previstas. Dela cuida o art. 162 da LF. Quando todos os credores cujos créditos são alcançados pelo plano (isto é, nele altera-se seu valor, vencimento, condições de pagamento, garantias etc.) aderiram às suas cláusulas, a homologação judicial não é obrigatória. Se o plano de recuperação extrajudicial ostenta a assinatura de todos os credores por ele atingidos, a homologação não é condição para os obrigar. Eles já se encontram obrigados nos termos do plano, por força da adesão resultante de manifestação de vontade. O ato judicial não é necessário para que o crédito seja alterado em sua extensão ou condições.

Dois são os motivos que podem justificar a homologação facultativa. O primeiro é revestir o ato de maior solenidade, para chamar a atenção das partes para a sua importância. O segundo é possibilitar a alienação por hasta judicial de filiais ou unidades produtivas isoladas, quando prevista a medida (LF, art. 166).

Ao requerer a homologação facultativa, o devedor deve instruir o pedido com a justificativa do pleito e o instrumento de recuperação extrajudicial (plano, acordo, termo etc.) assinado por todos os credores aderentes. Após receber a petição inicial devidamente instruída, o juiz determina a publicação de edital convocando os credores a apresentarem eventuais impugnações. O prazo para impugnar o plano de recuperação extrajudicial é de 30 dias, seguintes à publicação do edital. Nos mesmos 30 dias, o devedor requerente deve provar que comunicou, por carta, todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no Brasil, informando-lhes a distribuição do pedido de homologação extrajudicial, as condições do plano apresentado e o prazo para a impugnação.

Processada a impugnação, se houver, o juiz decide o pedido, homologando o plano de recuperação extrajudicial ou denegando a homologação.

3. HOMOLOGAÇÃO OBRIGATÓRIA

Ao lado da homologação facultativa do plano de recuperação extrajudicial, prevê a LF também a homologação obrigatória. Trata-se da hipótese em que o devedor conseguiu obter a adesão de parte significativa dos seus credores ao plano de recuperação, mas uma pequena minoria resiste a suportar suas consequências. Nesse caso, é injusto que a oportunidade de superação da crise da empresa se perca em razão da recusa de parcela minoritária dos credores.

Com a homologação judicial do plano de recuperação extrajudicial, estendem-se os efeitos do plano aos minoritários nele referidos, suprindo-se desse modo a necessidade da adesão voluntária.

Para ser homologado com base no art. 163, o plano de recuperação extrajudicial deve ostentar a assinatura de credores titulares de pelo menos 3/5 de todos os créditos de cada *espécie*. Por "espécies" de crédito se deve entender, para os fins de aplicação desse dispositivo, as classes referidas nos incs. II, IV, V, VI e VIII do art. 83: a) crédito com garantia real; b) crédito com privilégio especial; c) crédito com privilégio geral; d) crédito quirografário; e) crédito subordinado. São essas cinco as espécies de crédito a serem consideradas na recuperação extrajudicial. A adesão ao plano, para autorizar sua homologação obrigatória, deve ser de credores titulares de pelo menos 3/5 dos créditos com garantia real, de pelo menos 3/5 dos com privilégio especial, de pelo menos 3/5 dos com privilégio geral e assim por diante.

Só têm relevância considerar, na aferição do elevado grau de adesão ao plano de recuperação extrajudicial, os créditos *alcançados* pelo plano (LF, art. 163, § 2.º).

O processamento da homologação obrigatória é idêntico ao da facultativa, exceto no que diz respeito à instrução da petição inicial. Para o pedido de homologação facultativa, a lei estabeleceu instrução singela, consistente na justificativa e no plano. Não há mesmo sentido em exigir-se mais do devedor nessa hipótese, porque os efeitos da homologação facultativa são modestos. O plano conta com a adesão de todos os credores por ele alcançado, e a homologação não lhes afeta os direitos creditórios.

Contudo, a instrução do pedido de homologação obrigatória, em vista do maior alcance dos efeitos desta, deve ser mais complexa. Além da justificativa e do plano (com a assinatura da maioria aderente), deve o devedor apresentar em juízo: *a)* exposição de sua situação patrimonial; *b)* demonstrações contábeis relativas ao último exercício; *c)* demonstrações contábeis referentes ao período, desde o fim do último exercício e a data do plano, levantadas especialmente para o pedido; *d)* documento comprobatório da outorga do poder para novar ou transigir para os subscritores do plano em nome dos credores (por exemplo: ato de investidura do administrador de sociedade empresária acompanhado do estatuto ou do contrato social, instrumento de procuração com poderes específicos etc.); *e)* relação nominal de todos os credores, com endereço, classificação e valor atualizado do crédito, além da origem, do vencimento e da remissão ao seu registro contábil (LF, art. 163, § 6.º).

4. OS CREDITORES NA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Alguns dos credores estão preservados da recuperação extrajudicial, mesmo a homologada judicialmente. A recuperação extrajudicial não altera minimamente os direitos dessas categorias de credores. São, por isso, sujeitos de direito que não podem renegociar os créditos que detêm perante a sociedade empresária por meio do expediente da recuperação extrajudicial. A renegociação só pode se fazer por regras próprias da disciplina legal do crédito em questão ou, quando inexistentes, pelas do direito das obrigações.

Os credores preservados da recuperação extrajudicial são: *a)* titulares de créditos derivados da relação empregatícia ou de acidente de trabalho; *b)* credor tributário; *c)* proprietário fiduciário, arrendador mercantil, vendedor ou promitente vendedor de imóvel por contrato irrevogável e vendedor titular de reserva de domínio; *d)* instituição financeira credora por adiantamento ao exportador (ACC).

Todos os demais credores estão expostos aos efeitos da recuperação extrajudicial homologada. Se o plano tiver obtido a adesão da maioria (60% do valor do passivo de cada espécie atingida), a extensão dos seus efeitos aos minoritários renitentes é consequência da homologação judicial.

Após a distribuição do pedido de homologação, o credor que tiver aderido ao plano de recuperação extrajudicial não pode dele desistir, a menos que os demais signatários concordem. A anuência do devedor e de todos os credores é condição para a existência, validade e eficácia do arrependimento porque o plano de recuperação extrajudicial deve sempre ser considerado em sua integralidade. Se faltar qualquer um de seus elementos, é possível que o objetivo pretendido (isto é, a recuperação da empresa) não seja alcançado. Desse modo, como a adesão de cada credor é sempre feita no pressuposto de que todos os signatários vão dar sua parcela de contribuição para a realização desse objetivo, a desistência de qualquer um deles afeta os interesses dos demais. Atenta a isso, a lei exige a concordância tanto do devedor como dos outros credores aderentes, para que um desses últimos possa se liberar do previsto no

plano.

Capítulo 31. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

1. INTRODUÇÃO

Na forma prevista pela Lei 6.024/74 (LILE), as instituições financeiras estão sujeitas a um regime de execução concursal de natureza *extrajudicial*.

O regime de execução concursal extrajudicial não exclui em caráter absoluto a falência das instituições financeiras que, em determinadas hipóteses, pode ser decretada. Assim, se a instituição financeira não estiver sob liquidação extrajudicial ou sob intervenção decretada pelo Banco Central, ela poderá ter a sua falência decretada judicialmente *nas mesmas condições previstas para os demais exercentes de atividade empresarial*. Quando houver impontualidade injustificada ou prática de ato de falência de sua parte, poderão os credores requerer a decretação da quebra. Além disso, estando sob o regime de liquidação extrajudicial ou intervenção, o Banco Central deve autorizar o oferecimento de pedido judicial da falência da instituição, que será feito, respectivamente, pelo liquidante ou pelo interventor, nos casos delineados pela lei (LILE, arts. 21, *b*, e 12, *d*).

Convivem, dessa forma, os dois regimes. A execução concursal do patrimônio da instituição financeira devedora será feita, conforme o caso, ou pela falência, segundo os preceitos da LF, ou pela liquidação extrajudicial, de acordo com a LILE.

Não há, conforme alguns doutrinadores pretenderam inicialmente, qualquer inconstitucionalidade nesta sistemática criada pelo legislador. A existência da liquidação extrajudicial não importa inobservância do preceito constitucional que impede à lei excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5.º, XXXV), na medida em que os atos administrativos praticados, seja pelo Banco Central, seja pelos seus agentes, estão sujeitos ao controle jurisdicional.

A liquidação extrajudicial também não exclui a liquidação ordinária disciplinada pelos arts. 208 a 218 da LSA. Este é o procedimento destinado à realização do ativo e pagamento do passivo da instituição financeira dissolvida de pleno direito ou por decisão judicial (LSA, art. 206, I e II), ao passo que a liquidação extrajudicial é modalidade de execução concursal.

As instituições financeiras federais não estão sujeitas à liquidação extrajudicial, uma vez que a União, na qualidade de controladora dessas sociedades, deve proceder à sua liquidação ordinária, sempre que entender conveniente o encerramento das atividades por elas desenvolvidas.

Por fim, registre-se que o mesmo regime de liquidação extrajudicial previsto para as instituições financeiras é também estendido às sociedades integrantes do sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários, às sociedades corretoras (LILE, art. 52), seguradoras, de capitalização, às entidades de previdência privada (Lei 10.190/2001, art. 3.º) e às sociedades arrendadoras que tenham por objeto exclusivo a exploração de *leasing*.

2. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O Banco Central é o órgão da administração indireta federal competente para a decretação da

liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Esta é modalidade de ato administrativo vinculado, de sorte que apenas nas hipóteses elencadas pela lei pode aquela autarquia decretá-la.

Entre as causas que autorizam a liquidação extrajudicial, é possível discernir dois grupos.

Um está relacionado diretamente com os fundamentos da execução concursal (a justiça do tratamento paritário dos credores diante da insolvência patrimonial do devedor) e compreende as hipóteses das alíneas *a* e *c* do inc. I do art. 15 da LILE: comprometimento da situação econômica ou financeira, especialmente a impontualidade ou a prática de ato de falência, e prejuízo que sujeite os credores quirografários a risco anormal.

O outro grupo de causas autorizadoras da liquidação extrajudicial representa não um expediente para o tratamento isonômico dos credores, mas uma verdadeira sanção administrativa a cargo das autoridades monetárias. São deste grupo as causas das alíneas *b* e *d* do art. 15, I, da LILE: violação grave das normas legais ou estatutárias ou das determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central ou o atraso superior a 90 dias para o início da liquidação ordinária, bem como sua morosidade, após a cassação da autorização para funcionar.

Desta forma, a liquidação extrajudicial ganha um perfil ambíguo, podendo ser utilizada como medida de coibição às infrações dos administradores de uma instituição financeira, mesmo que esta se encontre absolutamente solvável.

A liquidação extrajudicial também pode ser decretada pelo Banco Central a pedido da própria instituição, representada pelos seus administradores devidamente autorizados pelo estatuto, ou pelo interventor, quando estiver aquela sob o regime de intervenção.

A decretação da liquidação extrajudicial importa a suspensão das ações e execuções judiciais existentes e na proibição de ajuizamento de novas ações (LILE, art. 18, *a*). Afasta-se, assim, a possibilidade de decretação da falência da instituição liquidanda. Por outro lado, há o vencimento antecipado e interrompe-se o curso da prescrição de todas as obrigações de que seja devedora a liquidanda (LILE, art. 18, *b* e *e*). Finalmente, o ato de decretação torna inexigível a cláusula penal dos contratos unilaterais antecipadamente vencidos, os juros posteriores à decretação (enquanto não for pago integralmente o passivo), bem como as penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas (LILE, art. 18, *c*, *d* e *f*).

A correção monetária é devida sobre a totalidade das obrigações da instituição em liquidação (Dec.-lei 1.477/76, art. 1.º).

A liquidação extrajudicial desenvolve-se sob o comando do liquidante nomeado pelo Banco Central, a quem a lei reserva amplos poderes de administração. Trata-se do órgão da pessoa jurídica liquidanda responsável pela manifestação de sua vontade e, neste sentido, cabe-lhe verificar e classificar os créditos, contratar e demitir funcionários, fixar-lhes os vencimentos, outorgar e cassar mandato, representar a sociedade em juízo e, enfim, praticar todos os atos jurídicos em nome da entidade relacionados à liquidação. Para ultimar os negócios pendentes ou para onerar ou alienar bens, necessita o liquidante de prévia e expressa autorização do Banco Central.

O liquidante é investido em suas funções por meio de termo de posse lavrado no livro "diário" da instituição financeira, e deve proceder à imediata arrecadação, por termo, de todos os livros e

documentos de interesse para a administração da massa, bem como determinar o levantamento de balanço geral e inventário de todos os livros, documentos, dinheiro e bens.

Os administradores em exercício quando da decretação da liquidação devem assinar, também, o termo de arrecadação, o balanço geral e o inventário, cabendo-lhes, ainda, a prestação de informações gerais atinentes à administração, patrimônio e mandatos da instituição (LILE, art. 10).

Nos 60 dias seguintes à sua posse, o liquidante apresentará ao Banco Central um relatório contendo: a) exame da escrituração, da aplicação dos fundos e disponibilidade e da situação econômico-financeira da instituição; b) atos e omissões danosos eventualmente ocorridos, com a correspondente comprovação; c) adoção de medidas convenientes à liquidanda, devidamente justificadas (LILE, art. 11). O prazo para a entrega do relatório poderá ser prorrogado pelo Banco Central.

Ao receber o relatório, o Banco Central autorizará ou a continuidade da liquidação ou o requerimento da falência. Esta última alternativa deve ser adotada se o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos metade do passivo quirografário ou se houver indícios de crime falimentar (LILE, art. 21, b).

Autorizada a continuação da liquidação, o liquidante, por meio de um aviso no *Diário Oficial* da União e em jornal de grande circulação, convocará os credores a habilitarem os seus créditos. Os credores por depósito ou por letras de câmbio de aceite da instituição financeira estão dispensados de habilitação. É o próprio liquidante que decide sobre a admissão e classificação dos créditos, cabendo desta decisão recurso ao Banco Central. Julgados os créditos, o liquidante organizará o quadro geral de credores, dando-lhe publicidade juntamente com o balanço geral.

No prazo de 10 dias da divulgação do quadro geral de credores, poderão os interessados oferecer impugnação a ser encaminhada e decidida pelo Banco Central. Quando este julgar os recursos e as impugnações, o liquidante publicará novamente o quadro geral, com as eventuais alterações. Os habilitantes que não se sentirem satisfeitos com a decisão administrativa poderão, nos 30 dias seguintes à publicação da versão definitiva do quadro geral de credores, dar continuidade às ações que se encontravam suspensas ou propor as que couberem. O liquidante, sendo cientificado da lide, reservará recursos para a eventualidade de reconhecimento judicial do crédito (LILE, art. 27).

A venda dos bens do ativo da instituição será feita por meio de licitação realizada pelo liquidante, sendo necessária a prévia e expressa autorização do Banco Central. A venda pode ser feita a qualquer tempo, independentemente do procedimento de verificação dos créditos (LILE, art. 16, § 1.º). A realização do ativo por forma diversa só é cabível no resguardo da economia pública, da poupança privada ou da segurança nacional, mediante prévia e expressa autorização do Banco Central (LILE, art. 31).

À liquidação extrajudicial aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei de Falências, equiparando-se o liquidante ao administrador judicial, e o Banco Central ao juiz (LILE, art. 34). Com base neste dispositivo, inclusive, é que se tem entendido como indispensável a intervenção do Ministério Público nas ações em que for parte ou interessada uma instituição financeira em liquidação. Por outro lado, os negócios praticados pela instituição passíveis de enquadramento nos arts. 129 e 130 da LF poderão ser objeto de ação revocatória para declaração da ineficácia dos atos de burla à lei. A ação revocatória será proposta pelo liquidante perante o juiz a quem caberia processar e julgar a falência da instituição financeira em liquidação (LILE, art. 35).

3. REORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A liquidação extrajudicial determina a extinção da personalidade jurídica da instituição financeira e, quase sempre, importa a cessação da atividade econômica por ela desenvolvida, com prejuízos aos seus empregados, consumidores e à própria comunidade. Assim, quando possível, a liquidação deve ser evitada. Dentro deste contexto, o legislador colocou à disposição das autoridades monetárias dois instrumentos que visam precisamente à reorganização da instituição financeira. São eles a intervenção (LILE, arts. 2.º a 14) e o regime de administração especial temporária (RAET) (Decreto-Lei 2.321/87). Ambos os instrumentos têm o mesmo objetivo, ou seja, possibilitar a recuperação econômico-financeira e a reorganização da instituição financeira, evitando-se sua liquidação extrajudicial.

Diferenciam-se a intervenção e o RAET nos seguintes aspectos: *a)* quanto às causas que autorizam a decretação pelo Banco Central; *b)* quanto aos efeitos; *c)* quanto ao prazo de duração; *d)* quanto ao agente.

No tocante às causas, a intervenção pode ser decretada quando ocorrer prejuízo decorrente de má administração que sujeite os seus credores a risco (LILE, art. 2.º, I), ou infrações reiteradas à legislação bancária (inc. II), ou, ainda, impontualidade injustificada ou ato de falência, se for possível evitar-se a liquidação extrajudicial (inc. III). Já o RAET pode ser decretado nestas três hipóteses e, mais, nas seguintes: existência de passivo a descoberto, gestão temerária ou fraudulenta, prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de política econômica ou financeira traçadas em lei e, finalmente, a desobediência às normas referentes à conta de reservas bancárias (Decreto-Lei 2.321/87, art. 1.º).

Como se percebe, no tocante a este critério de diferenciação, o RAET é mais abrangente. Note-se, também, a utilização de instituto primordialmente destinado à recuperação econômica e financeira da entidade devedora como uma medida sancionadora em vista do descumprimento de normas administrativas.

Referentemente aos efeitos, a intervenção produz a suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas e da fluência do prazo das vincendas contraídas antes de sua decretação, bem como a inexigibilidade dos depósitos (LILE, art. 6.º). Nenhum dos credores existentes na data da intervenção poderá, portanto, exigir o seu crédito, devendo aguardar o término desta ou eventual decisão do Banco Central. Não poderá, por outro lado, requerer a falência da instituição financeira. Os credores posteriores à intervenção, por seu turno, podem exercer os direitos emergentes do título que possuem. A intervenção também implica a suspensão do mandato dos administradores, membros do Conselho Fiscal e demais órgãos estatutários (LILE, art. 50).

Por sua vez, o RAET não afeta o curso regular dos negócios nem o normal funcionamento da instituição financeira, reduzindo-se os seus efeitos à perda do mandato dos administradores e membros do Conselho Fiscal (Decreto-Lei 2.321/87, art. 2.º). Os credores, incluindo aqueles por contrato de depósito, exercem os respectivos direitos sem qualquer limitação, podendo ajuizar ações e execuções judiciais, ou, mesmo, requerer a falência da instituição financeira devedora.

Estas diferenças devem servir de critério para a autoridade administrativa optar pela intervenção ou pelo RAET. Quando a recuperação e reorganização da instituição financeira pode ocorrer sem maiores prejuízos para os seus credores, o Banco Central deve preferir o RAET à intervenção.

Em relação à diferença pertinente ao prazo de duração, prevê a lei que a intervenção não será superior a 6 meses, podendo ser prorrogada, uma única vez, por até 6 meses (LILE, art. 4.º), enquanto o

RAET tem o prazo determinado pela autoridade administrativa, podendo ser prorrogado por período não superior, *se absolutamente necessário* (Decreto-Lei 2.321/87, art. 1.º, parágrafo único).

Por fim, a intervenção é executada por um interventor (LILE, art. 5.º) e o RAET por um conselho diretor (Decreto-Lei 2.321/87, art. 3.º). Ambos são nomeados pelo Banco Central, e, com o termo de posse lavrado nos livros da instituição financeira, passam a exercer a representação legal desta, com plenos poderes de gestão. O número de membros do conselho diretor é definido em função do necessário à condução dos negócios sociais.

A intervenção e o RAET cessam quando é decretada a falência ou a liquidação extrajudicial da instituição financeira ou quando esta se reorganiza (inclusive por meio da cisão, fusão, incorporação, venda ou desapropriação do controle acionário), restabelecendo-se a normalidade de sua situação econômico-financeira.

4. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

O legislador estabelece um regime próprio de apuração e efetivação de responsabilidade civil dos administradores das instituições financeiras pelos danos que lhe causam.

A doutrina, por vezes, considera que o tratamento reservado pela lei aos administradores de instituições financeiras acaba por equipará-los aos acionistas diretores das sociedades em comandita por ações (que respondem subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações sociais referentes à sua gestão). Em outras ocasiões, discute se o regime próprio instituiu hipótese de responsabilidade objetiva (independente de culpa) ou subjetiva.

Mas, a rigor, o administrador de instituição financeira tem responsabilidade civil de *natureza e extensão* idêntica à atribuída ao administrador de qualquer outra sociedade anônima. Apenas se diferencia o regime específico de responsabilização no que diz respeito à *apuração e efetivação*. Assim, o administrador da instituição financeira responde pelos danos que causar à pessoa jurídica em decorrência do descumprimento dos deveres legais (LSA, arts. 153 a 157), ou seja, pelos prejuízos decorrentes de má administração.

Claro está que a responsabilidade decorre de ato próprio dele, administrador. Não criou o legislador nenhuma outra figura de responsabilidade subsidiária. Por esta razão, a responsabilização do administrador de instituição financeira encontra seus limites no montante do prejuízo causado (LILE, art. 40, parágrafo único).

Assim, se em função de ato omissivo ou comissivo de má administração, o administrador de instituição financeira causar danos a esta, estará obrigado a indenizá-los. Encontra-se, desta forma, na mesmíssima situação do diretor de uma companhia com outro objeto social que, por administrá-la mal, acarreta dano à sociedade.

A diferença reside, como dito, nos meios legais de apuração e efetivação da responsabilidade. Na companhia não financeira, se os acionistas concluem que determinado administrador não está desenvolvendo a sua função com a competência necessária, devem substituí-lo pela forma apropriada e, em assembleia, deliberar pela responsabilização. Caberá aos demais administradores reunirem os elementos comprobatórios daquele fato para a devida ação judicial de responsabilidade civil, podendo os acionistas, na forma da lei, atuar como substitutos processuais da sociedade.

Quando, no entanto, se trata de instituição financeira em liquidação extrajudicial, sob intervenção ou em RAET, o legislador estabeleceu uma sistemática diversa para a apuração e efetivação da responsabilidade civil dos administradores. Inicialmente, esta sistemática prevê a instauração de um *inquérito* no âmbito do Banco Central para investigar se a pessoa jurídica financeira sofreu ou não prejuízo em decorrência de má administração e, em caso afirmativo, quais os responsáveis. Prevê também que todos os bens dos administradores ficam indisponíveis. Com tais determinações, criou o legislador apenas mecanismos que tornam mais eficaz a responsabilização dos administradores.

Tanto é assim que as medidas previstas no regime especial simplesmente se desconstituem caso a ação judicial de responsabilidade civil não é proposta dentro do prazo fixado na lei. Mas, apenas a medida excepcional destinada a garantir a efetividade da responsabilização deixa de existir, permanecendo incólume a possibilidade de se responsabilizar o administrador enquanto não prescrita a ação.

Se o *inquérito* instaurado pelo Banco Central concluir pela inexistência de prejuízo, ele será arquivado naquela autarquia, ou, se houver falência em curso, remetido ao juiz para apensamento aos autos deste processo. Se concluir pela existência de prejuízo, será remetido ao juiz competente de acordo com a legislação falimentar. Claro está que a conclusão do *inquérito*, por si só, não é suficiente para se condenar o administrador em indenizar a instituição financeira. É necessária a ação judicial de responsabilidade civil. Para esta finalidade, o *inquérito* concluído no Banco Central e encaminhado ao juiz é remetido ao Ministério Público, a quem a lei atribui legitimidade ativa para a ação de indenização. Contudo, se a ação não for proposta em 30 dias, o Ministério Público perde a iniciativa, e, se nenhum credor a propuser nos 15 dias seguintes, cessa a indisponibilidade dos bens do administrador. Ou seja, ele poderá, ainda, ser responsabilizado, mas bens de seu patrimônio somente serão atingidos em execução judicial após a ação de conhecimento. Além do mais, a sua responsabilização somente poderá ser promovida na forma prevista pela lei em relação aos administradores em geral (LSA, arts. 158 e 159).

Em princípio, a indisponibilidade dos bens atinge todas as pessoas que, nos 12 meses anteriores à decretação, se encontravam no exercício da função de administrador da instituição financeira, o que compreende os diretores e membros do Conselho de Administração. Para que os membros do Conselho Fiscal tenham os seus bens indisponíveis, é necessária a aprovação do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central (LILE, art. 36). Se o *inquérito* concluir pela responsabilização de administradores cujos bens não se encontram indisponíveis (é o caso, por exemplo, daqueles que exerceram o cargo de diretor há mais de 12 meses antes da decretação), caberá ao Ministério Público requerer, em juízo, nos 8 dias seguintes ao recebimento daquele, o arresto dos respectivos bens. Também este se levanta se a ação de responsabilidade civil não for intentada no prazo da lei.

O controlador da instituição financeira responde solidariamente com o administrador nos casos de liquidação extrajudicial, intervenção ou regime de administração especial temporária (Decreto-Lei 2.321/87, art. 15; Lei 9.447/97, art. 1.º). Aqui também não se trata de responsabilidade subsidiária e ilimitada por atos da sociedade, conforme podem, à primeira vista, dar a entender os dispositivos em questão. Na verdade, o controlador, independentemente de culpa em relação ao *ato* danoso praticado pelo administrador, responde solidariamente pela respectiva indenização. O vínculo de solidariedade não aproxima o controlador e as obrigações sociais, mas este e o administrador responsável pelos atos danosos. Não é necessária a prova de ter o controlador agido com culpa, mas é necessária a de que o administrador agiu assim, administrando mal a instituição. Sem culpa deste último, não responde nem ele,

nem o controlador.

QUINTA PARTE - CONTRATOS EMPRESARIAIS

(Autor)

Fábio Ulhoa Coelho

Capítulo 32. TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

1. CONTRATOS EMPRESARIAIS

Na exploração da atividade empresarial a que se dedica, o empresário individual ou a sociedade empresária celebram vários contratos. Pode-se dizer que combinar os fatores de produção é contrair e executar obrigações nascidas principalmente de contratos. Lembrem-se os fatores: capital, insumos, mão de obra e tecnologia. Pois bem, investir capital pressupõe a celebração de contrato bancário, pelo menos o de depósito. Para obter insumos, é necessário contratar a aquisição de matéria-prima, eletricidade ou mercadorias para revender. Articular na empresa o trabalho significa contratar empregados (CLT), prestadores de serviços autônomos ou empresa de fornecimento de mão de obra (terceirizada). A aquisição ou criação de tecnologia faz-se por contratos industriais (licença ou cessão de patente, transferência de *know-how*). Além desses, para organizar o estabelecimento, por vezes o empresário loca o imóvel, faz *leasing* de veículos e equipamentos, acautela-se com seguro. Ao oferecer os bens ou serviços que produz ou circula, ele igualmente celebra contratos com consumidores ou outros empresários. Ao conceder crédito, normalmente negocia-o com bancos, mediante descontos ou *factoring*.

Os contratos que o empresário contrai podem estar sujeitos a cinco regimes jurídicos diferentes, no direito brasileiro: administrativo, do trabalho, do consumidor, civil e comercial. Dependendo de quem seja o outro contratante, as normas aplicáveis ao contrato serão diferentes.

Se o empresário contrata com o Poder Público ou concessionária de serviço público, o contrato é *administrativo* (por exemplo, se o fabricante de móveis vence licitação promovida por Prefeitura, para substituir o mobiliário de uma repartição, o contrato que vier a assinar será desta espécie). Se o outro contratante é empregado, na acepção legal do termo (CLT, art. 3.º), o contrato é *de trabalho*. Se consumidor (ou empresário em situação análoga à de consumidor), a relação contratual está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Se o contrato é celebrado entre empresários, o regime aplicável é o de direito comercial. Nas demais hipóteses, o contrato é *civil*, e está regido pelo Código Civil ou por legislação especial.

Os contratos são empresariais (*comerciais* ou *mercantis*), assim, se os dois contratantes são empresários.

Os contratos empresariais podem estar sujeitos ao CC ou ao CDC, dependendo, uma vez mais, das condições dos contratantes. Se os empresários são *iguais*, sob o ponto de vista da condição econômica (quer dizer, ambos podem contratar advogados e outros profissionais antes de assinarem o instrumento contratual, de forma que, ao fazê-lo, estão plenamente informados sobre a extensão dos direitos e

obrigações contratados), o contrato empresarial está sujeito ao CC; se *desiguais* os contratantes (ou seja, um deles está em situação de vulnerabilidade econômica frente ao outro), o contrato empresarial será regido pelo CDC.

Quando o banco contrata com a construtora a edificação de sua sede, o contrato é empresarial sujeito ao CC, porque ambos os empresários negociam em pé de igualdade. Mas, quando o mesmo banco concede empréstimo a microempresário, o contrato empresarial está sujeito à legislação consumerista, já que este último se encontra em situação análoga à de consumidor.

O mais adequado seria uma reforma legislativa que disciplinasse especificamente os contratos entre empresários, classificando-os de acordo com as condições dos contratantes (iguais e desiguais) e reservando a cada tipo disciplina compatível com a tutela dos interesses objeto de contrato.

Enquanto esta reforma não se realiza, aplica-se o Código Civil (ou legislação especial) aos contratos empresariais entre iguais e o Código de Defesa do Consumidor aos empresariais entre desiguais.

Observe-se, porém, que mesmo quando disciplinado pelo CC, o contrato empresarial é regido por princípios próprios, que, fundados na livre iniciativa e concorrência, limitam as hipóteses de revisão judicial, obstam a alegação de invalidade por lesão, modulam a boa-fé e a função social.

2. CONTRATOS E OBRIGAÇÕES

A doutrina costuma afirmar que os contratos são fontes de obrigações. Esta ideia é uma simples metáfora, e, sendo assim, pode no máximo auxiliar na compreensão do assunto, mas nunca conseguiria efetivamente explicá-lo.

Para se entender a relação entre contrato e obrigação, é necessário partir-se da diferença entre, de um lado, o vínculo que une duas ou mais pessoas no sentido de as autorizar a exigirem determinada prestação umas das outras, e, de outro, o documento comprobatório da existência deste vínculo. É comum utilizar-se a expressão "contrato" para designar tanto o vínculo como o documento, o que gera alguma confusão. Para evitá-la, passarei a chamar de contrato apenas a relação entre as pessoas, valendo-me da expressão "instrumento" na referência ao respectivo documento comprobatório. Neste contexto, portanto, contrato é uma das modalidades de obrigação, ou seja, espécie de vínculo entre as pessoas, em virtude do qual são exigíveis prestações.

A obrigação é a consequência que o direito posto atribui a determinado fato. Assim, quem aufere renda, por exemplo, fica obrigado a pagar o respectivo imposto; quem causa culposamente dano a outrem, deve indenizá-los; quem adquire a quota não integralizada do capital social de uma limitada será responsável pelas dívidas sociais dentro do limite legal.

Entre os fatos que o direito recolhe para considerar como geradores de obrigação encontra-se a vontade humana. Se uma pessoa, por sua própria vontade, quer se obrigar perante outra (em função, ou não, de uma contraprestação desta), o direito tem reconhecido eficácia a tal intenção, no sentido de pôr à disposição das partes o aparelho estatal de coerção com vistas a garantir a realização do quanto se declarou.

A existência e a extensão de uma obrigação dependem das disposições de direito positivo ou da vontade das pessoas diretamente interessadas. Quando são as normas jurídicas que definem totalmente a

existência e a extensão do vínculo obrigacional, estamos diante de *obrigação legal*. Nesta categoria, encontram-se os tributos, a pensão alimentícia, a indenização por ato ilícito danoso, os benefícios previdenciários. Porém, quando a definição da existência ou da extensão da obrigação não se encontra exaurida na respectiva disciplina legal, reservando-se à vontade das pessoas diretamente envolvidas na relação a faculdade de participar desta definição, temos diante de nós uma categoria diversa de obrigação. Neste segundo conjunto de vínculos obrigacionais, encontra-se o contrato, ao lado das obrigações não contratuais, de caráter institucional (casamento, constituição de sociedade por ações, instituição de fundação etc.) ou provenientes de atos unilaterais (promessa de recompensa, gestão de negócios etc.). Estes dois tipos de obrigações (contratuais e não contratuais) diferenciam-se pelo regime jurídico de sua constituição e dissolução.

Se a existência e a extensão da relação obrigacional dependem exclusivamente da vontade das pessoas, inexistindo norma jurídica que reconheça eficácia a esta, então o vínculo representa simples obrigação natural, como a dívida de jogo, o dízimo para entidades religiosas ou a contribuição para obras assistenciais. Tais vínculos não têm caráter jurídico, mas apenas moral.

Em suma, pode-se situar o contrato no conjunto dos vínculos obrigacionais em que a existência e a extensão da obrigação, que certa pessoa tem de dar, fazer ou não fazer algo para outra, são definidas em parte pela lei e em parte pela vontade dela mesma. O contrato é espécie deste gênero de obrigação.

Sempre houve uma determinada disciplina dos contratos por assim dizer *externa* à vontade das partes. Na Antiguidade, o direito romano reconhecia validade aos contratos reais se tivessem sido contraídos com a observância de um ritual realizado com o uso de uma balança. Na Idade Média, os instrumentos de certos tipos de contrato deveriam conter a chancela de autoridade feudal para valerem. Mesmo no mercantilismo, ao contrário do que costumava pregar o liberalismo clássico, nunca existiu uma absoluta liberdade de contratar, tendo o estado disciplinado normativamente o contrato desde o início. É certo que esta disciplina tem crescido progressivamente, ainda mais no capitalismo dos nossos dias. A predefinição da existência e da extensão do vínculo em algumas hipóteses é de tal forma exaurida pelas normas jurídicas em vigor, que não resta qualquer margem de atuação para a vontade das partes. Nestes casos, como o do chamado seguro obrigatório, cuja contratação é imposta a todo o proprietário de veículo automotor, rigorosamente não se cuida de obrigação contratual, mas legal. Para que haja contrato, é indispensável uma participação da vontade do devedor, ainda que mínima, no que se refere às definições atinentes à existência e à extensão das obrigações contraídas.

3. CONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL

Dois princípios regem a constituição do vínculo contratual: *consensualismo* e *relatividade*.

Pelo princípio do consensualismo, o contrato se constitui, via de regra, pelo encontro das vontades manifestadas pelas partes, não sendo necessária mais nenhuma outra condição. Há, no entanto, algumas exceções, isto é, determinados contratos que exigem, para a sua formação, além da convergência da vontade das partes, também algum outro elemento.

As exceções ao princípio do consensualismo estão representadas, de um lado, pelos contratos *reais* (como o mútuo ou o depósito, que se constituem somente com a entrega da coisa objeto da avença) e, de outro, pelos *solenes* (em relação aos quais o direito condiciona a constituição à elaboração de certo instrumento contratual: por exemplo, a licença de marca, que deve ser escrita). É claro que anteriormente

à constituição do vínculo contratual inexistente qualquer obrigação juridicamente válida e eficaz; daí a importância de se classificar o contrato como consensual, real ou solene.

Assim, em termos gerais os contratos empresariais (entre empresários) estão constituídos (perfeitos e acabados) assim que se verifica o encontro de vontade das pessoas participantes do vínculo (princípio do consensualismo).

Aquela parte que toma a iniciativa da constituição do contrato chama-se proponente ou polícitante, e a sua manifestação de vontade é a *proposta*. Já a destinatária da proposta chama-se oblato ou aceitante, e a manifestação de vontade dela é denominada *aceitação*. A doutrina classifica as declarações de vontade em tácitas ou expressas, mencionando que estas, por sua vez, podem ser orais, escritas ou simbólicas. Quando a lei não exigir a manifestação expressa, ela poderá ser tácita. Observada, portanto, esta regra, o proponente e o aceitante podem manifestar a sua vontade pelos muitos meios de comunicação existentes, desde a mímica mais rudimentar até a mais sofisticada transmissão eletrônica.

Ao elaborar a proposta, o proponente fica obrigado pelos seus termos, salvo as exceções da lei (CC, art. 427). Esta obrigação cessa apenas nas seguintes hipóteses: *a*) quando a proposta é dirigida a pessoa presente, sem a fixação de prazo para a resposta, a falta de aceitação imediata desobriga o proponente (CC, art. 428, I); *b*) se feita a pessoa ausente, sem prazo, o proponente não mais estará obrigado se transcorrer prazo suficiente para a resposta, sem a manifestação do oblato (CC, art. 428, II); *c*) no caso da proposta elaborada com a fixação de prazo para a resposta, a fluência deste sem aceitação desobriga o proponente (CC, art. 428, III); *d*) arrependendo-se o proponente, estará desobrigado se transmitir ao oblato, anterior ou concomitantemente à proposta, a sua retratação (CC, art. 428, IV); *e*) finalmente, em qualquer caso, se o oblato manifestar a sua recusa em aceitar os termos da proposta.

A aceitação absolutamente concorde com a proposta, manifestada em tempo hábil, obriga o aceitante. Já aquela aceitação que introduz alterações nos termos da proposta ou é manifestada a destempo deverá ser tratada como uma nova proposta.

Pelo princípio da relatividade, o contrato gera efeitos apenas entre as partes por ele vinculadas, não criando, em regra, direitos ou deveres para pessoas estranhas à relação. Aqui também há algumas exceções, como o seguro de vida ou a estipulação em favor de terceiro, que são contratos constitutivos de crédito em benefício de pessoa não participante do acordo de vontades. Além deste aspecto atinente aos sujeitos atingidos pelo contrato, menciona a doutrina um aspecto objetivo no princípio da relatividade, pelo qual o contrato não alcança bens estranhos ao seu objeto.

Uma discussão bastante interessante diz respeito àquelas situações aparentes, que iludem contratantes de boa-fé. Imagine-se um comerciante que, no decorrer de alguns anos, tivesse mantido reiteradas negociações com certo atacadista por meio de determinado representante deste. Rompido o vínculo de representação, sem o conhecimento do comerciante, os negócios posteriormente realizados por meio do antigo representante vincularão o atacadista. É o que propõe a teoria da aparência, segundo a qual uma situação aparente pode gerar obrigações para terceiros quando o contratante, de boa-fé, tinha razões efetivas para tomá-la por real. Esta teoria é mais comumente aplicada nas hipóteses de excesso de mandato, continuação de fato de mandato findo, inobservância de diretrizes do representado pelo representante etc. Orlando Gomes admite até mesmo a responsabilização do empresário por atos praticados por falso representante, quando a aparência de direito poderia enganar o contratante médio.

Quando o contrato se insere no âmbito da tutela do consumidor, o princípio da relatividade também

tem sua pertinência ressalvada em alguns casos, pois admite-se a reclamação contra o fabricante do produto viciado, embora a relação contratual de compra e venda tenha se estabelecido na verdade entre o consumidor e o comerciante varejista.

4. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO

Ao se vincularem por um contrato, as partes assumem obrigações, podendo uma exigir da outra a prestação prometida. Esta é a regra geral, sintetizada pela cláusula *pacta sunt servanda*, implícita em todas as avenças. Em outros termos, a ninguém é possível liberar-se, por sua própria e exclusiva vontade, de obrigação assumida em contrato. Se o vínculo nasceu de um encontro de vontades, ele somente poderá ser desfeito por desejo de todas as pessoas envolvidas na constituição (ressalvadas as hipóteses de desconstituição por fatores externos à manifestação de vontade). Isto significa especificamente que, em todos os contratos, são implícitas as cláusulas de irretratabilidade e de intangibilidade. Pela primeira, afasta-se a possibilidade de dissolução total do vínculo por simples vontade de uma das partes; pela outra, revela-se impossível a alteração unilateral das condições, prazos, valores e demais cláusulas contratadas.

A cláusula *pacta sunt servanda*, no entanto, não tem aplicação absoluta e se encontra limitada por outra cláusula, também implícita em certos contratos, que possibilita a revisão diante de imprevisíveis alterações econômicas. Trata-se da cláusula *rebus sic stantibus*, que sintetiza a teoria da imprevisão.

Segundo esta cláusula, se uma das partes contratantes tiver a sua situação econômica alterada em virtude de fatores imprevisíveis e independentes de sua vontade, e em função desta alteração o cumprimento do contratado acabar se revelando excessivamente oneroso para ela, então será possível a revisão das condições em que o contrato foi estabelecido.

A cláusula *rebus sic stantibus* é implícita apenas nos contratos comutativos, ou seja, naqueles em que há equilíbrio entre a vantagem auferida e a prestação dada por cada uma das partes. Nos contratos aleatórios, os contratantes assumem o risco de ganhar ou perder, já que inexistente tal equilíbrio. Note-se que a distinção entre estas duas categorias de contrato não toma por base a comparação entre as obrigações das partes, que não precisam ser equivalentes em nenhuma hipótese. Leva-se em conta, isto sim, o equilíbrio entre o benefício perseguido e a prestação devida, sob o ponto de vista de cada contratante isoladamente considerado. O contrato também deve ser de execução diferida ou sucessiva, ou seja, nos contratos de execução imediata, não há, como nos aleatórios, implícita a cláusula de revisão.

Para a aplicação da teoria da imprevisão, é necessário que as condições econômicas de uma das partes, ao tempo do cumprimento do contrato, sejam substancialmente diversas daquelas existentes quando da sua celebração. A alteração das condições econômicas, por sua vez, não poderia ter sido razoavelmente antevista, ou seja, é imprescindível a sua imprevisibilidade. Finalmente, o cumprimento do contrato, na nova situação econômica, deve revelar-se excessivamente oneroso para uma das partes, de tal modo que aquela não teria assumido a obrigação contratual caso pudesse ter previsto a mudança.

Alguns autores, ainda, entendem que a revisão só pode ser obtida pelo contratante que, agindo em inequívoca boa-fé, se socorre do Judiciário *antes* do vencimento de sua obrigação.

O contrato, portanto, tem força obrigatória. Quem expressa a vontade de assumir obrigação perante outra pessoa fica responsável nos termos de sua declaração. Há, contudo, duas hipóteses em que o

contrato deixa temporariamente de ter força obrigatória. Em primeiro lugar, a própria convergência de vontades constitutiva do vínculo pode sustar, pelo prazo e nas condições estabelecidas de comum acordo, o cumprimento do contrato. Outra hipótese de suspensão do vínculo contratual é a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Claro que se cuida, aqui, daquelas situações imprevisíveis que não comprometem definitivamente o cumprimento do contrato, mas apenas o postergam. Se há impossibilidade cabal de execução do contratado, então o caso fortuito ou a força maior dão ensejo à resolução do contrato e não à suspensão de sua exigibilidade.

Por fim, no tocante à força obrigatória, é necessário mencionar-se que os contratos bilaterais contêm, implícita, a cláusula da *exceptio non adimpleti contractus*, pela qual uma parte não pode exigir o cumprimento do contrato pela outra, se estiver em mora em relação à sua própria obrigação. Ainda em relação aos contratos bilaterais, destaque-se que a parte, à qual incumbe cumprir o objeto da avença em primeiro lugar, pode exigir da outra a prestação prometida, ou garantias, se tiver ocorrido diminuição no patrimônio desta última capaz de comprometer a execução do contrato (CC, art. 477).

5. DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL

Sendo o contrato espécie de vínculo obrigacional, todas as causas extintivas de obrigações dão ensejo à sua desconstituição. Assim, a prescrição, a confusão, a compensação etc. causam o desfazimento da relação contratual. Fora estas causas, a desconstituição do contrato pode também decorrer da invalidação ou da dissolução do vínculo.

A invalidação de um contrato ocorre em função de causas anteriores ou contemporâneas à constituição, a saber, a incapacidade das partes, a ilicitude do objeto, a inidoneidade da forma ou vício de consentimento ou social (erro, dolo, simulação etc.).

Pode verificar-se, segundo a causa que dá ensejo à invalidade, uma hipótese de nulidade ou anulabilidade do contrato. Uma e outra atingem a própria validade do negócio jurídico praticado, e, por isso, as partes devem retornar à situação em que se encontravam anteriormente ao contrato.

Já a dissolução está relacionada com causas posteriores à constituição do contrato, ou seja, a inexecução e a vontade das partes. Na primeira hipótese, dá-se a resolução, e, na segunda, a rescisão do contrato.

A resolução resulta do não cumprimento das obrigações assumidas por uma das partes em decorrência de ação ou omissão a ela imputável (resolução voluntária ou culposa) ou em função de fatores externos à atuação do contratante que impossibilitam a execução do contrato, como o caso fortuito, força maior ou a insolvência (resolução involuntária). Nos contratos bilaterais, existe a cláusula resolutiva tácita, pela qual o descumprimento de obrigação por um dos contratantes autoriza o outro a requerer em juízo a dissolução do vínculo.

Com a resolução, as partes retornam à situação jurídica anterior ao contrato, já que esta forma de dissolução opera efeitos retroativos. Neste sentido, as partes terão direito de pleitear a restituição do que entregaram no cumprimento de suas obrigações contratuais. Além disto, será devida indenização por perdas e danos nas hipóteses de inexecução voluntária (CC, art. 475). O valor da indenização pode ser previamente acordado entre as partes, por meio da estipulação de cláusula penal compensatória, que dispensa o prejudicado de promover a prova da extensão dos danos sofridos. Em regra, a pena

compensatória não poderá ser superior ao valor do contrato (CC, art. 412).

O outro modo de dissolução é a rescisão, motivada pela vontade das partes. Em geral, somente se dissolve o vínculo contratual mediante acordo bilateral. Admite-se a rescisão unilateral, chamada de denúncia, apenas se o prazo do contrato é indeterminado, o próprio instrumento contratual contiver cláusula autorizando-a ou se decorrer da essência do contrato, como no caso do mandato.

Na rescisão bilateral, as consequências serão as contratadas pelas partes, que têm ampla liberdade para dispor sobre como se dará a composição dos interesses. Já a rescisão unilateral, quando admitida, não opera efeitos retroativos. Às partes cabe apenas solucionar as eventuais pendências (por exemplo: o mandante deve pagar as comissões devidas ao mandatário), e, se previsto na cláusula de arrependimento, pagar a multa penitencial.

Costuma-se empregar o termo "rescisão" como equivalente a "dissolução" do contrato - embora alguma doutrina manifeste reservas em relação a isto, referindo-se à rescisão como uma forma específica de dissolução (a derivada de *lesão* - art. 157 do CC).

Capítulo 33. COMPRA E VENDA MERCANTIL

1. NATUREZA MERCANTIL DA COMPRA E VENDA

A compra e venda é mercantil quando comprador e vendedor são empresários. Trata-se do contrato elementar da atividade empresarial. Numa esquematização simples, o comércio pode ser explicado como a sucessão de contratos de compra e venda. O importador compra o produto do fabricante sediado no exterior e o revende ao atacadista, que o revende ao varejista e assim por diante.

Muitas vezes convém a dois empresários entabularem negociações de cunho geral, com o objetivo de agilizar e facilitar os negócios. O supermercado pode contratar com o atacadista de laticínios a aquisição destas mercadorias por um ano, fixando as condições básicas para o conjunto de contratos de compra e venda que celebrarão naquele período (por exemplo: quantidade, preço, locais de entrega). Neste caso, costuma-se chamar o negócio acertado entre os empresários de *contrato de fornecimento*. Note-se que não há, na relação interempresarial correspondente ao fornecimento, nada mais que uma série de contratos de compra e venda, cujas cláusulas foram negociadas em termos gerais, para facilitar a administração dos negócios de cada contratante. O contrato de fornecimento não configura modalidade de colaboração (Cap. 34).

A compra e venda mercantil é, na maioria das vezes, contrato sujeito às normas do Código Civil. Por ser contrato entre empresários, porém, sujeita-se a regime específico em caso de falência (item 4). Eventualmente, pode-se configurar, na relação contratual entre empresário-comprador e empresário-vendedor, uma compra e venda sujeita ao CDC. Será este o caso se o empresário-comprador for consumidor, na acepção legal do termo (*Cap. 8*, item 3), ou estiver em condição análoga a de consumidor.

2. FORMAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL

A compra e venda mercantil é contrato consensual, ou seja, para a sua constituição é suficiente o encontro de vontades do comprador e do vendedor. Basta que eles se entendam quanto a coisa e ao preço para que o vínculo contratual se aperfeiçoe.

No tocante à coisa, pode tratar-se de bem de qualquer espécie (imóvel, móvel ou semovente). Eles poderão ser corpóreos ou incorpóreos, repelindo-se apenas a venda dos considerados fora do comércio, ou seja, os insuscetíveis de apropriação e os legalmente inalienáveis. Além disto, a coisa pode ser própria ou alheia, sendo bastante usual no comércio a venda de bens que o vendedor ainda não adquiriu, mas deverá fazê-lo, em razão da atividade econômica por ele exercida.

Em relação ao preço, registre-se que este deverá ser pago em dinheiro. Caso contrário, cuidar-se-á de troca e não de compra e venda. Deverá ser previsto o pagamento em moeda nacional, em regra, posto que o direito brasileiro só admite o pagamento de compra e venda em moeda estrangeira quando se trata de importação ou exportação (Decreto Lei 857/69, art. 2º, I).

A regra geral para a fixação do preço é a da plena liberdade das partes, em perfeito ajuste com o princípio da liberdade de iniciativa estabelecido pela Constituição.

Observados, assim, tais limites jurídicos, os empresários celebram contrato de compra e venda mercantil quando entram em acordo relativamente à coisa e ao preço. A execução do contratado pode, no entanto, estar subordinada ao implemento de uma condição. É possível, por exemplo, condicionar se a venda à aprovação do comprador quanto à qualidade do bem. São as chamadas vendas a contento, usuais no ramo de bebidas ou vestuário. Outra possibilidade é a de se estipular a entrega da coisa vendida em determinado lugar e prazo, sob pena de resolução da avença. Ou, então, a previsão da cláusula de retrovenda, pela qual a vontade do vendedor de readquirir o bem, manifestada em certo prazo, opera como condição resolutiva da compra e venda.

Em relação à execução, a compra e venda pode ser imediata, diferida ou continuada. Na primeira hipótese, as partes devem cumprir as obrigações assumidas logo após a conclusão do contrato. Na segunda, comprador e vendedor estabelecem uma data futura para o cumprimento das respectivas obrigações, como na compra e venda a termo, muito comum nas Bolsas de valores ou de mercadorias. Na terceira, têm-se as chamadas vendas complexas, em que a execução do contratado se desdobra em diversos atos, como, por exemplo, no contrato de fornecimento ou de assinatura.

3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Celebrado o contrato de compra e venda mercantil, o comprador assume a obrigação de pagar o preço e o vendedor a de transferir o domínio, ou seja, proceder à entrega da coisa no prazo. Se o primeiro não cumpre a sua parte na avença, responde pelo valor devido, além das perdas e danos ou da pena compensatória e demais encargos assumidos. Já, se o vendedor não cumpre a obrigação de entregar a coisa, o comprador poderá optar entre o direito à indenização por perdas e danos ou o cumprimento do contrato (CC, art. 475).

Além de transferir o domínio da coisa vendida, o vendedor também se compromete a responder por vício redibitório (CC, art. 441) e por evicção (CC, art. 447). O primeiro se verifica quando o bem entregue não corresponde às especificações acordadas entre as partes, no sentido de se revelar impróprio ao uso a que se destina ou de reduzido valor. Por evicção se entende o dever de defender em juízo a venda perante terceiros reivindicantes da coisa objeto do contrato. Tal dever inexistente se o comprador tinha ciência da reivindicação e assumira o risco correspondente.

No que diz respeito a responsabilidade pelo transporte da mercadoria transacionada, cabe ao vendedor as despesas com a tradição (CC, art. 490). Como esta se opera no lugar em que se encontra o bem vendido, é, em princípio, do vendedor a obrigação de providenciar a entrega no estabelecimento empresarial do comprador, contratando os serviços de transporte por sua conta e risco.

Obviamente, as partes podem estabelecer disposição diversa, atribuindo ao comprador parte ou a totalidade das despesas e riscos inerentes ao transporte da mercadoria. Isto é, aliás, bastante comum. Para uniformizar esta distribuição de responsabilidades entre as partes, principalmente nas transações entre empresários estabelecidos em países diferentes, a Câmara de Comércio Internacional (CCI) convencionou algumas cláusulas padrões, os *Incoterms*. Estas cláusulas foram criadas em 1936 e já passaram por sucessivas revisões (1953, 1967, 1976, 1980, 1990 e 2000), sendo que a última delas data de 2010.

De acordo com os Incoterms 2010, a compra e venda está agrupada em 4 diferentes classes, segundo a distribuição entre as partes das despesas relativas a tradição. Têm-se, então, contratos de partida

(Grupo “E”), de transporte principal não pago (Grupo “F”), de transporte principal pago (Grupo “C”) e de chegada (Grupo “D”).

Em relação aos contratos de partida, estabelece se, pela cláusula EXW (Ex Works – local de retirada), que o comprador assume com exclusividade os custos e riscos relativos ao recolhimento das mercadorias do estabelecimento do vendedor, devendo pagar todas as despesas necessárias a tradição dos bens transacionados, inclusive o carregamento no veículo de transporte, o seguro e o desembaraço alfandegário.

Para os contratos de transporte principal não pago, são previstas 3 cláusulas: FCA (*Free Carrier* – local indicado), em que se convencionou caber ao vendedor o pagamento do desembaraço para a exportação e a entrega das mercadorias, no local designado, ao transportador contratado pelo comprador, o qual assume também todas as demais despesas; FAS (*Free Alongside Ship* – porto de embarque indicado), pelo qual se obriga o vendedor a transportar o bem transacionado até um determinado porto, cabendo ao comprador as despesas com o desembaraço para a exportação, embarque das mercadorias, seguros e outras necessárias; e FOB (*Free On Board* – porto de embarque indicado), em que as despesas com o transporte da mercadoria até um certo porto, com o embarque desta no navio e com o desembaraço para a exportação, correm por conta do vendedor, sendo as demais encargos do comprador.

Com referência aos contratos de transporte principal pago, os Incoterms 2010 estabelecem 4 cláusulas: CFR (*Cost and Freight* – porto de destino indicado), segundo o qual competem ao vendedor as despesas relativas a entrega das mercadorias no porto de destino convencionado, responsabilizando se pelo transporte, embarque e desembaraço para a exportação, mas transferindo ao comprador os riscos de perda ou dano, em razão de ocorrências havidas após o embarque da coisa vendida no navio atracado no porto de origem; CIF (*Cost, Insurance and Freight* – porto de destino indicado), por meio do qual o vendedor assume todas as despesas com o transporte até um determinado porto, incluindo seguro marítimo e desembaraço para a exportação; CPT (*Carriage Paid To...* – local de destino indicado), que reserva ao vendedor as despesas com o transporte das mercadorias até uma localidade designada, salvo as relativas à perda ou dano destas, que são transferidas ao comprador; CIP (*Carriage and Insurance Paid To...* – local de destino indicado), significando que o vendedor arca com as despesas de transporte das mercadorias até determinada localidade, inclusive as relacionadas com a perda ou dano durante o transporte.

Finalmente, os contratos de chegada comportam 3 cláusulas: DAT (*Delivered at Terminal* – indicação do terminal de destino), em que o vendedor se obriga por todas as despesas até o desembarque das mercadorias vendidas num terminal; DAP (*Delivered at Place* – indicação do lugar de destino), em que ele é obrigado pelas despesas até a mercadoria ficar disponível ao comprador, num determinado lugar, diferente de um terminal, cabendo a este último pagar o desembarque; e DDP (*Delivered Duty Paid* – local de destino indicado), segundo o qual o vendedor coloca as mercadorias disponíveis ao comprador no local designado, no país de importação, respondendo, em decorrência, pelas despesas de transporte, seguro e desembaraço para a importação.

4. ESPECIFICIDADE DA COMPRA E VENDA MERCANTIL

A especificidade da compra e venda mercantil está na disciplina das consequências para o vendedor da instauração da execução concursal do patrimônio do comprador. A execução concursal do devedor consiste na *falência* (se o comprador é empresário ou sociedade empresária) ou *insolvência* (quando não

é). Pois bem, a regra geral, aplicável à compra e venda civil, é a de que o vendedor pode exigir, na insolvência do comprador, uma caução antes de proceder à entrega da coisa vendida (CC, art. 495).

Na compra e venda mercantil, os direitos do vendedor, na falência do comprador, variam segundo o momento em que se encontrava a execução do contrato quando da quebra. Em alguns casos, o vendedor tem o direito a restituição da coisa; em outros, à notificação do administrador para que seja decidido se seu contrato será resolvido ou deverá ser cumprido. Mas, em nenhuma circunstância, pode o vendedor na compra e venda mercantil exigir do comprador falido (isto é, da massa falida) a prestação de caução do pagamento como condição para fazer a entrega da coisa vendida. O art. 495 do CC não se aplica a compra e venda mercantil, sujeitas às regras específicas da LF, e nisso reside sua especificidade.

A razão do tratamento específico da compra e venda mercantil, na hipótese de instauração do concurso de credores do comprador, é compreensível. No giro econômico, as mercadorias e insumos constituem um elemento de extrema importância para a sobrevivência das empresas. O legislador deve procurar compatibilizar, de um lado, os interesses gerais dos credores e os particulares do vendedor, de forma a que as coisas vendidas ao falido e não entregues possam ter a alocação mais apropriada para a economia. Daí a complexidade da disciplina da matéria quando a compra e venda é mercantil. Na civil, pode a lei cuidar da proteção exclusiva dos interesses do vendedor, caso instaurada a insolvência do comprador, porque a coisa objeto de contrato não circula como mercadoria ou insumo de nenhuma atividade empresarial.

Capítulo 34. CONTRATOS DE COLABORAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O comércio é atividade humana bastante antiga, cuja essência consiste em levar toda sorte de bens a quem se interesse em tê-los e se disponha a pagar por eles. Trata-se de uma atividade de intermediação entre o consumidor e o produtor, pela qual os bens fabricados ou colhidos da natureza por este são distribuídos ao mercado. Para desenvolver esta atividade, o comerciante geralmente adquire do produtor os bens para revendê-los a outro comerciante (atacado), ao próprio consumidor (varejo) ou a ambos (atacarejo).

O contrato de compra e venda mercantil, assim, constitui-se no meio contratual por excelência para a exploração da atividade comercial.

Não é, contudo, o único. Outras relações contratuais têm sido desenvolvidas pelo comércio com vistas ao fornecimento de bens ao mercado consumidor. São elas a comissão, a representação comercial, a concessão mercantil, a franquia e a distribuição. Proponho agrupá-los sob a denominação de "contratos de colaboração".

Os contratos de colaboração empresarial definem-se pela obrigação peculiar assumida por um dos contratantes ("colaborador") perante o outro ("fornecedor"): a de *criar ou ampliar o mercado dos produtos ou serviços fabricados ou comercializados pelo fornecedor*.

O colaborador, assim, obriga-se a fazer investimentos em divulgação, propaganda, manutenção de estoques, treinamento de pessoal e outros destinados a despertar em consumidores o hábito de adquirir os produtos ou serviços do fornecedor. Dependendo da espécie de colaboração contratada, os investimentos na criação ou consolidação do mercado são maiores ou menores; a obrigação de realizá-los, contudo, é inerente aos contratos de colaboração empresarial.

Quando não é contratada a obrigação de criar, consolidar ou desenvolver mercado para certo produto ou serviço, o contrato empresarial não se classifica como *de colaboração*. É, por exemplo, o caso do fornecimento de mercadorias. Como visto no capítulo anterior, ele é nada mais que uma série de contratos de compra e venda; o comprador não tem, perante o vendedor no contrato de fornecimento, a obrigação de criar mercado para a coisa comprada.

Os contratos de colaboração, em razão da obrigação essencial que os caracteriza, possuem a marca comum da *subordinação empresarial* estabelecida entre as partes. O comerciante contratado para distribuir, junto ao mercado consumidor, a mercadoria fabricada pelo outro contratante tem, perante este, o dever de atender a determinados padrões de exploração da atividade empresarial. Em outros termos, o colaborador deve organizar-se empresarialmente da forma definida pelo fornecedor seguindo as orientações e determinações partidas deste.

Atente-se para a natureza específica desta subordinação, que não tem caráter *pessoal*, mas sim *empresarial*. Esta distinção é muito importante, porque a subordinação pessoal caracteriza relação contratual significativamente diversa: a do vínculo empregatício, disciplinada pelo direito do trabalho. Já a subordinação empresarial está relacionada à organização da própria atividade econômica, ou seja, da

empresa.

Por vezes, o empresário tenta disfarçar uma relação de emprego com a aparência da representação comercial, por exemplo, para se furtar ao cumprimento dos encargos sociais. Esta tentativa é infrutífera se demonstrada a existência de subordinação pessoal. Ou seja, se o contratado possuir um negócio próprio, mesmo que a ingerência do contratante na sua organização seja grande, a subordinação será empresarial, cabendo ao direito comercial a disciplina dos seus efeitos obrigacionais. Caso contrário, tratar-se-á de mal disfarçada relação de emprego, sujeita às normas do direito do trabalho.

Por meio de um contrato de colaboração, o colaborador contratado (comissário, representante, concessionário, franqueado ou distribuidor) se obriga a colocar junto aos interessados as mercadorias comercializadas ou produzidas pelo fornecedor contratante (comitente, representado, concedente, franqueador ou distribuído), observando as orientações gerais ou específicas por este fixadas. A comissão pode também ser utilizada para a aquisição de bens pelo comitente, e não apenas para a colocação de produtos no mercado de consumo. A franquia, por outro lado, não diz respeito apenas ao comércio de mercadorias, mas pode se referir a prestação de serviços. De qualquer forma, atento a estas particularidades, proponho examinem-se os contratos aqui relacionados em conjunto no contexto do escoamento de mercadorias, ou seja, abstraindo a compra de bens pelo comitente e a prestação de serviços.

A colaboração empresarial pode ser de duas espécies: *por aproximação* ou *por intermediação*.

Na colaboração por aproximação, o colaborador não é intermediário, ou seja, não adquire o produto do fornecedor para revendê-lo. Apenas identifica quem possa estar interessado em fazê-lo. O comitente e o representante comercial são colaboradores por aproximação. São remunerados por um percentual dos negócios que ajudam a viabilizar, pago pelo fornecedor.

Já na colaboração por intermediação, o colaborador celebra com o fornecedor contrato de compra e venda; adquire os produtos para os revender. O concessionário e o franqueado são colaboradores por intermediação. Neste caso, não há remuneração por serviços; o colaborador ganha com o resultado positivo de sua atividade empresarial.

O contrato de distribuição pode classificar-se em uma ou outra categoria. Na distribuição-aproximação, o distribuidor não ocupa um elo próprio na cadeia de circulação de mercadorias; isto é, não compra produto do distribuído para o revender, mas encontra terceiros com interesse em comprá-lo. Já na distribuição-intermediação, o distribuidor ocupa um elo na cadeia de escoamento de mercadorias, comprando do distribuído o produto que irá revender a outro empresário ou ao consumidor (item 6).

2. COMISSÃO

Por comissão mercantil entende-se o vínculo contratual em que um empresário (comissário) se obriga a realizar negócios mercantis por conta de outro (comitente), *mas em nome próprio*, assumindo, portanto, perante terceiros responsabilidade pessoal pelos atos praticados.

O comissário concretiza transações comerciais do interesse do comitente, mas este não participa dos negócios, podendo até permanecer incógnito. Trata-se de contrato normalmente empregado em operações nas quais o comprador ou vendedor de mercadorias prefere não ser conhecido. Nem sempre convém ao empresário que se saiba do seu interesse em comprar ou vender certo bem. Há casos, por exemplo, em

que o preço da coisa pode crescer, e muito, quando o vendedor sabe ser o interessado um grande empresário. A comissão também facilita negociações de *commodities* pela agilidade que proporciona.

O contrato de comissão é próximo ao de mandato. Nos dois, uma pessoa (comissário ou mandatário) se obriga a praticar atos em nome de outra (comitente ou mandante). A diferença da comissão em relação ao mandato consiste na imputação da responsabilidade perante terceiros: o mandatário não responde, se agir nos limites dos poderes outorgados, porque pratica atos em nome do mandante; já o comissário será parte no contrato e responderá nos termos pactuados, porque realiza negócios em seu próprio nome. Salvo quanto a esta diferença, aplica-se à comissão a disciplina normativa do mandato (CC, art. 709).

Acentue-se que as negociações levadas a efeito pelo comissário atendem, na verdade, aos interesses do comitente, sendo, por esta razão, empreendidas por conta e risco deste. Assim, todos os riscos associados ao negócio cabem, em princípio, ao comitente. Verificada, por exemplo, a inadimplência do terceiro para quem a mercadoria foi vendida, as consequências decorrentes serão suportadas pelo comitente.

Tendo sido a comissão contratada com a cláusula *del credere*, pode o comissário responder, perante o comitente, pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo terceiro com quem contratou, solidariamente com este. Distribuem-se, assim, os riscos relacionados ao adimplemento das obrigações pelo terceiro. Mesmo na comissão *del credere*, correm por conta do comitente os demais riscos, como o de vício na coisa vendida ou evicção.

Perante o comitente, o comissário tem a obrigação de observar as instruções expendidas (CC, arts. 695 a 704), bem como zelar pelos bens a ele confiados, agindo com diligência e lealdade (art. 695) e prestar contas do movimento econômico do contrato (arts. 668 e 709). Perante o terceiro, o comissário tem todas as obrigações decorrentes do contrato que firmaram, porque não existe nenhuma relação jurídica entre aquele e o comitente.

O comissário tem direito a remuneração pelos serviços prestados, denominada "comissão". Esta varia de acordo com o valor e natureza do negócio praticado. Tem direito também de responsabilizar o comitente em regresso na hipótese de insolvência do terceiro contratante, salvo se a comissão contempla a cláusula *del credere* (que, conforme visto, lhe transfere este risco).

3. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

A representação comercial é o contrato pelo qual uma das partes (representante comercial autônomo) se obriga a obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas pela outra parte (representado). Sob o ponto de vista lógico ou econômico, poderia ser entendida como uma espécie de mandato, mas, juridicamente falando, este enfoque estaria equivocado. Isto porque a atividade desenvolvida pelo representante comercial possui uma disciplina jurídica própria que não a considera como uma modalidade específica de mandato.

A representação comercial é atividade autônoma. Ademais, o representante comercial não tem poderes para concluir a negociação em nome do representado. Cabe a este aprovar ou não os pedidos de compra obtidos e encaminhados pelo representante. O mandatário, ao contrário, titula poderes para negociar em nome do mandante, vinculando-o juridicamente perante terceiros.

Inexiste qualquer vínculo de emprego entre o representado e o representante comercial autônomo. A

subordinação deste àquele tem caráter exclusivamente empresarial, ou seja, cinge-se à organização do exercício da atividade econômica. O representante comercial autônomo é empresário, pessoa natural ou jurídica. Como tal, estrutura e dirige negócio próprio, ainda que exíguo e simples. Na organização de sua atividade negocial, o representante comercial sofre considerável ingerência do representado, mas que diz respeito apenas à forma de exploração do negócio, não à pessoa dele. Caso as relações não se verifiquem desta maneira, ou seja, se existir subordinação que extrapole o aspecto meramente negocial para alcançar a pessoa mesma do representante, então não haverá contrato empresarial, mas de trabalho.

O exercício da atividade de representação comercial autônoma está disciplinado pela Lei 4.886/65. O representante comercial autônomo deve registrar-se no órgão profissional, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Está sujeito à observância dos preceitos éticos e administrativos definidos para a sua profissão, bem como ao poder disciplinar correspondente. Se o representante comercial for pessoa jurídica (sociedade empresária), deve ser registrado também na Junta Comercial.

O contrato de representação comercial deve ser celebrado por escrito e observar os requisitos do art. 27 da Lei 4.886/65.

São obrigações do representante comercial autônomo: *a*) obter, com diligência, pedidos de compra e venda, em nome do representado, ajudando-o a expandir o seu negócio e promover os seus produtos (art. 28); *b*) observar, se prevista, a cota de produtividade, ou seja, a obtenção de um número mínimo de pedidos a cada mês; *c*) seguir as instruções fixadas pelo representado (art. 29); *d*) informar o representado sobre o andamento dos negócios, nas oportunidades definidas em contrato ou quando solicitado (art. 28), e prestar-lhe contas; *e*) observar as obrigações profissionais (art. 19); *f*) respeitar a cláusula de exclusividade de representação, se expressamente pactuada (arts. 31, parágrafo único, e 41).

São obrigações do representado: *a*) pagar a retribuição devida ao representante, assim que o comprador efetuar o seu pagamento ou, antes, se não manifestar recusa por escrito no prazo de 15, 30, 60 ou 120 dias, conforme a localização do seu domicílio (mesma praça, mesmo Estado, Estado diverso ou exterior, respectivamente - arts. 32 e 33); *b*) respeitar a cláusula de exclusividade de zona, que o proíbe de vender os seus produtos em determinada base territorial delimitada em contrato, a não ser por meio do representante contratado para atuar nesta área. Caso um negócio se concretize sem a observância dessa condição, o representante tem direito à comissão correspondente (art. 31). É obrigatória a identificação da zona no contrato de representação, sendo a exclusividade de zona legalmente considerada cláusula implícita nos contratos omissos (Lei 4.886/65, art. 27, *d*).

A lei estabelece as indenizações devidas pela resolução do contrato de representação comercial. Nos contratos com prazo indeterminado, firmados há mais de 6 meses, a parte que o denunciar está obrigada a conceder pré-aviso de 30 dias ou pagar a indenização correspondente a 1/3 das comissões referentes aos últimos 3 meses. Trata-se, aqui, de resolução sem culpa de qualquer das partes contratantes (art. 34).

O representado poderá promover a resolução do contrato quando o representante incorrer em determinadas práticas definidas em lei (desídia no cumprimento das obrigações contratuais, atos que importem em descrédito comercial do representado, condenação definitiva por crime infamante, por exemplo) ou havendo força maior (art. 35). Neste caso, nenhuma indenização será devida ao representante, e este ainda poderá ser responsabilizado, com base no direito civil (CC, art. 475), pelos danos que causou ao representado.

Por outro lado, o representante poderá resolver o contrato quando o representado a isto der causa,

incorrendo em certas práticas elencadas em lei (inobservância da cláusula de exclusividade, mora no pagamento da comissão, fixação abusiva de preços na zona do representante, por exemplo), ou quando se verificar a força maior (art. 36). Nesta hipótese, o representante terá direito a indenização prevista em contrato por prazo indeterminado, nunca inferior a um doze avos do total das retribuições auferidas, monetariamente atualizadas. Se o contrato tinha sido firmado com prazo determinado, a indenização será equivalente à multiplicação de metade do número de meses contratados pela média mensal das retribuições auferidas.

Também na hipótese de resolução do contrato por prazo indeterminado, feita unilateralmente pelo representado, nos termos do art. 34, tem-se considerado devida indenização em favor do representante.

Em qualquer hipótese, será também cabível, conforme entendem doutrina e jurisprudência, a indenização correspondente ao pré-aviso.

4. CONCESSÃO COMERCIAL

Este é o contrato em que um empresário (concessionário) se obriga a comercializar, com ou sem exclusividade, com ou sem cláusula de territorialidade, os produtos fabricados por outro empresário (concedente).

Por cláusula de exclusividade se entende a proibição de o concessionário comercializar com produtos diversos dos fabricados pelo concedente; e por cláusula de territorialidade, a proibição de o concedente comercializar, direta ou indiretamente, os seus produtos na área de atuação reservada a um concessionário.

A lei somente disciplina a concessão comercial referente ao comércio de veículos automotores terrestres, como os automóveis, caminhões, ônibus, tratores, motocicletas e similares (Lei 6.729/79 - *Lei Ferrari*). Quando tem por objeto o comércio de qualquer outra mercadoria, a concessão comercial é contrato atípico, ou seja, não sujeito a determinada disciplina legal.

No contrato de concessão comercial de veículos automotores, o concedente assume as seguintes obrigações: *a)* permitir gratuitamente o uso de suas marcas pelo concessionário (art. 3º, III); *b)* vender ao concessionário os veículos de sua fabricação, na quantidade prevista em cota fixada de acordo com a estimativa de produção do mercado interno e a capacidade empresarial, desempenho e potencial de vendas do concessionário (art. 7º); *c)* observar, na definição da área operacional de cada concessionária, distâncias mínimas segundo o critério de potencial de mercado (art. 5º, II); *d)* não vender diretamente os veículos de sua fabricação na área operacional de uma concessionária, salvo à Administração Pública direta ou indireta, ao Corpo Diplomático ou a clientes especiais (art. 15, II).

O concessionário, por sua vez, na concessão de veículos automotores se obriga a: *a)* respeitar a cláusula de exclusividade, se houver; vale dizer, não comercializar com nenhum outro veículo senão o fabricado pelo concedente; *b)* observar o índice de fidelidade para a aquisição de componentes que vier a ser estabelecido, de comum acordo com os demais concessionários e concedente, na Convenção de Marca (art. 8º, parágrafo único, I); *c)* comprar do concedente os veículos na quantidade prevista na cota respectiva, sendo-lhe facultado limitar o estoque (art. 10, § 1º); *d)* organizar-se empresarialmente de forma a atender os padrões determinados pelo concedente, para a comercialização dos veículos e para a assistência técnica aos consumidores (art. 20).

Em relação aos acessórios, poderá o concessionário comercializar livremente os produtos que considerar interessantes, já que a lei cogita apenas de índice de fidelidade para os componentes. Os preços dos veículos ao consumidor são fixados pelo concessionário e não pelo concedente (art. 13).

5. FRANQUIA

A franquia é o contrato pelo qual um empresário (franqueador - *franchisor*) licencia o uso de sua marca a outro (franqueado - *franchisee*) e presta-lhe serviços de organização empresarial, com ou sem venda de produtos. Por meio deste tipo de contrato, uma pessoa com algum capital pode estabelecer-se comercialmente sem precisar proceder ao estudo e equacionamento de muitos dos aspectos do empreendimento, basicamente os relacionados com a estruturação administrativa, treinamento de funcionários e técnicas de *marketing*. Isto porque tais aspectos encontram-se já suficiente e devidamente equacionados por outro empresário, titular de marca de certo prestígio, e que fornece ao interessado em se estabelecer os subsídios indispensáveis à estruturação do negócio.

A franquia consiste, pois, na conjugação de dois contratos: licenciamento de uso de marca e prestação de serviços de organização empresarial.

Normalmente, o franqueado dispõe de recursos e deseja constituir uma empresa comercial ou de prestação de serviços. Contudo, não tem os conhecimentos técnicos e de administração e economia geralmente necessários ao sucesso do empreendimento. Do outro lado, há o franqueador, titular de marca já conhecida dos consumidores, que deseja ampliar a oferta do seu produto ou serviço, mas sem as despesas e riscos inerentes a implantação de filiais.

Pela franquia, o franqueado adquire do franqueador os serviços de organização empresarial e mantém, com os seus recursos, mas com estrita observância das diretrizes da franquia, um estabelecimento que comercia os produtos ou presta os serviços da marca do franqueador. Ambas as partes têm vantagens, porque o franqueado se estabelece negociando produtos ou serviços já trabalhados junto ao público consumidor, por meio de técnicas de *marketing* testadas e aperfeiçoadas pelo franqueador; e este, por sua vez, pode ampliar a oferta da sua mercadoria ou serviço, sem novos aportes de capital.

Os serviços de organização empresarial que o franqueador presta ao franqueado são geralmente os decorrentes de três contratos, que podem ser tratados autonomamente: *a)* contrato de *engineering*, pelo qual o franqueador define, projeta ou executa o *layout* do estabelecimento do franqueado; *b)* o *management*, relativo ao treinamento dos funcionários do franqueado e a estruturação da administração do negócio; *c)* o *marketing*, pertinente as técnicas de colocação dos produtos ou serviços junto aos consumidores, envolvendo estudos de mercado, publicidade, vendas promocionais, lançamento de novos produtos ou serviços etc.

A franquia é contrato atípico. No entanto, costuma-se atribuir aos franqueados as seguintes obrigações: *a)* pagamento ao franqueador de taxa de adesão à franquia e de percentual do faturamento; *b)* pagamento pelos serviços de organização empresarial prestados pelo franqueador; *c)* proibição de oferecer aos consumidores os produtos ou serviços diferentes dos da marca do franqueador, por ele fabricados, aprovados ou simplesmente indicados; *d)* observar estritamente as instruções e o preço de venda ao consumidor estabelecidos pelo franqueador.

A seu turno, o franqueador tem normalmente as seguintes obrigações: *a)* permitir ao franqueado o uso de sua marca; *b)* prestar os serviços de organização empresarial.

A Lei 8.955/94, embora discipline determinados aspectos da franquia, não a tornou um contrato típico. Ao contrário, as relações entre franqueador e franqueado continuam regendo-se exclusivamente pelas cláusulas contratadas. O que o legislador estabeleceu com essa lei foi a regra de absoluta transparência nas negociações que antecedem a adesão do franqueado à franquia. Para tanto, o franqueador deve fornecer aos interessados uma Circular de Oferta de Franquia (COF) que, em linguagem clara e acessível, preste as informações essenciais da operação (art. 3º). Sob pena de anulabilidade do contrato, a COF deve ser entregue aos interessados com a antecedência mínima de dez dias e não pode conter informações falsas (arts. 4º e 7º).

6. DISTRIBUIÇÃO

A criação, consolidação ou ampliação de mercados, por meio da colaboração empresarial, pode resultar de atos do colaborador de *aproximação* ou de *intermediação*. No primeiro caso, o colaborador identifica pessoas interessadas em adquirir (e, no caso da comissão, também vender) produtos do outro empresário contratante; no segundo, ele mesmo adquire os produtos (e, no caso da franquia, também serviços) do outro contratante e os revende no mercado.

O contrato de distribuição é modalidade de colaboração empresarial que pode se enquadrar em qualquer uma dessas espécies.

6.1. Distribuição-aproximação

A distribuição-aproximação é contrato em que um dos empresários (distribuidor) se obriga a promover, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a realização de certos negócios por conta de outro empresário (proponente), em zona determinada e tendo em sua posse as mercadorias a serem vendidas. Se faltar à distribuição-aproximação o último requisito, isto é, se o distribuidor não tiver em mãos as mercadorias que promove, o contrato é denominado "agência" (CC, art. 710).

A distribuição-aproximação e a agência são contratos *típicos*, regidos no Código Civil e sujeitos às mesmas regras. O instrumento deve identificar uma base territorial correspondente ao *mercado* em que as partes manterão a colaboração ("zona de atuação"). São cláusulas implícitas nestes contratos a de *exclusividade de distribuição* ou simplesmente *exclusividade* (pela qual o distribuidor ou agente não podem trabalhar para outros proponentes na zona de atuação) e a de *exclusividade de zona* ou *territorialidade* (em que o proponente deve abster-se de realizar negócios na zona de atuação, a não ser com os aproximados pelo distribuidor ou agente). A lei assegura ao distribuidor ou agente o direito à remuneração pelos negócios realizados em desrespeito à cláusula de territorialidade (CC, art. 714).

Na distribuição-aproximação, o distribuidor ou agente são remunerados por um percentual dos negócios que ajudam a realizar (a "comissão"). A obrigação principal do proponente é a de pagar a comissão, podendo o contrato condicioná-la ao efetivo pagamento do preço pelo terceiro adquirente das mercadorias. A seu turno, a obrigação principal que distribuidor ou agente assumem é a de encontrar interessados em adquirir os produtos do proponente e, encontrando-os, receber deles pedido de compra. O proponente não está obrigado a aceitar todos os pedidos de compra encaminhados pelo distribuidor ou agente, mas também não pode recusá-los todos imotivadamente, cessando o ritmo da colaboração. Se o

fizer, o proponente deve indenizar o distribuidor ou agente (CC, art. 715).

Os contratos de distribuição-aproximação e os de agência podem ser celebrados com ou sem prazo. Na primeira hipótese, transcorrido o período contratado, cessam as obrigações de parte a parte; na segunda, o vínculo contratual se desfaz depois de 90 dias da notificação que qualquer um dos empresários promover ("aviso prévio"). Na resolução dos contratos por prazo indeterminado, se o distribuidor ou agente não haviam ainda recuperado os investimentos com algum resultado líquido, tendo em vista o prazo em que razoavelmente poderiam tê-lo feito, o proponente está obrigado a indenizá-los (CC, art. 720 e parágrafo único).

6.2. Distribuição-intermediação

A distribuição-intermediação é contrato atípico, não disciplinado na lei. É o celebrado entre distribuidoras de combustível e os postos de abastecimento de suas bandeiras, entre fábrica de cerveja e os atacadistas zonais etc.

Caracteriza-se, independentemente da denominação dada pelo instrumento contratual, pela obrigação que um empresário (distribuidor) assume, perante o outro (distribuído), de criar, consolidar ou ampliar o mercado dos produtos deste último, *comprando-os para revender*. Quando presente esta última característica no contrato de colaboração, não se aplicam as normas do Código Civil sobre agência ou distribuição-aproximação acima indicadas, porque nem sempre são estas inteiramente compatíveis com sua estrutura e função econômica.

Na distribuição atípica (por intermediação), distribuidor e distribuído têm apenas os direitos e obrigações que negociaram. Como é contrato atípico, as relações entre os seus contratantes regem-se apenas pelo contido no respectivo instrumento contratual. A exclusividade, territorialidade, hipóteses de resolução, direito à indenização, prazo e os demais elementos da colaboração podem ser livremente negociados entre distribuidor e distribuído. Não há balizamentos legais nem consequências legalmente previstas para o caso de resolução.

Omisso o instrumento contratual da distribuição-intermediação, o conflito de interesses entre os empresários contratantes *pode* ser eventualmente resolvido por aplicação analógica das regras sobre o contrato de concessão comercial, que é, dentre os de colaboração, o mais próximo.

Capítulo 35. CONTRATOS BANCÁRIOS

1. ATIVIDADE BANCÁRIA

Por atividade bancária entende-se, juridicamente falando, "a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira". Esse conceito é extraído da definição legal de instituições financeiras (LRB, art. 17). Abarca uma gama considerável de operações econômicas, ligadas direta ou indiretamente à concessão, circulação ou administração do crédito.

Estabelecendo-se um paralelo com a atividade industrial, pode-se dizer que a matéria-prima do banco e o produto por ele oferecido ao mercado é o crédito. Como todo conceito jurídico, porém, o de atividade bancária suscita algumas dificuldades em sua aplicação, o que tem gerado dúvidas quanto à natureza bancária de certos contratos.

Para se exercer atividade bancária, é necessária autorização governamental. O órgão competente para expedir-la é o Banco Central do Brasil, autarquia da União integrante do Sistema Financeiro Nacional, a quem a lei atribuiu, entre outras, as funções de emitir a moeda, executar os serviços do meio circulante, controlar o capital estrangeiro e realizar as operações de redesconto e empréstimo a instituições financeiras. Para funcionamento no Brasil de instituições financeiras estrangeiras, a autorização é dada por decreto do Presidente da República.

A lei estabelece pena de reclusão de um a quatro anos para o exercício de atividade bancária sem autorização do Banco Central ou, se for o caso, da Presidência da República (Lei 7.492/86, art. 16).

As instituições financeiras adotam sempre a forma de sociedade anônima. Sua administração, no entanto, submete-se a regras específicas e é controlada pelo Banco Central. Esse controle compreende, entre outros mecanismos, a aprovação do nome dos administradores eleitos pelos órgãos societários, a fiscalização das operações realizadas, a autorização para a alienação do controle acionário ou para a transformação, fusão, cisão ou incorporação, bem como a decretação do RAET, intervenção ou liquidação extrajudicial.

Para um contrato ser bancário, o primeiro requisito é ser uma das partes necessariamente um banco. O outro requisito é a inserção da função econômica do contrato no contexto do exercício da atividade bancária. Assim, se o contrato tem a função de "coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros", então somente uma instituição financeira devidamente autorizada pelo governo poderá contratá-lo. E, neste caso, o contrato é definido como bancário.

Claro está que não basta a presença do banco em um dos polos da relação contratual para que o contrato seja bancário. Uma instituição financeira se envolve em muitos negócios jurídicos, tais como a locação, a compra e venda de imóveis, a aquisição de programa de computador etc.. Estes diversos contratos não se tornam "bancários" somente em razão da participação do banco como contratante. Será bancário se cumprir função econômica inserida na atividade bancária, hipótese em que é indispensável a presença do banco na relação contratual.

São bancários aqueles contratos que somente podem ser feitos com um banco, ou seja, aqueles que

configurariam infração à lei caso fossem celebrados com pessoa física ou jurídica não autorizada a funcionar como instituição financeira.

As operações bancárias são costumeiramente divididas pela doutrina em *típicas* e *atípicas*. São típicas as relacionadas com o crédito e atípicas as prestações de serviços acessórios aos clientes, como a locação de cofres ou a custódia de valores.

As operações típicas, por sua vez, subdividem-se em *passivas* (em que o banco assume a posição de devedor da obrigação principal) e *ativas* (em que o banco assume a posição de credor da obrigação principal). Geralmente, entre uma instituição financeira e cada um de seus clientes, estabelecem-se várias relações jurídicas. Se uma pessoa "abre conta" num banco, celebra contrato de depósito bancário; se obtém cheque especial, firma contrato de abertura de crédito; ao autorizar débitos automáticos (impostos, taxas, duplicatas), outorga mandato ao banco, etc.

Dessa complexa gama de relações nascem contratos com características próprias, que reclamam configuração jurídica específica. O depósito bancário, por exemplo, tem tantas peculiaridades que, rigorosamente falando, não pode ser considerado espécie de depósito. Daí a importância do estudo em separado dos contratos bancários.

Algumas operações creditícias oferecidas pelas instituições financeiras ao mercado de consumo estão sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (arts. 3.º, § 2.º, e 52). Se o trabalhador tem o salário depositado em conta-corrente junto a certo banco, ele é consumidor de serviços prestados por este banco ao mercado de consumo. Está, portanto, sob a tutela do CDC. Contudo, o contrato bancário feito com empresário, no contexto da exploração de uma atividade empresarial, presume-se que o contratante não é vulnerável como os consumidores. Aliás, se o empresário apenas intermedeia o crédito, a sua relação com o banco não se caracteriza juridicamente como consumo. Neste caso, o CDC não incide e o direito comercial rege o contrato.

Em todas as suas operações, a instituição financeira manterá sigilo das informações relacionadas às operações ativas e passivas ou serviços prestados (LC 105/01, art. 1.º). É a regra do sigilo bancário, que visa proteger o direito à intimidade dos que contratam com bancos. Prevê a lei exceções à regra do sigilo bancário, em que prevalecem interesses superiores aos ligados à proteção da intimidade: *a*) investigação de crime, em qualquer fase do inquérito ou processo judicial (art. 1.º, § 4.º); *b*) ordem do Poder Judiciário, que deve zelar pela conservação do caráter sigiloso do dado informado (art. 3.º); *c*) ordem do Poder Legislativo, no exercício de sua competência constitucional e legal de fiscalização da Administração Pública (art. 4.º); *d*) requisição da autoridade fiscal, após iniciado o regular procedimento tributário (arts. 5.º e 6.º); *e*) requisição do Banco Central ou CVM (arts. 2.º e 7.º); *f*) requisição do CADE, na investigação de infração contra a ordem econômica (LIOE, arts. 9.º, XVIII, e 13, VI, *a*). Salvo nessas seis hipóteses, a divulgação pela instituição financeira, ou por terceiros, de informações relativas às operações bancárias constitui crime de quebra de sigilo, punido com reclusão de 1 a 4 anos (LC 105/01, art. 10).

2. OPERAÇÕES PASSIVAS

Nos contratos bancários compreendidos na categoria das operações passivas, a instituição financeira assume o polo passivo da relação negocial; isto é, ela se torna devedora, levando-se em conta a principal obrigação contratada.

Os contratos ligados às operações passivas têm a função econômica de captação dos recursos de que necessita o banco para o desenvolvimento de sua atividade. Os principais contratos dessa natureza são o depósito bancário, a conta-corrente bancária e a aplicação financeira.

O depósito bancário é contrato pelo qual uma pessoa (depositante) entrega valores monetários a um banco, que se obriga a restituí-los quando solicitados. É o mais corriqueiro dos contratos bancários. A entrega e restituição dos recursos monetários são registradas em conta-corrente e o cheque é um dos instrumentos de solicitação de restituição dos recursos depositados.

O depósito bancário é contrato autônomo. Guarda inequivocamente proximidade com o depósito irregular e com o mútuo, mas não pode ser entendido como espécie deste ou daquele. O depósito irregular tem por objeto coisa fungível, e o depositário se obriga a restituir bem do mesmo gênero, quantidade e qualidade do depositado. Estes elementos podem ser identificados na relação entre o depositante de recursos monetários e o banco, mas a instituição financeira, a partir do contrato de depósito bancário, passa a titularizar a *propriedade* dos valores depositados e não a simples guarda, como ocorre em relação ao depositário no depósito irregular. A relação entre o cliente e o banco, nesse contrato, é de verdadeira fidúcia.

Por outro lado, há no depósito bancário elementos do contrato de mútuo, que é o empréstimo de coisa fungível. O depositante encontra-se perante o banco em situação similar ao do mutuante em face do mutuário. Mas trata-se apenas de similitude, por não ser da essência do depósito bancário a remuneração pela permanência dos recursos em mãos do banco e, outrossim, o depositante pode unilateralmente resgatar o bem objeto do contrato. Tais características afastam o depósito bancário do mútuo.

Há três modalidades de depósito: *a) à vista*, em que o banco obriga-se a restituir ao depositante (ou a terceiro por ordem do depositante), total ou parcialmente, os recursos depositados imediatamente após a ordem recebida; *b) a pré-aviso*, em que, ordenada pelo depositante a restituição, total ou parcial, dos recursos depositados, deve o banco providenciá-la em determinado prazo contratado entre as partes; *c) a prazo fixo*, em que o depositante não pode solicitar a restituição dos recursos antes de determinada data.

Os depósitos bancários desta última categoria (a prazo fixo) são geralmente remunerados. As Cadernetas de Poupança são produtos oferecidos pelos bancos que, sob o ponto de vista contratual, representam depósito bancário a prazo fixo. A definição do prazo mínimo para resgate pode ser condição da remuneração, como nas Cadernetas de Poupança, ou do próprio negócio. Assim, no primeiro caso, o depositante que pretender a restituição dos recursos antes do prazo perde a remuneração; no segundo, o depositante sequer pode solicitá-la antes do prazo fixado.

O depósito bancário é contrato real, isto é, somente se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro pelo depositante ao banco. Normalmente celebrado por prazo indeterminado, extingue-se por resilição unilateral de qualquer das partes. Também a compensação é causa extintiva do contrato, podendo o banco debitar da conta do depositante o valor de créditos líquidos de que seja titular. Por fim, extingue o contrato a falta de movimentação pelo prazo de 30 anos (Lei 370/37), hipótese em que o banco deve recolher ao Tesouro Nacional os recursos existentes na conta do depositante.

Outro contrato da categoria das operações passivas é a conta-corrente. Trata-se de contrato diferente do depósito bancário, embora vulgarmente se tome um pelo outro. A conta-corrente é o contrato pelo qual o banco se obriga a receber valores monetários entregues pelo correntista ou por terceiros e proceder a pagamentos por ordem do mesmo correntista, utilizando-se desses recursos. Guarda semelhança com o

depósito bancário, porque o banco tem a obrigação de restituir os recursos mantidos em conta-corrente ao correntista imediatamente após a ordem deste. Mas é contrato de função econômica mais ampla, porque, por meio dele, o banco presta serviço de administração de caixa para o correntista. Essa particularidade, ademais, o distancia também do contrato de conta-corrente não-bancário.

É contrato consensual; ou seja, aperfeiçoa-se mesmo antes de o correntista entregar qualquer dinheiro ao banco, ficando a conta a ser dotada, por exemplo, por recursos entregues ao banco por devedores do correntista, em pagamento a crédito deste.

A aplicação financeira, por sua vez, é o contrato pelo qual o depositante autoriza o banco a empregar em determinados investimentos (ações, títulos da dívida pública e outros) o dinheiro mantido em conta de depósito. O depositante terá direito à remuneração do valor investido, conforme o sucesso obtido pelo banco na utilização dos recursos, observadas as normas estabelecidas pelas autoridades monetárias. São normalmente associados aos fundos de investimentos. Na hipótese, não há que se falar em mandato ou corretagem, porque o cliente não pode fixar orientação ao banco quanto à melhor forma de empregar os seus recursos. Tal emprego será feito de acordo com os critérios que o próprio banco adotar, observado o regulamento do fundo. Cuida-se, assim, de contrato autônomo.

3. OPERAÇÕES ATIVAS

Os contratos bancários relacionados com operações ativas são aqueles em que o banco assume a posição de credor da obrigação principal. Comumente, em qualquer relação contratual, as partes têm obrigações ativas (a receber) e passivas (a prestar). Somente é possível, portanto, adotar-se o critério de classificação aqui referido considerando-se a posição ativa ou passiva do banco no tocante à obrigação principal. Dessa forma, por exemplo, na abertura de crédito, o banco é essencialmente o credor, mas isso não significa que não tenha nenhuma obrigação perante o cliente. Ao contrário, na abertura de crédito, cabe ao banco pôr à disposição do cliente os recursos contratados.

Pelos contratos ligados à categoria das operações ativas, os bancos concedem crédito a uns clientes, valendo-se dos recursos que, por meio de contratos da categoria das operações passivas, captou junto a outros clientes. Essa intermediação do crédito configura a essência da atividade bancária. Os principais contratos bancários de operações ativas são: mútuo bancário, desconto, abertura de crédito e crédito documentário.

3.1. Mútuo bancário

O mútuo bancário é o contrato pelo qual o banco empresta ao cliente certa quantia de dinheiro. A matriz dessa figura contratual evidentemente é o mútuo civil, definido como empréstimo de coisa fungível (CC, art. 586). O mútuo ganha contornos próprios quando o mutuante é instituição financeira. Em especial, no que diz respeito à taxa de juros.

O mútuo bancário é contrato real, e somente se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro objeto do empréstimo, pelo banco mutuante ao cliente mutuário. Antes disso, inexistente contrato e, conseqüentemente, nenhuma obrigação se pode imputar ao banco, se ele, mesmo após concluídas as tratativas com o cliente, não lhe entregar o dinheiro.

O mutuário, após receber o dinheiro mutuado, tem as seguintes obrigações: a) pagar o valor emprestado; b) pagar a correção monetária, se prevista; c) pagar juros, encargos, comissões e demais

taxas constantes do instrumento de contrato; d) amortizar (pagar antecipadamente) o valor emprestado nos prazos estabelecidos contratualmente.

O banco mutuante, por sua vez, não assume nenhuma obrigação perante o mutuário. Trata-se, portanto, de contrato unilateral, em que somente uma das partes (o mutuário) é obrigada.

Não vigora para o mútuo bancário a limitação nas taxas de juros prescrita pelo Código Civil (arts. 406 e 591; Decreto 22.626/33). Tem entendido a jurisprudência que o art. 4.º da LRB, ao atribuir competência ao Conselho Monetário Nacional para disciplinar as taxas de juros a serem praticadas pelas instituições financeiras, excluiu os contratos bancários da limitação legal imposta aos juros dos mútuos civis.

Quanto à forma, o mútuo bancário somente exige instrumento público se houver garantia real hipotecária (ressalvada a hipótese de emissão de cédula de crédito, com oneração de bem imóvel, quando é dispensada a escritura pública).

Questão interessante relativa ao contrato de mútuo está relacionada com a impossibilidade de o mutuário obrigar o mutuante a receber a devolução do valor emprestado *antes* do prazo contratado, com vistas a obter a redução proporcional do valor dos juros. Não existe esta possibilidade porque a expectativa do mutuante é a de fazer emprego remunerado de seu capital; expectativa que seria frustrada, ao menos em parte, pelo pagamento antecipado. O direito protege o interesse do mutuante e fixa a regra de que a devolução do valor emprestado antes do prazo contratualmente estabelecido somente pode ocorrer com a sua concordância. Essa regra tem apenas uma exceção, prevista no CDC, segundo a qual, no mútuo em que o mutuário é juridicamente consumidor, ele tem direito ao pagamento antecipado do devido com redução proporcional de juros e demais acréscimos (art. 52, § 2.º).

Por fim, defino "financiamento" como sendo o mútuo bancário em que o mutuário assume a obrigação de conferir determinada finalidade ao dinheiro emprestado, como, por exemplo, investir no desenvolvimento de uma atividade econômica ou adquirir a casa própria.

No financiamento, o banco tem direito de proceder a vistorias confirmatórias ou, mesmo, entregar o dinheiro emprestado diretamente a terceiros (a incorporadora do imóvel adquirido com financiamento, p. ex.). Uma das razões disso se encontra no fato de que, por vezes, há crédito bancário subsidiado por programas governamentais para o fomento de determinadas atividades econômicas ou destinado ao equacionamento da questão habitacional. Neste caso, com o objetivo de se evitarem desvios ou distorções, a instituição financeira tem não só a prerrogativa, mas até o dever de se assegurar quanto ao adequado emprego dos recursos financiados.

Há na doutrina quem conceitue diferentemente o financiamento, tomando-o pelo contrato em que o banco adianta ao cliente os recursos necessários a determinado empreendimento, para reavê-los junto a devedores do financiado.

3.2. Desconto bancário

O desconto bancário é o contrato em que o banco (descontador) antecipa ao cliente (descontário) o valor de crédito deste contra terceiro, mesmo não vencido, recebendo-o em cessão.

O banco, ao pagar pelo crédito descontado, deduz do seu valor a importância relativa a despesas e

juros correspondentes ao lapso temporal entre a data da antecipação e a do vencimento. O seu ganho nesse negócio decorre exatamente dessa dedução, sem a qual a operação não seria atraente à instituição financeira.

Na análise da natureza jurídica desse contrato, dividem-se os doutrinadores. Há quem considere a transferência do crédito como verdadeiro pagamento *pro solvendo* de contrato de mútuo celebrado entre o banco e o cliente. Outra parte da doutrina configura o desconto como contrato misto, conjugação do mútuo bancário e dação de crédito. E há também os que veem na hipótese um verdadeiro contrato autônomo.

O desconto pode ter por objeto a antecipação de crédito constante de qualquer instrumento jurídico. Normalmente, contudo, os bancos descontam apenas os chamados *títulos bancáveis*, ou seja, os títulos de crédito em geral. Isto é fácil de se entender. Pelas regras aplicáveis aos títulos de crédito, os "adquirentes" destes instrumentos estão preservados diante de eventuais exceções oponíveis pelos devedores ao credor originário; garantia que não existe na cessão civil de crédito.

Dessa forma, os títulos de créditos favorecem a circulação do crédito por eles documentados. Uma instituição financeira, ao descontar uma cambial, está tutelada em seus interesses pelos princípios do direito cambiário (cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações). Assim, ela se dispõe mais facilmente a descontar um título de crédito do que um crédito documentado em instrumento de outra natureza.

Nesse contexto, o descontário transfere ao banco o seu crédito e recebe deste uma importância correspondente ao respectivo valor, mas deduzido de despesas, juros, comissões e outras parcelas contratadas. Quando se trata de título de crédito, a transferência se faz mediante endosso. Normalmente, o banco-descontador (endossatário) não aceita a inserção, no endosso, da cláusula "sem garantia", porque quer resguardar o seu direito de crédito contra o cliente-descontário (endossante).

É importante acentuar que, embora o endosso seja indispensável à perfeição do desconto de título de crédito, há outros negócios jurídicos entre banco e cliente decorrentes também do endosso de títulos. Quer dizer, o banco pode receber título endossado por seu cliente sem a configuração do desconto bancário.

São pelo menos três situações em que o banco recebe, por endosso, títulos de crédito de seus clientes: a) o cliente contrata o serviço de cobrança prestado pela instituição financeira, praticando endosso-mandato, mediante o qual a investe na qualidade de mandatária para o recebimento do crédito devido por terceiro; b) o cliente contrai mútuo bancário e oferece em penhor os créditos por ele titularizados, praticando o endosso-caução, que investe o banco na qualidade de credor pignoratício; c) o cliente transfere o seu crédito ao banco, que passa a titularizá-lo em virtude do endosso. Nas duas primeiras, o endosso é *impróprio*, enquanto na última, é *próprio*. Somente no caso de endosso próprio, pode haver desconto bancário.

Trata-se de contrato real, que se aperfeiçoa com a transferência do crédito ao descontador. A partir de então, fica o banco com a obrigação de antecipar o valor contratado.

Se o crédito transferido for pago no vencimento, pelo terceiro devedor, extingue-se a relação contratual entre descontário e descontador. Caso contrário, o banco poderá optar por uma das seguintes alternativas: a) cobrança judicial do devedor do título descontado, fundamentando-se na titularidade do

crédito; b) cobrança judicial do endossante (descontário), com fundamento no direito cambiário, sendo nesta hipótese indispensável o protesto do título dentro do prazo legal para a conservação do direito creditício; c) cobrança judicial do descontário, com fundamento no contrato de desconto, caso em que o protesto do título descontado é facultativo.

Essa terceira alternativa somente é cabível em razão de se configurar o desconto bancário um contrato autônomo. Qualquer entendimento diverso no tocante à sua natureza implicaria o reconhecimento ao banco apenas dos direitos decorrentes do endosso ou da cessão. Em outros termos, se fosse negado ao desconto bancário o caráter de negócio jurídico autônomo, a instituição financeira deveria ser tratada simplesmente como uma endossatária (se o objeto do desconto é título de crédito) ou cessionária (se o objeto é diverso, como, p. ex., um contrato administrativo). Como endossatária, ela perderia o direito creditício contra o endossante se não providenciasse o protesto em tempo hábil (salvo a inserção no endosso da cláusula "sem despesas"), e como cessionária nem sequer teria, em regra, direito de regresso contra o cedente (*Cap. 18*, item 3). Exatamente porque se trata de contrato autônomo, o banco pode cobrar do descontário o crédito não pago pelo terceiro devedor, fundando-se apenas nos direitos emergentes da relação contratual nascida com o desconto.

Por vezes, o banco descontador desconta, ele próprio, junto a outra instituição financeira o crédito que descontou. Essa operação denomina-se *redesconto*. Apenas o Banco Central pode receber créditos dos bancos mediante redesconto (LRB, art. 10, X).

3.3. Abertura de crédito

Pelo contrato de abertura de crédito, o banco põe certa quantia de dinheiro à disposição do cliente, que pode ou não se utilizar desses recursos. Em geral, contrata-se que o cliente somente irá pagar juros e encargos se e quando lançar mão do crédito aberto. Associada a contrato de depósito, costuma-se designar a abertura de crédito pelo nome de "cheque especial".

Cuida-se de contrato consensual e bilateral, em que a marca distintiva é a disponibilização de recursos financeiros. Comumente, os bancos não cobram comissão apenas pela disponibilização do dinheiro ao cliente, mas poderiam fazê-lo se entendessem conveniente sob o ponto de vista negocial. Os juros, correção monetária e encargos, por sua vez, são devidos em regra a partir da efetiva utilização do crédito aberto.

Há duas modalidades de contrato de abertura de crédito: a) a abertura simples, em que o cliente, uma vez utilizado o crédito, não tem a faculdade de reduzir o montante do devido antes de determinado prazo; b) a abertura em conta-corrente, bem mais usual, em que o cliente pode, mediante entradas, reduzir o débito perante a instituição financeira.

3.4. Crédito documentário

Esse contrato, de larga utilização no comércio internacional, define-se pela obrigação assumida por um banco (emissor), perante o seu cliente (ordenante), de proceder a pagamentos em favor de terceiro (beneficiário), contra a apresentação de documentos. Estes documentos estão relacionados a negócio realizado entre o ordenante (como devedor) e o beneficiário (como credor).

Com o crédito documentário, assim, o importador pode contratar uma instituição financeira para que ela realize pagamento em favor do exportador, à vista dos documentos representativos das mercadorias.

A função econômica do crédito documentário é de suma importância.

Ele implica, para o comprador (no exemplo, o importador), o financiamento da operação, porque normalmente restituirá ao banco em prestações o valor recebido à vista pelo beneficiário. E configura, para o vendedor (o exportador), uma garantia de pagamento, em virtude da solvência da instituição financeira.

O crédito documentário é contrato autônomo, resultante da conjugação de diversos outros contratos. O banco emissor age como mandatário do ordenador, mas entre ambos também há abertura de crédito. Entre ordenante e beneficiário, estabelecem-se relações jurídicas outras, como a compra e venda.

No crédito documentário conhecido por *revolving credit*, nota-se também a presença do contrato de conta-corrente, pois o valor do crédito disponibilizado ao beneficiário, pelo banco emissor, varia de acordo com as entradas feitas pelo ordenante.

Firmado o contrato com o ordenante, cabe ao banco confirmar a disponibilização do crédito junto ao beneficiário, mediante a emissão da "carta de crédito". Após expedir as mercadorias vendidas, o beneficiário, munido da *carta* e dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações assumidas perante o ordenante (por exemplo: o documento de embarque das mercadorias em determinado navio), solicita ao banco emissor o pagamento. Por vezes, uma segunda instituição financeira (chamada "banco correspondente") interfere no negócio, intermediando as relações entre o banco emissor e o beneficiário do crédito documentário.

Importante registrar que a instituição financeira concedente do crédito documentário não assume nenhuma responsabilidade em virtude da relação contratual estabelecida entre ordenante e beneficiário. Perante o ordenante, tem apenas a responsabilidade de proceder à rigorosa conferência dos documentos apresentados pelo beneficiário, observando as instruções fornecidas e os usos e costumes. Perante o beneficiário, responde somente pelo pagamento do valor constante da confirmação do crédito. Se as mercadorias entregues não atendem às especificações do pedido de compra, se há vícios ou desatendimento de prazos, tais aspectos dizem respeito unicamente às relações entre ordenante e beneficiário.

A Câmara de Comércio Internacional tem estabelecido, desde 1929, a uniformização da disciplina geralmente adotada nos contratos de crédito documentário (*Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits* - UCP). Para que o contrato se submeta à disciplina dessa uniformização, devem as partes fazer expressa referência às normas desta entidade.

4. CONTRATOS BANCÁRIOS IMPRÓPRIOS

A doutrina diverge na definição da natureza bancária de determinados contratos, em relação aos quais debatem os autores sobre a necessidade ou não da participação, em um dos polos da relação negocial, de uma instituição financeira devidamente autorizada a funcionar.

É o caso da alienação fiduciária em garantia, da faturização, do arrendamento mercantil e do cartão de crédito. Proponho denominar-se este conjunto de contratos de "bancários impróprios".

4.1. Alienação fiduciária em garantia

Por alienação fiduciária entende-se aquele negócio em que uma das partes (fiduciante), proprietário de um bem, aliena-o em confiança para a outra (fiduciário), a qual se obriga a devolver-lhe a propriedade do mesmo bem nas hipóteses delineadas em contrato.

Destaco a natureza instrumental do negócio. A alienação fiduciária será sempre um negócio-meio a propiciar a realização de um negócio-fim. A função econômica do contrato, portanto, pode estar relacionada à viabilização da administração do bem alienado, da subsequente transferência de domínio a terceiros ou, em sua modalidade mais usual, à garantia de dívida do fiduciante em favor do fiduciário.

A alienação fiduciária em garantia (AFG), introduzida no direito brasileiro pela Lei de Mercado de Capitais, em 1965 (Lei 4.728/65 - LMC), é espécie do gênero alienação fiduciária. Trata-se de contrato instrumental de um mútuo, em que o mutuário-fiduciante (devedor), para garantia do cumprimento de suas obrigações, aliena ao mutuante-fiduciário (credor) a propriedade de um bem. Essa alienação se faz em fidúcia, de modo que o credor tem apenas o domínio resolúvel e a posse indireta do bem alienado, ficando o devedor como depositário e possuidor direto desta. Com o pagamento da dívida garantida pela AFG, resolve-se o domínio em favor do fiduciante, que passa a titularizar a plena propriedade do bem dado em garantia.

Embora seja negócio de larga utilização no financiamento de bens de consumo duráveis, nada impede que a alienação fiduciária em garantia tenha por objeto bem já pertencente ao devedor (STJ, Súmula 28). O objeto do contrato pode ser bem móvel (infungível ou fungível) ou imóvel.

a) Bem móvel infungível. Quando o contrato tem por objeto bem móvel infungível (e é celebrado no âmbito do mercado financeiro ou de capitais ou se destina a garantir créditos fiscais ou previdenciários), a mora ou o inadimplemento do fiduciante acarreta a pronta exigibilidade das prestações vincendas e possibilita ao fiduciário requerer em juízo a busca e apreensão do bem móvel objeto do contrato. Faculta a lei a venda da coisa pelo credor fiduciário independentemente de leilão, avaliação prévia ou interpelação do devedor. Justifica-se essa prerrogativa em virtude de titularizar o credor o domínio resolúvel da coisa dada em garantia. Requerida a busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente, o fiduciante poderá pagar todo o valor devido em razão do contrato de mútuo garantido (e não somente emendar a mora) e, com isso, receber de novo a posse do bem e passar a titularizá-lo livre de ônus.

Note-se, a busca e apreensão e a consolidação da propriedade são meios ágeis de efetivação da garantia manejáveis apenas pelos credores fiduciários de contratos celebrados no contexto do mercado financeiro ou de capitais ou destinados à garantia de débitos fiscais ou previdenciários (Decreto-Lei 911/69, art. 8.º-A). Os demais credores em decorrência de AFG de bens móveis infungíveis têm apenas a alternativa de promover a execução do crédito; encontram-se em posição semelhante a do credor pignoratício.

b) Bem móvel fungível. A AFG de bem móvel fungível só pode ser feita como operação no âmbito do mercado financeiro ou de capitais, ou para garantir créditos fiscais ou previdenciários (LMC, art. 66-B). A efetivação da garantia é feita por aqueles mesmos meios ágeis (busca e apreensão e consolidação da propriedade).

c) Bem imóvel. Quando a alienação fiduciária em garantia tem por objeto bem imóvel, aplicam-se os arts. 22 a 33 da Lei 9.514/97, que instituiu o sistema de financiamento imobiliário. Não é o caso de busca e apreensão porque os direitos do credor fiduciário se tornam efetivos por meio apenas da consolidação

da propriedade do bem em seu nome. Essa consolidação decorre da falta de purgação da mora, perante o Registro de Imóveis, pelo devedor regularmente intimado (art. 26).

A natureza bancária do contrato de alienação fiduciária em garantia é discutível. Apesar de sua considerável utilização por empresários que exploram atividade não bancária, em especial os consórcios de automóvel, grande parte da doutrina e da jurisprudência tem considerado que apenas instituições financeiras regularmente estabelecidas poderiam celebrar tal modalidade de contrato como mutuante-fiduciária. Esse entendimento baseia-se, sobretudo, no fato de o negócio jurídico em questão ter sido introduzido no direito nacional em diploma legislativo voltado especificamente à disciplina do mercado de capitais.

A solução para a controvérsia da natureza bancária da AFG deve ser pesquisada na análise da extensão do art. 17 da LRB. Se a AFG se encontrar compreendida entre as operações ali descritas, então não restariam dúvidas de que somente aos bancos estaria autorizada a realização do contrato. Caso contrário, revelando-se a AFG negócio estranho ao universo delineado pelo conceito legal de atividade bancária, a qualquer mutuante seria lícito contratar garantia dessa natureza. O fato de o legislador ter optado por tratar da disciplina do negócio nesta ou naquela lei poderá representar, no máximo, falta de rigor na técnica legislativa, mas não um dado hermenêutico de relevância, mormente quando redundante em limitação da liberdade contratual, princípio que decorre da liberdade de iniciativa, constitucionalmente assegurada.

A AFG de bem móvel infungível ou de imóvel não é, portanto, negócio exclusivo de instituição financeira (quando o objeto da garantia é bem móvel fungível, o contrato é legalmente definido como bancário). A sua natureza, como a de toda alienação fiduciária, é meramente instrumental, de negócio-meio. Dessa forma, no âmbito do direito privado, pode estar associada a mútuo bancário ou civil ou mesmo a qualquer outro contrato, ainda que não exclusivo de banco. A função econômica da AFG não está *necessariamente* abrangida pela "coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros", essência da atividade bancária; embora *possa*, por evidente, estar associada a essas operações.

É certo que as garantias conferidas pela AFG ao credor são bem mais consistentes se é ele for instituição financeira (pois, nesse caso, considera-se o contrato celebrado no contexto do mercado financeiro). Também têm as mesmas substanciais garantias os que operam no mercado de capitais e a Receita Federal. De qualquer modo, a inexistência de meios ágeis para a efetivação da garantia fiduciária para os demais credores não é propriamente impeditivo à celebração do contrato por pessoas privadas que não sejam instituições financeiras; é apenas desmotivador.

4.2. Faturização ("factoring")

Faturização - ou "fomento comercial" - é o contrato pelo qual uma sociedade empresária (faturizadora) se obriga a cobrar os devedores de exercente de atividade econômica, empresária ou não (faturizado), prestando a este os serviços de administração de crédito.

Como se pode perceber, quando o exercente de atividade econômica concede crédito aos consumidores ou aos compradores de seus produtos ou serviços, ele passa a ter mais uma preocupação empresarial, consistente na necessidade de se administrar a concessão do crédito. Isto compreende não somente o controle dos vencimentos, o acompanhamento da flutuação das taxas de juros, os contatos com os inadimplentes, a adoção das medidas assecuratórias do direito creditício, como também a cobrança

judicial propriamente dita. Além disso, o empresário, ao conceder crédito, assume o risco de insolvência do consumidor ou do comprador.

Claro que, em tese, o empresário não está obrigado a abrir crédito a quem procura os produtos ou serviços por ele oferecidos. Contudo, a competição econômica, por vezes, não lhe dá outra alternativa. Se não criar facilidades de pagamento aos seus consumidores, o empresário pode perdê-los para o concorrente.

O contrato de faturização tem a função econômica de poupar o empresário das preocupações empresariais decorrentes da outorga de prazos e facilidades para pagamento aos seus clientes. Por esse negócio, a faturizadora presta ao empresário o serviço de administração do crédito, garantindo o pagamento das faturas por este emitidas. Com a faturização, a faturizadora assume as seguintes obrigações: *a)* gerir os créditos do faturizado, procedendo ao controle dos vencimentos, providenciando os avisos e protestos assecuratórios do direito creditício, bem como cobrando os devedores das faturas; *b)* assumir os riscos do inadimplemento dos devedores do faturizado; *c)* garantir o pagamento das faturas objeto de faturização.

Há duas modalidades de faturização: *a)* quando a faturizadora garante o pagamento das faturas antecipando o valor ao faturizado (*conventional factoring*); *b)* quando a faturizadora paga o valor das faturas ao faturizado apenas no vencimento (*maturity factoring*).

A modalidade *conventional* compreende três elementos: serviços de administração do crédito, seguro e financiamento, enquanto a modalidade *maturity* abrange apenas a prestação de serviços de administração do crédito e o seguro.

No plano doutrinário, a natureza bancária do *conventional factoring* é indiscutível, à vista da antecipação pela faturizadora do crédito concedido pelo faturizado a terceiros, o que representa inequívoca operação de intermediação creditícia abrangida pelo art. 17 da LRB. Já em relação ao *maturity factoring*, em razão da inexistência do financiamento, há dúvidas quanto ao seu caráter bancário. Conforme ensina Newton De Lucca, no entanto, se a faturizadora assumir os riscos do inadimplemento das faturas objeto do contrato, a faturização se revestirá, também neste caso, de nítida natureza bancária.

No plano regulamentar, contudo, não se considera o *factoring* espécie de contrato bancário, em qualquer de suas modalidades. O Banco Central já considerou, no passado, a faturização um contrato bancário. Atualmente, porém, nenhuma norma veda a exploração da atividade de faturização de créditos a não exercentes de atividade bancária.

As empresas de fomento mercantil (as faturizadoras) também devem manter, a exemplo das instituições financeiras, sigilo sobre as suas operações (LC 105/01, art. 1.º, § 2.º).

4.3. Arrendamento mercantil ("leasing")

Na definição doutrinária, arrendamento mercantil é a locação caracterizada pela faculdade conferida ao locatário de, ao seu término, optar pela compra do bem locado.

O arrendamento mercantil é contrato atípico, para os fins de direito privado. Rege-se pelas cláusulas contratadas, entre as quais a que autoriza o locatário, por ato unilateral de vontade praticado no fim do

prazo de locação, adquirir o bem locado, amortizando no preço da aquisição os valores pagos a título de aluguel.

A lei, preocupada com as repercussões tributárias do arrendamento mercantil, definiu-o como o negócio realizado entre uma pessoa jurídica (arrendadora) e uma pessoa física ou jurídica (arrendatária) cujo objeto é a locação de bens adquiridos pela primeira de acordo com as especificações fornecidas pela segunda e para uso desta (Lei 6.099/74, art. 1.º, parágrafo único). Para o direito tributário, só é arrendamento mercantil o contrato que atende a este conceito.

Dessa forma, um arrendamento mercantil que não se enquadre na definição legal, embora seja locação com opção de compra para o direito privado, será considerado simples compra e venda a prazo, para os fins de tributação (Lei 6.099/74, art. 11, § 1.º). Em suma, uma coisa é a disciplina das obrigações dos contratantes entre eles - para esta finalidade, prevalecem as cláusulas fixadas no respectivo instrumento. Outra coisa é a disciplina das obrigações dos contratantes perante o fisco - nesta hipótese, somente o arrendamento mercantil que atende às especificações legais será tido como tal.

Assim, a lei não admite que se considerem, para fins fiscais, como arrendamento mercantil determinadas modalidades desse contrato, tais como o *self leasing* (em que as partes são coligadas ou interdependentes) e o *leasing* em que o arrendador é o próprio fabricante do produto arrendado. Tais operações receberão o tratamento tributário da compra e venda a prazo. Por outro lado, o *leasing back* (em que a arrendadora adquire o bem a arrendar da própria arrendatária) deve ser tributariamente tratado como arrendamento mercantil.

Pode ser objeto de arrendamento mercantil o bem imóvel ou móvel de produção nacional, bem como os de produção estrangeira autorizados pelo Conselho Monetário Nacional (Lei 6.099/74, art. 10).

A exploração da atividade de *leasing* está disciplinada pela Res. BC 2.309/96, que distingue duas modalidades de contrato: o *leasing* financeiro e o operacional. A primeira se caracteriza, basicamente, pela inexistência de resíduo expressivo. Isto é, para o exercício da opção de compra, o arrendatário desembolsa uma importância de pequeno valor, devendo a soma das prestações correspondentes à locação ser suficiente para a recuperação do custo do bem e o retorno do investimento da arrendadora. Na segunda modalidade, como essa soma não pode ultrapassar 75% do custo do bem arrendado, o resíduo a ser pago pela arrendatária, no momento da opção de compra, tende a ser expressivo. O resíduo pode ser pago antecipadamente, obrigando-se a arrendadora a restituí-lo, caso o arrendatário não opte pela aquisição do bem.

Há julgados, porém, que consideram a cláusula de *valor residual garantido* (VRG) uma distorção do *leasing*, determinando que os direitos e obrigações das partes sejam tratados como se o vínculo entre elas fosse o de compra e venda a prazo.

Outro aspecto a acentuar é o da responsabilidade pelos danos decorrentes do uso da coisa arrendada. Enquanto a arrendatária não exerce a opção de compra, a arrendadora tem a posição contratual de locadora e a situação jurídica de proprietária do bem. Em princípio, portanto, deveria responder por danos provenientes do uso do bem de sua propriedade. Mas, não obstante, a jurisprudência tem entendido que não se pode responsabilizá-la neste caso. A Súmula 492 do STF, referente à responsabilização dos locadores de veículos, não tem sido aplicada às sociedades operadoras de *leasing*.

No tocante à discussão sobre a sua natureza bancária, é inequívoco que o exercício da opção de

compra pelo arrendatário importa a caracterização do pagamento dos aluguéis como verdadeiro financiamento. Se o arrendatário, no entanto, não se vale da faculdade de adquirir o bem, inexiste qualquer característica nessa relação contratual que possa sugerir a natureza bancária. O próprio legislador não vinculou a celebração do contrato à qualidade de instituição financeira da arrendadora, tributando como arrendamento mercantil também aqueles contratos de que nenhum banco participa. No mesmo sentido, o Conselho Monetário Nacional decidiu que as operações de arrendamento mercantil somente podem ser exploradas por sociedades anônimas dedicadas essencialmente a essa atividade ou por instituições financeiras especificamente autorizadas.

As sociedades dedicadas ao arrendamento mercantil são consideradas instituições financeiras também para os efeitos da lei do sigilo bancário (LC 105/01, art. 1.º, VII).

4.4. Cartão de crédito

Pelo contrato de cartão de crédito, uma instituição financeira (emissora) se obriga perante uma pessoa física ou jurídica (titular) a pagar o crédito concedido a esta por terceiro, empresário credenciado por aquela (fornecedor).

O cartão de crédito, propriamente dito, é o documento pelo qual o titular prova, perante o fornecedor, a existência do contrato com a instituição financeira emissora. Importante mecanismo na mobilização do crédito ao consumidor, o cartão de crédito é usado pelo titular nas suas compras de produtos ou serviços comercializados pelo fornecedor. O valor dessa compra, por força do crédito que o fornecedor dá ao titular, será pago, sem qualquer acréscimo, na data do vencimento mensal do cartão, diretamente à emissora. Esta, por sua vez, repassará o valor do pagamento ao fornecedor, mediante a exibição das notas de venda.

Trata-se de contrato bancário, na medida em que a emissora, na verdade, financia tanto o titular como o fornecedor. O primeiro pode, em virtude de disposição contratual, parcelar o valor da compra, em vez de pagá-lo totalmente no vencimento mensal do cartão. Este parcelamento, por certo, acarreta o pagamento de juros, comissões e correção monetária. Já o fornecedor, de posse das notas de venda, pode negociar o recebimento antecipado, com deduções equivalentes ao pagamento de juros e encargos.

Mesmo se o titular pagar todas as suas dívidas com o cartão integralmente na data de vencimento mensal e o fornecedor não negociar a antecipação do valor das notas de venda em seu poder, o cartão de crédito estará instrumentalizando uma operação de intermediação de recursos financeiros, de inegável natureza bancária.

A lei do sigilo bancário elencou as administradoras de cartão de crédito entre as instituições financeiras que devem conservar sigilo sobre suas operações e serviços (LC 105/01, art. 1.º, VI).

Cabe ressaltar que o fornecedor não está obrigado a conceder crédito a seus consumidores. Portanto, não se pode obrigá-lo a aceitar pagamento mediante cartão de crédito. Mesmo o fornecedor credenciado pode condicionar a aceitação do cartão de crédito a valores mínimos de compra, para que a transação conserve o interesse para a sua empresa. Eventualmente, ele poderá responder perante a sociedade emissora, que o descredenciará ou cobrará multa contratual. Mas perante o titular, nenhuma responsabilidade advém ao fornecedor credenciado pela recusa na aceitação do cartão de crédito. O essencial na análise desse negócio é não se perder de vista que o uso do cartão apenas instrumentaliza a concessão de crédito feita pelo fornecedor ao titular.

Capítulo 36. CONTRATOS INTELECTUAIS

1. INTRODUÇÃO

Contratos intelectuais são os contratos empresariais relacionados aos direitos intelectuais, isto é, à propriedade industrial (cessão de patente, cessão de registro industrial, licença de uso de patente de invenção, licença de uso de marca e transferência de tecnologia) ou ao direito autoral (a comercialização de *software*).

A lei cuida do registro destes contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Esta formalidade, no entanto, visa apenas a conferir eficácia ao negócio perante terceiros, notadamente o fisco e as autoridades monetárias. Assim, para que a remuneração devida em razão do contrato possa servir de base para a dedutibilidade fiscal e para que a sua remessa ao exterior seja admitida pelo governo, é indispensável o cumprimento deste requisito formal. Porém, para que o contrato produza efeitos entre os contratantes, é irrelevante se foi providenciado, ou não, o registro no INPI.

2. CESSÃO DE DIREITO INDUSTRIAL

A cessão de direito industrial pode ter por objeto uma patente (de invenção ou de modelo de utilidade) ou um registro industrial (de desenho industrial ou de marca).

No primeiro caso, o titular da patente (cedente) transfere os direitos desta, total ou parcialmente, ao outro contratante (cessionário). A cessão pode dizer respeito a patente já concedida pelo INPI, ou apenas solicitada (LPI, art. 68).

A cessão pode ser total, quer dizer, compreender todos os direitos titularizados pelo cedente, ou parcial. Esta última pode ser limitada quanto ao objeto da patente (transferem-se alguns dos direitos industriais outorgados pelo instrumento) ou quanto à área de atuação do cessionário (transfere-se o direito de exploração econômica com exclusividade dentro de certo país, por exemplo). A cessão parcial do direito industrial pode ser também utilizada para a instituição de condomínio sobre a patente. Neste último caso, o condômino pode explorar a patente de forma isolada e independentemente do pagamento de remuneração aos demais coproprietários. Contudo, nenhum deles pode ceder, licenciar ou autorizar a exploração da patente por terceiros sem a anuência dos demais.

Rege-se a cessão de patente pelas normas atinentes à cessão de direitos, observadas as disposições específicas da legislação sobre a propriedade industrial (LPI, arts. 58 a 60).

Assim, o cedente responde, perante o cessionário, pela existência do direito industrial à data da cessão (CC, art. 295). Ou seja, se for declarado o cancelamento, a nulidade ou caducidade da patente, por fato anterior à cessão, o cessionário terá direito à resolução do contrato com perdas e danos. Em se tratando de anulação ou caducidade parcial, o cessionário poderá preferir o abatimento no preço da cessão ao desfazimento desta.

Ademais, o cedente responde por perdas e danos caso a invenção ou modelo não apresente o desempenho por ele propagado. Não responde, porém, pelos resultados unilateralmente esperados pelo cessionário, mas não obtidos com a exploração da patente.

Na hipótese de o cedente aperfeiçoar o invento patenteado, poderá obter o direito ao aperfeiçoamento, não se encontrando obrigado a cedê-lo ao cessionário se não houver esta obrigação contratual. Contudo, se a cessão tiver sido total, não poderá explorar o aperfeiçoamento junto com a invenção cedida, sem a anuência do cessionário, ou de titular atual da patente, salvo se o instrumento de cessão dispuser em contrário. Por fim, o cedente tem o direito moral à veiculação de seu nome na publicidade ou comercialização da invenção ou modelo, mesmo após sucessivas cessões.

A cessão de registro industrial, por sua vez, é o contrato pelo qual o proprietário de registro de desenho industrial ou de marca (cedente) transfere ao outro contratante (cessionário), total ou parcialmente, os direitos de sua exploração econômica com exclusividade. Tal como a cessão de patente, é contrato regido pelas disposições atinentes à cessão de direitos e pelas regras específicas contidas nos arts. 121, 134 e 135 da LPI.

Desse modo, o cedente responde pela existência do direito industrial ao tempo da cessão, podendo o cessionário demandar a resolução desta e perdas e danos na hipótese de anulação, cancelamento ou caducidade por fato anterior à transferência.

A cessão de registro industrial de marca deve compreender todos os registros, concedidos ou solicitados pelo cedente, de marcas iguais ou semelhantes. Não pode a cessão limitar-se, portanto, a apenas algumas das classes em que se encontra registrada a marca, sob pena de o INPI declarar de ofício o cancelamento dos registros ou pedidos não abrangidos pela transferência (LPI, art. 135).

3. LICENÇA DE USO DE DIREITO INDUSTRIAL

O titular de direito industrial pode (e, em determinadas hipóteses, deve) licenciar o uso da patente ou do registro por terceiros. Difere-se a licença da cessão na medida em que a primeira não transfere a titularidade do direito industrial, que continua no patrimônio do licenciador. Esta modalidade de contrato industrial subsume-se, em decorrência, ao regime da locação de coisa (CC, arts. 565 a 578) e ao disciplinado pelas normas específicas da propriedade industrial (LPI, arts. 61 a 74, 139 e 140).

Assim, o cancelamento, anulação ou caducidade do direito, bem como o indeferimento do pedido de patente, não importam no dever de o licenciador indenizar o licenciado.

A licença de uso é contrato *intuitu personae*, e, portanto, o licenciado não pode transferir os seus direitos a terceiros ou mesmo valer-se deles para a integralização de capital de sociedade, salvo expressa autorização do licenciador. Dessa característica decorre também a resolução do contrato em caso de cessão do direito industrial, a menos que o instrumento de licença contemple cláusula de vigência perante o cessionário e esteja registrado no INPI.

O licenciamento de uso de direito industrial pode ser pactuado com ou sem exclusividade e o seu prazo não pode exceder à duração do próprio direito licenciado.

A licença para uso de patente é o contrato pelo qual o seu titular (licenciador ou concedente) autoriza a exploração econômica deste pelo outro contratante (licenciado ou concessionário). Prevê a lei a obrigatoriedade da licença quando o titular de patente exerce os direitos correspondentes de forma abusiva ou se, por meio dela, incorre em abuso de poder econômico (LPI, art. 68; LIOE, art. 38, IV, *a*).

Também cabe a licença compulsória caso o objeto da patente não esteja sendo explorado no Brasil,

salvo motivo justo, ou se a sua comercialização não satisfaz às necessidades do mercado (LPI, art. 68, § 1.º). Caracterizadas essas situações, qualquer pessoa com legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para realizar a eficiente exploração da patente pode requerer ao INPI a licença compulsória.

A obrigatoriedade da licença tem caráter de sanção. Há, de outro lado, hipóteses legais de licença compulsória motivada por razões de ordem técnica, como a dependência de uma patente em relação a outra (LPI, art. 70, I), e o atendimento de emergência nacional ou interesse público (art. 71).

As licenças compulsórias de patente, seja qual for o seu fundamento, não concedem exclusividade ao licenciado e não comportam sublicenciamento.

Já a licença para uso de registro industrial é o contrato em que uma parte (licenciador ou concedente) autoriza a exploração do desenho industrial ou da marca de sua titularidade pelo outro contratante (licenciado ou concessionário).

É comum constar desse tipo de contrato cláusula que permita ao concedente exercer efetivo controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços identificados pela marca licenciada, em atenção aos interesses dos consumidores (LPI, art. 139). O direito consumerista brasileiro não ostenta norma expressa acerca da responsabilidade civil do licenciador por fato do produto ou serviço oferecido pelo licenciado, com uso de desenho industrial ou das marcas por aqueles titularizados. Mesmo inexistente norma expressa, porém, deve-se entender que o consumidor tem o direito de demandar o titular da marca aposta nos produtos ou serviços defeituosos, por danos sofridos em decorrência destes, mesmo quando são oferecidos ao mercado por terceiros licenciados. Por outro lado, é evidente que o consumidor não poderá demandar o titular do registro se ficar provada a contrafação, isto é, que o produto ou serviço defeituoso foi oferecido ao mercado por alguém não licenciado.

Há uma modalidade específica de licença de uso de registro industrial de marca, denominada *merchandising*, em que o licenciador (*merchandisor*) *autoriza o* licenciado (*merchandise*) *a usar a* marca apenas em produtos ou serviços que ele não oferece ao mercado. Quando famosa fábrica de refrigerante licencia o uso de sua marca em peças de vestuário, por exemplo, configura-se este tipo especial de licença. No *merchandising*, a responsabilidade do licenciador por fato do produto ou serviço oferecido pelo licenciado existe apenas se o consumidor não puder distinguir razoavelmente a natureza publicitária da utilização da marca no produto ou serviço defeituoso.

4. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Em sentido lato, tecnologia é o tipo de conhecimento que estabelece as adequadas relações entre meio e fim. Distingue-se da ciência em função de sua finalidade, já que o objetivo do saber tecnológico não se relaciona com a pesquisa da verdade, mas com a da mais apropriada forma de se atingirem fins definidos. A clínica médica, contabilidade e a própria doutrina jurídica são conhecimentos tecnológicos, são tecnologias.

Em sentido estrito, a expressão "tecnologia" tem sido geralmente vinculada a determinados campos do conhecimento humano, situado entre a técnica e a ciência. É nesta última concepção, mais estreita, que a tecnologia tem sido objeto de contrato entre empresários.

Para fins de regência jurídica dos contratos intelectuais, tecnologia é o saber industrial, um tipo de conhecimento utilizável na produção de bem ou comodidade destinados à comercialização. Somente esta

espécie de saber tecnológico tem valor de mercado, e, por isso, o direito se ocupa em disciplinar os muitos interesses que gravitam em torno de sua circulação econômica. Principalmente num país periférico, como o nosso, a internação de *know-how* (importação de tecnologia) acaba interferindo em importantíssimos aspectos da economia, como, por exemplo, a política cambial ou de controle do capital estrangeiro.

Houve tempo em que as cláusulas do contrato de transferência de tecnologia eram estabelecidas pelo Poder Público, por meio do INPI, e a manifestação de vontade das partes limitava-se à adesão ao negócio, nos termos estabelecidos pela norma. Com a desregulamentação da economia da década de 1990, a transferência de tecnologia perdeu esse caráter, ficando apenas sujeita à averbação no INPI, para produzir os efeitos de natureza fiscal (dedutibilidade para fins de tributação) e monetária (registro no Banco Central da entrada e saída de capitais). Idêntica postura de não ingerência do Estado nos termos do contrato encontra-se também na lei (LPI, art. 211).

Costumam-se apontar as seguintes modalidades da transferência de tecnologia: *a)* licença de uso de patente; *b)* licença de uso de registro industrial (uso de desenho industrial ou de marca); *c)* fornecimento de tecnologia; *d)* prestação de serviços de assistência técnica e científica. As duas primeiras espécies contratuais, já examinadas nos itens anteriores, podem ou não servir de efetivo instrumento de transmissão de tecnologia, mas isso não é da essência do contrato. Para que o detentor de um saber tecnológico o repasse a outra pessoa, pode perfeitamente valer-se do licenciamento de uso de direito industrial. Contudo, nem sempre a licença importa transferência de tecnologia. O licenciador pode não assumir nenhuma obrigação no sentido de transmitir seus conhecimentos ao licenciado.

Com efeito, o titular de patente industrial pode autorizar a sua exploração econômica por outrem, e este, ao término do contrato, não se encontrar capacitado para explorar a invenção ou modelo de utilidade sem o concurso do licenciador. Mantendo a tecnologia em segredo, o titular da patente pode autorizar o seu uso pelo licenciado sem transmitir-lhe o *know-how*.

Em relação à licença de uso de desenho industrial ou, ainda, de marca, esta circunstância é inclusive mais perceptível. O titular de uma marca registrada pode licenciar o seu uso por terceiros sem sequer existir qualquer conhecimento específico passível de transmissão. Mas, ainda que a licença de uso de direito industrial não seja instrumento de efetiva transição de conhecimento de um para outro contratante, deve-se providenciar sua averbação no INPI, para que produza todos os efeitos tributários e monetários, bem como perante terceiros.

Relativamente aos dois outros contratos (fornecimento de tecnologia e assistência técnica e científica), estes invariavelmente importam na transmissão do *know-how* de um para outro contratante. Tais negócios podem ter por objeto até mesmo saber tecnológico não abrangido por nenhuma propriedade industrial. São, assim, contratos em que uma das partes (cedente), detentora de conhecimento protegido ou não por patente, obriga-se a capacitar a outra (cessionário) na aplicação desse conhecimento e obtenção de seus resultados econômicos.

Na transferência de tecnologia, o objetivo negocial é a capacitação do cessionário. Por isso, o cedente deve fornecer-lhe todos os dados e informações técnicas, bem como prestar-lhe a assistência necessária à realização dessa finalidade. Se as partes pactuaram cláusula de indisponibilidade da tecnologia transferida, ou de sigilo, responderá o cessionário por perdas e danos decorrentes de sua inobservância.

5. COMERCIALIZAÇÃO DE "SOFTWARE"

Software ou "*programa de computador*" designa o conjunto de instruções indispensáveis ao tratamento eletrônico de informações.

Os direitos titularizados pelo criador de um *software* não são tutelados pela propriedade industrial, mas pelo direito autoral. Esta foi a alternativa seguida pelo direito brasileiro, ao disciplinar a propriedade e a comercialização dos programas de computador (Lei 9.609/98). Esta opção, adotada também por vários outros países, redundou em importantes consequências no tocante à extensão e natureza da tutela jurídica, em razão das diferenças existentes entre os regimes jurídicos do direito industrial e do autoral.

Quanto a dois aspectos se distinguem os direitos do inventor, regidos pela propriedade industrial, e os do autor, disciplinados pelo direito civil: extensão e natureza.

Em relação à extensão, a proteção titularizada pelo inventor é mais ampla do que a deferida ao autor, uma vez que alcança a própria ideia inventiva, excluindo a possibilidade de terceiro fazer uso de trabalho semelhante, embora original. O direito autoral, por sua vez, limita a tutela à forma de exteriorização da ideia, não impedindo obra semelhante, salvo em caso de plágio.

Já, relativamente à natureza da tutela, o direito do inventor se constitui somente após a edição de ato administrativo de outorga (concessão da patente pelo INPI), enquanto o do autor decorre da apresentação da obra ao público e, portanto, independe de qualquer reconhecimento estatal.

Ao se afirmar que o criador de *software* tem a proteção do direito autoral, isto significa, portanto, desfruta da prerrogativa de impedir a comercialização por terceiros de programa de computador com idêntica *forma*, desde o momento em que o torna público, por qualquer meio. O seu direito não alcança outros programas semelhantes, de forma suficientemente diferenciada. Por outro lado, a utilização doméstica e não comercial de programa idêntico criado por terceiro não está vedada.

A cópia de programa de computador (prática conhecida por "pirataria") representa conduta ilícita, lesiva aos direitos do seu autor, mesmo que tenha sido feita sem qualquer intuito lucrativo. Mas nenhuma ofensa a tais direitos existe na *criação* de idêntico *software*, desde que sua utilização não seja diretamente econômica. Outro aspecto relacionado com a natureza *autoral* do direito do criador do *software* é a licitude da chamada "engenharia às avessas". Ou seja, não lesa os direitos do criador a desmontagem do *software*, por terceiro interessado em descobrir a estrutura interna do programa, com vistas ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos.

O direito autoral protege a forma do programa de computador contra os plágios, e não a própria ideia inventiva. Tanto assim que o registro no INPI é feito a partir somente de trechos do programa e outros dados suficientes à caracterização da independência de sua concepção e identidade, os quais se revestem de caráter sigiloso. Por outro lado, a proteção do autor do *software* independe de qualquer formalidade junto aos órgãos públicos. Quem provar, por qualquer meio, ter sido o criador do *software*, poderá demandar aquele que o plagiou. O registro no INPI não tem, neste caso, caráter constitutivo, exatamente por se tratar de direito autoral, e não industrial.

Apenas para se recordar o inventor, para obter a proteção do direito industrial, deve solicitar a patente, apresentando detalhadamente a sua ideia. Esta será obrigatoriamente tornada pública pelo INPI

(LPI, art. 30), durante a tramitação do pedido. Enfim, o inventor somente terá direito de exclusividade sobre a invenção se lhe for concedida a patente.

Os direitos intelectuais sobre *software*, em síntese, estão protegidos pela lei do direito autoral (Lei 9.610, de 1998), salvo quanto às matérias disciplinadas de forma diversa no diploma legal específico (Lei 9.609/98). Neste último, por exemplo, foi fixado o prazo de duração do direito autoral sobre *softwares* em 50 anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à publicação ou criação do produto; sendo diverso (inferior) do prazo de duração dos direitos autorais em geral, afasta-se a aplicação deste.

Um programa de computador pode ser objeto de contrato entre empresários (cessão ou licença de uso ou, ainda, transferência de tecnologia) ou entre o titular dos direitos de comercialização e o usuário. Quanto a este último, previu a Lei 9.609/98 (arts. 7.º e 8.º), as seguintes condições, destinadas à tutela do usuário do programa (consumidor): *a*) obrigatória menção na embalagem, nos suportes físicos e no instrumento contratual, do prazo de validade técnica do *software*; *b*) garantia da prestação de serviços técnicos complementares, com vistas ao adequado funcionamento do *software*.

Capítulo 37. SEGURO

1. INTRODUÇÃO

O seguro é o contrato em que uma parte (seguradora) se obriga, mediante o recebimento do pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo da outra parte (segurado), contra riscos predeterminados (CC, art. 757). Esta garantia se materializa, entre outras obrigações, na de pagar determinada quantia ao segurado ou a terceiros beneficiários, caso ocorra determinado sinistro (evento futuro e incerto).

Trata-se, em termos estritamente econômicos, de instrumento de socialização de riscos, pois os segurados podem ser vistos como que contribuindo para a constituição de um fundo, destinado a cobrir, ainda que parcialmente, os prejuízos que alguns deles provavelmente irão sofrer.

Cálculos atuariais possibilitam a previsão, com relativo grau de certeza, dos eventos danosos. Pela atividade securitária, estes prejuízos previsíveis não são suportados individualmente apenas pelo titular do interesse atingido, mas são distribuídos, *por assim dizer*, entre diversos segurados. Esta característica da atividade securitária é denominada *mutualidade*.

O seguro proporciona ao segurado substancial economia, à medida que tem os seus interesses preservados a um custo consideravelmente inferior àquele em que incorreria se tivesse que suportar "isoladamente" as consequências do evento danoso. O pagamento do prêmio devido pelo segurado à seguradora deve ser feito obrigatoriamente por meio da rede bancária (Lei 5.627/70, art. 8º).

2. SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS

O Sistema Nacional de Seguros Privados foi instituído pelo Decreto-Lei 73/66 (Lei dos Seguros - LS). É integrado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), pelo IRB Brasil Resseguros S.A., pelas sociedades seguradoras e pelos corretores.

O CNSP é o órgão da administração direta federal ao qual incumbe traçar a política geral de seguros privados, disciplinar a constituição, funcionamento e fiscalização das seguradoras, fixar as características gerais do contrato de seguro, normatizar as operações securitárias e aplicar as sanções legais (LS, art. 32).

A SUSEP é uma autarquia com objeto voltado à promoção da política definida pelo CNSP e à fiscalização das seguradoras (LS, art. 36). Cabe-lhe, entre outras, a tarefa de proceder a liquidação extrajudicial destas sociedades. Ela tem competência para fiscalizar todas as seguradoras, exceto as especializadas em seguro saúde, que se encontram sob o controle de outra autarquia federal, a Agência Nacional de Saúde (ANS).

Já o IRB Brasil Resseguros S.A. é sociedade de economia mista com capital representado por ações titularizadas metade pela União (Lei 9.482/97) e metade pelas seguradoras. O resseguro é o contrato pelo qual uma seguradora garante seus riscos junto à resseguradora (LC n. 126/07).

As seguradoras devem estar especificamente autorizadas pelo governo federal para a exploração da atividade securitária. A contratação de seguro sem esta autorização importa a pena de multa em valor equivalente à importância segurada (LS, art. 113). Apenas sociedades anônimas podem ser seguradoras (exceto as cooperativas, que podem operar com seguros agrícolas ou de acidente do trabalho).

Os fundadores de sociedade com objeto de exploração de atividade securitária devem inicialmente requerer ao CNSP a autorização para funcionamento. Concedida, devem comprovar junto à SUSEP, nos 90 dias seguintes, o atendimento das formalidades de constituição e de eventuais exigências específicas. Na sequência, será expedida a carta-patente. A autorização para funcionamento pode ser limitada a determinadas operações (LS, arts. 74 a 78).

A sociedade seguradora não pode falir, a pedido de credor (LS, art. 26), deve possuir o capital mínimo estipulado pelo CNSP (LS, art. 32, VI, e Lei 5.627/70) e a alteração de seu estatuto só terá eficácia após a aprovação pelo governo federal (LS, art. 77). Além disso, sujeita-se a regime próprio de distribuição do resultado obtido com o desenvolvimento de sua atividade econômica. Isto é, a seguradora tem o dever de constituir reservas técnicas, fundos especiais e provisões, com observância dos critérios determinados pelo CNSP. Além disso, a alienação, promessa de alienação ou oneração dos bens garantidores destas reservas, fundos e provisões depende de autorização da SUSEP (LS, arts. 84 e 85).

Por outro lado, diversos mecanismos são previstos por lei para a fiscalização das seguradoras pelas autoridades securitárias, como a intervenção da SUSEP (mediante a nomeação de Diretor Fiscal, com honorários pagos pela sociedade) e a concessão de tratamento técnico e financeiro excepcional destinado a recuperação da empresa seguradora (LS, art. 73 e seus parágrafos).

A lei estabelece regime específico de liquidação das sociedades seguradoras, que pode ter caráter sancionador (LS, art. 96, *a e b*) ou justificar-se apenas como medida de saneamento econômico (LS, art. 96, *c e d*). Em qualquer hipótese, mesmo se deliberada pelos acionistas, a liquidação da sociedade seguradora será processada pela SUSEP, seguindo o procedimento legalmente definido, e, nas omissões deste, a lei falimentar (LS, arts. 98 a 107). O controlador, administradores e membros do conselho fiscal das seguradoras estão sujeitos às mesmas regras de apuração e efetivação de responsabilidade dos de instituições financeiras (Lei 10.190/2001).

Finalmente, os corretores de seguros são pessoas naturais ou jurídicas cuja atividade econômica é a de aproximação das seguradoras e segurados. O exercício desta profissão é fiscalizado pela SUSEP, que procede à habilitação e registro dos corretores.

A estrutura básica do Sistema Nacional de Seguros Privados foi aproveitada pelo legislador para disciplinar o controle das atividades de capitalização (Decreto-Lei 261/67) e de previdência privada (Lei 6.435/77).

3. NATUREZA DO CONTRATO DE SEGURO

O seguro é contrato de adesão, comutativo e consensual.

Marca significativa do contrato de seguro é a sua extensa disciplina pela legislação e pelas autoridades securitárias. Trata-se de contrato em que as cláusulas são, em sua quase totalidade, definidas por normas ou pelos órgãos governamentais. Restam às partes reduzida margem para negociações. Por exemplo, o contrato de seguro não pode conter cláusula dispensando ou reduzindo o prêmio (LS, art. 30)

ou facultando a resilição unilateral (art. 13).

Por outro lado, o CNSP tem poderes para padronizar as cláusulas e impressos necessários à contratação mediante emissão de bilhete de seguro (LS, art. 10, § 1º), e a SUSEP pode fixar condições de apólices e tarifas de observância obrigatória (art. 36, c).

A atividade securitária pressupõe a realização de negócios em massa. Ou seja, se um empresário, por hipótese, assumisse a obrigação contratual de indenizar os prejuízos sofridos por uma única pessoa, em razão de evento futuro e incerto, configurar-se-ia, na verdade, o contrato de jogo ou aposta, mas não o seguro. Nesta situação hipotética, estaria ausente o requisito da mutualidade (distribuição de certo risco entre as pessoas a ele expostas).

O seguro é contrato de adesão (CC, arts. 423 e 424; CDC, art. 54). Se contiver cláusulas ambíguas ou contraditórias, elas serão interpretadas em favor do segurado (ou terceiro beneficiário).

O razoável consenso doutrinário existente no tocante a esta particularidade do seguro (contrato de adesão) não se reproduz na discussão quanto a sua natureza comutativa e consensual.

A obrigação da seguradora é a de garantir interesse do segurado e a deste, de pagar o prêmio. Antes da entrada em vigor do Código Civil, predominava na doutrina o entendimento de que o seguro era contrato aleatório, isto é, envolveria uma *álea*, porque as partes não têm, ao contratá-lo, como antever sua execução. De fato, no momento da celebração do seguro, o segurado não sabe se será compensadora a realização da despesa relativa ao pagamento do prêmio. Também a seguradora, nesta oportunidade, não tem como saber se irá ou não arcar com o pagamento da indenização ou prestação àquele segurado em especial. A *álea*, portanto, está presente neste aspecto das relações entre os contratantes: a possibilidade de ocorrência do evento danoso. É claro que as partes mensuram a conveniência econômica em contratar ou não o seguro e o quanto a ocorrência do evento futuro e incerto pode interferir com os respectivos interesses, mas isto em nada altera a natureza aleatória do sinistro, que pode ou não ocorrer. Aliás, um evento danoso que certamente irá ocorrer não pode ser segurado por nenhuma seguradora; e o que certamente *não* irá ocorrer, nenhum segurado se interessa por segurar.

Em relação à questão da *álea*, ainda antes da entrada em vigor do Código Civil, certo entendimento doutrinário negava sua existência para a seguradora, sob o argumento de que, considerando-se toda a massa contratual da qual participa, não assume obrigação de resultados desconhecidos. Se é verdade que a seguradora não tem como antever quais serão exatamente os contratos que liquidará pagando ao segurado ou ao beneficiário, é também indubitável que cálculos atuariais lhe possibilitam dimensionar quantos dos seguros contratados serão e quantos não serão liquidados. A empresarialidade da atividade securitária desfaz a *álea*, tornando os eventuais insucessos um risco empresarial como de outro empresário qualquer.

Com a entrada em vigor do Código Civil, deixou de haver elementos para se sustentar a natureza aleatória do contrato de seguro. A lei não define mais a obrigação da seguradora como sendo a de pagar ao segurado (ou a terceiro beneficiário) uma determinada prestação, caso venha a ocorrer evento danoso futuro e incerto. A obrigação é mais ampla e consiste na de garantir o segurado contra riscos. O pagamento é, na verdade, *um* dos aspectos desta obrigação contraída pela seguradora.

Para dar cumprimento a essa obrigação (garantir os segurados contra riscos), a seguradora não está só obrigada a pagar a prestação devida, nas hipóteses delineadas em contrato, mas deve também adotar

providências de gerenciamento empresarial com vistas a manter-se em condições econômicas, financeiras e patrimoniais para fazê-lo, quando ocorrer o sinistro. Quando a seguradora não constitui reservas adequadas, ela não está apenas descumprindo normas administrativas da SUSEP; está também descumprindo a obrigação de garantir seus segurados. Não há, em outros termos, nenhuma álea: executar o contrato de seguro significa administrar a empresa securitária de modo a garantir os seus segurados contra os riscos contratados.

Referentemente à segunda questão, também muda, com a entrada em vigor do Código Civil, a classificação do contrato de seguro no direito brasileiro. Antes, a lei condicionava a constituição do vínculo contratual a certa formalidade (elaboração de documento escrito denominado apólice ou o lançamento da operação nos livros da seguradora), de sorte que a solenidade do contrato encontrava-se relativamente clara na lei.

No mundo todo, porém, os regulamentos mais modernos do contrato de seguro já haviam descartado a exigência da formalidade estrita. Por outro lado, em razão do tráfico mercantil e suas necessidades, podia-se até mesmo dizer que o dispositivo legal impositivo da forma solene estava, há tempos, em desuso. Atualmente, a apólice ou o bilhete de seguro são instrumentos de *prova* do contrato, mas não o constituem. Aliás, prova-se a contratação do seguro por qualquer documento comprobatório do pagamento do prêmio, como a guia de compensação bancária ou o recibo do corretor (CC, art. 758).

4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Celebrado o seguro, assume a seguradora a obrigação de garantir o interesse do segurado contra os riscos indicados em contrato. Deste modo, deve organizar-se empresarialmente e gerir os recursos provenientes do pagamento do prêmio (em especial a parte denominada de "prêmio puro") de forma a atender aos compromissos com seus segurados ou beneficiários.

Se verificado o sinistro, cujos efeitos danosos era intenção do segurado evitar ou atenuar, a seguradora deve pagar-lhe a importância determinada (CC, art. 757). Já em relação ao segurado, estabelece à lei as obrigações de pagar o prêmio, prestar informações verídicas, abster-se de aumentar o risco em torno do interesse segurado e comunicar à seguradora tanto a verificação de incidente que aumente o risco como a do próprio sinistro.

O contrato deve fixar a data ou datas de pagamento do prêmio. Em regra, o atraso no adimplemento desta obrigação tem, por consequência, a fluência de juros e correção monetária previstos em contrato. Mas o segurado não terá direito de receber da seguradora a importância prevista em contrato se estiver em mora no pagamento do prêmio, caso o sinistro se verifique antes de sua purgação (CC, art. 763). Assim, se o segurado atrasou o pagamento do prêmio ou de prestação deste, e, em seguida, verificou-se o sinistro, ele não pode cobrar da seguradora o pagamento do valor previsto em contrato. A jurisprudência tem atenuado o rigor dessas normas, principalmente na defesa de interesses do consumidor.

O segurado tem o dever de prestar informações verídicas para que a seguradora possa dimensionar o risco a que se submete o interesse objeto do contrato e o valor do prêmio a ser pago. A inobservância deste dever é sancionada com a perda do direito ao seguro, sem prejuízo da cobrança do prêmio (CC, art. 766).

Também perderá o direito ao seguro o segurado que aumentar intencionalmente os riscos envolventes

do interesse objeto de contrato. Por exemplo, se o proprietário de automóvel segurado confia-o às mãos de motorista sem habilitação, isto pode acarretar, dependendo dos elementos específicos do caso concreto, aumento injustificável do risco de acidentes com o veículo. Trata-se de análise casuística, que o juiz deve fazer com atenção as circunstâncias reais (CC, art. 768).

Por fim, em duas oportunidades tem o segurado a obrigação de proceder a comunicações à seguradora. Em primeiro lugar, na ocorrência de fator que aumente o risco a que se submete o interesse objeto de seguro. Este aumento de risco pode dar ensejo a resolução do contrato pela seguradora, desde que se manifeste nos 15 dias seguintes a comunicação do agravamento do risco feita pelo segurado. O seguro ainda valerá por 30 dias seguintes ao recebimento, pelo segurado, da notificação da seguradora. Neste caso, também, deve-se restituir parte do prêmio, proporcional a redução do tempo da cobertura (CC, art. 769 e parágrafos). Em segundo lugar, deve ser comunicada à seguradora, de imediato, a verificação do sinistro. O atraso injustificado nesta comunicação acarretará a perda do direito à indenização. Entende-se que a seguradora, tempestivamente advertida do sinistro, tendo condições de evitá-lo ou de atenuá-lo em suas consequências, teria direito de tentar salvar o interesse segurado (CC, art. 771).

5. ESPÉCIES DE SEGURO

O seguro, de acordo com a natureza do interesse segurado, pode ser "de dano" (ou "de ramos elementares") ou "de pessoas" ("vida" ou "acidentes pessoais com morte").

5.1. SEGURO DE DANO

O seguro de dano (ou de "ramos elementares") tem por objeto os interesses relacionados ao patrimônio (bens, valores, direitos etc.), obrigações, saúde e integridade física do segurado. Compreende-se nesta categoria todos os seguros, menos o de *vida e de acidentes pessoais com morte*.

Característica essencial dos seguros de dano é a natureza indenizatória do pagamento devido pela seguradora. Ao contrário do que ocorre com o seguro de pessoa, o segurado contrata com a seguradora a recomposição de seu patrimônio, caso venha a ser atingido por sinistro, como, por exemplo, a incapacidade laborativa, despesas com saúde, responsabilidade civil perante terceiros, inadimplemento de devedores, prejuízos patrimoniais.

Assim sendo, a liquidação do seguro não pode representar meio de enriquecimento do segurado, mas apenas de "reposição de perdas".

Neste contexto, portanto, não é lícito ao segurado contratar pelo seu valor integral mais de um seguro de ramo elementar, referente ao mesmo interesse (prática irregular denominada *sobresseguro*), nem, por outro lado, segurá-lo em importância superior ao seu valor, pois, caso contrário, sobrevindo o sinistro, ocorreria o locupletamento sem causa (CC, art. 778).

Pela mesma razão de o seguro de dano ser simples "reposição de perdas", se o interesse for segurado por importância inferior ao seu valor, entende-se que o segurado optou por assumir pessoalmente o risco em relação a parte não segurada. Nesta situação, verificando-se o sinistro, a seguradora responde proporcionalmente ao valor do objeto do contrato, suportando o próprio segurado o restante (regra proporcional).

Note-se que a vedação do sobresseguo funda-se no caráter indenizatório da prestação devida pela seguradora. Ou seja, se inexistisse essa proibição legal, a perda de bens segurados passaria a ser mais vantajosa, ao beneficiário do seguro, do que a sua conservação, estimulando-se, em certa medida, a negligência na guarda daqueles. O sobresseguo, incompatível com a natureza indenizatória da prestação devida pela seguradora, no caso de operação em ramo elementar, não se confunde com o *cosseguo* ou com o seguro cumulativo, modalidades admitidas pelo direito. Entende-se por cosseguo aquele em que diversas seguradoras se responsabilizam por uma parte da indenização devida em razão do sinistro (CC, art. 761); e por seguro cumulativo aquele em que segurados, cada qual motivado por interesse próprio, celebram contratos de seguro referentes a um mesmo bem.

Preveem-se em lei hipóteses em que a contratação do seguro é obrigatória, sob pena de multa aplicada pela SUSEP (LS, arts. 20, 112 e 119). A mais conhecida é a de cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Incumbe ao Conselho Nacional de Trânsito implantar e fiscalizar medidas impeditivas do licenciamento e da circulação dos veículos automotores terrestres cujo proprietário não contratou o seguro obrigatório (Lei 6.194/74, art. 12, §§ 1º e 2º).

O seguro obrigatório está sujeito a mesma disciplina geral do contrato no tocante às obrigações das partes. A obrigatoriedade diz respeito à *contratação*, e não à liquidação do seguro. Dessa forma, o segurado pode, por exemplo, perder o direito ao seguro se a sua conduta culposa redundar em aumento dos riscos (CC, art. 768). Nos seguros obrigatórios, a indenização será paga diretamente ao terceiro prejudicado (art. 788).

5.2. SEGURO DE PESSOA

A dificuldade em se construir um conceito unitário para o seguro está relacionada ao caráter da prestação devida pela seguradora no seguro de vida. Neste tipo de contrato, o pagamento devido ao beneficiário, em decorrência do sinistro, não tem natureza indenizatória.

Aliás, nem poderia ter, uma vez que a vida, juridicamente falando, não pode ser objeto de avaliação, não tem preço.

O devido pelas seguradoras, ao se verificar o evento descrito no contrato de seguro (a morte do segurado antes de certo termo, sua sobrevivência após certo termo ou acidente pessoal com morte), não tem a natureza de ressarcimento ao beneficiário por dano sofrido. Cuida-se, simplesmente, do adimplemento de obrigação pecuniária decorrente de contrato de garantia contra riscos. Por esta razão, o valor devido por contrato pela seguradora não é chamado, na lei, de *indenização* (como no caso dos seguros de dano), mas sim de *capital*.

Como a prestação assumida pela seguradora (capital), no seguro de pessoa, não tem natureza indenizatória, não é vedado o sobresseguo. Ao segurado, conseqüentemente, é lícito contratar tantos seguros de vida quantos queira, e o beneficiário poderá, uma vez ocorrida a morte ou sobrevida daquele, reclamar o pagamento de todas as seguradoras (CC, art. 789). Pela mesma razão, a regra proporcional não tem qualquer pertinência, devendo o seguro ser liquidado pelo valor total da apólice.

Atente-se para a circunstância de que, por vezes, a morte de uma pessoa pode tornar exigível a prestação de seguradora, sem que o seguro seja, por isto, caracterizado como de vida. É o caso da morte de pedestre provocada por veículo automotor terrestre. A liquidação do seguro obrigatório, nesta

situação, feita em favor do cônjuge sobrevivente (Lei 6.194/74, art. 4º), apenas de forma indireta decorre do falecimento, posto que diretamente está vinculada à responsabilidade civil do proprietário do veículo. Trata-se, assim, de seguro de ramo elementar.

Ao contratar seguro de vida, o proponente, que não é necessariamente o segurado (a pessoa cuja morte ou sobrevida é objeto de contrato - CC, art. 790), nomeia o beneficiário da prestação contratada com a seguradora. Se este não estiver identificado na apólice, entende-se que o seguro foi estipulado metade em favor do cônjuge não separado judicialmente e o restante dos herdeiros do segurado, seguida a ordem da vocação hereditária (art. 792).

O recebimento pelo beneficiário do capital devido pela seguradora, quando falece o segurado, não tem a natureza de sucessão. É o próprio beneficiário o titular do direito de crédito, de modo que não incide sobre a importância paga qualquer tributo de transmissão *causa mortis*. Por esta mesma razão, os credores do falecido não podem executar os seus créditos sobre a mesma importância (CC, art. 794). É claro que, morrendo o próprio beneficiário, após ter-se tornado titular do crédito perante a seguradora, os herdeiros ou legatários daquele sucedem-no na importância contratada, hipótese em que o seu pagamento deve ser considerado herança ou legado.

O beneficiário de seguro de vida não terá direito ao recebimento do capital se a morte é voluntária, tal como a decorrente de suicídio premeditado. O suicídio não premeditado não é causa excludente de recebimento do valor do seguro (Súmula 61 do STJ). Considera-se dessa categoria o suicídio cometido após os dois primeiros anos de vigência inicial do seguro ou de sua recondução depois de suspenso (CC, art. 798). Também não exonera a seguradora o falecimento ocorrido em razão da prática de esportes arriscados, exercício de atividade profissional perigosa, cirurgia, prestação de serviços militares, atos de humanidade em auxílio de outrem ou dos riscos maiores oferecidos por meio de transporte (CC, art. 799).

No passado, era muito comum as seguradoras solicitarem dos pretendentes ao seguro de vida o exame de saúde, como meio de mensurar a probabilidade de liquidação do contrato. Hoje, com a evolução dos cálculos atuariais e o desenvolvimento do mercado securitário, esta exigência tem sido paulatinamente abandonada. Nos seguros em grupo, aliás, a perícia médica sempre foi dispensada. O fato de a seguradora não condicionar o contrato à realização do exame de saúde, contudo, não libera o segurado do dever de prestar informações verídicas, quando da assinatura da proposta ou do bilhete, perdendo o beneficiário o direito ao seguro caso não tenha sido cumprida tal obrigação.

6. SEGURO-SAÚDE

Há duas modalidades de plano privado de assistência à saúde. A primeira é a contratada com operadora de plano de assistência à saúde que presta, diretamente ou por terceiros, serviços médico-hospitalares ou odontológicos aos seus consumidores. A segunda é o seguro-saúde, em que a operadora não presta serviços desta natureza aos seus consumidores, mas, como seguradora, oferece-lhes a garantia contra riscos associados à saúde.

Nas duas modalidades, a operadora deve administrar empresarialmente os recursos de que têm a disponibilidade com vistas a manter-se em condições econômicas, financeiras e patrimoniais aptas ao pleno atendimento das obrigações contraídas perante os consumidores. Por esta razão, a exploração dessa atividade empresarial - plano de assistência à saúde - é fiscalizada pelo governo, por meio de uma

autarquia especializada, a Agência Nacional de Saúde - ANS (Lei 9.565/98).

O seguro-saúde só pode ser oferecido por seguradoras especializadas nesse tipo de contrato. Quer dizer, o objeto da seguradora deve ser exclusivamente a exploração de seguro-saúde. Ela pode pertencer a grupo de empresas voltadas à exploração da atividade securitária em outros ramos (automóveis, responsabilidade civil, vida etc.), mas deve ser uma sociedade empresária autônoma, revestida da forma de sociedade anônima. Esta exigência visa facilitar a fiscalização da atividade (Lei 10.185/2001). Como mencionado acima, as seguradoras especializadas em seguro-saúde não estão sujeitas à SUSEP, mas à ANS.

7. CAPITALIZAÇÃO

Capitalização é o contrato pelo qual uma sociedade anônima, especificamente autorizada pelo governo federal a operar com este gênero de atividade econômica, se compromete, mediante contribuições periódicas do outro contratante, a pagar-lhe importância mínima ao término de prazo determinado. Comumente, firma-se cláusula contratual com a previsão de prêmios ou de antecipação do pagamento do capital a contratantes sorteados. Configura-se a capitalização como contrato aleatório apenas se pactuada esta cláusula de premiação ou antecipação por sorteio, que, inclusive, representa o aspecto atraente do produto. Mais que o recebimento do capital, ao término do prazo convencionado, interessa aos contratantes a possibilidade de ganhos oferecida pela eventual premiação.

Para o contrato, é indispensável a emissão do respectivo título de capitalização pela sociedade anônima autorizada a operar neste ramo de atividade. Tal documento tem a natureza de título de crédito impróprio de investimento e, por este motivo, comporta somente a forma nominativa (Lei 8.021/90, art. 2º, II).

A exploração desta atividade econômica é disciplinada pelo Decreto-Lei 261/67, que instituiu o Sistema Nacional de Capitalização, aproveitando a estrutura do Sistema Nacional de Seguros Privados. Compete, assim, ao CNSP e à SUSEP controlar e normatizar o mercado. As sociedades de capitalização estão submetidas a regime jurídico próximo ao delineado para as seguradoras. Ou seja, o seu funcionamento depende de autorização governamental, elas não podem falir a pedido de credor e submetem-se à liquidação extrajudicial.

É da essência econômica do contrato de capitalização a poupança do contratante que, ao se obrigar pelas prestações periódicas, acaba forçando-se a economizar certa parte de sua renda. No prazo do contrato, ele terá direito à restituição do capital poupado, ou parte deste, acrescido dos consectários definidos no título. Existem no mercado produtos denominados *capitalização*, aos quais, não obstante, falta esta marca da poupança, uma vez que o contratante desembolsa, para a aquisição do título, apenas uma única prestação e de valor comumente exíguo. A rigor, cuida-se de contrato de jogo ou aposta travestido de capitalização.